

CLAUDIO KIPER

MANUAL DE
DERECHOS REALES ^{MNR}

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
DE LA NACIÓN. LEY 26.994

RUBINZAL - CULZONI EDITORES

Talcahuano 442 - Tel. (011) 4373-0544 - C1013AAJ Buenos Aires
Salta 3464 - Tel. (0342) 401-9300 - S3000CMV Santa Fe

Kiper, Claudio
Manual de Derechos Reales / Claudio Kiper. - 1ª ed. revisada. - Santa Fe : Rubinzal-Culzoni, 2016.
920 p. ; 23 x 18 cm
ISBN 978-987-30-0704-0
1. Derecho Civil. 2. Derechos Reales. I. Título.
CDD 346

RUBINZAL - CULZONI EDITORES
de RUBINZAL Y ASOCIADOS S. A.
Talcahuano 442 - Tel. (011) 4373-0544 - C1013AAJ Buenos Aires

A la memoria de mi hermano BERNARDO

Queda hecho el depósito que dispone la ley 11.723

IMPRESO EN ARGENTINA

CAPÍTULO I

TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS REALES

MNR

SUMARIO: I. Metodología del Código. II. El derecho real es un derecho subjetivo. III. Los derechos reales en la clasificación de los derechos según la oponibilidad y el contenido. IV. Concepto del derecho real. V. Objeto del derecho real. VI. Concepto de cosa. VII. Enumeración de los derechos reales. VIII. Convalidación. IX. Derechos reales no incluidos por el Código Civil y Comercial. X. Derechos reales legislados fuera del Código Civil y Comercial. XI. Diferencias entre los derechos reales y los derechos personales. XII. Conexiones entre los derechos reales y los personales. XIII. Clasificación de los derechos reales. XIV. Transmisibilidad. XV. Modos de adquisición de los derechos reales. XVI. Clasificación. XVII. Modos de extinción de los derechos reales. XVIII. Concepto de carga real. XIX. Obligaciones reales.

I. Metodología del Código

El Código Civil y Comercial está organizado con un Título Preliminar y seis libros. El Libro Cuarto está dedicado a los Derechos Reales y se divide en 13 títulos. Además, en el Libro Sexto se establecen disposiciones comunes a los derechos personales y a los derechos reales (v. gr.: prescripción, privilegios, etc.).

En el Título I del Libro Cuarto se regulan disposiciones generales y principios relativos a los derechos reales, lo que constituye un acierto y una novedad, pues evitan que, al tratarse cada uno de los derechos reales, se repitan cuestiones atinentes a la constitución, extinción, etcétera. El objeto de los derechos reales es, principalmente, la cosa. El Código Civil y Comercial trata sobre los bienes y cosas en el Título Preliminar (Cap. 4, arts. 15/18), y con más detalle se refiere a los bienes y a las cosas, y a su clasificación, en los artículos 225 a 243.

II. El derecho real es un derecho subjetivo

El derecho subjetivo integra una serie de facultades y atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico a favor de una persona, para obrar en defensa y protección de sus intereses. En cambio, se llama derecho objetivo al conjunto de normas que regulan la conducta humana, al ordenamiento jurídico impuesto por el Estado.

En lo que aquí interesa, sin desviarnos del tema, teniendo en cuenta que los derechos reales conceden a su titular facultades sobre una cosa (potestad), y que éstas están protegidas por el ordenamiento jurídico, fácil es concluir que los derechos reales importan derechos subjetivos. El titular tiene la facultad de hacer respetar y cumplir con los fines del mismo derecho. Como por ejemplo, el dueño defenderse ante la turbación ilegítima.

III. Los derechos reales en la clasificación de los derechos según la oponibilidad y el contenido

Los derechos subjetivos son pasibles de diversas clasificaciones. Se enumerarán las más importantes y su vinculación con los derechos reales.

En cuanto a su oponibilidad, los derechos se clasifican en absolutos y relativos, según pueda hacérselos valer indeterminadamente o sólo frente a sujetos especialmente determinados. Los derechos reales son una especie dentro de los derechos absolutos, en tanto que los personales son derechos relativos. En los derechos absolutos el sujeto tiene una potestad sobre un objeto determinado, para cuyo ejercicio no requiere la concurrencia de ningún otro sujeto: no hay una persona obligada a cumplir una prestación.

El otro criterio clasificatorio trascendente es el que apunta al contenido de los derechos subjetivos. Así, se afirma que si el objeto de tales derechos se traduce en un valor económico, es patrimonial; en caso contrario, es extrapatrimonial.

En cuanto al mentado valor económico, cabe tener presente que, según el artículo 16 del Código Civil y Comercial, las cosas son bienes

materiales susceptibles de tener un valor económico. Tanto los derechos reales como los personales son patrimoniales por su contenido.

En síntesis, los derechos reales son absolutos y patrimoniales, y los personales son relativos y también patrimoniales. El efecto *erga omnes* de los derechos reales se aprecia claramente cuando se ejercen las facultades de persecución y de preferencia. Hay otras categorías de derechos que también responden a tales criterios clasificatorios. Los llamados "derechos personalísimos" (a la vida, al honor, a la integridad física, etc.) son absolutos en cuanto a su oponibilidad y extrapatrimoniales en cuanto a su contenido. No es tan sencilla la caracterización de los derivados de las relaciones de familia, dado que respecto a la oponibilidad podemos calificarlos en mixtos, y en orden al contenido, son preponderantemente extrapatrimoniales. Los derechos intelectuales son absolutos y patrimoniales sólo en su aspecto económico.

IV. Concepto del derecho real

a) Distintas doctrinas

a.1) Doctrina clásica

Esta concepción parte de la diferenciación neta entre los derechos reales y personales. Cabe recordar que esta división no es romana, ya que en el Derecho Romano se distinguían los derechos subjetivos entre aquellos protegidos por una acción real (*actio in rem*) y los derechos protegidos por una acción personal (*actio in personam*), clasificación erigida por los clásicos en la médula del sistema de los derechos subjetivos. Dicha división es más procesal que de derecho sustantivo, a diferencia de lo que sucede actualmente, ya que las acciones derivan de los derechos que las sustentan.

Lo cierto es que desde tiempos romanos el derecho real se presenta como un poder directo sobre la cosa que recae. Para asegurar la eficacia de ese poder, sin intermediarios, directo, surgen las acciones reales, que se ejercen frente a cualquiera, *erga omnes*. El derecho personal, en cambio, se asienta en una relación jurídica entre dos personas.

La concepción clásica describe el derecho real por oposición al personal, sobre la base de la existencia o no de un sujeto pasivo determinado, lo que alude incuestionablemente a la diferente oponibilidad que media entre ambas categorías. Pero, además, esto le permite entrar en el terreno de las facultades del sujeto activo (derecho personal) y titular (derecho real), pues mientras el primero puede obligar al sujeto pasivo a una conducta determinada de acción u omisión, el segundo puede "sacar" de una cosa un beneficio mayor o menor, según el contenido de su derecho.

a.2) *Doctrinas unitarias*

Así como la teoría clásica es dualista, éstas son las que impugnan la división dicotómica: derecho real-derecho personal. Puede clasificárselas, a su vez, en personalistas o realistas, según que la pretendida unificación se haga sobre una u otra categoría de derechos.

Entre las primeras, la más célebre es la que se atribuye a Planiol, aunque su mayor desarrollo corresponde a la tesis de su discípulo Michas, y se reduce a describir al derecho real como una obligación pasivamente universal (también Planiol y Ripert, Kelsen). Parte de ideas ampliamente difundidas con anterioridad a su formulación, en especial las de Kant, quien afirmaba que toda relación de derecho se establece entre personas, no entre persona y cosa, de modo que a todo derecho corresponde un deber, es absurdo suponer la obligación de una persona respecto de una cosa. También la doctrina alemana insistía en que la relación se da entre personas, y no entre persona y cosa.

Esta doctrina unitaria impugna la concepción clásica en cuanto alumbra una relación directa entre el titular del derecho y la cosa. Así, afirma que no existen diferencias fundamentales entre el derecho real y el derecho personal en la medida en que, tanto en uno como en otro, existe una obligación, dado que el derecho real sería también de naturaleza obligacional, siendo su objeto una prestación consistente en una abstención u omisión que pesaría sobre todos los integrantes de la comunidad. Así, por ejemplo, si el deudor le debe plata a su acreedor, aquél es claramente el sujeto pasivo de la obligación, mientras

que si alguien es dueño de una casa, toda la sociedad debe respetar ese derecho, no debe molestar, interferir. De ahí el nombre de "obligación pasiva universal" ya que el sujeto pasivo es ilimitado.

Esta teoría merece objeciones graves y evidentes. Desdeña el aspecto interno del derecho real que se patentiza en esa relación jurídico-económica de señorío que otorga al titular la facultad de extraer por sí solo el beneficio de la cosa según el contenido de su derecho. Por otro lado, confunde los conceptos porque esa mentada obligación pasiva universal no es una obligación en el sentido técnico de la palabra, no tiene contenido económico para el obligado (supuestamente obligado), dado que no grava su patrimonio, no figura en su pasivo. En rigor, no se trata de una obligación a cargo de toda la sociedad, sino de un mero deber de abstención, de inercia, que no es técnicamente lo mismo.

Por su parte, la doctrina unitaria "realista" (Gaudement, Saleilles) reduce todo a una relación entre patrimonios, y produce una despersonalización del derecho subjetivo al afirmar que los derechos personales no tienen por objeto una conducta del deudor o sujeto pasivo, sino su patrimonio, circunstancia que se apoya en la célebre máxima según la cual "el patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores".

En términos más sencillos la cuestión es la siguiente: una persona es dueña de una casa, tiene una relación con una cosa. Una persona es acreedora de otra y si el deudor no cumple, puede embargar y rematar alguna cosa para satisfacer su crédito, de modo que nuevamente la relación se da con una cosa.

En primer lugar, la máxima antes citada constituye una generalización que no excede el marco de un mero aforismo y carece de entidad para fundar una doctrina científica. Además, se caracteriza el derecho partiendo del momento anormal o excepcional del incumplimiento, única ocasión en la cual el acreedor obtiene la facultad de agredir el patrimonio de su deudor.

Finalmente, las dificultades de esta doctrina se agudizan cuando se trata de obligaciones de hacer o no hacer, y aún más, cuando ha sido expresamente tenida en cuenta la persona del deudor (obligaciones *intuitu personæ*).

a.3) *Teoría de la institución*

Clasifica a los derechos por su contenido institucional, preponderante en los reales y menguado en los personales. Para aquellos derechos de mayor contenido institucional debe aplicarse el derecho disciplinario, mientras que para los de menor contenido bastaría con normas estatutarias. Los derechos reales estarían ubicados en una categoría intermedia, entre los derechos personalísimos y los de familia (máximos exponentes del mayor contenido institucional). Se trata de la teoría institucionalista, principalmente sostenida por Hauriou. Esta teoría no es muy útil para definir al derecho real, sólo muestra una de sus características ya que no desconoce la distinción entre derechos reales y personales.

a.4) *Teoría del sujeto pasivo determinado*

Con distintos razonamientos y criterios clasificatorios, Arangio Ruiz y Ginossar advierten en los derechos reales sobre la cosa ajena, la existencia de un sujeto pasivo determinado, a la manera de los derechos personales, con lo cual se produce la relativización de los derechos reales. Este sujeto pasivo no es el sujeto pasivo universal de Planiol y de los sostenedores de la doctrina unitaria personalista que ya se expuso, sino un sujeto concreto y determinado, a la manera de los derechos personales. Dicho sujeto es el propietario de la cosa gravada por el derecho real desmembrado. Incluso en el derecho de dominio puede haber un sujeto pasivo determinado, que sería el vendedor de la cosa, ya que debe la garantía de evicción.

Esta teoría es rechazada, ya que la doctrina afirma que no hay obligación que corresponda a los derechos reales. Se trata en todos los casos de un deber de inercia, de abstención, de no interferir, mas no de una obligación. Ésa es la situación del titular de una cosa gravada.

a.5) *Doctrina moderna*

La teoría clásica, en tanto pone el acento en la relación entre el hombre y la cosa, no puede ser desatendida; la esencia del derecho real se basa en esa potestad directa. Claro que éste es el aspecto interno

o estático del derecho real, por lo que modernamente se procura contemplar también el aspecto externo o dinámico, esto es, la relación del titular con el resto de la sociedad, lo que se visualiza en la oponibilidad *erga omnes*, y en los derechos de preferencia y de persecución (Castán, Barassi y otros).

Es muy trascendente la definición de Allende: "Es un derecho absoluto, de contenido patrimonial, cuyas normas sustancialmente de orden público, establecen entre una persona (sujeto activo) y una cosa (objeto) una relación inmediata, que previa publicidad, obliga a la sociedad (sujeto pasivo) a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al mismo (obligación negativa), naciendo para el caso de violación una acción real y que otorga a sus titulares las ventajas inherentes al *ius perseguendi* y al *ius preferendi*".

La definición presenta la esencia, el contenido, sujeto, objeto y los caracteres fundamentales del derecho real: a) derecho absoluto: implica su oponibilidad *erga omnes*; b) de contenido patrimonial: los derechos reales son susceptibles de valor, por lo que integran el patrimonio (art. 16); c) naturaleza jurídica de sus normas: sustancialmente de orden público, lo que surge de los artículos 1884 y 1887 (*numerus clausus*), lo que no quiere decir que *todas* las normas relativas a los derechos reales sean de orden público; d) sujeto activo: puede serlo una persona humana o ideal; e) objeto: son las cosas ciertas, individualmente determinadas, en el comercio y actualmente existentes (excepcionalmente pueden serlo otros bienes -art. 1883-); f) relación inmediata: su titular, para extraer el beneficio de la cosa sobre la que recae el derecho, no necesita ningún intermediario. Inmediatez no significa "cercanía", sino que el titular obtiene la utilidad sin necesidad de la actuación de otra persona; g) publicidad: si el derecho real puede oponerse a todos, es indispensable que ese derecho pueda ser conocido también por todos. Hay dos formas de cumplimiento: la tradición y la inscripción en registros especiales; h) el sujeto pasivo es toda la sociedad, que está obligada a respetar la acción del titular del derecho sobre su cosa ("obligación de inercia"); i) acciones reales: protegen a los derechos reales en caso que se atente contra su existencia, plenitud o libertad; j) *ius perseguendi* y *ius preferendi*: perseguir la cosa en manos de cualquiera que la tenga (con

las limitaciones de la propia ley), y obtener ventajas como el privilegio, derecho de exclusión, prevalecer sobre derechos reales posteriores, etcétera.

b) Definición legal

Según el artículo 724 del Código Civil y Comercial, "La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés". Por su parte, dice el artículo 1882, "El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en este Código".

El derecho real es aquel que no tiene obligación correspondiente, que sí la tiene el derecho personal, con lo que se afirma la división dicotómica que domina todo el método del Código. La definición del artículo 1882 resalta el poder jurídico directo de una persona sobre el objeto, regulado por normas de orden público, con fuerte oponibilidad.

Dice el artículo 1882 que el derecho real es un poder jurídico, ya que es de la esencia de este tipo de derechos el poder que tiene su titular sobre el objeto para desplegar sus facultades. El dominio es el derecho real que otorga la mayor cantidad de facultades posibles, y otros otorgan menos, pero siempre el poder existe. El poder jurídico es un derecho subjetivo cuya esencia consiste en un señorío de la voluntad sobre objetos, que se ejerce en forma autónoma e independiente de otra voluntad. El poder es jurídico, ya que puede haber poder sobre una cosa de hecho, con prescindencia de lo jurídico, como sucede con las relaciones de poder, que se verán más adelante.

Agrega dicha norma que es de "estructura legal". Esto es así porque el contenido de los derechos reales está plasmado, esencialmente, en la ley (ver art. 1884). Aquí impera el orden público, aunque el Código reserva cierto margen a la autonomía de la voluntad.

Ese poder del titular sobre el objeto se ejerce en forma directa, sin intermediarios. Además, como se adelantó, a las facultades mencionadas el Código suma las de persecución y de preferencia.

El titular del derecho real puede ser una persona humana o jurídica, con excepción de los derechos de uso y habitación, de que sólo pueden ser titulares personas humanas (arts. 2154 y 2158).

c) Persecución y preferencia

Dice el artículo 1886: "El derecho real atribuye a su titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra, y de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente". Esta norma consagra dos atributos típicos de los derechos reales.

En primer lugar, los derechos reales —oponibles *erga omnes*— atribuyen el derecho de persecución, esto es, la facultad de perseguir la cosa en poder de quien la tenga. Se trata del *ius perseguendi*. En los derechos personales, el acreedor sólo puede demandar —en principio— al deudor que se obligó. En el campo de los derechos reales, las acciones siguen la cosa más que a una persona determinada, de allí que puedan ir contra cualquiera.

Sin embargo, esta facultad tiene límites, ya que en ciertas ocasiones el Código protege al subadquirente de buena fe y a título oneroso, para favorecer la seguridad dinámica y la circulación de los bienes.

En segundo lugar, aparece el derecho de preferencia, que tiene dos vertientes: por un lado, el derecho real constituido con anterioridad prevalece sobre el constituido posteriormente (primero en el tiempo primero en el Derecho, *prior in tempore potior in iure*). Así, por ejemplo, si el inmueble está hipotecado y luego se lo grava con una servidumbre, el acreedor hipotecario puede solicitar que el inmueble se ejecute libre de la servidumbre. Para que esto funcione es menester que los derechos reales se encuentren debidamente publicitados.

Por otro lado, se encuentra el privilegio, que permite a ciertos acreedores percibir su crédito con preferencia a otros, en el caso de venta de la cosa. Los derechos reales de garantía cuentan con privilegio.

V. Objeto del derecho real

Dispone el artículo 1883 del Código que "El derecho real se ejerce

sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa.

"El objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley".

La gran novedad es que el objeto de los derechos reales, de acuerdo a esta norma, no sólo son las cosas sino que también pueden serlo los bienes.

No es sencillo encontrar en el Código un caso de derecho real sobre un derecho, pero se abre la puerta. Puede que así se considere al crédito instrumentado objeto de la prenda. Otro caso puede ser el derecho de superficie cuando aún no se plantó, construyó o forestó (ver art. 2120).

No dice que la cosa sea cierta y determinada, y actualmente existente, pero son recaudos que cabe exigir, salvo supuestos de excepción. Además de la materialidad, el objeto del derecho real se caracteriza por la especialidad, ya que sólo es posible sobre cosas individualizadas, específicas, actuales. La especialidad se conecta con la inmediatez, en tanto el poder inmediato sobre una cosa presupone que ésta fue determinada y que actualmente existe. Se advierten aquí las diferencias con los derechos de crédito, que pueden tener por objeto bienes genéricos y/o futuros. La regla de la especialidad permite entender que no exista el derecho real sobre el patrimonio, sino sobre las cosas singulares que lo componen.

Quedan excluidas del régimen de los derechos reales las cosas del dominio público (ver art. 237).

En principio, no puede haber derechos reales sobre "una parte material", pues ello implicaría una partición antes de tiempo. Por regla el derecho real recae sobre toda la cosa, aunque pueda ser dividido el uso. No obstante, hay excepciones, así el artículo 2163 dice que "La servidumbre puede tener por objeto la totalidad o una parte material del inmueble ajeno". También la superficie, el usufructo, el uso y la habitación pueden tener por objeto partes materiales (arts. 2116, 2130, inc. a, 2154, 2158). A su vez, la acción reivindicatoria puede intentarse por una parte material de la cosa (arts. 2251, 2252, 2261).

MNR

En cuanto al ejercicio, hay situaciones en las que si bien el derecho real se ejerce sobre toda la cosa, existen limitaciones de tipo jurídico-ideal, no material, como sucede en el condominio, en el que el derecho real se ejerce sobre todo el objeto pero por una parte indivisa. El objeto es sin duda "una cosa" y la referencia a la parte indivisa apunta a indicar la proporción del derecho sobre la cosa, la medida de la participación en la cosa común, por ello se establece que se ejerce "por una parte indivisa".

VI. Concepto de cosa

El nuevo Código sigue la línea del anterior, ya que cosas son bienes materiales susceptibles de valor económico. Establece el artículo 16: "*Bienes y cosas*. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre".

Lo determinante es si son materiales, es decir si entra una materia física en su composición. Por tanto las cosas podrán ser sólidas, líquidas o gaseosas, pero al ocupar un lugar en el espacio resultarán comprendidas dentro del concepto.

a) Energía

No afirma el artículo 16 que la energía sea una "cosa", lo que no podría hacer sin desvirtuar el concepto establecido en el primer párrafo; se limita a declarar aplicables a aquélla las normas referentes a éstas. Se aplicarán en la medida en que sean compatibles. Resulta difícil imaginar relaciones como la posesión y la tenencia sobre la energía, o acciones posesorias o reales sobre tales fuerzas. Más sencilla resulta la asimilación en el ámbito de los derechos personales, ya que nada impide la celebración de un contrato de compraventa u otro apropiado.

Probablemente, esta asimilación responda a determinados criterios, porque cuando se roba energía es necesario que sean aplicables las disposiciones del Código Penal en materia de hurto o robo. Así lo ha

entendido la jurisprudencia en varios casos en los que se ha penalizado el acto de esa manera, asimilando la energía a las cosas, criterio no seguido por el legislador.

b) *Cuerpo humano*

No es una cosa y está alejado de toda idea de valor económico; por consiguiente, no puede ser objeto de un derecho real. Tiene mayor vinculación con el sujeto del derecho, dado que es el soporte físico de la persona, y correspondencia con los llamados "derechos personalísimos", de absoluta oponibilidad y contenido extrapatrimonial. El cuerpo humano se confunde con la persona, es el soporte que le da visibilidad, por lo que si el hombre no puede ser considerado cosa, tampoco puede serlo el cuerpo humano.

Sin embargo, la situación puede ser vista desde otro ángulo cuando sus partes son lícitamente separadas. Se suele citar como ejemplos el cabello, la sangre, la leche de madre, ciertos órganos, etcétera. Si esta separación no ofende el orden jurídico, tales partes, en tanto tengan valor en el amplio margen que brinda el artículo 17, pueden ser consideradas cosas en el sentido técnico del vocablo, por lo que se puede otorgar respecto de ellas actos dispositivos de derechos. Ello con mayor razón si se reproducen, como los tres primeros ejemplos citados.

Aquellas partes no renovables, suelen ser muy útiles en ocasiones para la investigación científica y para el descubrimiento de remedios a enfermedades.

En nuestro Derecho se debe tener presente la ley de trasplantes de órganos y materiales anatómicos 24.193, que regula "La ablación de órganos y material anatómico para la implantación de los mismos de cadáveres humanos a seres humanos, y entre seres humanos" (art. 1°).

Desde el ángulo opuesto, se encuentran aquellas cosas que se introducen en el cuerpo humano (v. gr.: un marcapasos, una prótesis, un tornillo, etc.). Dejan de ser cosas y se transforman en bienes personalísimos del individuo en el cual se han implantado.

c) *Cadáver y partes del cuerpo humano*

Vigente el Código anterior la doctrina se dividió en torno a si el cadáver, y partes del cuerpo humano separadas (especialmente si son renovables) podían ser reputados cosas. Respecto de estas últimas, el Código parece inclinarse por la negativa, teniendo en cuenta que luego de definir a las cosas, en el artículo siguiente se refiere a los derechos sobre el cuerpo humano.

Dice el artículo 17: "Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales".

Claro que también podría sostenerse que sí lo son, y que lo que hace el artículo 17 es aclarar que el concepto de valor no siempre es el económico. En fin, es una disputa aún no terminada.

El Código trae la siguiente disposición: "Artículo 56 – *Actos de disposición sobre el propio cuerpo*. Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

"La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial.

"El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no puede ser suplido, y es libremente revocable".

Además, el artículo 58 regula las condiciones necesarias para que pueda realizarse una investigación en seres humanos.

En cuanto al cadáver, parece razonable sostener que se trata de una cosa, generalmente sin valor económico; excepcionalmente puede tenerlo cuando, por ejemplo, se adquieren huesos o partes en un museo o facultad de medicina. Es inaceptable sostener, como hacen algunos, que se trata de un resto de la personalidad, o de una semipersona; la persona humana termina con la muerte (art. 93, Cód. Civ. y Com.).

Si bien es una cosa, debe respetarse la memoria de la persona, por lo que se entiende que son muy limitados los actos jurídicos que pueden celebrarse a su respecto. Se aplican los principios generales.

Prevé el artículo 61: "*Exequias*. La persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier forma, el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad".

d) *El embrión*

Al no haber una ley que contemple la situación, se trata de un tema polémico que divide a juristas, religiosos, filósofos, médicos, biólogos, etcétera. Puede decirse que hay, dejando de lado variantes, dos grupos principales: quienes consideran que el embrión es una cosa, y quienes lo consideran una persona. Son obvias las consecuencias y efectos que derivan de adoptar una postura u otra.

e) *Espacio aéreo*

Se ha discutido en doctrina si el espacio aéreo puede ser objeto de los derechos reales. Se suele afirmar que el espacio aéreo no es una cosa que exista materialmente, sino el medio en el que se encuentra la cosa y que es necesario para su existencia y ejercicio (concepto de relación), de modo que los contratos que suelen tener por objeto al espacio aéreo (v. gr.: futuras construcciones, derecho de sobreelevar en la propiedad horizontal, entre los más notorios), entran en el ámbito de los derechos personales.

VII. Enumeración de los derechos reales

a) "*Numerus clausus*"

Dice el artículo 1884: "*Estructura*. La regulación de los derechos

reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida sólo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley, o la modificación de su estructura". Los derechos reales y su estructura son creados y regulados por la ley (orden público). Este segundo aspecto es una regla que admite excepciones.

La norma en estudio dispone que los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. La mención de la "ley" no se limita al Código, sino que abarca todas aquellas leyes que dicte el Congreso nacional en uso de sus facultades constitucionales. En caso contrario, es decir si se constituyesen otros derechos reales que los previstos en la ley o se modificasen los existentes, el mismo artículo dispone expresamente su nulidad. Así, por ejemplo, si se constituye el derecho de enfiteusis, tal creación sería inválida.

El artículo 1884 extiende la prohibición también a la modificación de los derechos reales existentes, pero existen otras normas que atemperan el rigor, como las previstas en los artículos 1684, 1688, 1967, 1985, 1987, 1995, 2120, 2122, 2126, 2127, 2132, 2138, 2139, 2145, 2165, 2167, 2211, 2216, 2225, 2229, 2235, entre otros.

En el campo de los derechos personales reina el principio de la autonomía de la voluntad privada y la libertad de las convenciones, que es su consecuencia necesaria. Allí las reglas jurídicas son sustancialmente supletorias de la voluntad no expresada o incompletamente expresada, y si bien se regulan tipos contractuales nominados, ello no impide que los particulares se aparten de tal regulación, y aunque éstos, en sus convenciones, alumbren contratos no previstos (innominados o atípicos) u otros que resulten una combinación de las figuras legisladas o no (mixtos). Por supuesto que existe un reducido conjunto de reglas imperativas que se imponen a la voluntad privada, y constituyen el limitado ámbito de intervención del orden público en este sector del Derecho (ver arts. 958 y ss.).

Además, tampoco se puede modificar la regulación legal que de los derechos reales hace el Código (o cualquier ley que cree otro derecho real) en los contratos o testamentos que formalicen los particulares.

El fundamento de esta disposición que hace del *numerus clausus*

un principio incontestable en materia de derechos reales, se apreció en la nota al artículo 2502 del Código derogado, donde el Codificador, entre otras cosas, decía: "El Derecho Romano no reconoce al lado de la propiedad, sino un pequeño número de derechos reales, especialmente determinados, y era por lo tanto privada la creación arbitraria de nuevos derechos reales". Luego reseñó los males que se produjeron a partir de la Edad Media, sobre todo en la época feudal, por la creación incontrolada de una gran variedad de derechos y gravámenes, con lo que "las propiedades iban a su ruina", produciéndose una "fuente fecunda de complicaciones y de pleitos" y perjudicando "la explotación de esos bienes y la libre circulación de las propiedades, perpetuamente embarazadas".

El actual Código Civil y Comercial mantiene la regla tradicional del número cerrado, pero a la vez incorpora nuevos derechos reales: "los conjuntos inmobiliarios", "el tiempo compartido" y "el cementerio privado", y le da un marco más amplio al derecho de superficie, ya que antes sólo se admitía la superficie forestal. A pesar del intento, no agregó a la lista a la propiedad comunitaria indígena.

El artículo 1887 dispone lo siguiente: "*Enumeración*. Son derechos reales en este Código:

- "a) el dominio;
- "b) el condominio;
- "c) la propiedad horizontal;
- "d) los conjuntos inmobiliarios;
- "e) el tiempo compartido;
- "f) el cementerio privado;
- "g) la superficie;
- "h) el usufructo;
- "i) el uso;
- "j) la habitación;
- "k) la servidumbre;
- "l) la hipoteca;
- "m) la anticresis;
- "n) la prenda".

Este artículo enumera taxativamente los derechos reales permitidos.

En esta materia rige el orden público y hay un número cerrado (*numerus clausus*) de derechos reales permitidos. Es el sistema de muchos países, aunque cabe advertir que otros admiten el número abierto de derechos reales.

Vale destacar que los derechos reales pueden ser creados por otras leyes, además del Código Civil. Así sucede con la hipoteca naval, la prenda con registro, entre otros. Debe tratarse de leyes nacionales, ya que a las provincias les está vedado crear derechos reales (art. 75, inc. 12, Const. Nac.). Tampoco se podría crear un derecho real por decreto u ordenanza.

El número cerrado y la tipicidad son muy importantes en lo que concierne a los derechos reales sobre cosa ajena, pues se parte del principio de la libertad de los inmuebles. Si se admitiera una multiplicidad de derechos sobre cosa ajena, se terminaría por vaciar de contenido y por desnaturalizar al derecho de dominio, como ocurrió en la Edad Media.

Como se señaló anteriormente, en algunos países rige el *numerus apertus* de derechos reales; así, por ejemplo, en España, aunque los doctrinarios españoles discuten sobre el tema.

b) Diferencias entre creación legal y fuente legal

La creación del derecho real siempre es obra de la ley, mientras que la fuente de constitución puede ser otra. Una cosa es el origen del derecho real, siempre legal, y otra distinta su causa fuente, que puede ser la ley, el contrato, un testamento, etcétera. Las causas jurídicas de constitución varían según el derecho real de que se trate. Así, por ejemplo, el condominio puede tener fuente legal, en cambio la hipoteca únicamente puede ser convencional.

VIII. Convalidación

Se llama convalidación a la figura que permite regularizar la situación cuando alguien transmite un derecho real que no tiene pero luego lo adquiere. En este sentido, dispone el artículo 1885 que "Si quien constituye o transmite un derecho real que no tiene, lo adquiere posteriormente, la constitución o transmisión queda convalidada".

Por regla nadie puede transmitir un derecho que no tiene, ni siquiera mejor al que tiene (*nemo plus iuris* -art. 399-). Tal transmisión sería inoponible al verdadero titular y generaría la responsabilidad del transmisor.

No obstante, el artículo 1885 consagra el instituto de la convalidación de los derechos reales. Este principio apunta a un acto jurídico originariamente ineficaz que posteriormente por un suceso que ocurre luego de su celebración, adquiere validez con efecto retroactivo al momento de su otorgamiento para el cumplimiento de los efectos legales pertinentes. Ello, claro está, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.

El principio de convalidación rige para "todos" los derechos reales.

Si quien transmite el derecho real, cumpliendo con los requisitos de forma (v. gr.: escritura pública si se trata de inmuebles), no es el verdadero titular, es decir, no está legitimado para efectuar la transmisión, el adquirente cuenta con un "justo título", que le permitirá consolidar su situación al cabo de 10 años de posesión, si es de buena fe (ver arts. 1892, 1898, 1902/1903 y concs.). Ahora, si antes de ese plazo el transmitente que no estaba legitimado por alguna causa adquiere el derecho que ya transmitió, se opera la convalidación.

IX. Derechos reales no incluidos por el Código Civil y Comercial

a) *Los censos y las rentas*

Las rentas pueden constituirse como derechos personales o como derechos reales. En el primer caso (ej. renta vitalicia) no hay afectación de una cosa al cumplimiento. Hay renta real, llamada "censo", cuando la obligación asumida por el deudor de la renta se establece como carga de un bien inmueble y debe ser soportada por los sucesivos adquirentes. Censualista es el que debe recibir el canon, renta o pensión, y censatario el que lo paga.

Los censos no están permitidos. El Código Civil derogado los permitía por cinco años (art. 2614), aunque la norma no tuvo aplicación práctica.

b) *Enfiteusis*

Es el derecho real por el cual el propietario de un inmueble rústico enajena su dominio útil, permanentemente o por largo tiempo, a otra persona, a cambio de una pensión o canon cierto e invariable. El derecho del enfiteuta es transmisible a los herederos y por actos entre vivos.

c) *Vinculaciones*

La unión o sujeción de todos o determinados bienes a dominio perpetuo de una familia estableciendo un determinado orden sucesorio con prohibición de enajenar y los gravámenes o cargas perpetuas que se imponen en algunas fundaciones reciben el nombre genérico de vinculaciones.

El mayorazgo es el derecho por el cual el constituyente establece el orden sucesorio asegurando la inalienabilidad e indivisibilidad del bien.

Las capellanías constituyen un tipo de vinculación por la cual se establece, con carácter real y generalmente a perpetuidad, una carga sobre un bien inmueble, con una finalidad pía (ej. dar misas periódicamente en sufragio del alma del instituyente).

Estuvieron permitidas hasta que finalmente la ley 4124 las suprimió, y dispuso una compensación en dinero.

d) *Tanteo y retracto*

El tanteo o preferencia es un derecho real que tiene un tercero para que en el caso de que el dueño de una cosa la enajene, lo prefiera a él. Este derecho da lugar al derecho de retracto, por el cual si el dueño realiza la enajenación sin respetar la preferencia del tercero, éste puede dejar sin efecto la enajenación.

X. Derechos reales legislados fuera del Código Civil y Comercial

Como se dijo, el artículo 1887 del Código Civil y Comercial no obsta a que por leyes nacionales se creen otros derechos. En efecto, el artículo 1884 se refiere a la necesidad de una ley, y el Código es una ley pero no la única. De ahí que el artículo 1887 diga que "son

derechos reales en este Código...”, permitiendo así que pueda haber otros fuera de este ordenamiento.

Entre los más importantes cabe mencionar:

- Los warrants, vinculados a derechos de garantía sobre cosas muebles (mercaderías, frutos y productos), tendientes a la movilización del crédito prendario. Están legislados en las leyes 928 y 9643. El Código les reconoce privilegio (art. 2582, inc. e).
- Los debentures, actualmente contemplados en la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, también son una expresión de los derechos de garantía, cuando las sociedades por acciones recurren al crédito público emitiendo estos títulos con garantía especial o flotante.
- La prenda con registro es un derecho de garantía por el cual se afectan cosas muebles registrables que quedan en poder del deudor, debiéndose inscribir el instrumento en un registro especial. Este derecho otorga al acreedor diversas ventajas vinculadas con su ejecución judicial y un privilegio especial. Está regulado por el decreto-ley 15.348/46, ratificado por la ley 12.962 (t. o. por dec. 897/95).
- La Ley de Navegación 20.094 regula la copropiedad naval, que guarda algunas diferencias con el condominio del Código, la hipoteca naval que se aplica a buques de más de diez toneladas y la prenda naval con desplazamiento para buques de menos de diez toneladas.
- El Código Aeronáutico (ley 17.285) prevé la hipoteca aeronáutica, derecho de garantía cuyo objeto lo constituye una aeronave o una parte indivisa o su motor.

XI. Diferencias entre los derechos reales y los derechos personales

Los derechos reales se diferencian de los personales por diversos factores:

a) Objeto

El objeto de los derechos personales es la prestación, conducta del

MNR

deudor a la que se obliga a favor del acreedor (dar, hacer o no hacer); el de los derechos reales es generalmente la cosa, que debe ser cierta, actual y determinada. La inherencia de la cosa es el rasgo característico de esta clase de derechos, lo que resulta ajeno a los derechos personales. En situaciones excepcionales el Código admite que el objeto sea un bien. Los derechos personales pueden apuntar a cosas futuras o indeterminadas.

b) Sujetos

En cuanto a los sujetos, la doctrina clásica sostiene que los derechos reales se diferencian de los personales por la ausencia de sujeto pasivo.

Los derechos personales admiten la unidad o pluralidad de sujetos activos y/o pasivos, resultando siempre factible su concurrencia sin limitaciones. Los derechos reales, según su naturaleza, pueden ser concurrentes o exclusivos, es decir que permiten o prohíben la concurrencia sobre un mismo objeto del mismo derecho real.

c) Orden público

En los derechos personales impera el principio de la autonomía de la voluntad, con la sola limitación que impone el orden público, la moral, las buenas costumbres, la buena fe. En los derechos reales predomina el orden público, reservando un estrecho espacio a la autonomía de la voluntad.

d) Inmediatez

En los derechos personales la relación es indirecta o mediata entre el titular del derecho y el objeto, puesto que el cumplimiento de la obligación depende, en principio, de la conducta del deudor. En los derechos reales, el titular obtiene el beneficio directo de la cosa, sin que medie la actuación de otra persona; son inmediatos.

e) Carácter absoluto

Los derechos personales son relativos en cuanto a su oponibilidad, mientras que los derechos reales son absolutos (son oponibles *erga omnes*).

f) *Publicidad*

En los derechos personales no se requiere la publicidad, precisamente por ser relativos; la publicidad es ajena a estos derechos. En los derechos reales, por tratarse de derechos absolutos y con la finalidad de que resulten oponibles y sean respetados, deben ser conocidos por todos.

Cuando se transmite o constituye un derecho real sobre un inmueble, es necesaria la publicidad registral para que sea oponible a terceros.

g) *Duración*

Los derechos reales permanecen en el tiempo con respecto al beneficio que acuerdan al titular, pueden ser perpetuos o temporarios, los derechos personales tienen un carácter instantáneo o transitorio pues el momento de la obtención del beneficio por el acreedor coincide con la extinción del derecho. Los derechos personales son siempre temporarios, pues no corresponde que una persona se encuentre obligada por siempre.

h) *"Ius perseguendi"*

El sujeto titular de un derecho real goza del *ius perseguendi*, lo que implica que puede perseguir la cosa, sin importar —en principio— el sujeto que la tenga bajo su poder. Esto también suele denominarse "inherencia". El derecho personal, en principio, carece de persecución con relación al objeto.

i) *"Ius preferendi"*

Asimismo, el titular del derecho real goza también del *ius preferendi* que importa el derecho de ser preferido en el ejercicio de su derecho con respecto a otros derechos reales de igual o distinta naturaleza sobre la misma cosa, posteriormente constituidos conforme al principio *prior in tempore potior in iure*. También algunos derechos reales cuentan con privilegio para el cobro (v. gr.: hipoteca).

j) *Abandono*

El acreedor puede renunciar a sus derechos personales en beneficio

del deudor, lo que implica un modo de extinción de las obligaciones. El titular de un derecho real puede abdicar de él mediante el abandono o la renuncia de su derecho. En el caso de que se trate de un inmueble y se abandone el dominio o la propiedad horizontal, se beneficia al Estado; si se abandona el condominio, a los condóminos, y si se trata de un derecho real sobre cosa ajena, al dueño, condómino o propietario horizontal. Si el objeto es mueble beneficia al sujeto que se ha apropiado de él, a los condóminos y al dueño o condómino.

k) *Pérdida de la cosa*

En el derecho real, cuando el objeto se pierde, se opera su extinción, no así en el derecho personal, ya que no se extingue aunque desaparezcan todos los bienes del deudor.

l) *Posesión*

Casi todos los derechos reales se ejercen por la posesión, lo que no ocurre con los derechos de crédito.

m) *Prescripción*

Cuando, por el transcurso del tiempo, se opera la prescripción adquisitiva, ésta importa un modo de adquisición de determinados derechos reales, mientras que en los derechos personales rige la prescripción liberatoria que los extingue, impidiendo que la obligación pueda ser reclamada en juicio. Existe, sin embargo, un modo de extinción de derechos reales mediante una suerte de prescripción liberatoria que extingue los derechos reales de goce o disfrute sobre cosa ajena y que se produce por el no uso.

n) *Causa*

Los derechos personales se originan en la causa que determina la ley (título), en los derechos reales, basta en algunos casos el hecho o acto jurídico para que nazca el derecho real (título), mientras que en otros se requiere que sobrevenga o preceda otro hecho o acto (modo) para que se produzca la adquisición del derecho.

ñ) *Carácter estático*

Así como la obligación presenta un carácter dinámico, ya que se trata de un instrumento importante para el tráfico económico, los derechos reales presentan una situación más estática. Claro que son generalidades que admiten en cada caso excepciones.

o) *Acciones*

Los derechos reales cuentan con la protección de acciones reales, que se dirigen contra cualquier persona que pretenda negar su existencia, plenitud o libertad, mientras que los personales generan acciones que sólo pueden dirigirse contra el obligado. Aquí cobra relevancia el *ius persequendi*, mencionado anteriormente.

p) *Juez competente*

En los conflictos vinculados a derechos reales, suele ser juez competente el del lugar en el que esté situada la cosa, mientras que en los derechos personales puede serlo el del lugar de celebración del contrato, o de cumplimiento de la obligación, o el del domicilio del deudor. La cuestión depende de los códigos procesales, que por ser locales, pueden variar de una provincia a otra.

También son diferentes las normas de Derecho Internacional Privado aplicables a unos y otros. Para los derechos reales se aplica lo previsto en los artículos 2663 a 2670.

XII. Conexiones entre los derechos reales y los personales

Así como hay diferencias, también hay vinculaciones entre ambos:

- a) Las transmisiones de derechos reales por actos entre vivos tienen su causa fuente en un derecho personal (v. gr.: compraventa, permuta, donación, etc.).
- b) Hay derechos reales que son accesorios de derechos personales, como ocurre con los derechos reales de garantía. A su vez, hay derechos reales que abarcan derechos personales accesorios (v. gr.: tiempo compartido, servidumbre, etc.).
- c) Cuando se ataca un derecho real, además de la protección po-

sesoria o real, el titular puede pedir una indemnización, accesorio o sustitutivo. En ocasiones, la ley adjudica el derecho real (v. gr.: medianería) e impone al adjudicatario la obligación de pagar el precio correspondiente.

- d) Hay ciertas obligaciones que son ambulatorias, se transmiten con una cosa. También se las conoce como obligaciones reales o *propter rem*.

XIII. Clasificación de los derechos reales

a) *Derechos reales sobre cosa propia o cosa ajena*

Dice el artículo 1888: "Son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie si existe propiedad superficiaria. Los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena..."

Cuando se constituye un derecho sobre cosa ajena (v. gr.: usufructo), se configura una carga real, y el derecho real sobre cosa propia está desmembrado; el dominio es imperfecto (art. 1964).

La superficie es un derecho real sobre cosa propia cuando ya hay propiedad superficiaria, tema controvertido en el sistema anterior, que sólo admitió la superficie forestal. Por ende, si aún no se ejerció el derecho de plantar, construir o forestar, el derecho es sobre inmueble ajeno.

Los derechos reales sobre cosa ajena a su vez se dividen en derechos de disfrute (superficie si no existe propiedad superficiaria, usufructo, uso, habitación, servidumbres) y de garantía (hipoteca, prenda, anticresis).

b) *Derechos reales principales y accesorios*

Dispone el artículo 1889 que "Los derechos reales son principales, excepto los accesorios de un crédito en función de garantía. Son accesorios la hipoteca, la anticresis y la prenda".

Los únicos derechos reales accesorios, según el Código, son los de garantía. Dependen para su existencia de un derecho personal al que acceden (art. 857). No se pueden adquirir por prescripción (art. 2565).

c) *Derechos reales sobre cosas registrables y no registrables*

Dispone el artículo 1890: "Los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan. Recaen sobre cosas no registrables, cuando los documentos portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción".

Los derechos reales recaen esencialmente sobre cosas, las que pueden ser inmuebles o muebles, y éstas a su vez son registrables o no registrables, cuando los documentos portantes de derechos tengan acceso al registro, ya sea para su oponibilidad (buques, aeronaves, ganado), o también para su constitución (automotores, caballos de pura sangre).

d) *Ejercicio por la posesión o por actos posesorios*

Según el artículo 1891: "Todos los derechos reales regulados en este Código se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca.

"Las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su titular ostente la posesión".

El artículo 1891 aclara en la parte final que hay actos posesorios concretos en las servidumbres positivas, que son aquellas en las que la carga real consiste en soportar su ejercicio (v. gr.: de paso); es negativa si la carga real se limita a una abstención determinada imputada en el título (art. 2164).

XIV. Transmisibilidad

Establece el artículo 1906 que "Todos los derechos reales son transmisibles, excepto disposición legal en contrario". Se sienta claramente una regla general, con el fin de evitar la casuística. Al tratarse de un principio, se puede concluir que, en caso de duda, debe estarse por la transmisibilidad. En el mismo sentido, surge del artículo 398 que "Todos los derechos son transmisibles excepto estipulación válida de las partes o que ello resulte de una prohibición legal o que importe trasgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres".

Coincide con la regla del artículo 1972, que veda en los actos a

título oneroso las cláusulas de no enajenar. Se trata de favorecer la circulación de los bienes, de evitar que queden estancados.

Claro que esto es así "excepto disposición legal en contrario", dice el propio artículo 1906. Así, entonces, el derecho de habitación no lo es. El usufructo sí es transmisible, pero no se extiende más allá de la vida del usufructuario cedente (art. 2142).

El condominio sobre un muro, o una servidumbre, no puede ser transmitido con independencia del inmueble al que accede.

En ocasiones la ley autoriza pactos de no enajenar, como sucede, por ejemplo, en el ámbito del fideicomiso (art. 1688). Además, cabe recordar que por regla el fiduciario puede disponer o gravar en tanto lo requieran los fines del fideicomiso (art. cit.).

Otro límite encuentran ciertos actos de disposición que requieren la conformidad de otra persona (v. gr.: del cónyuge, art. 250).

El Código aclara en el artículo 234 cuándo los bienes están fuera del comercio: "Están fuera del comercio los bienes cuya transmisión está expresamente prohibida: a) por la ley; b) por actos jurídicos, en cuanto este Código permite tales prohibiciones".

XV. Modos de adquisición de los derechos reales

En el Título I, Capítulo 2, del Libro Cuarto, el Código trata la adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad de los derechos reales. Se trata de un acierto dedicar una parte general, especialmente a las causas de adquisición y de extinción, lo que no estaba previsto en el Código anterior.

Los modos de adquirir derechos reales son los siguientes: título y modo; voluntad de la ley, prescripción adquisitiva y sucesión. Éstos son generales, aplicables a la mayoría de los derechos reales (v. gr.: no todos se pueden adquirir por prescripción), pero cabe aclarar que existen modos especiales de adquisición de algunos derechos reales. Así, por ejemplo, el dominio tiene otros medios regulados especialmente al tratar este derecho real (ver arts. 1947 y ss.).

Cabe advertir que el Código prohíbe la constitución judicial, esto es, que el derecho real sea constituido o impuesto por un juez (art. 1896). Esto es así salvo que alguna norma dispusiera lo contrario.

XVI. Clasificación

Atendiendo a distintas circunstancias, los modos de adquirir son clasificados así: 1) por actos entre vivos y *mortis causa*; 2) a título universal y a título singular; 3) originarios y derivados, siendo esta última clasificación la que reviste mayor interés.

- 1) Por actos entre vivos o *mortis causa*: el primero, está representado por el título y el modo (art. 1892); del segundo, es ejemplo el legado de cosa cierta;
- 2) a título universal y a título singular: según si lo adquirido fuera la totalidad o una parte de los bienes que constituyen un patrimonio, o si fuese una cosa determinada; verificándose el primer caso en la sucesión por causa de muerte o la transmisión fiduciaria de una universalidad, y el segundo cuando la cosa es adquirida por medio de un acto jurídico eficaz para transmitir el derecho. Claro que cuando se transmite una universalidad, el derecho real recae sobre cada una de las cosas que la componen, y
- 3) originario se llama el modo cuando la cosa se adquiere independientemente y a pesar del derecho que tenía el propietario anterior, o cuando la cosa no tenía dueño (*res nullius*), o había sido abandonada (*res derelictæ*), como sucede con la atribución legal de la cosa mueble al tercero de buena fe y a título oneroso (art. 1895), la apropiación, la transformación, la accesión y la prescripción adquisitiva o usucapión (aunque la doctrina no es pacífica en este último punto).

En cambio, cuando se adquiere de un titular anterior se dice que el modo de adquirir es "derivado", y eso trae como consecuencia que el adquirente —en principio— tendrá la cosa con todas las cargas, gravámenes y limitaciones que pesaban sobre aquél, además de los que la ley le imponga, porque le es de aplicación la regla del Derecho Romano que "nadie puede transferir a otro más derecho que el que él mismo tenga", incorporado por nuestro Código al artículo 399.

Cuando el modo de adquirir ha sido derivado, el Código llama "sucesor" (singular o universal) a quien la recibió (art. 400).

Modos de adquisición derivados son la tradición, la inscripción registral constitutiva, y la sucesión en los derechos del dueño (arts. 2277 y ss.).

a) *Adquisición derivada por actos entre vivos. El título y el modo*

La adquisición derivada (no originaria) por actos entre vivos de derechos reales que se ejercen por la posesión requiere la concurrencia del título y del modo. La tradición por sí sola no sirve para transmitir el derecho real, si no va precedida de un negocio jurídico antecedente que justifica la transmisión.

El título suficiente (art. 1892) es un acto jurídico en los términos del artículo 259, apto para transmisión de un derecho real propio del disponente capaz y legitimado al efecto (art. 399), y que debe ser formalizado de acuerdo a los requisitos legales para alcanzar el fin perseguido.

El modo es el acto a través del cual la adquisición tiene lugar para la materialización de la mencionada posibilidad.

Si el otorgante es incapaz o no estaba legitimado para tal fin, sólo se está en presencia de un "justo título" para usucapir (art. 1902). En cuanto a la capacidad, de acuerdo a lo que surge de los artículos 22 y siguientes, es necesario contar con más de 18 años de edad (salvo emancipación) y no haber sido declarado incapaz.

Por otro lado, cuando se trata de cosas inmuebles, la forma requerida es la escritura pública (art. 1017).

La palabra "título" responde al concepto de "causa", es decir, el acto jurídico que sirve de causa a la tradición; así, por ejemplo, la venta, donación, permuta, aporte en sociedad, pago por entrega de bienes, etcétera. El título sería la causa mediata, y la tradición la causa inmediata.

Concretemos con un ejemplo: Pedro le vende a Juan un cuadro por la suma de un millón de pesos. Ese contrato de compraventa queda perfecto el día en que Pedro y Juan (vendedor y comprador) se ponen de acuerdo sobre el precio y la cosa. En esta primera etapa, que termina con el perfeccionamiento del contrato, nos encontramos con dos obligaciones que tienen como fuente el contrato mismo. Una obligación para Pedro de entregar el cuadro y una obligación para Juan de entregar el precio. Por la misma razón nos encontramos frente a dos derechos

personales: uno para Pedro, que consiste en poder exigirle a Juan el cumplimiento de la prestación de dar (pagar el millón de pesos), obligación frente a la cual Pedro es acreedor o titular del derecho personal. El otro derecho personal, para Juan, cuyo objeto es la prestación u obligación, en cabeza de Pedro, de entregar la pintura. Juan es acreedor del cuadro. Ahora desarrollemos el ejemplo hasta convertir a Juan en dueño de la obra artística. En el momento en que Pedro cumple con su obligación de vendedor, esto es, en el momento en que Pedro le entrega el cuadro a Juan, esa entrega equivale a tradición, que es uno de los modos de adquirir el dominio. Ésta es la segunda etapa. La que tiene que ver con el modo. La primera se agota en el título, y la segunda, en el modo. Sumadas las dos, surge el derecho real. La primera sola origina el derecho personal. Se concluye, entonces, que el derecho personal surge de las fuentes de las obligaciones, en tanto que el derecho real surge de la unión del título y el modo, y pasa a ser el modo la causa próxima del derecho real (por estar más cerca del derecho real) y el título la causa remota del derecho real.

En cuanto a la tradición en sí misma, es menester la realización de actos materiales en los términos de los artículos 1924 y siguientes. Asimismo, es necesario que quien transmite la cosa sea su propietario y que *tradens* y *accipiens* sean capaces.

En consecuencia, de los distintos modos de adquisición de los derechos reales, sólo resulta factible referirse al título y al modo con relación a la tradición; quedando excluidos los modos originarios como: la apropiación, la accesión y la prescripción adquisitiva.

La tradición es constitutiva del derecho real. Este requisito de *raigambre* romanista constituye un principio con muy pocas excepciones en el Código Civil y Comercial: la *traditio brevi manu* y el *constituto possessorio* (arts. 1892, segundo párrafo y 1923).

En el caso de las servidumbres positivas, el primer uso equivale a la tradición.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe advertir que en ciertos casos especiales, como señala el artículo 1892, el modo no es la tradición sino la inscripción registral. Es el caso, por ejemplo, de los automotores y de los caballos de pura sangre de carrera, en el que la inscripción en el Registro es constitutiva.

MNR

Queda fuera de este sistema el derecho real de hipoteca, el que no se ejerce por la posesión y, por lo tanto, no hay tradición; se constituye con el título.

a.1) Oponibilidad a terceros

Los derechos reales son oponibles *erga omnes*. Por lo tanto, requieren de publicidad para ser conocidos y oponibles a ciertos terceros. Dice el artículo 1893: "La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este Código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente.

"Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso.

"Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real.

"No pueden prevalecerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real".

a.2) Formas de concretar la publicidad

En términos generales, la publicidad consiste en llevar a conocimiento de los interesados actos o hechos jurídicos reconocidos y apoyados por la ley.

El artículo 1893 prevé dos formas de hacer públicos los derechos reales. Una es la tradición, la que, además de su función constitutiva del derecho real, cumple un rol publicitario cuando se trata de cosas muebles no registrables (v. gr.: un reloj).

Cuando se trata de cosas registrables, sean muebles o inmuebles, sea la inscripción declarativa o constitutiva, la publicidad se concreta a través de la inscripción en el Registro que corresponda. Si bien el segundo párrafo del artículo 1893 dice, de manera poco feliz, "Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso", cabe limitar la publicidad posesoria a aquellas adquisiciones o mutaciones de derechos reales sobre cosas no registrables.

De no ser así, el sistema generará muchas incertidumbres e inseguridad. Ese alcance cabe darle a la expresión "según el caso".

a.3) *Inscripción y publicidad*

En materia de cosas registrables, la inscripción del título en el Registro le otorga oponibilidad frente a terceros interesados de buena fe.

a.4) *Naturaleza de la inscripción registral*

La inscripción es constitutiva cuando se la impone aun con referencia a las partes del negocio jurídico fuente de la transmisión, como también para la oponibilidad a los terceros, y declarativa (no constitutiva) si la exigencia no alcanza ni a las partes del negocio jurídico, ni a los terceros desinteresados y se concreta a obrar como presupuesto de la oponibilidad a los terceros interesados.

La ley 17.801 dispone una inscripción de definidos rasgos declarativos en sus artículos 2º, 20 y 22, dejando aclarado que el registro tiene por finalidad la publicidad y oponibilidad de terceros, y que las partes, sus herederos y los que han intervenido en la formalización del documento no podrán prevalerse de la falta de inscripción, y respecto de ellos el derecho documentado se considera registrado.

En nuestro sistema hay registros diversos y con efectos diferentes. Así para los inmuebles la inscripción registral tiene efectos declarativos, esto es, al solo efecto de que el acto jurídico inscripto sea oponible a terceros. Lo mismo acontece con los buques y las aeronaves. En cambio, para los automotores, la inscripción registral es constitutiva, de modo que surte efectos no sólo para los terceros sino también para las partes del negocio. Lo mismo sucede con los caballos de pura sangre de carrera.

a.5) *Los terceros frente a la inscripción*

El tercero es una persona ajena o distinta de dos o más que intervienen en un negocio jurídico, es decir, aquella que no es parte en el acto y por tanto no puede, en principio, verse perjudicada por los efectos de las relaciones jurídicas vinculantes para otros (art. 1021).

Los terceros que menciona el artículo 1021 son los *pænitus extranei*,

simples terceros o terceros desinteresados. Por el contrario, los terceros interesados son los que tienen un interés legítimo y se hallan facultados para invocar la inoponibilidad del derecho real no inscripto. Los sucesores particulares, los titulares de otros derechos reales, la masa del concurso (civil o comercial), los acreedores privilegiados, retentores, simples quirografarios, entre otros, son los que revisten este carácter, genéricamente podemos señalar que son terceros interesados los titulares de derechos subjetivos.

Los terceros interesados son todos los que tengan un interés jurídico por ser titulares de un derecho subjetivo, para cuyo ejercicio no sea indiferente la registración del derecho real. Y la publicidad del derecho real o de la situación jurídica registrada puede no ser indiferente en dos sentidos: bien por no hallarse registrado un derecho real impidiéndole ejercer el suyo propio; bien por haberse registrado alguna mutación que impida o perjudique su ejercicio. Si la registración o la falta de ella no genera al tercero ninguna dificultad o imposibilidad de ejercer su derecho en plenitud, entonces, este tercero carece de interés y bastará la publicidad traditiva-posesoria. La gran mayoría de la sociedad, obligada pasivamente a respetar el derecho real constituido con título y modo, entrará en esta categoría. Relacionando este concepto con la seguridad jurídica, se está frente a una situación de "seguridad estática".

El Código se refiere a terceros interesados, siguiendo la terminología más aceptada en doctrina.

Por último, también hay que advertir que el artículo 1893 exige la registración para los terceros interesados que además sean de buena fe. Dice la última parte que "no pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real". Así, por ejemplo, el testigo del acto no puede alegar desconocimiento por la falta de inscripción, cuando es indudable que conoce lo sucedido. Aceptar lo contrario sería avalar la mala fe.

Serán de buena fe aquellos terceros que, obrando con cuidado y previsión, siendo diligentes y agotando los medios que la ley pone a su disposición para obrar seguros, actúen en consecuencia.

b) *Adquisición por causa de muerte*

En la transmisión de los derechos reales por causa de muerte —es decir, por vía sucesoria—, el requisito de la tradición del *tradens* al *accipiens* no es aplicable.

No es necesaria la tradición, ya que dispone el artículo 2280: "Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor..."

c) *Adquisición legal*

Dice el artículo 1894: "*Adquisición legal*. Se adquieren por mero efecto de la ley, los condominios con indivisión forzosa perdurable de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles y de muros, cercos y fosos cuando el cerramiento es forzoso, y el que se origina en la accesión de cosas muebles inseparables; la habitación del cónyuge y del conviviente supérstite, y los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe".

La ley es otro modo de adquirir derechos reales.

Además de los casos aquí enumerados hay otros, como sucede con el artículo 2166 que prevé casos de servidumbres forzosas, esto es, impuestas por la ley.

d) *Prescripción adquisitiva*

Éste es el otro modo general de adquirir derechos reales. Dice el artículo 1897: "La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley". Es un modo originario (no derivado) de adquirir.

Es un acierto regular la prescripción adquisitiva entre los modos de adquisición de los derechos reales y en la Parte general, a diferencia del Código de Vélez que la reguló al final, junto con la prescripción liberatoria.

Por su propia definición, quedan excluidos de su campo de apli-

cación los derechos reales que no se ejercen por la posesión ni por actos posesorios como la hipoteca o las servidumbres negativas. Además, el Código prohíbe que la superficie pueda ser adquirida por usucapión larga (art. 2119).

El Código regula dos clases de prescripción adquisitiva: larga y breve.

e) *Subasta judicial*

Se discute si la adquisición en subasta importa un modo originario o derivado de adquirir. En mi opinión, se trata de una venta, forzada pero venta al fin. Por ende, es un modo derivado.

XVII. Modos de extinción de los derechos reales

El Código enumera causas generales de extinción de los derechos reales. Dice el artículo 1907: "*Extinción*. Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, éstos se extinguen, por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono y por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena".

a) *Destrucción*

En cuanto a la destrucción de la cosa, es lógico ya que el derecho real carecería de objeto. La destrucción debe ser total, pues si es parcial, el derecho real continuaría sobre la parte restante. Dice el artículo 1907: "si la ley no autoriza su reconstrucción". Claro ejemplo de ello es el derecho de superficie, que no se extingue si el superficiario reconstruye o reforesta (art. 2122).

En algún caso la extinción de la cosa puede ser jurídica, en lugar de física. Ello ocurriría, por ejemplo, si pasa al dominio público del Estado, en cuyo caso no puede ser objeto de un derecho real.

b) *Abandono*

El abandono, del derecho real no de la posesión, debe ser categórico.

Según el artículo 948, la voluntad de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que permiten inducirlos es restrictiva.

Si se trata de inmuebles, debe ser formalizado por escritura pública, ya que según el artículo 1017, inciso a, deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Si se trata de cosas registrables, el abandono deberá ser registrado, ya sea la inscripción declarativa o constitutiva. Los inmuebles sin dueño pertenecen al dominio privado del Estado (art. 236, inc. a). Las cosas muebles abandonadas pueden ser adquiridas por apropiación.

La renuncia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos (art. 1989).

El abandono, si se trata de obligaciones *propter rem* (art. 1937), libera a quien lo hizo; caso contrario no hay liberación (ver, por ejemplo, art. 2123 para la superficie).

c) Consolidación

La consolidación se produce en los derechos reales sobre cosa ajena cuando una misma persona reúne la titularidad de ambos derechos, ya que si alguien es dueño no tendría sentido que mantenga un derecho real sobre su propia cosa (v. gr.: usufructuario que compra el inmueble). Cabe advertir que también en el derecho de superficie se prevé la consolidación (art. 2124). La consolidación no puede operar en perjuicio de terceros, cuyos derechos reales deben subsistir.

d) Otros modos

Como bien aclara el artículo 1907, se trata de causas generales que en principio abarcan a todos los derechos reales, pero no son las únicas. En la regulación de los distintos derechos reales se encuentran causas especiales de muchos de ellos. Así, por ejemplo, el usufructo se extingue por el no uso, lo que no es aplicable al dominio.

XVIII. Concepto de carga real

Dice el artículo 1888: "...Con relación al dueño de la cosa, los

derechos reales sobre cosa ajena constituyen cargas o gravámenes reales. Las cosas se presumen sin gravamen, excepto prueba en contrario. Toda duda sobre la existencia de un gravamen real, su extensión o el modo de ejercicio, se interpreta a favor del titular del bien gravado".

Esta norma aclara el concepto de carga real. Dice que los derechos sobre cosa ajena importan cargas reales respecto del dueño. Así, por ejemplo, si sobre un inmueble pesa una servidumbre, ésta es una carga real que debe ser soportada por los sucesores de ese inmueble. La idea de carga real es la existencia de un derecho real adherido a la cosa, que debe ser mantenido.

Así, en materia de servidumbres, constituyen un derecho real para el fundo dominante (servidumbre activa) y una carga real para el fundo sirviente (servidumbre pasiva). En la hipoteca, el acreedor es el titular del derecho real, y el propietario de la cosa hipotecada (sea o no deudor de la obligación principal) soporta la carga real.

La deonomación "carga real", en el Código, hace referencia al aspecto pasivo de los derechos reales.

XIX. Obligaciones reales

En general, el derecho real atribuye a su titular un poder sobre una cosa, no ligado directamente a obligaciones de su parte. Sin embargo, existen supuestos en que la existencia de un derecho real o relación posesoria conlleva para su titular la existencia de determinadas obligaciones: son las llamadas obligaciones *propter rem*, ambulatorias, o reales (obligaciones "a causa de la cosa"), que se derivan de su titularidad. Se dice que la obligación "viaja con la cosa". La prestación puede tener por objeto dar, hacer o no hacer.

Esta ambulatoriedad se produce aun en ausencia de acuerdo de partes. La ley es causa no sólo del nacimiento de la obligación, sino también de su transmisión y extinción. La voluntad de los sujetos de la relación en ese punto es indiferente. Si se pactase que el deudor no queda liberado con el abandono de la cosa, la razón de la subsistencia de la obligación tendría por fuente al contrato pero no sería ya una obligación *propter rem*.

Se encuentran en el Código algunos ejemplos. Así, en el Capítulo 4,

Título III, Libro Cuarto, se regulan los límites al dominio, que son considerados derechos y deberes inherentes a la posesión (arts. 1932, 1933 y 1937); allí hay supuestos de obligaciones *propter rem*, como la del propietario de no alterar el curso natural de las aguas (art. 1975). También pueden citarse el artículo 2028, según el cual la abdicación de la medianería libera de la obligación de pagar créditos originados en la conservación, construcción o reconstrucción del muro divisorio; el artículo 1956, según el cual el dueño de la cosa perdida puede liberarse de pagarle una recompensa al hallador si le transmite su dominio; la obligación del usufructuario de efectuar mejoras necesarias (art. 2146); o la obligación de los titulares de terrenos sobre cuyos límites existe incertidumbre, de proceder a investigar y demarcar dichos límites (arts. 2266 y 2267).

Como se dijo, cuatro son las características de las obligaciones reales: a) nacen de la ley, son *ex lege*; b) se originan en virtud de una relación del sujeto con la cosa, que puede apoyarse en un derecho real, en la posesión, y hasta en la tenencia; c) la ambulatoriedad; d) la posibilidad de liberarse por el abandono de la cosa o por alguna otra causa que implique el cese de la relación con dicha cosa (v. gr.: venta, destrucción, etc.).

Una situación compleja es determinar si, en caso de incumplimiento, el deudor responde con todo su patrimonio o sólo con la cosa con la que vino adherida la obligación (responsabilidad *intra rem*).

El Código actual establece una limitación de responsabilidad a la cosa transmitida. En efecto, dice el artículo 1937: "*Transmisión de obligaciones al sucesor*. El sucesor particular sucede a su antecesor en las obligaciones inherentes a la posesión sobre la cosa; pero el sucesor particular responde sólo con la cosa sobre la cual recae el derecho real. El antecesor queda liberado, excepto estipulación o disposición legal".

Cabe inferir que esta norma se refiere a las obligaciones reales, ya que se titula "transmisión de obligaciones al sucesor", alude a "obligaciones inherentes a la posesión", especie del género "deberes inherentes a la posesión", que abarca un espectro más amplio que incluye a las cargas reales, entre otros (ver art. 1933).

Por lo tanto, puede hacerse una distinción. Respecto de la obligación

generada, devengada, durante la titularidad de una relación real o de poder, el deudor responde con todo su patrimonio, como sucede —por regla— con todos los deudores (art. 743). En cambio, transmitida la cosa a otro, el sucesor particular responde sólo con la cosa, al haberse devengado la deuda cuando él no era el titular.

El artículo 1937 se refiere al sucesor singular (aquel que recibe un derecho en particular, art. 400), ya que en caso de sucesión universal los herederos continúan a la persona del causante en todos sus derechos y obligaciones (art. 2277), y responden por sus deudas con los bienes que reciben, o con su valor en caso de haber sido enajenados (art. 2280, *in fine*).

CAPÍTULO II

RELACIONES DE PODER

(primera parte)

MNR

SUMARIO: I. Introducción. Relaciones de hecho entre la persona y la cosa. II. Posesión. Concepto. III. Cuestiones de prueba. Presunciones. IV. Naturaleza jurídica de la posesión. V. Importancia de la posesión. VI. Tenencia. Concepto. VII. Relaciones derivadas de un vínculo de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad (servidores de la posesión). VIII. Yuxtaposición local. IX. Objeto. X. Exclusividad de la posesión y de la tenencia. XI. Coposesión o cotenencia. XII. Clasificación de la posesión y de la tenencia.

I. Introducción. Relaciones de hecho entre la persona y la cosa

Son distintas las relaciones de hecho —no de derecho— que pueden establecerse entre una o más personas y una o más cosas. Tales relaciones de hecho, que el Código Civil y Comercial llama “relaciones de poder”, también son llamadas “materiales”, “posesorias” o “reales”. Lo importante es que no hay que confundirlas con las relaciones jurídicas que pueden establecerse entre la persona y la cosa, ya sea que se apoyen en la existencia de un derecho real o de uno personal. Así, por ejemplo, se puede ser dueño de una cosa (derecho real-relación jurídica) y a la vez poseedor de esa misma cosa (relación de hecho). En este caso coinciden o se superponen una relación jurídica y otra material. Pero también puede ocurrir que una persona sea poseedora de una cosa sin ser su dueña, y sin tener tampoco un derecho personal que justifique su relación, de manera que se está en presencia de una relación de hecho que no está acompañada de una relación de derecho. Esto se visualiza en el ejemplo del ladrón que roba un bolso, quien

a pesar de no tener ningún derecho sobre la cosa, y saber que no lo tiene, sí tiene una relación material con dicho objeto.

Las relaciones de poder que pueden establecerse entre la persona y la cosa son las siguientes: 1) posesión; 2) tenencia; 3) las derivadas de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad (servidores de la posesión). El Código no enumera a la yuxtaposición local. Se explica en los Fundamentos que no vale la pena, pues como simple relación de lugar constituye un contacto físico que carece de toda voluntariedad y, en consecuencia, de efectos jurídicos.

II. Posesión. Concepto

El tema de la posesión encierra numerosas dificultades. Hay que tener en cuenta que la posesión estuvo sometida a la influencia de elementos históricos muy heterogéneos (romanos, germánicos, canónicos). La existencia de textos aparentemente contradictorios en las fuentes romanas, las interpolaciones de los mismos, la terminología ambigua, exenta de constancia y a veces ambivalente, contribuyen a la dificultad de estudiar el instituto.

a) Distintas teorías

El intento de explicar la diferencia de trato entre los poseedores y los simples detentadores, dio origen a dos teorías radicalmente opuestas sobre el concepto de la posesión romana, en torno a las cuales se ha desplegado la controversia científica sobre el tema: la de Savigny y la de Ihering, principalmente.

a.1) Teoría de Savigny

Esta teoría, también llamada clásica o subjetiva, se basa sobre todo en la idea de que, para la existencia de la posesión, es necesaria la concurrencia de dos elementos: el *corpus* y el *animus domini*.

El *corpus* es el poder de hecho sobre la cosa, el poder físico; es la posibilidad de disponer físicamente de una cosa. No es necesario el contacto físico con la cosa, ya que es suficiente con la posibilidad física de ejercer una influencia inmediata sobre ella y de excluir toda

influencia extraña. El *corpus* debía darse en la constitución de la relación sin que sea necesario el contacto permanente, ya que era suficiente con que se pudiera restablecer posteriormente, no obstante las interrupciones de ese poder material.

Ahora bien, si ese poder físico con la cosa está acompañado de otro elemento, el *animus domini*, según la teoría de Savigny se configura la posesión. Si falta, sólo habrá tenencia.

El *animus domini*, en una primera aproximación, puede ser definido como la intención de comportarse con la cosa como lo haría su dueño. Con más precisión, se puede decir que dicho elemento significa la actitud de no reconocer en otra persona un derecho real superior.

Así, por ejemplo, el ladrón, quien tiene el contacto físico con la cosa por él robada, al comportarse con ella como si fuera su dueño y no reconocer sobre dicha cosa un derecho superior al que él está ejerciendo, tiene *animus domini* y es, por ende, poseedor. Es indiferente que él sepa que no es su dueño, pues lo que interesa es su intención, razón por la cual la teoría se denomina subjetiva. El convencimiento que él pueda tener acerca de su falta de derecho legítimo, incidirá en que su posesión sea calificada de buena o de mala fe, pero no lo priva de su condición de poseedor.

En síntesis, según la teoría de este autor, si una persona reúne en su cabeza los dos elementos —el *corpus* y el *animus domini*— es poseedor. En cambio, si faltan ambos, sólo habrá yuxtaposición local; si falta el segundo, habrá tenencia.

De tal manera, el tenedor es quien tiene el *corpus* —el contacto físico con la cosa—, pero carece del *animus domini*. Así, si a una persona se le confía alguna cosa para que la guarde, si bien está en contacto físico con ella, esa relación no está acompañada del *animus domini*, en tanto reconoce un derecho superior en cabeza de su dueño —quien se la confió— y, por tanto, es tenedor.

a.2) Teoría de Ihering

Este autor, en sus obras *La voluntad en la posesión*, *El fundamento de la protección posesoria* y *El espíritu del Derecho Romano*, criticó

la tesis de Savigny, a la que consideró subjetiva, y expuso su propia posición sobre el tema elaborando la teoría que llamó "objetiva".

Para Ihering todos los detentadores son poseedores en nombre propio y, como tales, deberían gozar de la protección posesoria. La diferencia entre posesión y detentación no radica —sostenía— en la intención del sujeto (teoría subjetiva), sino en la voluntad de la ley (teoría objetiva), la que, en ciertos casos, por motivos prácticos, niega a la tenencia los efectos jurídicos de la posesión.

Ihering entendía que para configurar la posesión era suficiente con el *corpus*, ya que entendía que el *animus* estaba ínsito en el poder de hecho ejercido sobre la cosa. El primero era el único elemento visible y susceptible de comprobación, y era una manifestación externa del ánimo.

Esta doctrina, al mismo tiempo que separaba a la posesión de la propiedad, coloca a la relación posesoria al servicio integral de la propiedad. Se basaba en el entendimiento de que la propiedad sin la posesión era como un tesoro sin la llave para abrirlo, o como un árbol fructífero sin los medios necesarios para recogerlos. La posesión era, por lo tanto, una exteriorización del dominio, presentándose como condición de nacimiento de un derecho, o sea, como un punto de transición momentáneo para la propiedad, o bien como fundamento de un derecho.

La crítica a Savigny se basaba en la circunstancia de que al ser el *animus domini* un elemento subjetivo, dependiente de la intención del sujeto, resultaba de muy difícil prueba.

Propone entonces dicho jurista otra manera de diferenciar a la posesión de la tenencia sobre bases objetivas, prescindiendo de la voluntad de quien tiene la cosa. La posesión, según Ihering, consiste en el ejercicio de un poder de hecho sobre las cosas, conforme a su destino natural. Es decir que toda relación entre el hombre y la cosa —por supuesto en tanto exista un mínimo de voluntad— implica la posesión, a menos que una disposición expresa de la ley establezca que sólo hay tenencia.

Así, si se observa a una persona sembrando un campo, en principio esa relación con el inmueble debe ser reputada posesión; pero si esa persona es un arrendatario, o se halla allí circunstancialmente por haber

sido contratada para ese trabajo, como la ley nos dice que en ese caso hay tenencia, es entonces el Derecho el que por razones de orden práctico priva a esa relación de los efectos de la posesión.

Se reemplaza la voluntad individual del sujeto, el elemento intencional o subjetivo, por la voluntad abstracta de la ley, que es objetiva. Esto facilita, según Ihering, la prueba, pues basta con demostrar que existe el *corpus* para que la relación sea considerada posesión; si alguien pretende demostrar que hay tenencia, debe probar que la ley priva a esa relación de la protección posesoria, en virtud de la causa por la cual se originó.

Explica dicho autor su posición y la de Savigny por medio de famosas fórmulas algebraicas:

Para Savigny:

$$P = c + a + A$$

$$T = c + a$$

Es decir que posesión (P) es igual al contacto físico o mera yuxtaposición local (c) acompañado de un mínimo de voluntad (a), todo lo cual configura el *corpus*, más el *animus domini* (A). La tenencia (T) es equivalente al *corpus* (c + a), en ausencia del *animus domini*.

Para Ihering:

$$P = c + a$$

$$T = c + a - n$$

Es decir que la posesión es igual al *corpus* (c + a), mientras que la tenencia (T) es el *corpus* (c + a), pero cuando la ley (n) priva a ese poder de hecho de los efectos de la posesión por mediar un elemento negativo (*causa detentionis*).

Como se puede apreciar, lo más importante de la teoría objetiva consiste en la desaparición del *animus domini*, elemento que era fundamental en la tesis de Savigny para determinar la existencia de la posesión.

a.3) *Teoría de Saleilles*

Saleilles, a diferencia de Savigny, que resaltaba el aspecto físico de la relación, y de Ihering, que buscaba el aspecto jurídico, pone el acento en el aspecto económico de la relación, lo que consideraba fundamental.

Destaca este autor la insuficiencia de los actos exteriores que constituyen el *corpus* para descubrir en ellos el *animus domini*, y advierte sobre la necesidad de relacionar la prueba de este *animus* con el título en virtud del cual se posee, lo que es llamado prueba de la *causa possessionis*. En este aspecto se puede decir que es una doctrina intermedia entre las otras dos.

Define a la posesión como una efectividad consciente y querida de apropiación económica de las cosas. El *corpus* viene a ser el elemento visible de esa relación económica entre el hombre y las cosas, es un "conjunto de hechos susceptibles de descubrir una relación permanente de apropiación económica".

En cuanto al *animus*, concuerda con Ihering en que no debía ser necesariamente el concepto romanista del *animus domini*, sino que sería el propósito de realizar esa apropiación de la cosa, de explotarla en beneficio propio, de un modo independiente.

a.4) *Consideraciones sobre las teorías de Ihering y de Saleilles*

No obstante las críticas a que fue sometida, la teoría de Savigny, basada en una fiel interpretación de los textos romanos, no ha perdido su solidez y conserva todo su valor. Prueba de esto último es que el Código (también el Código derogado), como se verá, la ha recogido y, por tanto, tiene una notable influencia en nuestro sistema.

En cuanto a las dificultades probatorias alegadas por Ihering, en verdad no son tales, ya que el *animus domini* no es un elemento puramente subjetivo, sino que se manifiesta con hechos exteriores, de modo que se objetiviza. Cuando se trata de probar su existencia, la cuestión no consiste en penetrar en la mente del sujeto, sino en observar su actividad exterior. Así, si una persona siembra, cultiva, edifica, alambra un inmueble, se está en presencia de actos reveladores de su comportamiento como dueño, sin que sea menester descifrar su inten-

ción; ésta se exteriorizó. En el caso de que otra persona pretenda demostrar lo contrario, tampoco la prueba es difícil, pues como señala Allende lo hará: "a) probando que soy locatario; b) probando que cuando mandé alambra el campo solicité autorización al propietario o que éste pagó tal alambra, etcétera".

Se llega entonces a la conclusión de que la teoría subjetiva y la objetiva se asemejan en el fondo, ya que el procedimiento probatorio a seguir resulta ser el mismo.

La tesis de Saleilles peca de reducir todo a un interés económico, el que puede tener importancia en cuanto a las relaciones de derecho (reales o personales), pero faltar en materia posesoria, donde se trata de relaciones materiales. Además, no siempre existe el interés de beneficiarse con la cosa o de explotarla económicamente. Más aún, muchas veces se tiene la posesión de cosas solamente por motivaciones afectivas.

b) *La cuestión en el Código Civil y Comercial*

Según el artículo 1909: "Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no". Se aprecia la adhesión a la teoría subjetiva de Savigny, con alguna atenuación ya que pone el acento en el comportamiento, en lugar de la intención.

El artículo 1909, en cuanto alude a que una persona tenga "un poder de hecho sobre una cosa", expresa el *corpus*, y la referencia a "comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no", refleja la necesidad del *animus domini*.

Complementa este panorama el artículo 1910, que define a la tenencia cuando una persona tiene el *corpus* (poder de hecho), pero "se comporta como representante del poseedor". Es claro que esta última expresión indica la falta de *animus domini*, circunstancia que determina que el sujeto sea calificado como tenedor.

En estas condiciones, el Código recoge la teoría subjetiva, según la cual la posesión se configura por la concurrencia de dos elementos: el *corpus* y el *animus domini*.

El *corpus* consiste en la posibilidad de disponer físicamente de la cosa. Esa posibilidad se visualiza fácilmente cuando la persona está en contacto directo con el objeto (por ejemplo, cuando alguien tiene un paraguas en su mano). Sin embargo, hay que tener presente que para la existencia del *corpus* no siempre es necesario ese contacto directo, pues es suficiente con la posibilidad de poder disponer físicamente. Así, en los días de sol, el paraguas estará guardado en un armario, y no en la mano del interesado; pero igualmente existe el *corpus*, ya que basta con que exista la posibilidad, lo que se concretaría cuando el sujeto lo saca del lugar en el cual está guardado y lo utiliza, esto es, dispone de él físicamente. Lo que se debe comprender es que no es necesario el contacto permanente con la cosa, sino que es suficiente que se pueda hacer efectivo ese contacto cuando la persona así lo decida. Éste es el criterio que surge del texto del artículo 1922, inciso b.

El *animus domini* es el otro elemento de la posesión; sumado al *corpus* determina su existencia; en cambio, si falta, sólo hay tenencia.

El concepto del *animus domini*, en el Código fluye con mayor claridad del artículo 1910, donde se dice que hay tenencia si se comporta como representante del poseedor. De esta forma, para la existencia del *animus domini*, y para arribar a la posesión, se requiere "comportarse como titular de un derecho real", es decir, comportarse con la cosa sin reconocer en otra persona un derecho real superior al que se está ejerciendo.

Este *animus domini*, contrariamente a lo que exponía Ihering, no radica en la mera voluntad íntima del poseedor, sino que apunta a la intención exteriorizada, o sea, traducida en hechos exteriores. Esos hechos exteriores que reflejan el *animus* pueden ser realizados aun faltando el *corpus*, como sucede con el pago de impuestos por quien no ocupa el inmueble, aunque generalmente el *animus* se expresa por medio del *corpus*.

c) Cuasiposesión. Su inexistencia

En el Derecho Romano, se identificaba al poseedor con el propietario. Los que tenían un poder sobre la cosa en virtud de ejercer otro derecho real (prenda, usufructo, etc.) eran considerados como extraños

a la noción de posesión. No obstante, se reconocía que eran merecedores de una tutela análoga a la asignada al poseedor *uti dominus*, por lo que fueron llamados *quasiposeedores* para indicar su acercamiento al modelo de la posesión.

En el artículo 1909 se definió al *animus domini* como el hecho de comportarse "como titular de un derecho real"; lo que permite considerar, por ejemplo, al usufructuario también poseedor, ya que no reconoce en otro un derecho de usufructo superior al que tiene; se comporta como titular de un derecho real. Desde este punto de vista, el usufructuario, como todos los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, tiene *animus domini* y, por ende, es reputado poseedor.

El artículo 1909 alude a "un derecho real", es decir, son poseedores quienes ejercen un derecho real, y entre ellos se halla el usufructuario. De lo contrario, la norma debería decir que son poseedores los que se comportan como titulares del derecho de dominio. A su vez, el artículo 1891 nos indica que casi todos los derechos reales se "ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca".

Aclarado este aspecto, no existe en el Código la llamada "cuasiposesión". Para cierto sector de la doctrina, los titulares de derechos reales distintos del dominio no eran poseedores sino cuasiposeedores, es decir, como si fueran poseedores. Esta tesis, sostenida por algunos durante la vigencia del Código de Vélez, ha quedado ahora superada ya que el Código Civil y Comercial es claro en no admitir la cuasiposesión.

III. Cuestiones de prueba. Presunciones

En el Código existen algunas directivas que facilitan la prueba, y que incluso hacen presumir que la relación material entre la persona y la cosa es posesión; presunción que admite prueba en contrario.

a) Presunción de posesión

Dice el artículo 1911: "Se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad, se llama, en este Código, servidor de la posesión".

La lógica y el sentido común hacen suponer que si una persona ejerce un poder de hecho sobre la cosa es muy probable que sea su poseedor. Así, por ejemplo, si una persona ocupa un inmueble, o lo siembra, cultiva, edifica, etcétera, cabe imaginar que es el poseedor. Puede no ser así, en cuyo caso se demostrará lo contrario. Esta norma, a su vez, facilita la prueba.

Se trata de una presunción *iuris tantum* que puede ser destruida por prueba contraria: quien pretenda que quien tiene un poder de hecho sobre una cosa no es poseedor, sino tenedor, deberá probarlo (por ejemplo: exhibiendo un contrato de locación que demuestre la falta de *animus domini*).

b) Presunción de fecha y extensión

Dice el artículo 1914: "Si media título se presume que la relación de poder comienza desde la fecha del título y tiene la extensión que en él se indica".

En armonía con otras normas del Código, se establece la presunción de que la relación comienza en la fecha del título. Se agrega otra presunción vinculada a la extensión.

El artículo 1914 comienza diciendo: "si media título". Por ende, sólo tiene interés esta norma cuando quien ejerce una relación de poder cuenta, además, con un título, ya que puede no tenerlo. En tal caso, se presume que la relación se inició en la fecha del título.

Armonizando esta norma con los artículos 1898 y 1903, que sólo se refieren a la posesión en el ámbito de la prescripción breve, pueden añadirse dos conclusiones: a) es una presunción que admite prueba en contrario; b) si la cosa es registrable y la registración es constitutiva, habrá que calcular, o al menos presumir, el inicio de la posesión desde dicho evento, si es que ocurrió.

La segunda presunción se vincula a la extensión. La existencia del título es conveniente a efectos de acreditar la "extensión" de la posesión, ya que el artículo 1914 establece la presunción de que comprende la extensión del título.

En el caso de esta norma, cabe entender por título también a los

MNR

instrumentos privados. De lo que se trata no es de probar la existencia de un derecho real sino tan sólo la extensión de la posesión.

El ejemplo clásico que suele darse es el de quien, además de la superficie indicada en su título, posee una mayor que pretende adquirir por usucapión. Así, por ejemplo, si a una persona se le otorga la posesión de una parte de un inmueble, cabe suponer que ésa es la verdadera extensión de la relación de poder. Si la persona ejerció la relación en una superficie mayor a la prevista en el título, deberá demostrarlo.

Se trata de presunciones *iuris tantum*, como se desprende con más claridad del texto del artículo 1903.

c) Inmutabilidad de la causa. Intervención

Dice el artículo 1915: "Nadie puede cambiar la especie de su relación de poder, por su mera voluntad, o por el solo transcurso del tiempo. Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, y sus actos producen ese efecto".

c.1) Principio de inmutabilidad de la causa

Esta regla desvirtúa la crítica de Ihering en el sentido de que el *animus domini* era un elemento variable sujeto al capricho de las personas. Ello porque, como dice el artículo, "nadie puede cambiar la especie [...] por su mera voluntad", con lo cual no es cierto que el poseedor pueda cambiar de idea y convertirse en tenedor, pues nadie puede hacerlo por su propia voluntad, como sostenía Ihering al examinar la teoría de Savigny.

Tampoco es posible alterar la especie de la relación "por el solo transcurso del tiempo". Esto significa que quien comenzó siendo poseedor en ese carácter continúa, sin que influya en su situación el transcurso del tiempo. Tampoco influye su voluntad interna, la cual resulta inoperante.

Ahora bien, si el poseedor se convierte en tenedor (propietario que vende su casa y continúa habitándola como locatario), el Cód-

go entiende que continúa como tal hasta tanto se pruebe lo contrario (ver art. 1923). La prueba no será difícil, pues basta presentar el contrato de venta y el de locación, pero lo interesante es que el cambio de la relación surge de circunstancias externas —en el ejemplo, los actos jurídicos respectivos—, y no de la mera voluntad interna del poseedor, la que por sí sola es insuficiente.

Asimismo, quien comenzó como tenedor (posee por otro) continúa como tal mientras no se pruebe lo contrario, de manera que su propia voluntad, o el solo transcurso del tiempo, son ineficaces para alterar la situación. Dicha prueba también surgirá de circunstancias que excedan la voluntad del sujeto, y al mero transcurso del tiempo, como podría ser la existencia de un contrato de compraventa demostrativo de que quien hasta entonces era tenedor adquirió el inmueble, convirtiéndose así en poseedor.

Estos cambios de especie, de manera bilateral, son lo que regula el artículo 1923 al contemplar la *traditio brevi manu* y el *constituto posesorio*.

c.2) Intersión de título

Según se expuso, existe un principio referente a la inmutabilidad de la causa. Dicho principio no impide que la causa pueda transformarse en determinadas circunstancias; lo que prohíbe es que ello pueda hacerse "por su mera voluntad", o "por el solo transcurso del tiempo". La tenencia puede transformarse en posesión, o viceversa, mudando el concepto de modo inequívoco, activo y operante.

Existen casos en que el cambio de la relación posesoria está permitido, lo cual puede ocurrir en forma bilateral o unilateral. Se cambia la causa en forma bilateral cuando existe acuerdo entre los interesados. Así, nada impide que poseedor y tenedor se pongan de acuerdo y decidan alterar la relación posesoria; por ejemplo, si el tenedor le compra la cosa al poseedor.

La intersión de título puede ser también unilateral, lo que ocurre cuando la voluntad de cambiar la causa se manifiesta por actos exteriores, y esos actos producen el efecto de excluir al poseedor. No son suficientes para ello los pensamientos íntimos, no basta el cambio

interno de la voluntad —como creía Ihering acerca de la teoría de Savigny—; para que la intersión se produzca es menester que se trate de actos que se manifiesten exteriormente. Es necesario que se trate de actos concluyentes e inequívocos, que la oposición del tenedor al poseedor sea total, inconfundible y activa, es decir, que salga del ámbito subjetivo del tenedor e incida sobre la cosa y sobre la relación con el poseedor.

Si el locatario cree que es el dueño del inmueble, con ese pensamiento no conseguirá alterar su relación y convertirse de tenedor en poseedor; pero si manifiesta esa voluntad exteriormente, expulsando al locador de la finca y privándolo de su posesión, negándole todo derecho sobre ella, ejerciendo actos de dominio, intervertirá su título.

La intersión requiere de actos de oposición, y no de meras expresiones verbales, que sean lo suficientemente precisos para significar la voluntad del tenedor de excluir al poseedor, y deben ser lo suficientemente públicos graves para poner en conocimiento de la situación al poseedor, para que éste pueda hacer valer sus derechos. El acto de oposición es al mismo tiempo un acto de afirmación de la posesión propia y de negación de la posesión ajena.

También hay intersión de título cuando el coposeedor excluye a los otros y comienza una posesión exclusiva. La idea de la intersión puede ser aplicada, asimismo, en los supuestos de posesión correspondiente a derechos reales sobre cosa ajena. Así, por ejemplo, el usufructuario podría desconocer el derecho del nudo propietario, mediante los actos de oposición adecuados, para después intentar la adquisición del dominio por usucapión.

Teniendo en cuenta que el principio general es el de la inmutabilidad de la causa (art. 2353), quien invoca la intersión de título tiene a su cargo la prueba de los actos materiales inequívocos e individuales de exclusión.

d) Presunción de legitimidad

Esta presunción surge del artículo 1916, según el cual "Las relaciones de poder se presumen legítimas, a menos que exista prueba en

contrario. Son ilegítimas cuando no importan el ejercicio de un derecho real o personal constituido de conformidad con las previsiones de la ley". Agrega el artículo 1917: "*Innecesariedad de título*. El sujeto de la relación de poder sobre una cosa no tiene obligación de producir su título a la posesión o a la tenencia, sino en el caso que deba exhibirlo como obligación inherente a su relación de poder".

El fundamento del artículo 1916 reside en que es natural, ordinario, lo más corriente, que quien ejerce el contenido de un derecho, tenga el derecho mismo que aparentemente ejercita, correspondiendo la prueba al que afirma lo contrario. Es también lo normal suponer que no existe una persona -verdadero titular del derecho- que fue despojado. Se trata de entender, en principio, que la apariencia coincide con la realidad.

En cuanto al artículo 1917, la idea base es que, en principio, el sujeto de la relación de poder nada debe demostrar. Quien lo enfrente y pretenda lo contrario, eso es, quien afirme la ilegitimidad de la relación, carga con la prueba, lo que tiene importancia, como se verá más adelante, en el ámbito de las acciones posesorias y reales (arts. 2243, 2256/2258, 2270).

El artículo 1916 presume que tal posesión se ajusta a derecho, es decir, que se adquirió con justa causa. Esta presunción no sólo exonera al poseedor de exhibir su título (en sentido instrumental), sino también de tener que justificar la causa de su adquisición. Al ser así, quien demanda al poseedor, en principio debe acreditar que tiene un mejor derecho, sin que le resulte suficiente acreditar que el poseedor demandado carece de derecho a poseer la cosa.

d.1) *Debe ser una relación actual*

La presunción del artículo 1917 sólo beneficia al poseedor o tenedor actual, frente al cual hay que producir la prueba de un mejor derecho. No puede ser alegada en su favor por un poseedor anterior que ya no tiene la cosa.

d.2) *Posesión de cosas muebles*

Las ventajas emergentes de las presunciones establecidas en los

artículos 1916 y 1917 resultan aplicables tanto al poseedor de cosas inmuebles como de muebles. En materia de cosas muebles la presunción de la existencia del derecho es todavía más fuerte, al punto de que, si se dan determinadas circunstancias, se convierte en una adquisición legal irrefutable (ver art. 1895).

e) *Presunción de continuidad*

Establece el artículo 1930 que "Se presume, a menos que exista prueba en contrario, que el sujeto actual de la posesión o de la tenencia que prueba haberla ejercitado anteriormente, la mantuvo durante el tiempo intermedio".

Es una norma que facilita la prueba, especialmente en los juicios de usucapión. Puede suceder que la situación no haya sido de esa forma, en cuyo caso el interesado deberá destruir la presunción demostrando lo contrario.

f) *Presunción de adquirir a título oneroso*

El artículo 1895 se refiere a la adquisición legal de derechos reales sobre cosas muebles por un subadquirente. Dice que "La posesión de buena fe del subadquirente de cosas muebles no registrables que no sean hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir los derechos reales principales excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita".

g) *Presunción de posesión y duda sobre las fechas*

En el ámbito del juicio posesorio, se verá que no se pueden ventilar cuestiones sobre el mejor derecho, sino que se resuelven cuestiones de hecho, cualquiera sea el derecho de las partes. Dice el artículo 2243: "Si es dudoso quién ejerce la relación de poder al tiempo de la lesión, se considera que la tiene quien acredita estar en contacto con la cosa en la fecha más próxima a la lesión. Si esta prueba no se produce, se juzga que es poseedor o tenedor el que prueba una relación de poder más antigua".

IV. Naturaleza jurídica de la posesión

Existen diversas posturas acerca de la naturaleza jurídica de la posesión. Para algunos se trata de un hecho, para otros de un derecho, y en este último supuesto se puede alegar que consiste en un derecho personal, en un derecho real o en un derecho mixto.

a) Teorías que la consideran un derecho

El principal sostenedor de esta tesis fue Ihering. Partía dicho autor de su concepto de derecho subjetivo, al cual definía como "todo interés jurídicamente protegido". Admitido ello, como la posesión está jurídicamente protegida, pues el ordenamiento jurídico brinda acciones en su defensa cuando es violada, debía verse en ella a un derecho. Dentro de los derechos la ubica como un derecho real, porque existe una relación directa e inmediata entre el poseedor y la cosa.

En esta línea de ideas cabe mencionar también la tesis de Molitor, quien sostenía que la posesión es un derecho porque reside en ella el elemento de todo derecho, que es la voluntad. Como la posesión requiere del elemento intencional, el *animus domini* aplicado a su objeto, es indudable la existencia de la voluntad, la voluntad de someter la cosa a una detención material.

b) Teorías que la consideran un hecho

Entre los defensores de esta doctrina cabe mencionar a Savigny en primer término. Para el jurisconsulto alemán, la posesión, en sí misma, debía reputársela un hecho, y sólo en razón de sus consecuencias jurídicas entra en el campo del Derecho. Es decir, se trata de un hecho que produce consecuencias o efectos jurídicos. Entre sus principales efectos jurídicos se hallan las defensas posesorias y la posibilidad de adquirir por usucapión.

c) La cuestión en el Código

Existen diversas razones que, con apoyo en los artículos del Código, permiten llegar a la conclusión de que la posesión consiste en un hecho, que produce efectos jurídicos (*jus possessionis*).

Así, pues, el artículo 1917 dice que el poseedor no tiene que producir su título.

El Código se ocupa antes de la posesión, y después comienza el tratamiento de los derechos reales, lo que permite suponer que la primera es un elemento de los segundos.

La posesión no está enumerada en el artículo 1887 entre los derechos reales admitidos por el Código. Tampoco fue legislada entre los derechos personales, pues está ubicada en el Libro Cuarto de los derechos reales. Por tanto, no es un derecho personal ni real.

El artículo 1909 define a la posesión sin decir que se trate de un derecho real. En cambio, el Código, al definir a otros derechos reales en particular, utiliza la frase "es el derecho real".

El Código admite que la posesión pueda ser adquirida o tenida por vicios tales como la violencia (art. 1921), lo que no sería admisible si se tratase de un derecho.

En el artículo 1901 se regula sobre la accesión de posesiones, es decir, la unión de dos posesiones a que antes se hizo referencia.

La posesión no tiene acceso al Registro de la Propiedad Inmueble, pese a que pueden tener acceso situaciones débiles, como la de un derecho real sujeto a condición resolutoria. Ocurre que la posesión es un fenómeno que se detiene en la superficie, en la apariencia, y no indaga en el fondo.

En conclusión, se advierte que en el Código la posesión es tratada como un estado de hecho, que el Derecho defiende y protege y le asigna consecuencias jurídicas. Las más importantes son las defensas posesorias, la adquisición de cosas muebles no hurtadas ni pérdidas de buena fe y la posibilidad de usucapir.

V. Importancia de la posesión

La posesión, como estado de hecho, es productora de importantes consecuencias, por lo cual sus funciones son diversas.

La posesión es el contenido de los derechos reales, pues en la mayoría de éstos sin ella no sería posible el ejercicio de las facultades que otorgan a sus titulares. Se debe exceptuar de esta apreciación a la hipoteca y a las servidumbres, que no son ejercidas por la posesión,

aunque con la salvedad de que en las servidumbres positivas el uso que se haga de ellas tiene lugar de posesión (arts. 1891 y 1892).

Cuando se enfrentan judicialmente quien alega ser titular de un derecho real sobre la cosa, y el poseedor actual, éste nada tiene que probar —aunque si quiere puede hacerlo—, pues a quien pretende desplazarlo le incumbe la carga de la prueba. Esa situación de hecho, como tal, es respetada por la legislación, y sólo cede ante quien demuestre un mejor derecho (ver art. 2256).

A la posesión, como estado de hecho, el Derecho le otorga protección por medio de acciones judiciales, y también por la defensa privada o extrajudicial (ver arts. 2238, 2240 y concs.).

En la adquisición de derechos reales por actos entre vivos sobre inmuebles, en forma derivada, además del título suficiente es necesaria la tradición posesoria.

En materia de cosas muebles no registrables, no hurtadas ni perdidas, la posesión de buena fe y el título oneroso atribuyen el derecho real sobre la cosa (art. 1895).

La posesión que reúna ciertos requisitos, ejercida durante los plazos pertinentes, permite adquirir el dominio por prescripción de las cosas inmuebles y muebles (arts. 1897 y ss.).

El poseedor de buena fe, aunque carezca del derecho de poseer, hace suyos los frutos percibidos y los naturales devengados en el tiempo de su posesión (art. 1935).

La posesión genera derechos, obligaciones y responsabilidades, con relación a frutos, mejoras, gastos, riesgos sufridos por la cosa o daños que provoca.

VI. Tenencia. Concepto

Dice el artículo 1910: "*Tenencia*. Hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, y se comporta como representante del poseedor".

La tenencia, al igual que la posesión, requiere de la configuración del *corpus*, entendido éste como contacto o posibilidad de disponer físicamente de una cosa, pero falta en aquélla el otro elemento de la posesión: el *animus domini*.

Existe en la tenencia un poder de hecho sobre la cosa, pero la posesión se ejerce en nombre de otra persona, se reconoce en otro un derecho superior, según se desprende del artículo 1910.

Se diferencia la tenencia de la posesión en que aquélla no produce muchos de los efectos que produce la segunda. Así el tenedor no puede adquirir el derecho real por prescripción, ni hacer suyos los frutos percibidos, ni la tenencia de cosas muebles hace adquirir su propiedad. En cambio, se le reconoce al tenedor la posibilidad de defender su situación por medio de algunas acciones posesorias (arts. 2238 y 2245), y también por medio de la defensa extrajudicial prevista por el artículo 2240. Cabe agregar que en el Código Procesal se autoriza tanto a tenedores como a poseedores a intentar los interdictos que allí se regulan (v. arts. 610, inc. 1º; 614, inc. 1º, y 619).

La tenencia goza de algunos efectos (ver arts. 1932 y 1940).

a) Clasificación de la tenencia

Como se verá más adelante, tanto la tenencia, como la posesión, según el Código, pueden ser legítimas o ilegítimas, y la segunda de buena o de mala fe.

Sin perjuicio de ello, la doctrina encuentra otras clasificaciones. Así, ha clasificado a la tenencia en absoluta y relativa.

a.1) Tenencia absoluta

Las cosas que pertenecen al dominio público del Estado (nacional, provincial o municipal) se encuentran fuera del comercio y, consecuentemente, no pueden ser poseídas. Sin perjuicio de ello, en principio, son susceptibles de uso general por parte de la comunidad o de uso especial (privativo o exclusivo) por quienes han sido particularmente autorizados al efecto (art. 237).

De lo dicho se sigue que, al no existir posesión, la tenencia existe de manera independiente. En otros términos, el tenedor no representa ninguna posesión ni es poseedor en nombre de otro.

a.2) Tenencia relativa

Es la prevista por el Código Civil y Comercial, y definida en el

artículo 1910. En este caso, el tenedor reconoce, con relación a la cosa que detiene en su poder, la posesión de otra persona.

b) *Deber de nombrar al poseedor*

Dado que el tenedor representa la posesión de otro, cuando fuere demandado en razón de la cosa cuya tenencia ejerce (v. gr., por reivindicación), deberá denunciar al verdadero poseedor.

c) *Derecho a los gastos. Retención*

El tenedor tiene derecho al reintegro de los gastos o mejoras que, indispensables para el buen mantenimiento de la cosa, hubiese tenido que afrontar. Se trata de aquellas erogaciones imprescindibles para evitar el deterioro o pérdida de la cosa; en resumen: de aquellos gastos que el propietario fatalmente hubiera tenido que realizar y sin los cuales la cosa no hubiera podido ser conservada.

El derecho a reclamar el reintegro de lo gastado en la conservación y el derecho de retención frente a la negativa de reembolso, deberán ser analizados a la luz del régimen legal del acto jurídico fuente de la tenencia y de lo previsto por las partes en el respectivo contrato, pues nada obsta a que ciertos gastos, como ocurre frecuentemente en la práctica (v. gr., el pago de las expensas comunes en el contrato de locación de inmueble), sean puestos a cargo del tenedor.

VII. Relaciones derivadas de un vínculo de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad (servidores de la posesión)

Dispone el artículo 1911 que "...Quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad, se llama, en este Código, servidor de la posesión".

La de los servidores de la posesión es otra categoría de las relaciones de hecho o materiales que pueden darse entre las personas y las cosas. Está tomada del Código Civil alemán (*Besitzdiener*; BGB, art. 855) y comprende, en principio, a aquellas relaciones basadas en un vínculo de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad.

MNR

Se trata de supuestos en los cuales no hay ni posesión ni tenencia, y tampoco yuxtaposición local. Son relaciones en las cuales los sujetos "sirven" a la posesión de otro. El servidor de la posesión es el ejecutor material de la posesión que otro tiene, pero nunca puede ser considerado poseedor, que sigue siendo el otro. A todos los efectos jurídicos hay que considerar que las cosas están en manos del poseedor, aun cuando se encuentren en poder del servidor de la posesión.

Ciertas personas ejercen un poder de hecho sobre la cosa en exclusivo interés de otro, a cuyas instrucciones han de sujetarse en todo momento. En tal caso, poseedor es solamente aquel en cuyo interés se ejerce la posesión. El que ostenta el poder de hecho no es poseedor, pues carece de interés propio, sino mero servidor de la posesión de otro. Por tal motivo, no disfruta de ninguna de las ventajas jurídicas de la posesión.

Existe relación derivada de un vínculo de dependencia cuando el obrero emplea las máquinas o herramientas de la fábrica en donde trabaja. En ocasiones el vínculo no es de dependencia desde el punto de vista laboral, sino que media una relación de servicio, caso en el que también se da esta figura. Lo mismo sucede con la relación que existe entre los pasajeros de un hotel y las cosas que hay en la habitación, donde existe una relación material derivada de un vínculo de hospedaje; así como con la relación de un huésped y el inmueble y los muebles que ocupa, donde existe tan sólo un vínculo de hospitalidad.

No están legitimados para intentar las acciones posesorias. En caso de que su relación sea violada o atacada, sólo pueden defenderla por medio de la defensa extrajudicial regulada por el artículo 2240. Fuera de la defensa privada, si sufren la turbación o el despojo por parte de un tercero, deben recurrir al poseedor, quien puede ejercer la acción correspondiente.

VIII. Yuxtaposición local

Según se expuso anteriormente, el *corpus*, para ser reputado tal, requiere que el contacto físico con la cosa sea querido, debe existir de parte del sujeto un mínimo de voluntad en realizar ese contacto.

Cuando ese contacto físico no es querido, cuando falta el mínimo de voluntad necesario, la relación entre la persona y la cosa recibe el nombre de "yuxtaposición local". Son clásicos los ejemplos del bebé y su chupete (aquí falta el mínimo de voluntad por tratarse de un incapaz en los términos de los arts. 25 y 1922, inc. a), del preso y sus cadenas (se dice que las cadenas lo tienen a él), y el de la persona dormida a la cual se le coloca un objeto en la mano. En estos casos el contacto físico no es querido, aun cuando haya conciencia de la relación.

El Código Civil y Comercial no enumera a esta relación inconsciente entre las relaciones de poder, por considerarlo innecesario.

IX. Objeto

El objeto de la posesión y de la tenencia, como primera pauta de aproximación, lo constituyen cosas, las que, además, deben ser ciertas y determinadas.

El Código, en el artículo 1912, limita el objeto de la posesión y de la tenencia a los bienes materiales, esto es, a las cosas determinadas; excluye a los bienes que no lo sean. No obstante, cabe advertir que el artículo 1883 abre la puerta para que, por excepción, los bienes puedan ser objeto de los derechos reales, por lo que no hay que descartar que pueda presentarse un supuesto de posesión o tenencia sobre un derecho.

Para el Código, de acuerdo a lo que surge del artículo 234, están fuera del comercio las cosas cuya transmisión está expresamente prohibida: a) por la ley; b) por actos jurídicos, en cuanto este Código permite tales prohibiciones. La novedad es que el Código no impide que puedan ser poseídas las cosas fuera del comercio, lo que sí ocurría en el Código anterior (art. 2401).

Es correcto, ya que hay cosas inalienables y, por lo tanto, fuera del comercio, que sin embargo pueden ser objeto de posesión. Así, por ejemplo, hay cosas relativamente inalienables (cosas del dominio privado del Estado, de incapaces, habidas gratuitamente por menores emancipados, vivienda afectada en los términos del art. 244); donadas con prohibición de enajenar (art. 1972), etcétera; y de otras absolutamente inalienables por haberse pactado o prohibido por una disposición

de última voluntad la enajenación. Además, si el poseedor de tales cosas fuese despojado, es también obvio que el despojante sería poseedor de ellas.

Por lo tanto, las únicas cosas fuera del comercio que no son susceptibles de posesión son las que pertenecen al dominio público del Estado.

Por último, aclara el artículo 1912 que la relación de poder puede abarcar toda la cosa o una parte material. Así, por ejemplo, el usufructo o la propiedad superficiaria pueden recaer sobre una parte del inmueble (arts. 2130 y 2116).

El objeto, como se dijo, es una cosa determinada. Por lo tanto, respecto a la relación de poder sobre universalidad de hecho, dispone el artículo 1927: "La relación de poder sobre una cosa compuesta de muchos cuerpos distintos y separados, pero unidos bajo un mismo nombre, como un rebaño o una piara, abarca sólo las partes individuales que comprende la cosa". Se descarta la relación de poder sobre una universalidad de hecho.

La relación de poder debe recaer sobre cosas determinadas (art. 1912); recae sobre las cosas individualmente consideradas, *ut singuli*.

Cuando se habla de conjunto de cosas, se está haciendo referencia a las universalidades. Ni la de derecho ni la de hecho pueden ser objeto de la relación de poder, la que siempre recae sobre cosas particulares o singulares.

X. Exclusividad de la posesión y de la tenencia

El artículo 1913, al igual que sucede con el derecho real de dominio (art. 1943), establece el principio de que la relación de poder es exclusiva, en el sentido de que no pueden dos personas, al mismo tiempo, ser poseedoras o tenedoras de toda la cosa. Si así ocurriera, ya no es posible hablar de posesión sino de coposesión o de cotenencia.

Dice el artículo 1913 que no pueden concurrir sobre la misma cosa varias relaciones "de la misma especie que se excluyan entre sí", de lo que se puede inferir que pueden presentarse situaciones en las que la cosa sea poseída por dos personas, al mismo tiempo, cuyas posesiones sean diferentes, en tanto no se excluyan entre sí. Así sucede,

por ejemplo, cuando la cosa fue gravada con usufructo, ya que concurren la posesión del nudo propietario y la del usufructuario.

Tampoco podrán concurrir dos tenencias iguales y de la misma naturaleza. A su vez, nada impide que concurren la posesión de una persona y la tenencia de otra distinta, ya que no son de la misma especie, y no se excluyen.

XI. Coposesión o cotenencia

Cuando la cosa es poseída en forma simultánea por más de una persona, y dicho objeto está indiviso (*pro indiviso*), hay allí una coposesión, que puede ser paralela, o no, a la existencia de un condominio, o de otro derecho real que no sea exclusivo, es decir que pueda tener por titular a más de una persona. Cada uno de los coposeedores tiene una parte ideal, abstracta, de modo que no es posible que cada uno de ellos ejerza la posesión sobre una parte concreta, determinada, de la cosa, salvo que así lo acuerden. La coposesión de cada poseedor recae sobre toda la cosa, pues la limitación es imaginaria. Sería incorrecto afirmar que en este caso el objeto de la posesión es una parte ideal, ya que siempre la posesión se proyecta sobre una cosa.

Para que haya coposesión deben darse dos requisitos: pluralidad de sujetos y que la cosa se encuentre en estado de indivisión. Cada poseedor puede ejercer actos posesorios sobre toda la cosa respetando la posesión de los otros coposeedores, sin excluirlos; es necesario que, al no tratarse de posesiones excluyentes entre sí, cada poseedor soporte la concurrencia de los otros poseedores.

Si uno de los coposeedores excluyese al otro, habría allí un supuesto de interversión de título, y el despojado podría intentar las acciones posesorias correspondientes, claro que para recuperar el ejercicio de su coposesión.

Frente a terceros, si hubiese un despojo, cada poseedor se encontraría habilitado para recuperar toda la cosa, y no solamente su parte ideal (ver arts. 2245 y 2251).

La coposesión puede ser un modo de adquirir el condominio por usucapión, si se mantiene durante el plazo previsto por la ley. Puede ser útil tanto para la prescripción breve como para la larga.

La coposesión no debe ser confundida con las situaciones mencionadas en el punto anterior, en las que concurren el ejercicio de derechos reales diferentes, ya que en éstas las posesiones no son iguales, son distintas, mientras que en la coposesión los coposeedores se encuentran en un plano de igualdad en lo que respecta a la titularidad y al ejercicio. Además, en el primer caso, uno de los poseedores se encuentra privado del uso y goce total o parcial de la cosa (v. gr.: si hay un usufructuario, el dueño no tiene el uso y goce de la cosa), mientras que en la coposesión todos tienen las mismas facultades para utilizar la cosa, limitadas por el respeto que corresponde al otro poseedor, al que no pueden excluir.

En lo pertinente, las reglas expuestas resultan aplicables a la cotenencia, esto es, cuando varias personas ejercen la tenencia de una cosa en común. Comparten el uso y deben hacerlo respetando el derecho igual del otro, y también pueden ejercer acciones posesorias para hacer que cese una turbación o para recuperar la tenencia.

XII. Clasificación de la posesión y de la tenencia

a) *Legítima e ilegítima*

Las relaciones de poder son legítimas cuando sean "...el ejercicio de un derecho real o personal constituido de conformidad con las previsiones de la ley" (art. 1916). De tal forma, si el titular de la relación carece de título, o lo tiene pero media alguna irregularidad, la relación será ilegítima.

Así, por ejemplo, quien adquiere un inmueble con título y modo suficientes, es un poseedor legítimo. En cambio, quien adquiere la posesión sin título, es un poseedor ilegítimo. Del mismo modo, un locatario que celebra el contrato debidamente es un tenedor legítimo.

El Código formula tres divisiones de la posesión conforme a las siguientes pautas: 1) según su origen o causa, la posesión puede ser legítima o ilegítima; 2) según las condiciones personales del poseedor, la posesión ilegítima puede ser, a su vez, de buena o de mala fe (arts. 1918/1920); 3) según la forma o modo en que es adquirida, la posesión de mala fe se subclasifica en viciosa y no viciosa (art. 1921).

b) *Caso del poseedor de inmueble con boleto de compraventa*

Para adquirir el derecho real se requiere título suficiente, y en materia de inmuebles debe estar formalizado por escritura pública (ver art. 1892). Cabe advertir que el artículo 1170, en determinadas condiciones, considera que el titular de un boleto de compraventa puede ser de buena fe. Reputarlo de buena fe tiene alguna importancia, pues influye en el régimen de los riesgos, frutos, mejoras, etcétera.

Una forma de armonizar puede ser la siguiente: el adquirente de la posesión con boleto de compraventa, si bien no es titular de un derecho real, sí cuenta con un derecho personal. El Código, en el artículo 1916, dice que la relación de poder es legítima cuando importe el ejercicio de un derecho real o "personal" constituido cumpliendo con las normas legales. De tal forma, el nuevo Código incluye a los derechos personales, por lo que bien puede considerarse que el poseedor con boleto de compraventa es legítimo, aun cuando no ejerza un derecho real que aún no adquirió.

c) *Relación de buena fe*

Dice el artículo 1918 que "El sujeto de la relación de poder es de buena fe si no conoce, ni puede conocer que carece de derecho, es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad".

La posesión y la tenencia ilegítimas pueden ser de buena y de mala fe. La buena fe en un sentido significa probidad, lealtad, ausencia de intención malévola. El Código se refiere a este aspecto cuando sienta que los contratos, y los derechos en general, deben ejecutarse de buena fe (arts. 9° y 961). En otro sentido, la palabra traduce la idea de persuasión, creencia, convicción sobre la legitimidad de una situación o hecho jurídico. El Código considera este aspecto al referirse a las relaciones de poder.

Dispone el artículo 1918 que es de buena fe "cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad". Esto significa que el poseedor o el tenedor están convencidos de que adquirieron el derecho real o el derecho personal de conformidad a las disposiciones del Código (o de otra ley), aunque en verdad no sea así.

Para que haya buena fe tal error de hecho debe ser esencial y excusable (art. 267), no debe provenir de una negligencia culpable (art. 266). Cuando se trata de un error de derecho, la buena fe no es posible (art. 8°).

Lo que caracteriza a la buena fe es un error en la mente del poseedor o tenedor, pero para que este error sea excusable es preciso que la posesión se funde en un título o causa de adquisición, apto de por sí para la adquisición del correspondiente derecho exteriorizado en la posesión, pero que en el caso no la produjo por adolecer de algún vicio o defecto que lo invalide. Pero no basta con la sola existencia del título, ya que si se trata de la adquisición derivada de derechos reales, es necesario también el modo (tradición). Por ende, si no hubo tradición, no hay siquiera posesión y, por lo tanto, no puede hablarse de posesión de buena fe, máxime cuando el error de derecho no es excusable. Si hubo tradición, para que el poseedor sea reputado de buena fe, además de contar con el título, no debe haber habido ningún vicio en la entrega de la cosa. El conocimiento del defecto de cualquiera de los dos (título y modo) elimina la buena fe.

Al tener que ser excusable el error del sujeto, no basta con su "ignorancia". Es necesario que su creencia se encuentre fundada, que sea razonable, y a ello sólo se llega si actuó sin negligencia. Hay un aspecto negativo (ignorancia) y otro positivo (diligencia).

Para ser de buena fe, el poseedor (también el tenedor) debe estar convencido de la legitimidad de su adquisición sin duda alguna. No debe ser considerado en estado de buena fe, el que duda si su autor era o no dueño de la cosa, y tenía o no el derecho de enajenarla, porque la duda es un término medio entre la buena y la mala fe.

d) *Presunción de buena fe*

Esta presunción se desprende del artículo 1919: "La relación de poder se presume de buena fe, a menos que exista prueba en contrario..." Además, en el Código, la buena fe es un principio, en lo que respecta al ejercicio de los derechos (art. 9°).

La buena fe se presume. Esta presunción tiene interés práctico, ya que libera al poseedor (o al tenedor) de la prueba -nada fácil- de su

buena fe. Tiene también un contenido ético, pues hay que considerar que generalmente las personas obran honestamente.

Se trata de una presunción *iuris tantum*, pues, como dice el artículo 1919, ello es así "a menos que exista prueba en contrario".

e) *Determinación de buena o mala fe*

Establece el artículo 1920 el momento en que cabe determinar la buena o mala fe: "La buena o mala fe se determina al comienzo de la relación de poder, y permanece invariable mientras no se produce una nueva adquisición.

"No siendo posible determinar el tiempo en que comienza la mala fe, se debe estar al día de la citación al juicio".

e.1) *Momento en el que se califica a la relación de poder*

La calificación de la relación debe ser realizada en el momento de su adquisición; la buena fe es inicial. Esto es que si la posesión (o la tenencia) en su origen fue de buena fe, así continúa su calificación, por ser indiferente el posterior conocimiento del poseedor de la ilegitimidad de su posesión. A su vez, si comenzó siendo de mala fe, también así perdurará la calificación.

e.2) *Buena fe y demanda de reivindicación triunfante*

En cuanto al poseedor de buena fe que es condenado por sentencia a restituir la cosa, si bien no pierde tal calidad, hay que tener presente que desde el día de la "citación al juicio" tiene un régimen especial en lo que respecta a la liquidación de los frutos percibidos, de los que por su negligencia hubiese dejado de percibir, y a la responsabilidad por deterioro de la cosa (ver arts. 1935/1936).

e.3) *Percepción de frutos*

Distinto es el sistema en cuanto a la percepción de frutos, ámbito en el cual la buena o mala fe se califica en cada hecho de percepción (art. 1935), sin ser suficiente la buena fe inicial. Cada acto de per-

cepción constituye un hecho aislado, cuyo carácter es independiente de las percepciones anteriores.

e.4) *Caso del sucesor*

En forma coherente, en el artículo 1935 se establece que lo que interesa es la situación del sucesor, cualquiera sea la calificación del antecesor. Dice la norma: "...la buena o mala fe del que sucede en la posesión de la cosa se juzga sólo con relación al sucesor y no por la buena o mala fe de su antecesor, sea la sucesión universal o particular".

e.4.1) *Sucesión universal*

Acaecida la muerte del poseedor o tenedor, el heredero continúa la persona del causante, y la relación se le trasmite. Por ello, si se trata de sucesión a título universal, la buena o mala fe de la posesión se determina por la condición del causante, cualquiera que sea la posesión del sucesor (art. 1901). Lo que ocurre es que la posesión es la misma por mediar en este caso identidad jurídica en las personas, y la calificación corresponde que sea hecha en el origen. No hay una posesión nueva en cabeza del heredero.

La regla expuesta no rige en materia de percepción de frutos, donde la buena o mala fe se determina en cada acto de percepción.

e.4.2) *Sucesión particular*

La solución es distinta de la expuesta precedentemente cuando se trata del sucesor singular. Es posible que un poseedor de mala fe (porque conocía la ilegitimidad de su posesión) transmita por venta u otro título la cosa a un tercero. Nada impide que éste pueda ser reputado de buena fe, pues aquí la calificación se hace en la persona del sucesor (art. 1920). El artículo 1920 dice que la buena o mala fe permanece invariable "mientras no se produce una nueva adquisición". En la sucesión particular hay una nueva adquisición.

En lo que respecta a la percepción de frutos, que es lo que trata el artículo 1935, la buena o mala fe se determina en cabeza del sucesor, cualquiera sea la calificación del antecesor.

e.5) *Concurrencia*

Nada dice el Código sobre esta cuestión. Cabe interpretar que si hay más de un poseedor o tenedor, cada uno responderá de su buena o mala fe.

e.6) *Personas jurídicas*

Según el criterio que preside a las personas jurídicas, dado que estas últimas sólo pueden adquirir la posesión por medio de sus representantes legales, y son consideradas personas enteramente distintas de sus miembros, la buena o mala fe de los miembros no incide sobre la buena o mala fe de la posesión de la persona jurídica.

En este caso la calificación debe ser hecha en la persona de los representantes necesarios.

f) *Relación de mala fe*

El Código no define a la relación de mala fe, pero se llega a ella fácilmente por el camino de la exclusión: hay mala fe en todos aquellos casos en los que falta la buena fe, esto es, cuando el sujeto no está persuadido, sin duda alguna, de la legitimidad de su adquisición. Además, para ser reputado de buena fe, el poseedor debe haber actuado con diligencia, realizando las averiguaciones necesarias.

La posesión de mala fe, según la forma en que haya sido adquirida, puede ser simple o no viciosa, o viciosa. Esta subclasificación no alcanza a la tenencia (art. 1921).

g) *Presunción de mala fe*

La presunción de buena fe es una regla que admite excepciones; la última parte del artículo 1919 deja a salvo casos en los que la mala fe se presume. Estas situaciones de excepción son:

- "a) cuando el título es de nulidad manifiesta;
- "b) cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece de medios para adquirirlas;
- "c) cuando recae sobre ganado marcado o señalado, si el diseño fue registrado por otra persona".

g.1) *Cuando el título es de nulidad manifiesta*

Ocurre que si el vicio es manifiesto, ostensible, el adquirente debió advertir la irregularidad. Si no la investigó, o la investigó y no la advirtió, su conducta es negligente y carece de justificación.

MNR

g.2) *Cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece de medios para adquirirlas*

Normalmente se tratará de cosas hurtadas o pérdidas, pero también puede darse esta situación en casos de desprendimiento voluntario. La norma no distingue, y no debe hacerlo el intérprete.

Aquí la tradición la realiza una persona "sospechosa". Cuando alguien compra a esta clase de personas cabe presumir que no actúa de buena fe, ya que pudo al menos dudar sobre el origen o la forma en que tal cosa llegó a poder de su vendedor.

El artículo 1919 vincula la calidad de la persona con dos posibles circunstancias: 1) que no tenga por costumbre vender cosas semejantes; 2) que no tenga capacidad o medios para adquirirlas.

El artículo 1919 utiliza la expresión "la mala fe se presume", lo que induce a afirmar que la presunción no admite prueba en contrario. Obsérvese que en la primera parte, al establecer la presunción de buena fe, se admite prueba en contra. Claro que también se puede considerar que la persona que adquirió en las condiciones descriptas por el artículo puede demostrar su buena fe, ya que motivos éticos imponen no omitir la presunción de probidad que contiene el artículo 1919. Parece más razonable esta última alternativa. Basta pensar que a veces se adquieren objetos valiosos de personas que no acostumbran venderlos y no por eso hay que sospechar, máxime cuando se trata de personas conocidas y que gozan de buena reputación y que posiblemente ignoraban que se trataba de una cosa sustraída o perdida.

g.3) *Cuando recae sobre ganado marcado o señalado, si el diseño fue registrado por otra persona*

Según la ley 22.939, que regula lo atinente a la propiedad del

ganado, quien tiene registrado el diseño de la marca o señal —lo cual es obligatorio—, es quien puede transmitir el derecho (arts. 4° y 6°). A su vez, se presume, salvo prueba en contrario, que el ganado mayor marcado y el ganado menor señalado, pertenece a quien tiene registrado a su nombre el diseño de la marca o señal (art. 9°).

Por lo tanto, si una persona adquiere ganado marcado o señalado a un sujeto que no tiene registrado a su nombre ese diseño, no puede alegar buena fe. Teniendo en cuenta que el artículo 9° referido acepta que se pruebe lo contrario, se puede entender que también esta presunción de mala fe admite ser rebatida.

h) *Mala fe simple o viciosa*

En cuanto a la posesión viciosa, la cuestión es tratada por el artículo 1921: "La posesión de mala fe es viciosa cuando es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa, o abuso de confianza; y cuando es de inmuebles, adquiridos por violencia, clandestinidad, o abuso de confianza. Los vicios de la posesión son relativos respecto de aquel contra quien se ejercen. En todos los casos, sea por el mismo que causa el vicio o por sus agentes, sea contra el poseedor o sus representantes". Aquí se describen los casos de posesión viciosa.

La posesión de mala fe puede ser simple o viciosa. Este artículo enumera los vicios de la posesión. Se trata de situaciones en las cuales la posesión no sólo es adquirida de mala fe, sino además en forma más grave en virtud de los métodos empleados.

Puede decirse que la posesión es viciosa cuando es adquirida ilegalmente, sin o contra la voluntad del poseedor, es decir, mediante desapoderamiento. Se da sin la conformidad del poseedor cuando hay clandestinidad, y contra su voluntad cuando hay violencia o abuso de confianza. En general, la posesión viciosa dimana de una apropiación o desapoderamiento prohibidos por la ley civil y reprimidos por la ley penal.

La posesión viciosa proyecta sus consecuencias en lo que respecta a la reivindicación triunfante y la destrucción o deterioro de la cosa (art. 1936). También impide la unión de posesiones, ya que para ello es necesario que una posesión derive de la otra (art. 1901), es decir, que haya habido tradición en lugar de desapoderamiento. En lo que

respecta a la usucapión larga, el Código pide que la posesión sea "ostensible", de modo que la clandestina no es apta para tal fin. La posesión viciosa se transmite con ese carácter al heredero.

h.1) *Muebles*

El artículo menciona al "hurto", el cual se configura por el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena (art. 162, Cód. Pen.). Con mayor razón la posesión es viciosa si fue adquirida por robo, que implica el uso de la fuerza (art. 164, Cód. Pen.).

Los casos de "estafa" están previstos en los artículos 172 y 173 del Código Penal. Entre los numerosos supuestos previstos, cabe citar el inciso 9° del artículo 173: "El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos". La posesión viciosa no es la de quien transmite cometiendo estafa, sino la de quien adquiere la cosa mueble sabiendo la verdadera situación. Aquí el tercero es de mala fe y, en razón de esa actitud, vicioso.

El "abuso de confianza", que es un vicio común a la posesión de cosas muebles o inmuebles, se configura cuando alguien ha recibido la cosa con obligación de restituirla (art. 1940, inc. c), pero no lo hace. Se trata del caso del tenedor que, no obstante estar obligado a restituir, no sólo no lo hace sino que intervierte su título para convertirse en poseedor. Para ello es menester que esa intención se manifieste por actos exteriores que revelen semejante propósito y que produzcan el efecto de privar de su posesión a quien la cosa debía serle restituida (art. 1915).

h.2) *Inmuebles*

En las cosas inmuebles, la posesión es viciosa cuando es adquirida por violencia, clandestinidad o abuso de confianza.

En cuanto a la "violencia", dice el artículo 276: "La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la

situación del amenazado y las demás circunstancias del caso". Ésta es la pauta a seguir. La "violencia" puede ser material (física) o moral (intimidación).

No hay que confundir la violencia como vicio de la posesión, con el vicio de violencia que puede afectar al contrato en virtud del cual la posesión fue adquirida.

La violencia puede ser utilizada directamente por la persona que pretende adquirir la posesión, o bien "por sus agentes". También puede ser sufrida por el poseedor "o sus representantes", esto es, su tenedor (ver art. 1940, inc. b).

Para que haya "clandestinidad" se requiere que medie ocultamiento, es decir, que la posesión no sea pública —"ostensible" dice el artículo 1900— respecto del anterior poseedor, aun cuando los terceros conozcan la situación. Para que el vicio exista no es necesario que el anterior poseedor conozca lo sucedido, sino que basta con que haya podido conocer la usurpación.

En principio, para que una posesión sea "clandestina" es necesario que no sea pública. Sin embargo, esto no es así en todos los casos, ya que se configura el vicio cuando la situación es oculta respecto del anterior poseedor. Por lo tanto, puede concluirse que una posesión es clandestina cuando se ejerce sin conocimiento del poseedor de la cosa. Si la posesión se ejerce a escondidas, el poseedor víctima de la usurpación, como no la conoce, se encuentra impedido de reaccionar contra ella.

Por último, el "abuso de confianza" fue explicado al tratar los vicios de la posesión de cosas muebles.

h.3) *Relatividad de los vicios*

Según se desprende del artículo 1921, los vicios de la posesión son relativos.

Esto significa que quien adquiere una posesión en forma viciosa, sólo reviste ese carácter frente a quien fue víctima del vicio, mas no frente a terceros. Así, si una persona desapodera violentamente a otra de su inmueble, será considerado poseedor vicioso con relación al despojado, pero no tendrá ese carácter frente a los demás.

CAPÍTULO III

RELACIONES DE PODER

(segunda parte)

SUMARIO: I. Adquisición de las relaciones de poder. II. Modos de adquisición. III. Desapoderamiento. IV. Tradición. V. *Traditio brevi manu y constituto posesorio*. VI. Conservación de las relaciones de poder. VII. Extinción de las relaciones de poder. VIII. Efectos de las relaciones de poder.

I. Adquisición de las relaciones de poder

Las relaciones de poder, especialmente la posesión y la tenencia, pueden ser adquiridas de diversas formas o maneras. Como principio, dispone el artículo 1922 que "Para adquirir una relación de poder sobre una cosa, ésta debe establecerse voluntariamente:

- "a) por sujeto capaz, excepto las personas menores de edad, para quienes es suficiente que tengan diez años;
- "b) por medio de un contacto con la cosa, de la posibilidad física de establecerlo, o cuando ella ingresa en el ámbito de custodia del adquirente".

Esta norma sienta algunas reglas generales para la adquisición de las relaciones de poder e indica algunos de los modos, que no son los únicos.

a) *Capacidad*

Uno de los recaudos para adquirir la relación de poder es la capacidad. En materia posesoria se requiere siempre un *animus* mínimo, que es la voluntad de poseer, de querer ejercitar sobre la cosa el poder

de hecho propio de la posesión. Por tal motivo, como se verá a continuación, están capacitados para adquirirla los que tengan una capacidad natural de entender y de querer.

La relación debe ser adquirida por intermedio de un representante legal en caso de ser el adquirente incapaz (art. 26), o en el supuesto de ser el adquirente una persona jurídica.

El artículo 1922 se aplica en los casos de adquisiciones unilaterales de la posesión, a los que cabe denominar modos originarios. En cambio, cuando se trata de adquirir la posesión por medio de la tradición, en tanto ésta es un acto jurídico, se exige la plena capacidad, es decir, la necesaria para celebrar actos jurídicos. No se aplica la excepción relativa al mayor de diez años. Lo mismo cabe decir de la *traditio brevi manu* y del *constituto posesorio*, que requieren de la celebración de un acto jurídico para que se adquiera la posesión.

a.1) Edad

Surge del artículo 1922, inciso a, que el sujeto debe tener más de diez años. No se requiere la plena capacidad, que se adquiere a los 18 años, sino una edad menor.

a.2) Habilidad mental

Dice el artículo 1922 que debe existir voluntad, y el inciso a, que, además de la edad, el sujeto debe ser "capaz". Según el artículo 24, inciso c, es incapaz de ejercicio "la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión".

b) "Corpus"

El inciso b, del artículo 1922, se refiere al *corpus*. Ya en la primera parte el referido artículo establece que la relación de poder necesita la voluntad, aludiendo al ánimo. Si la relación no es querida, no es relevante para el Código.

Siguiendo a Savigny, para que haya *corpus* no es necesario el contacto con la cosa, por ser suficiente la posibilidad física de tomarla. No obstante, cabe aclarar que la posibilidad de disponer físicamente de la cosa (*corpus*) no requiere estar en su presencia. En suma, en

algunos supuestos se adquiere la relación con el contacto con la cosa; en otros, se la adquiere antes de que se produzca el contacto, y aun antes de estar en "presencia de la cosa".

La última parte aplica la llamada "teoría de la custodia" (Savigny), según la cual se considera que la persona tiene el imperio absoluto de su casa o de un lugar que esté a su "exclusiva disposición", por lo que adquiere la posesión de las cosas que le son allí remitidas aunque no esté presente, y aun cuando ninguna otra persona la hubiese recibido.

Un ejemplo que se aprecia a diario es el reparto de periódicos que se envían y se colocan debajo de la puerta del habitante de un inmueble. Aun cuando éste se encuentre fuera del inmueble, de todos modos adquiere la posesión de los objetos que le fueron remitidos.

II. Modos de adquisición

Hay distintos medios de adquirir una relación de poder. En lo que concierne a la posesión, es posible distinguir si la cosa ya es poseída por otro, o no. Si no lo es (v. gr.: cosa abandonada, art. 1931, inc. e), bastaría con apropiarla (arg. art. 1947) u ocuparla si es inmueble; lo que el Código de Vélez denominaba *aprehensión*, y en este Código se llama "apoderamiento" (art. 1923, *in fine*). Si ya otro sujeto la posee, el adquirente puede adquirirla contra su voluntad (desapoderamiento), o con su conformidad (tradición, *traditio brevi manu*, *constituto posesorio*).

Los dos primeros medios son unilaterales, mientras que los tres últimos son bilaterales. En lo pertinente, estas reglas son trasladables a la tenencia, ya que el Código trata a ambas relaciones de igual forma.

Cabe advertir que cuando la cosa abandonada es mueble no registrable, el que la apropie adquiere también el derecho real de dominio, por lo que poca utilidad presenta esto en el ámbito posesorio.

III. Desapoderamiento

Se puede denominar desapoderamiento al hecho por el cual una per-

sona priva a otra, sin derecho, de su relación de poder. Claros ejemplos son los previstos en el artículo 1921 que se refiere a la posesión viciosa. Así, si se trata de cosas muebles, cuando se comete hurto, estafa o abuso de confianza, y si se trata de inmuebles, cuando se emplea la violencia, la clandestinidad, o el abuso de confianza.

El artículo 2238 explica que se configura cuando se pierde el objeto "ante actos materiales, producidos o de inminente producción, ejecutados con intención de tomar la posesión, contra la voluntad del poseedor o tenedor". Para hablar de desapoderamiento es necesario, obviamente, que de tales actos resulte esa privación (art. 2241). El artículo 2238 alude a la intención de tomar la "posesión", pero luego menciona también al tenedor. Por lo tanto, cabe inferir que éste es un medio que sirve para adquirir la posesión o la tenencia. Esta conclusión se impone si se tiene presente que otras normas le conceden la acción de despojo también al tenedor.

Éste es un modo unilateral de adquirir la relación de poder.

IV. Tradición

Dispone el artículo 1924: "Hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe. Debe consistir en la realización de actos materiales de, por lo menos, una de las partes, que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, los que no se suplen, con relación a terceros, por la mera declaración del que entrega de darla a quien la recibe, o de éste de recibirla".

La tradición es una forma de adquirir la relación de poder respecto de una cosa que otro posee o tiene; pero, a diferencia del caso de desapoderamiento, y del de apoderamiento examinados anteriormente, aquél presta su consentimiento en que la adquisición se realice. Dice el artículo 1924 que "Hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe". Cabe agregar, como surge del artículo 1922, que la entrega es voluntaria, pues de lo contrario se trataría de un desapoderamiento. La tradición es, evidentemente, un medio bilateral, dado que se opera por la voluntad de los intervinientes.

La tradición significa la entrega de la cosa. No obstante, como se examinó anteriormente, hay que tener en cuenta que para que se

concrete la entrega no es necesario un acto de aprehensión material del adquirente, ni la presencia de las partes, sino que es suficiente con que la cosa sea puesta a su disposición, en tanto el destinatario haya manifestado su consentimiento —expreso o tácito— de recibirla.

a) *Naturaleza jurídica*

Si bien no es un contrato, el hecho de que sea necesario el consentimiento de los participantes permite afirmar que la tradición es un acto jurídico, ya que se trata de un acto voluntario (art. 260), lícito (art. 259) y es, además, un acto jurídico bilateral.

Por tratarse de un acto jurídico, es necesario que se manifieste por un hecho exterior (art. 260); en la especie, por la realización de actos materiales de por lo menos una de las partes. Además, como acto jurídico requiere para su realización de la capacidad de las partes, sin que sea suficiente con su discernimiento. Tanto el *tradens* como el *accipiens* deben tener capacidad. No basta con tener más de diez años.

b) *Importancia de la tradición*

Hay que tener en cuenta que la tradición no es sólo un modo de transmitir la posesión, sino que también es un medio para transferir la tenencia o un derecho real, excepto la hipoteca y las servidumbres, aunque en las positivas el primer uso equivale a la tradición (art. 1892). En rigor, la tradición significa la entrega de la cosa, pues es esta última lo que se transmite, y según la causa que haya motivado la entrega, la cosa será adquirida en el carácter de tenedor, poseedor o titular de un derecho real.

La tradición cumple, asimismo, el papel de publicidad de los derechos reales en materia de cosas muebles no registrables.

La tradición es también la forma de cumplir o ejecutar las obligaciones de dar, y cuando se realiza desplaza los riesgos de la cosa hacia el *accipiens*. Lo atinente a este plano es materia del cumplimiento de las obligaciones, cuestión que excede el marco de esta obra.

c) *Forma de hacer la tradición*

El artículo 1924 alude a la forma de realizar la tradición, que no es la única ya que en el artículo siguiente se mencionan otras.

c.1) *Actos materiales*

Es necesario que se realicen actos materiales para considerar hecha la tradición. Esto supone, a su vez, tres posibilidades: 1) actos materiales de quien entrega la cosa con asentimiento de quien la recibe; 2) actos materiales de quien la recibe con asentimiento de quien la entrega; 3) el artículo 1924 dice que los actos materiales deben ser hechos, al menos, por una de las partes, por lo que pueden ser realizados por ambas partes.

Como ejemplo del primer supuesto se puede citar el caso de que el tradente entregue las llaves a la persona indicada por el adquirente, o que las deposite en la casa del adquirente o en otro lugar, en cumplimiento de una orden dada por éste. Existen actos materiales de quien entrega, y consentimiento de quien recibe, dado que aquél obra en cumplimiento de una orden o expresión de voluntad emanada del último.

El segundo se concreta cuando el adquirente realiza actos posesorios en el inmueble, en presencia del transmitente o con su consentimiento.

El último supuesto se advierte en la hipótesis de que el transmitente y el adquirente recorran juntos el inmueble, y que mientras el primero retira sus pertenencias, el segundo introduce las suyas (v. gr.: útiles, herramientas, ganado, etc.). Aquí los actos materiales son realizados conjuntamente.

Los actos materiales a los que se alude son los actos posesorios, algunos de los cuales enumera en forma no taxativa el artículo 1928.

c.2) *Actos posesorios*

Según el artículo 1928: "Constituyen actos posesorios sobre la cosa los siguientes: su cultura, percepción de frutos, amojonamiento o impresión de signos materiales, mejora, exclusión de terceros y, en general, su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga". Contiene una enumeración, no taxativa, de actos considerados posesorios.

MNR

Se trata de una enumeración —meramente enunciativa, no taxativa— de actos sobre cosas inmuebles o muebles que el Código llama posesorios, ya que lo esencial para que uno o varios hechos puedan ser considerados tales es que hayan sido ejercidos con *animus domini*. La expresión "cultura" se refiere al hecho de cultivar.

Esta norma, evidentemente, facilita la prueba de la posesión, pues cuando se realizan los actos que enumera, la ley dice que se está en presencia de actos "posesorios". Así, si una persona cultiva, repara o construye en un inmueble, el artículo 1928 indica que realiza actos de posesión, lo que conduce a la conclusión de que la posesión se presume, lo que el Código dispone de manera expresa (art. 1911).

La enumeración no es taxativa. Obsérvese que la norma dice "en general", "por cualquier modo que se obtenga", lo que da la idea de otras posibilidades. Por ende, se pueden señalar otros actos posesorios, tales como el acto de cercar, de alambrar, etcétera. Se trata, en definitiva, de actos de ocupación o de exclusión de terceros, hechos a los que sí se refiere el artículo 1928.

No cabe asignar tal carácter al pago de impuestos, pues por sí solo no revela el contacto con la cosa, en especial su apoderamiento. Los actos posesorios son actos materiales, mientras que el pago es un acto jurídico, aunque es una muy buena prueba del ánimo.

No deben ser asimilados a los actos posesorios los actos tolerados por el poseedor del inmueble. En este caso no se trata de actos que alguien ejerce en el inmueble de otro a sus espaldas, o contra su voluntad, sino por su tolerancia (v. gr., permitir que el vecino saque agua o algunas flores; o dejar que pasen sus animales para pastar o beber).

Se asimilan a los actos tolerados los llamados de "mera facultad", que tampoco son hábiles para generar una situación de posesión o un derecho en cabeza de un tercero.

c.3) *Relación de poder vacua*

Dice el artículo 1926: "Para adquirir por tradición la posesión o la tenencia, la cosa debe estar libre de toda relación excluyente, y no

debe mediar oposición alguna". Se establece un requisito adicional para que pueda configurarse la tradición.

Para que se concrete la tradición, además, es necesario que la cosa se encuentre libre de otra relación, lo que el artículo 1926 explica con mayor precisión. Esto es lo que se denomina *relación de poder vacua*.

La necesidad de la relación vacua no significa que el inmueble deba estar vacío, sino que al menos esté "libre de toda relación excluyente, y no debe mediar oposición alguna". Así, por ejemplo, si otra persona se encuentra en posesión del inmueble la tradición para transmitir la posesión no se puede realizar dado que no pueden concurrir dos poseedores de la misma naturaleza sobre la cosa (art. 1913). Si el inmueble se encuentra ocupado por usurpadores que pretenden adquirirlo por usucapión, será imposible para el adquirente realizar actos materiales sobre la cosa sin antes excluir a los poseedores actuales.

No cualquier ocupante constituye un obstáculo a la realización de la tradición. Debe ser un "contradictor", esto es, alguien que se encuentre ejerciendo la relación que se pretendió transmitir. Así, por ejemplo, si el inmueble se encuentra ocupado por quien es tenedor (v. gr., un locatario), ello no impide que se pueda transmitir la posesión (art. 1923). Sí, en cambio, sería un obstáculo si se pretende transferir la tenencia, ya que aquí habría dos relaciones de la misma especie, excluyentes entre sí.

c.4) La mera declaración

Puede ocurrir que las partes declaren haber hecho la tradición, o haberla recibido, o ambas cosas. En principio, esta declaración es insuficiente, y debe ser completada por la realización de otros actos que revelen la efectiva entrega de la cosa. No alcanza con la mera voluntad del tradente, pues se trata de un acto bilateral y porque además del consentimiento se necesita la realización de actos materiales. El acuerdo debe ser completado con la entrega, a excepción de casos especiales en los que el Código prescinde de la entrega (*traditio brevi manu* y *constituto posesorio*).

Corresponde advertir que es una práctica muy común en los con-

tratos, incluso en aquellos que son formalizados en escritura pública, que las partes y el escribano autorizante apelen a este tipo de fórmulas.

El Código dispone en la parte final del artículo 1924, que las declaraciones no suplen los actos materiales "con relación a terceros", de modo que entre las partes tendrían plenos efectos. Se acepta que las meras declaraciones de una de las partes, o de las dos, suplan la necesidad de hacer actos materiales, aunque ello sería inoponible a terceros. Respecto de estos últimos se necesita mayor seguridad y certeza, lo que no acontece cuando no hay actos materiales visibles.

d) Otras formas de tradición

Dispone el artículo 1925 lo siguiente: "También se considera hecha la tradición de cosas muebles, por la entrega de conocimientos, cartas de porte, facturas u otros documentos de conformidad con las reglas respectivas, sin oposición alguna, y si son remitidas por cuenta y orden de otro, cuando el remitente las entrega a quien debe transportarlas, si el adquirente aprueba el envío". Se indican otras formas de hacer la tradición, además de los actos materiales y la mera declaración.

V. *Traditio brevi manu* y *constituto posesorio*

Dice el artículo 750, que "El acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario". Sienta una regla pero admite que la ley, por excepción, disponga lo contrario.

Esto es lo que sucede en los casos de *traditio brevi manu* y *constituto posesorio*, en los que la tradición, como dice el artículo 1892, "no es necesaria".

a) "*Traditio brevi manu*"

Dice el artículo 1892 en el tercer párrafo que "No es necesaria, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la posea a su nombre, o cuando el que la posea a nombre del propietario, principia a poseerla a nombre de otro". Es similar el texto del artículo 1923.

Es lo que se conoce, desde el Derecho Romano, como *traditio brevi manu*. La posesión de cosas muebles e inmuebles puede adquirirse concurriendo sólo las voluntades del *tradens* y del *accipiens*, sin la necesidad de realización de actos materiales de alguno de ellos. Esto es lo que ocurre cuando la posesión es adquirida a través de la *traditio brevi manu* y del *constituto posesorio* (art. 1923).

a.1) Tenedor que pasa a ser poseedor

Quien se encuentra en la detentación de la cosa, en calidad de tenedor, pasa a poseerla como consecuencia de un acto jurídico en el cual las partes han volcado sus voluntades en tal sentido. Por ejemplo, si el locatario adquiere el dominio del inmueble alquilado, muta su relación con la cosa, contrato mediante, pasando de ser tenedor (locatario) a ser poseedor (dueño).

Por una cuestión de economía y practicidad, a fin de evitar inútiles desplazamientos de la cosa, la ley prescinde de la realización de actos exteriores, resultando suficiente el acuerdo de voluntades. En caso contrario, el tenedor tendría que abandonar la relación con la cosa entregándosela al poseedor, para que éste, ulteriormente, se la devuelva al tenedor, a fin de que adquiera la posesión por tradición.

a.2) Tenedor que poseyendo una cosa a nombre de una persona, pasa a poseerla a nombre de otra

Como se ve, el tenedor sigue siendo el mismo, pero se produce una mutación subjetiva en la relación posesoria: cambia la persona que posee la cosa. Por ejemplo, el dueño de un inmueble (antigua posesión) que, luego de darlo en locación (tenencia actual y permanente), lo vende a un tercero (nueva posesión).

Se advierte, a través del ejemplo, que no sería económico ni práctico exigir que el poseedor (dueño del inmueble y locador) le requiera la cosa raíz al tenedor (locatario), para luego, una vez en su poder, hacerle tradición de ella al comprador a fin de que instale su posesión (nuevo poseedor), debiendo éste, finalmente, reintegrarla al locatario (mismo tenedor).

Se destaca que, si bien se requiere que el tenedor sea notificado

del cambio de poseedor para que principie a poseer la cosa a nombre del nuevo poseedor, no resulta necesario su consentimiento, pues el tenedor es ajeno al acto jurídico que fundamenta la *traditio brevi manu*.

b) "Constituto posesorio"

Dice el artículo 1892 en el tercer párrafo que la tradición "Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente". Similar es el texto del artículo 1923.

Esta figura, de indiscutida naturaleza contractual, permite que quien está poseyendo por sí, transmita la posesión, pero conserve la cosa en su poder en calidad de tenedor o, en otros términos, constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente.

El transmitente, no obstante mantener la relación material con la cosa, desciende de la categoría de poseedor a la de tenedor. Por ejemplo, cuando el dueño de un inmueble lo vende y, acto siguiente, se lo alquila al adquirente.

En el caso, el vendedor transmite la posesión al comprador, y luego, contrato de locación mediante, deviene en locatario (tenedor) del inmueble que posea.

Tratándose de un instituto de excepción, el *constituto posesorio* debe ser probado fehacientemente por quien lo invoca, pues, en caso de duda, la interpretación debe ser restrictiva.

Un supuesto de *constituto posesorio* prevé el Código cuando se extingue el dominio revocable o el fiduciario. Quien hasta ese momento era poseedor, automáticamente se convierte en tenedor al resolverse el dominio que ostentaba hasta entonces (arts. 1706 y 1968).

VI. Conservación de las relaciones de poder

a) Principio general

El principio general lo sienta el artículo 1929: "La relación de poder se conserva hasta su extinción, aunque su ejercicio esté impedido por alguna causa transitoria".

La adquisición de la posesión requiere la concurrencia de dos elementos: el *corpus* y el *animus domini*. Si alguno de éstos falta no hay

posesión. Distinto es cuando se trata de conservar la posesión que ya ha sido adquirida; de acuerdo al sistema que viene del Derecho Romano y que seguía el Código de Vélez, no es menester que ambos elementos estén reunidos, sino que la posesión puede ser conservada por el solo ánimo. La posesión se conserva con mayor facilidad que la necesaria para adquirirla, ya que no se exige la persistencia de los requisitos que permitieron la adquisición.

Esto significa que para conservar la posesión no es necesario estar siempre en contacto material con la cosa, o ejercer permanentemente actos posesorios sobre ella, sino que es suficiente con la intención o ánimo de conservarla. En rigor, como dice el artículo 1929, se conserva hasta su extinción, esto es, mientras no aparezca alguna causa de extinción.

Éste es un principio que debe ser armonizado, ya que existen situaciones en las que el ánimo de conservar la posesión resulta insuficiente para conseguir ese efecto. Funciona en los casos en los que la desaparición del elemento corporal responde a circunstancias de carácter transitorio, destinadas a ser superadas en un plazo más o menos breve; pero no en los casos en los que la desaparición del elemento corporal es definitiva.

Así ocurre, por ejemplo, con la posesión de lugares que sólo pueden ser habitados durante determinadas épocas del año u ocupados por una inundación pasajera; con las cosas perdidas dentro del inmueble del poseedor (arg. art. 1922, inc. b); o con las cosas que están en un lugar que no se recuerda. Se trata de situaciones en las cuales la imposibilidad de ejercer actos sobre la cosa es transitoria, destinada a desaparecer, o en las que, con las palabras del artículo 1931, existe la "probabilidad razonable de hallar la cosa perdida".

En cambio, cuando la imposibilidad de ejercer actos sobre la cosa es definitiva (art. 1931, inc. c), la voluntad del poseedor (o del tenedor) por sí sola es insuficiente para conservar la relación. Es claro que si una persona viaja en tren y se le cae el encendedor por la ventanilla, o si un ladrón le quita la cartera, el solo ánimo de conservar la relación es insuficiente y se pierde. Lo mismo sucede cuando la cosa se destruye: el ánimo de conservarla es insuficiente.

Sin perjuicio de lo expuesto, también se aplica la regla de la con-

servación por inercia en los casos en los que no exista ningún impedimento pasajero para el ejercicio de actos. Teniendo en cuenta que no se presume el abandono (art. 1931, inc. e), si el sujeto no realiza actos, aun cuando pueda hacerlo, de todos modos la conserva. Para perderla es necesario que exprese una voluntad contraria, o bien que esa voluntad sea el resultado de la actividad de un tercero.

Si bien cuando se alude a la conservación de solo ánimo se trata de la posesión, ya que la tenencia no requiere el *animus*, las reglas expuestas sobre la conservación también son aplicables. La tenencia, en suma, se conserva también por inercia, mientras no suceda un hecho o acto que determine su extinción.

Para que se pierda el poder de hecho el Código exige que se manifieste una voluntad contraria, ya sea del propio titular de la relación (v. gr., si abandonó la cosa), o resultante de hechos de terceros que priven al sujeto de la relación, o la extinción o pérdida de la cosa.

b) Presunción de continuidad

Dice el artículo 1930: "Se presume, a menos que exista prueba en contrario, que el sujeto actual de la posesión o de la tenencia que prueba haberla ejercitado anteriormente, la mantuvo durante el tiempo intermedio". Es una norma que facilita la prueba, especialmente en los juicios de usucapión. Puede suceder que la situación no haya sido de esa forma, en cuyo caso el interesado deberá destruir la presunción demostrando lo contrario.

VII. Extinción de las relaciones de poder

Dispone el artículo 1931: "La posesión y la tenencia se extinguen cuando se pierde el poder de hecho sobre la cosa.

"En particular, hay extinción cuando:

- "a) se extingue la cosa;
- "b) otro priva al sujeto de la cosa;
- "c) el sujeto se encuentra en la imposibilidad física perdurable de ejercer la posesión o la tenencia;
- "d) desaparece la probabilidad razonable de hallar la cosa perdida;

"e) el sujeto hace abandono expreso y voluntario de la cosa".

En este artículo se enumeran las causas que pueden provocar la extinción de la relación de hecho sobre la cosa.

La relación de poder se extingue cuando "se pierde el poder de hecho sobre la cosa". Esto es por falta de *corpus* en todos aquellos casos en que el titular se halla en la imposibilidad de disponer físicamente de la cosa, en tanto esta imposibilidad sea definitiva, y no transitoria, de modo que su intención no resulta suficiente para conservarla.

a) Extinción de la cosa

El inciso a, del artículo 1931 se refiere a la extinción de la cosa. Contempla la extinción física de la cosa, aunque cabe incluir en su contenido a los casos en los que la cosa se extingue desde el punto de vista jurídico, por no ser susceptible de ser poseída, lo que podría ocurrir si pasa al dominio público.

Las causas que provoquen la extinción de la cosa pueden ser diversas: caso fortuito, hecho de un tercero o del propio titular. Cualquiera sea el motivo, la consecuencia inevitable será la extinción de la relación. La posibilidad de que el poseedor pueda obtener el resarcimiento del daño sufrido es una cuestión ajena a la subsistencia de la posesión.

El objeto de la posesión y de la tenencia lo constituyen las cosas de existencia actual y que están determinadas (art. 1912). Consecuencia de ello es que si la cosa se extingue, se pierde también la relación por falta de objeto, sin que el ánimo del sujeto de conservarla produzca algún efecto.

b) Privación de la cosa

Cuando "otro priva al sujeto de la cosa" (art. 1931, inc. b), contra su voluntad, se produce lo que el Código llama "desapoderamiento" (ver arts. 2238 y ss.). Generalmente se trata de casos que generan una posesión viciosa (ver art. 1921), aunque también podrían tener por objeto sólo la tenencia, ajena a esta subclasificación. Por ende, cabe interpretar que esto sucede cuando se obtiene la cosa poseída o tenida por otro, sin su consentimiento, contra su voluntad, aunque no se incurra en las situaciones previstas en el artículo 1921.

Si el sujeto se resiste y conserva una parte de la cosa sólo habrá desapoderamiento parcial.

c) Imposibilidad física de ejercer la posesión o la tenencia

Al tratar la conservación de la relación se señaló que ésta se conserva sola, por inercia, en tanto la imposibilidad de ejercer actos sobre la cosa fuese transitoria. En cambio, esa situación resulta insuficiente para conservarla cuando tal imposibilidad es definitiva, hipótesis en que la relación se pierde.

Se pone el ejemplo de las cosas caídas en lugares inaccesibles, como ocurre cuando caen al mar. Otra aplicación de esta idea se halla en el inciso d, de este artículo 1931, según el cual la relación se pierde "si desaparece la probabilidad razonable de hallar la cosa perdida", concepto similar al anterior.

d) Conservación de cosas perdidas

La pérdida de la cosa no siempre implica la extinción; el límite se encuentra en la existencia, o no, de la "probabilidad razonable" de encontrarla. Mientras exista esta probabilidad se conserva la relación (art. 1929), ya que existe una imposibilidad transitoria de ejercer actos; pero si ella desaparece, la voluntad es impotente ante la falta absoluta del *corpus*.

La determinación de cuándo existe la "probabilidad razonable" de encontrar la cosa perdida es una cuestión de hecho de no fácil solución, por lo subjetivo de la apreciación. No obstante, cabe entender que debe ser valorada en función de pautas objetivas, es decir que hay que medir si existe tal probabilidad, o si se justifica tal creencia, en función de lo que apreciaría el común de la gente, de acuerdo a estándares sociales, y no sobre la base del capricho del sujeto que no puede encontrar la cosa perdida.

Una consecuencia de la aplicación de esta norma, tal como se señaló anteriormente, es la presunción de continuidad. Esto significa que si la persona recupera la cosa perdida, como nunca perdió la relación de poder, hay que reputarlo poseedor o tenedor aun durante el período en que existió la probabilidad de recobrar dicha cosa.

Claro que esta presunción puede admitir prueba en contrario, cuya carga pesará sobre quien la cuestione.

e) *Abandono*

En el abandono el sujeto se desprende materialmente de la cosa —con lo cual cesa el *corpus*—, y dicho desprendimiento es voluntario. Si no fuese voluntario, habría desapoderamiento si ocurriese por la fuerza o coacción.

El abandono se da cuando el poseedor (o el tenedor), intencionalmente, se desprende de la cosa con el objeto de privarse de su disponibilidad física y de no ejercer más sobre ella actos posesorios. Así, por ejemplo, cuando alguien tira en el cesto de basura una cosa que le pertenece con el propósito de deshacerse de ella. En cambio, no hay abandono ni se pierde la relación cuando alguien se ausenta temporalmente de la casa de campo o de la que tiene en la playa, pues su ocupación en períodos alternados es la forma natural de su utilización. En tal caso, la relación se mantiene por inercia (art. 1929).

Para que el abandono sea tal, debe ser “expreso”. No alcanza con la mera manifestación de desprenderse de la cosa, sino que el desprendimiento material debe ser efectivo. Ello es así porque el abandono no se presume, de modo que la voluntad abdicativa debe exteriorizarse adecuadamente.

f) *Otros modos*

Aunque el artículo 1931 no los menciona, los modos bilaterales de adquirir las relaciones de poder también son causas de extinción. Tal es lo que ocurre con la tradición, la *traditio brevi manu*, y el *constituto posesorio*. En cada uno de ellos, mientras alguien adquiere la posesión, la pierde el transmitente.

VIII. Efectos de las relaciones de poder

a) *Derechos inherentes a la posesión y a la tenencia*

Dispone el artículo 1932: “El poseedor y el tenedor tienen derecho a ejercer las servidumbres reales que corresponden a la cosa que cons-

MNR

tituye su objeto. También tienen derecho a exigir el respeto de los límites impuestos en el Capítulo 4, Título III de este Libro”. Esta norma se refiere a los principales derechos inherentes a la posesión y a la tenencia de una cosa. Son derechos que pueden ejercerse mientras exista la relación con la cosa. Dicho artículo, en su título, sólo se refiere a la posesión, pero en su texto menciona también a la tenencia. Dejando de lado la confusión, cabe sostener que, por regla, los derechos abarcan a ambas relaciones de poder.

Este artículo, como surge de su propio texto, se refiere a derechos que tiene una persona por el hecho de ser poseedor o tenedor de una cosa determinada. Desaparecen cuando la persona deja de ser poseedora o tenedora de la cosa en cuestión, y nacen en cabeza del nuevo poseedor o tenedor, ya que se vinculan a la cosa y no a la persona.

La cosa puede ser mueble o inmueble; las reglas son las mismas. No obstante, el artículo se refiere a derechos propios de cosas inmuebles (servidumbres y límites al dominio).

a.1) *Servidumbres reales*

En tanto el poseedor o tenedor de un predio sirviente deben soportar la carga o gravamen que implica la existencia de una servidumbre constituida a favor del predio dominante, el poseedor o tenedor de éste resultan titulares del derecho de ejercer una servidumbre.

El titular del predio sirviente está obligado a tolerar el ejercicio de los derechos que le incumben al poseedor del inmueble beneficiado por la servidumbre, pudiendo éste acudir al uso de la acción confesoria en caso contrario (art. 2264).

a.2) *Límites al dominio*

Este artículo aclara que son derechos inherentes a la posesión las obligaciones derivadas de las relaciones de vecindad, reguladas en el Capítulo 4, Título III, del Libro Cuarto, bajo el nombre de *Límites al dominio*.

Estos derechos corresponden a poseedores, sean o no titulares de un derecho real, y en ciertos casos se extienden a tenedores.

Así, por ejemplo, un vecino no debe producir ruido que exceda

la normal tolerancia (art. 1973); es una obligación inherente a la posesión o a la tenencia. Si no la respeta, se estaría afectando el derecho inherente a la posesión o tenencia de quien lo padece.

b) *Deberes inherentes a la posesión*

Establece el artículo 1933 que "El poseedor y el tenedor tienen el deber de restituir la cosa a quien tenga el derecho de reclamarla, aunque no se haya contraído obligación al efecto.

"Deben respetar las cargas reales, las medidas judiciales inherentes a la cosa, y los límites impuestos en el Capítulo 4, Título III de este Libro". Este artículo es la contracara del anterior, ya que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro.

Así como la posesión y la tenencia de una cosa generan derechos a quien ejerce la relación de poder, como contrapartida también existen deberes que hay que respetar mientras se mantenga la relación con esa cosa.

b.1) *Obligación de restituir*

Tanto el poseedor como el tenedor pueden tener la obligación de restituir la cosa sobre la que ejercen el poder de hecho. Así, por ejemplo, el usufructuario tiene que devolverle la cosa al dueño acabado el usufructo (art. 2150); el dueño sujeto a resolución debe restituirla al dueño anterior; el locatario debe restituir al locador, etcétera. No siempre existirá el deber de restituir en la posesión, ello dependerá del tipo de derecho que se ejerza, y de la calidad del poseedor. En cambio, cuando se trata de la tenencia, siempre existe esa obligación (conf. art. 1940, inc. c). Además, cabe recordar que en el caso de los titulares de derechos reales sobre cosa ajena (v. gr.: usufructo, anticresis, etc.), cuando se extingue el derecho se convierten en tenedores, salvo que intervengan el título. A veces la obligación no es estrictamente de restituir sino de dar la cosa a quien no la tuvo antes, como sucede con la obligación del fiduciario de transmitírsela al fideicomisario, acabado el fideicomiso (art. 1698).

La obligación de restituir existe aun cuando "no se haya contraído obligación al efecto". Ocurre que este deber es inherente a la pose-

sión o a la tenencia, al margen de cualquier contratación. Así, por ejemplo, quien encuentra una cosa perdida está obligado a devolverla (art. 1955).

b.2) *Cargas reales que afectan a la cosa*

El hecho de que la cosa se encuentre gravada con un derecho real, como servidumbre o hipoteca, impone que quien posea la cosa deba respetarlo. Es una consecuencia del *ius persecuendi* característico de los derechos reales, y de su oponibilidad *erga omnes*. No se trata en estos casos de obligaciones reales, ni siquiera de obligaciones, sino de cargas reales, esto es el derecho real sobre cosa ajena visto desde el lado pasivo, esto es, de quien lo soporta.

b.3) *Medidas judiciales impuestas a la cosa*

Si sobre la cosa pesara alguna medida judicial, ésta debe ser respetada por los poseedores o tenedores de ella. Así, por ejemplo, si se trabó alguna medida cautelar (v. gr., prohibición de innovar, secuestro, etc.). Otro caso podría darse si un interesado consiguiese una orden judicial que obligase al poseedor a exhibir la cosa mueble. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el capítulo dedicado a las *Diligencias preliminares*, regula la cuestión en el artículo 323, incisos 2º y 4º, y en el artículo 325.

b.4) *Límites al dominio*

Estas restricciones, reguladas en el Capítulo 4, Título III, del Libro Cuarto, son inherentes a la posesión o tenencia de una cosa. Tal como se vio en el punto a, son deberes para unos y derechos para otros, recíprocamente.

c) *Adquisición de frutos o productos según la buena o mala fe*

c.1) *Concepto de frutos y productos. Diferencia*

Dice el artículo 233: "Frutos son los objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia.

"Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza.

"Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra.

"Frutos civiles son las rentas que la cosa produce.

"Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles.

"Productos son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia.

"Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa, si no son separados".

Por su parte, complementa este panorama el artículo 1934, que también alude a las mejoras:

Artículo 1934: "En este Código se entiende por:

"a) fruto percibido: el que separado de la cosa es objeto de una nueva relación posesoria. Si es fruto civil, se considera percibido el devengado y cobrado;

"b) fruto pendiente: el todavía no percibido. Fruto civil pendiente es el devengado y no cobrado..."

En otras palabras, puede decirse que el fruto es una parte de la cosa —no un accesorio, salvo los civiles— que puede ser separada o extraída de ella sin ocasionársele un perjuicio o menoscabo importante. Es fundamental que no se produzca una disminución o alteración de su sustancia. Por ejemplo, la cría de un animal, los frutos de un árbol o una planta, los alquileres de un inmueble, etcétera.

Por el contrario, el producto implica la modificación o menoscabo de la sustancia de la cosa, cuando no su conclusión. Una vez separados, la cosa no los produce, como las piedras sacadas de una cantera, o la madera extraída de un árbol.

c.2) Clasificación de los frutos

El artículo 233 establece la clasificación siguiente:

a) *Frutos naturales*. Son "las producciones espontáneas de la naturaleza", es decir aquellos que se generan sin el hecho del hombre, como la cría de animales, la leche, etcétera, aunque

el hombre intervenga en su separación, organice su producción o explotación, verbigracia, a través de cabañas, procesos de esquila, etcétera.

b) *Frutos industriales*. Son aquellos "que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra". Es indispensable para su generación el actuar del hombre, por ejemplo los cereales.

c) *Frutos civiles*. Son "las rentas que la cosa produce", las que provienen del uso o del goce de la cosa que se ha concedido a otro y también las que provienen de la privación del uso de la cosa, y los salarios del trabajo. A diferencia de los frutos naturales e industriales, que son parte de la cosa conformando con ella un todo, los frutos civiles tienen carácter de accesorios.

c.3) Momento en el que los frutos se entienden legalmente percibidos. Importancia

El artículo 1935 establece que el poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos y los naturales devengados, constituyendo la percepción de ellos un modo legal de adquisición de su dominio. Es así que el artículo 1934 regula desde cuándo se entienden percibidos los frutos, diferenciando los frutos naturales e industriales, que son sometidos a un régimen común, de los frutos civiles.

c.3.1) *Frutos naturales e industriales*

Los frutos naturales e industriales se consideran percibidos desde que se separan de la cosa y pueden ser susceptibles de una nueva relación.

El Código, al decir que el fruto percibido, además de separado, es objeto de "una nueva relación posesoria", se apoya en el Derecho francés, donde para que la percepción tenga lugar no basta con la mera separación, sino que se requiere de la efectiva aprehensión de la cosa por parte del poseedor de buena fe.

En resumen, los frutos naturales o industriales sólo se reputarán percibidos por el poseedor y, consecuentemente, de su propiedad, desde que se separen dentro del período de su posesión y antes de que cese su buena fe (art. 1920).

c.3.2) *Frutos civiles*

El artículo 1934, inciso a, dice que si es "fruto civil, se considera percibido el devengado y cobrado". Por lo tanto, para que el poseedor de buena fe pueda hacer suyos los frutos civiles no basta con que le sean adeudados, sino que es imprescindible que sean percibidos, lo cual acontece desde su cobro real y efectivo.

c.3.3) *Frutos pendientes*

Los frutos pendientes son los aún no percibidos. El artículo 1934, inciso b, establece que los frutos civiles no serán percibidos si están solamente devengados, de modo que descarta la percepción por día, lo cual significa que los frutos devengados durante el período de posesión de buena fe, que no fueron percibidos al tiempo de la restitución, son frutos pendientes y, por lo tanto, pertenecen al dueño de la cosa y no al poseedor (art. 1935).

c.4) *Buena fe y percepción de frutos*

Prevé la primera parte del artículo 1935: "La buena fe del poseedor debe existir en cada hecho de percepción de frutos; y la buena o mala fe del que sucede en la posesión de la cosa se juzga sólo con relación al sucesor y no por la buena o mala fe de su antecesor, sea la sucesión universal o particular".

Este artículo se aparta de la regla general que establece que la buena fe se determina en el origen de la relación (art. 1920).

c.4.1) *Sucesión universal*

Acaecida la muerte del poseedor, el heredero continúa la persona del causante, y la posesión se le transmite. Por ello, si se trata de sucesión a título universal, la buena o mala fe de la posesión se determina por la condición del causante, cualquiera que sea la posesión del sucesor (art. 1901).

La regla expuesta no rige en materia de percepción de frutos, donde la buena o mala fe se determina en cada acto de percepción, aunque se trate de una sucesión universal.

c.4.2) *Sucesión particular*

En lo que respecta a la percepción de frutos, que es lo que trata el artículo 1935, la buena o mala fe se determina en cabeza del sucesor, cualquiera sea la calificación del antecesor. Si ésta es la solución cuando se trata de la sucesión universal, con mayor razón debe imponerse en los supuestos de adquisiciones derivadas.

c.5) *Restitución y adquisición de frutos*

El artículo 1935 estipula que "...El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos y los naturales devengados no percibidos. El de mala fe debe restituir los percibidos y los que por su culpa deja de percibir. Sea de buena o mala fe, debe restituir los productos que haya obtenido de la cosa.

"Los frutos pendientes corresponden a quien tiene derecho a la restitución de la cosa".

Este artículo regula la suerte de los frutos y productos con relación al poseedor que debe restituir la cosa en caso de reivindicación triunfante.

Los frutos *pendientes*, industriales o civiles, pertenecen al que reivindica o tiene derecho a la restitución. Con respecto a los frutos naturales pendientes hace una distinción: si se devengaron, pertenecen al poseedor de buena fe, lo que no ocurre con los otros frutos, en los que resulta indiferente si se devengaron o no.

En todos los casos el poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos.

Antes de que se separen los frutos naturales e industriales integran la cosa, son parte de ésta, con el carácter de frutos *pendientes*. Por lo tanto, como la cosa pertenece a su dueño y en este estadio los frutos no se diferencian de ella, pues constituyen un todo, sin que pueda hablarse de lo principal y de lo accesorio, los frutos pendientes corresponden al propietario reivindicante.

Ahora bien, luego de ser levantados o separados los frutos cobran individualidad jurídica y pueden ser objeto de apropiación por una persona distinta del dueño de la cosa que les dio origen. Por lo tanto,

recién una vez separados, es decir percibidos, los frutos naturales e industriales pertenecen al poseedor de buena fe.

No obstante, en el caso de los frutos naturales *devengados*, el Código establece una excepción, otorgándoselos al poseedor de buena fe aun cuando no los hubiese percibido.

El poseedor de *mala fe* debe restituir los percibidos, y tampoco tiene derecho a los naturales devengados y no percibidos. Aunque la norma no lo dice, si los frutos ya no se encontraren en su poder, debe pagar su valor.

Además, es responsable de los que por su culpa se dejó de percibir. La norma se refiere a los frutos dejados de percibir (no a los pendientes), o sea a aquellos que la cosa dejó de producir por culpa o negligencia del poseedor de mala fe.

c.6) Cesación de la buena fe

Hay que recordar que la buena fe debe existir en cada acto de percepción (art. 1935) y que, según el artículo 1920, la citación al juicio determina la mala fe. Por ende, si el sujeto comenzó siendo de buena fe y con derecho a los frutos percibidos, una vez que sea notificado de la demanda, estará obligado a devolver los frutos que perciba a partir de ese momento.

c.7) Productos

Los productos obtenidos deben ser restituidos por el poseedor, aunque sea de buena fe.

A diferencia de los frutos, que son aquellos que la cosa produce de manera regular y periódica, sin alteración ni disminución de su sustancia, los productos implican la modificación o menoscabo de ella, cuando no la conclusión de la cosa. Los productos son los objetos que se separan o se sacan de ella y que una vez separados, la cosa no los produce.

c.8) Tenedor

Si bien el artículo 1935 está dentro del capítulo que alude a las relaciones de poder, su texto sólo se refiere al poseedor. Esto es lógico

ya que se trata de efectos propios de la posesión de buena fe y porque la norma está pensada para el supuesto de una reivindicación triunfante.

De todos modos, no es posible descartar su aplicación. En el caso de que un tenedor deba restituir la cosa, las soluciones previstas para el poseedor podrían serle aplicadas por analogía si se dieran las condiciones. Así, por ejemplo, podría ocurrir que alguien sea arrendatario de un campo de manera ilegítima, pero de buena fe.

d) Responsabilidad por destrucción de la cosa según la buena o mala fe

Este problema está previsto en el artículo 1936, cuyo texto establece que "El poseedor de buena fe no responde de la destrucción total o parcial de la cosa, sino hasta la concurrencia del provecho subsistente. El de mala fe responde de la destrucción total o parcial de la cosa, excepto que se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución.

"Si la posesión es viciosa, responde de la destrucción total o parcial de la cosa, aunque se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución". Aquí se analiza cuál es la situación del poseedor que debe restituir cuando la cosa sufrió una destrucción total o parcial.

d.1) Irresponsabilidad del poseedor de buena fe por la destrucción total o parcial de la cosa

El artículo 1936 sienta el principio de que el poseedor de buena fe no responde por la destrucción o deterioro de la cosa.

No responderá por hechos que sean el ejercicio regular del derecho de propiedad, pero sí deberá hacerlo cuando se advierta una conducta dolosa, o al menos abusiva.

d.2) Excepción a la regla de la irresponsabilidad

La regla de la irresponsabilidad no es absoluta, ya que hay que valorar la conducta del poseedor de buena fe. Además, el artículo 1936 admite otra excepción, que se configura cuando hubiese obtenido algún provecho, valor que determinará el límite hasta el que deberá

responder, aun cuando el daño sufrido por el dueño sea mayor. Eso surge claramente de la expresión "sino hasta la concurrencia del provecho subsistente", lo que significa una limitación de la responsabilidad.

En suma, si no obtuvo provecho alguno no responde. Si obtuvo algún provecho, responde hasta el límite determinado por tal beneficio.

d.3) Responsabilidad del poseedor de mala fe

d.3.1) Mala fe simple

El poseedor de mala fe es responsable del daño que le cause al propietario. Obviamente, responde de la destrucción total o parcial causada por un hecho suyo, por culpa o dolo, aun cuando no hubiese obtenido ningún provecho de la cosa. Esto es así porque se aplican los principios generales, según los cuales el deudor obligado a dar debe cuidar la cosa con diligencia (arts. 746 y cons.).

La norma no lo dice, pero puede interpretarse que no responde si el daño ocurrió por caso fortuito.

El artículo 1936 establece una excepción que le permite liberarse de responsabilidad si el deterioro "se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución". Así, por ejemplo, si la cosa se destruyó por una inundación, un huracán o un terremoto, y lo mismo le habría ocurrido si hubiese estado en poder del propietario.

La situación del poseedor de mala fe simple es menos grave que la del poseedor *vicioso*, para quien no rige esta exención (art. 1936, último párrafo).

e) Transmisión de obligaciones al sucesor

El tema es considerado por el artículo 1937: "El sucesor particular sucede a su antecesor en las obligaciones inherentes a la posesión sobre la cosa; pero el sucesor particular responde sólo con la cosa sobre la cual recae el derecho real. El antecesor queda liberado, excepto estipulación o disposición legal".

e.1) Obligaciones reales

MNR

Las obligaciones así llamadas se pretende que sean o, mejor, constituyan una situación intermedia entre los derechos reales y los personales, tomando de estos últimos el contenido del vínculo y de los primeros la circunstancia de que tal vínculo no se establece entre personas determinadas, sino entre quienes revisten la calidad de titulares de una relación de derecho real o posesoria respecto de alguna cosa, tanto en el aspecto activo (acreedor) como pasivo (deudor).

A estas obligaciones se las denomina *propter rem* porque van adheridas en la cosa: es la titularidad de ésta la que designa al sujeto pasivo de la deuda, y cuando aquélla cambia por pasar la cosa a un nuevo titular, cambia también el deudor, que pasa a serlo el nuevo titular. También se las llama *ambulatorias*.

e.2) Responsabilidad del deudor

En las obligaciones reales el deudor se libera con la enajenación y el abandono. La obligación ambula con la cosa.

En cuanto a la garantía, por regla, en las obligaciones, el deudor responde frente a ellas con todo su patrimonio. Dice el artículo 242 que "Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este Código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley sólo tienen por garantía los bienes que los integran". Completa esta idea el artículo 743.

Sin embargo, en el caso de estas obligaciones inherentes a la posesión, se establece que el sucesor no responde con todo su patrimonio sino, únicamente, "con la cosa sobre la cual recae el derecho real". El caso típico es el de las expensas en la propiedad horizontal, ya que el sucesor de quien no las pagó se encuentra también obligado (art. 2049), pero responde sólo con la unidad adquirida, por aplicación del artículo 1937.

Dice finalmente el artículo 1937 que el antecesor queda liberado, "excepto estipulación o disposición legal". Justamente, en el caso de las expensas, el artículo 2049 aclara que no hay liberación por el

abandono. Tampoco se libera el condómino que renuncia respecto de los gastos de conservación a los que estaba obligado (art. 1991). En cuanto a lo que estipulen las partes, ello no afecta a terceros.

f) *Indemnización y pago de mejoras*

f.1) *Mejoras. Concepto*

El Código contiene las siguientes normas:

- Artículo 751: "Mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Las mejoras pueden ser naturales o artificiales. Las artificiales, provenientes de hecho del hombre, se clasifican en necesarias, útiles y de mero lujo, recreo o suntuarias".
- Artículo 752: "La mejora natural autoriza al deudor a exigir un mayor valor. Si el acreedor no lo acepta, la obligación queda extinguida, sin responsabilidad para ninguna de las partes".
- Artículo 753: "El deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias, sin derecho a percibir su valor. No tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles ni por las de mero lujo, recreo o suntuarias, pero puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa".

El artículo 1934 complementa el cuadro:

- "c) mejora de mero mantenimiento: la reparación de deterioros menores originados por el uso ordinario de la cosa;
- "d) mejora necesaria: la reparación cuya realización es indispensable para la conservación de la cosa;
- "e) mejora útil: la beneficiosa para cualquier sujeto de la relación posesoria;
- "f) mejora suntuaria: la de mero lujo o recreo o provecho exclusivo para quien la hizo".

Mejoras necesarias. Son aquellas sin las cuales la cosa no podría ser conservada, es decir sin cuya realización la cosa se hubiere deteriorado o perdido, por ejemplo: reparaciones de muros, techos, cañerías, etcétera. Son indispensables.

Mejoras útiles. Se trata de aquellas que son de manifiesto provecho para cualquier poseedor de la cosa. Estas mejoras redundan, por lo

general, en un incremento del valor o renta de la cosa, por ejemplo: instalación de servicios, realización de cocheras, rellenado de terrenos, escurrimiento de aguas, etcétera.

Mejoras suntuarias. Son las de mero lujo o recreo, o de exclusiva utilidad para el que las hizo. Estas mejoras también son denominadas voluptuarias, ya que no contribuyen a la conservación de la cosa ni incrementan su valor o renta, sino que sólo sirven para adorno, lucimiento o recreo, por ejemplo: cierto tipo de decoración o pinturas.

Además, se agregan las de *mero mantenimiento*, que son la reparación de deterioros menores (v. gr.: limpieza de un filtro).

f.2) *Indemnización*

Prevé el artículo 1938 que "Ningún sujeto de relación de poder puede reclamar indemnización por las mejoras de mero mantenimiento ni por las suntuarias. Estas últimas pueden ser retiradas si al hacerlo no se daña la cosa. Todo sujeto de una relación de poder puede reclamar el costo de las mejoras necesarias, excepto que se hayan originado por su culpa si es de mala fe. Puede asimismo reclamar el pago de las mejoras útiles pero sólo hasta el mayor valor adquirido por la cosa. Los acrecentamientos originados por hechos de la naturaleza en ningún caso son indemnizables".

Como se puede apreciar, esta norma se refiere al "sujeto de relación de poder". Por ende, abarca su texto tanto a poseedores como tenedores. Claro que al estar pensada para el supuesto de una reivindicación triunfante, en el caso de existir un vínculo contractual habrá que atenderse a lo que las partes hayan pactado.

g) *Efectos propios de la posesión*

El Código, luego de tratar efectos comunes a las relaciones de poder, menciona algunos que son exclusivos de la posesión. En efecto, dice el artículo 1939 que "La posesión tiene los efectos previstos en los artículos 1895 y 1897 de este Código.

"A menos que exista disposición legal en contrario, el poseedor debe satisfacer el pago total de los impuestos, tasas y contribuciones que graven la cosa y cumplir la obligación de cerramiento".

La posesión, esté acompañada o no del derecho real, por sí sola produce importantes efectos. El artículo 1939 menciona dos: la adquisición legal de cosas muebles no hurtadas ni perdidas, y la posibilidad de adquirir el derecho real por usucapión. En las normas anteriores de este mismo capítulo se vieron otros, tales como la posibilidad de hacer propios los frutos percibidos, el derecho al reembolso de ciertas mejoras, etcétera. También cabe mencionar la posibilidad de defenderse a través de la defensa extrajudicial, y de las acciones posesorias.

g.1) *Pago de impuestos y otros deberes*

El artículo 1939 dispone que, salvo disposición legal en contrario, el poseedor debe atender los impuestos, tasas y contribuciones. Es lógico que quien aprovecha de la cosa deba atender estas obligaciones. Se trata de los impuestos territoriales y otras contribuciones que tienen su asiento —generalmente— en una cosa inmueble. Esta norma no se refiere a los tributos devengados durante la posesión de un antecesor (de lo que se ocupa el art. 1937), sino a los devengados durante la posesión del obligado.

También establece el artículo 1939 que el poseedor debe cumplir con la obligación de cerramiento. Por ende, se puede interpretar que aun sin ser dueño o titular de un derecho real, debe afrontar el pago de lo que corresponda. Claro que podría luego recuperarlo, al tratarse de una mejora necesaria (art. 1938).

Además, el artículo 2050 impone el pago de las expensas en propiedad horizontal a quienes sean poseedores por cualquier título.

h) *Efectos propios de la tenencia*

El Código, en algunas normas, trata en forma conjunta a la posesión y a la tenencia, en otras regula efectos propios de la posesión, y en el artículo 1940 se enuncian efectos propios de la tenencia. Del texto legal se desprenden deberes, pero también derechos.

Dice esta norma que "El tenedor debe:

"a) conservar la cosa, pero puede reclamar al poseedor el reintegro de los gastos;

"b) individualizar y comunicar al poseedor de quien es represen-

tante si se lo perturba en razón de la cosa, y de no hacerlo, responde por los daños ocasionados al poseedor y pierde la garantía por evicción, si ésta corresponde;

"c) restituir la cosa a quien tenga derecho a reclamarla, previa citación fehaciente de los otros que la pretenden".

h.1) *Deber de conservar la cosa*

El tenedor ejerce sobre la cosa un poder de hecho limitado por la voluntad de aquel a cuyo nombre posee y, claro está, por los términos y régimen del acto jurídico que dio origen a la tenencia. Además, pesa sobre el tenedor, desde el nacimiento de la relación con la cosa, el deber de restituirla al poseedor.

Consecuentemente, a fin de dar cabal cumplimiento a tales obligaciones, debe conservar la cosa de acuerdo a la naturaleza de la relación material y dentro de los límites trazados por el título en virtud del cual se constituyó tenedor, de tal manera de evitar su deterioro y destrucción.

h.2) *Derecho a ser indemnizado por gastos y mejoras necesarias*

El tenedor tiene derecho a ser reembolsado por los gastos o mejoras que, indispensables para el buen mantenimiento de la cosa, hubiese tenido que afrontar (art. 1938). Se trata de aquellas erogaciones imprescindibles para evitar el deterioro o pérdida de la cosa; en resumen: de aquellos gastos que el propietario fatalmente hubiera tenido que realizar y sin los cuales la cosa no hubiera podido ser conservada.

Consecuentemente, si al tenedor le es impuesto el deber legal de conservación, es justo reconocerle, como contracara, el derecho a ser resarcido de los gastos necesarios. Ello claro está, siempre y cuando tales gastos no hayan sido originados por su culpa (arg. art. 1938), y de que no se haya pactado otra cosa en el contrato.

h.3) *Derecho de retención*

Asimismo, ante la negativa del poseedor de pagar los mentados gastos o mejoras, el tenedor tendrá derecho a retener la cosa hasta ser indemnizado.

h.4) *Deber de nombrar al poseedor*

Dado que el tenedor representa la posesión de otro, cuando fuere demandado en razón de la cosa cuya tenencia ejerce (v. gr., por reivindicación), deberá denunciar al verdadero poseedor. También debe comunicar al poseedor cualquier perturbación.

Por su parte, el artículo 2255, en armónica vinculación con este precepto, establece que si la reivindicación fuera dirigida contra el tenedor, éste no estará obligado a responder la acción si denuncia el nombre y domicilio del poseedor, de manera tal que el demandante pueda enderezar la acción contra él y, por otra parte, para permitirle al poseedor defenderse.

Además, el artículo 1940 sanciona la omisión cercenándole la posibilidad de reclamar por evicción al poseedor.

A su vez, puede ser condenado, consiguientemente, a resarcir los perjuicios que sufra el poseedor al que representa.

h.5) *Deber de restitución*

El deber de restitución deriva de la propia naturaleza de la figura, pues el tenedor, al reconocer en los hechos, sobre la cosa que detenta, una potestad o señorío superior de otro sujeto, debe necesariamente concluirse, por lógica consecuencia, que está obligado a devolverla al verdadero poseedor. La obligación de restituir es característica de la tenencia.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DE LAS COSAS MUEBLES

MNR

SUMARIO: I. El artículo 1895 del Código Civil y Comercial. Ámbito de aplicación. II. Naturaleza jurídica de la adquisición. III. Requisitos. IV. Excepciones. V. Reivindicación de cosas hurtadas o perdidas. VI. Régimen de las cosas muebles registrables. VII. Prescripción.

I. El artículo 1895 del Código Civil y Comercial. Ámbito de aplicación

Dice el artículo 1895: "*Adquisición legal de derechos reales sobre muebles por subadquirente*. La posesión de buena fe del subadquirente de cosas muebles no registrables que no sean hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir los derechos reales principales excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita.

"Respecto de las cosas muebles registrables no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca.

"Tampoco existe buena fe aunque haya inscripción a favor de quien la invoca, si el respectivo régimen especial prevé la existencia de elementos identificatorios de la cosa registrable y éstos no son coincidentes".

Aquí se trata la situación del subadquirente de cosas muebles en las transmisiones a *non domino*.

Esta norma se aplica a los subadquirentes de cosas muebles no registrables, aunque sienta pautas para determinar la buena fe cuando se trata de cosas muebles registrables. Teniendo en cuenta que el artículo 392, si bien para inmuebles y cosas muebles registrables, en su última parte dispone que "Los subadquirentes no pueden ampararse

en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho", lo que reitera el artículo 2260, cabe inferir que se aplica este precepto a los casos de "desprendimiento voluntario", esto es, casos en los que el propietario de la cosa intervino, aun cuando su voluntad haya estado viciada o haya mediado alguna irregularidad. Si el titular del derecho real ni siquiera participó, el acto le sería inoponible y quedaría fuera de este sistema. Es que si no participó, se entra en la hipótesis de hurto o robo, que el artículo 1895 deja afuera. Lo mismo cabe decir si la cosa fue perdida, ya que no hubo desprendimiento voluntario del titular.

El ejemplo clásico es el siguiente: A, dueño de un libro, se lo presta a B. B, en lugar de devolverlo, se lo vende a C, quien ignora que el libro era de A y estaba convencido de adquirir correctamente. Planteado el conflicto entre A y C, el Código protege al segundo, para garantizar la seguridad dinámica. En efecto, la norma analizada sólo es aplicable cuando el propietario de la cosa mueble voluntariamente la entrega a quien, traicionando su confianza y comportándose como si fuese su dueño, la transmite; ello, en virtud de la apariencia que se crea por estar en contacto con la cosa.

Es claro que el verdadero propietario podía intentar una acción de carácter personal *ex contractu* contra aquel a quien le confió la tenencia de la cosa mueble. Pero cuando ésta es transmitida por quien estaba obligado a restituir (abuso de confianza) a un tercero de buena fe, se plantea un conflicto entre dos intereses incompatibles entre sí, y, en principio, tan dignos de protección el uno como el otro. Frente a esta coyuntura, la ley se ve obligada a tomar una difícil decisión: optar por el verdadero propietario, respetando a todo evento su dominio, o tomar partido en favor del tercero de buena fe, atribuyéndole la propiedad de la cosa mueble y sacrificar así el derecho del anterior propietario. El sistema romanista conduce a la protección del verdadero propietario en tanto no se haya operado la usucapión en favor del actual poseedor. En cambio, para el supuesto de desprendimiento voluntario, el Código sigue el sistema francés, optando por favorecer la situación del tercero adquirente de buena fe.

La adquisición de la propiedad por el tercero implica la pérdida simultánea del dominio por el anterior dueño, quien tendrá contra aquel

a quien había confiado la cosa, las acciones civiles correspondientes por haberla enajenado indebidamente.

El artículo 1895 se hace cargo de la particular dificultad que en la vida real encuentra el dueño para demostrar, documentación mediante, la adquisición de cosas muebles, de ahí que la posesión de buena fe hace adquirir la propiedad. Cabe aclarar que, como se verá más adelante, para repeler la acción reivindicatoria es necesario que el tercero, además de poseer de buena fe, haya adquirido a título oneroso.

Dice el artículo 1895 que las cosas no deben ser hurtadas o perdidas. Si se trata de cosas muebles robadas, hurtadas o perdidas, el subadquirente de buena fe puede adquirirlas por prescripción breve al cabo de dos años (arts. 1898 y 2254). Si carece de buena fe, cabe inferir que podrá adquirir luego de 20 o de 10 años de posesión, según el caso (art. 1899).

La ley tiende a proteger la buena fe de los terceros hasta el punto de convertirlos en dueños, por fuerza de las circunstancias. El fundamento de esta norma, relativa a cosas muebles, no es otro que la protección del tráfico y de la buena fe. El comprador lo hace de buena fe. Está convencido de que le compra al dueño. Si no es así, está frente a un error invencible. Es un error que cualquiera cometería. Se acepta la tesis de que el error común hace derecho. Ese error lo habría cometido cualquiera, por diligente que hubiera sido: es error común que merece protección.

II. Naturaleza jurídica de la adquisición

Dice el artículo 1895 que se trata de una adquisición legal (atribución de propiedad *ministerio legis*), pues su enfática redacción quiere significar con su firmeza el atribuir directamente por la norma, la propiedad al poseedor. Es la ley —por razones de conveniencia económica y de seguridad en las transacciones— la que hace que el adquirente de buena fe que se encuentra en posesión de la cosa, adquiera la propiedad de ella y pueda repeler cualquier acción de reivindicación del antiguo propietario, no obstante haberla recibido de quien no era el dueño.

La adquisición que realiza el tercero no es derivada sino originaria, ya que no se basa en el contrato que lo liga con el enajenante *non*

domino sino en la voluntad de la ley. Hay que tener en cuenta que ningún vínculo jurídico existe entre el tercero y el anterior dueño; por el contrario, el tercero adquiere contra o a pesar de la voluntad de dicho dueño.

III. Requisitos

El artículo 1895 protege a quienes adquieren cosas muebles de parte de quien no se encuentra legitimado, por no ser propietario (*a non domino*), o que siéndolo, no estaba legitimado para transmitir válidamente la propiedad al estar su título subordinado a una acción de nulidad, resolución, etcétera.

Como consecuencia de lo establecido en dicha norma, las acciones de resolución, nulidad, simulación, petición de herencia, etcétera, a las que pudiere verse sometido el precedente poseedor, no se proyectan contra el actual poseedor de buena fe. Así, por ejemplo, si una persona obtiene la propiedad de una cosa mueble en virtud de un acto anulable (v. gr.: por vicio de error), la acción de nulidad que intente el anterior dueño no puede afectar a un tercero adquirente de buena fe. Ocurre que en este caso también hubo un desprendimiento voluntario, por lo que el artículo 1895 resulta plenamente aplicable. La regla, como puede apreciarse en este ejemplo, alcanza su máxima expansión, ya que en este caso el reivindicante ni siquiera confió en la persona que obtuvo la cosa y luego la transmitió a un tercero, como sí ocurre en el ejemplo clásico del abuso de confianza.

El hecho común a todas estas situaciones que pueden presentarse, aunque con diversos matices, reside en el llamado "desprendimiento voluntario". En todos los casos habrá que analizar si el dueño que pretende recuperar de un tercero, intervino o no en la transmisión original.

Para que el tercero adquirente pueda invocar el principio que se desprende del artículo 1895, deben ser satisfechos ciertos requisitos.

a) Posesión

El tercero, para poder invocar la regla emergente del artículo 1895 en los supuestos de desprendimiento voluntario, debe ser poseedor de

la cosa mueble; los tenedores no pueden prevalerse de este sistema. Quien adquiera del no propietario la mera tenencia no tiene un título idóneo para adquirir la propiedad; además, reconoce el poder preferente de otro sobre la cosa.

Esta adquisición legal es uno de los efectos de la posesión (art. 1939). Del artículo 1911 surge una presunción *iuris tantum* de la existencia de la posesión, de manera que quien pretenda desconocer la calidad de poseedor tendrá que probarlo.

Además, cabe aplicar el principio sentado por el artículo 1895 a quienes hayan adquirido la posesión por cualquiera de los modos previstos por el Código, aun en los casos de *traditio brevi manu* y de *constituto posesorio*.

La posesión a la que se refiere el artículo 1895, que permite generar la adquisición legal del derecho real, puede ser aplicada a la adquisición de otros derechos reales y no sólo a la del dominio. Así, por ejemplo, si una persona adquiere de buena fe el usufructo de un reloj, de parte de quien no estaba legitimado, puede también invocar la regla emergente de dicha norma y conservar el usufructo. Si se puede adquirir el dominio, que es el derecho real más fuerte, con mayor razón hay que admitir que la misma regla debe servir para la adquisición de los derechos reales limitados. Además, el dominio no es el único derecho real que se ejerce por la posesión.

No obstante, cabe aclarar que el artículo 1895 se refiere a "los derechos reales principales", aunque parece haber una contradicción, el artículo 760.

b) Buena fe

La buena fe es otro de los requisitos que debe reunir el tercero para poder invocar la regla emergente del artículo 1895 y así repeler la acción reivindicatoria, o de nulidad, o de resolución, que intente el anterior propietario. La buena fe del poseedor es una exigencia claramente compatible con la teoría de la adquisición *a non domino*.

La buena fe también se presume (art. 1919), razón por la cual quien alegue la existencia de mala fe en el poseedor tendrá que demostrarlo.

b.1) Buena fe y cosas muebles registrables

En el caso de las cosas muebles registrables, el artículo 1895 dice que "...no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca. Tampoco existe buena fe aunque haya inscripción a favor de quien la invoca, si el respectivo régimen especial prevé la existencia de elementos identificatorios de la cosa registrable y éstos no son coincidentes".

El que adquiere una cosa mueble registrable sabe que debe inscribir en el Registro su adquisición, ya que el error de derecho no es excusable. Por ende, si no la hace, no puede ser considerado de buena fe.

Además, en ciertos casos debe el adquirente realizar determinadas comprobaciones. Por ejemplo, en el caso de los automotores es necesario verificar la numeración del motor, del chasis, etcétera. Si el sucesor adquiere a pesar de no coincidir los datos, no puede invocar buena fe. Su conducta fue negligente, aun cuando haya inscripto el título a su nombre.

c) Título oneroso

El artículo 1895 exige, además de la posesión y la buena fe, el título oneroso en cabeza del subadquirente, para escapar a la acción reivindicatoria del anterior propietario. Coincide con otras normas del Código, especialmente de los artículos 315, 337, 339, 340, 392, 462, 757, 760, 1079, 1166, 1705, 1819, 2260, 2283, 2315. Aquí juega el principio del enriquecimiento sin causa en virtud del cual se entiende que debe protegerse al que se empobrece y no al que se enriquece.

Cabe entender que quienes sean poseedores de buena fe, aun cuando hayan adquirido a título gratuito, gozan de la atribución de propiedad que establece dicho precepto. Pero, a efectos de poder repeler la acción reivindicatoria del anterior propietario, se requiere también que haya mediado una adquisición a título oneroso. El artículo 1895 dice "excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita". Es una excepción a la regla. Por ende, el poseedor de buena fe adquirió el derecho real, pero si el anterior dueño demuestra que la adquisición fue gratuita, cae la regla.

Se advierte que el Código presume la adquisición a título oneroso, teniendo en cuenta que la carga de la prueba recae sobre el verdadero propietario que reivindica.

d) Cosa mueble no hurtada ni perdida

En el caso de que la cosa sea hurtada o perdida (cabe incluir también al robo), esto es, que el propietario no se haya desprendido de ella voluntariamente, los terceros no gozan de la propiedad y no pueden repeler la acción reivindicatoria —al menos, mientras no se opere la prescripción adquisitiva—, aun cuando sean de buena fe y a título oneroso.

La diferencia con el caso examinado anteriormente radica en que no puede imputársele culpa al propietario por haber perdido o por haber sufrido el robo de la cosa mueble, dado que él no intervino en la transmisión (v. gr.: no se la entregó al ladrón), no ha mediado un desprendimiento voluntario sino forzoso, contra su voluntad. La solución del artículo concuerda con sus antecedentes históricos, en los cuales se admitió siempre la reivindicación cuando la cosa era robada o perdida. Las cosas robadas o hurtadas salen del poder del dueño "contra" su voluntad.

Cabe reputar como cosas perdidas a las que se extravían por caso fortuito o fuerza mayor, y a las que se pierden por negligencia (v. gr., envío a una dirección equivocada). Salen del poder del dueño "sin" su voluntad. Se puede decir que son cosas perdidas las que presentan las siguientes condiciones: 1) que se haya perdido la tenencia; 2) que la cosa no esté en el lugar en el que la haya guardado el poseedor o tenedor, y 3) que no se haya hecho abandono de esa cosa. Entran en este concepto aquellas que se pierden por caso fortuito o fuerza mayor, y también las que se extravían por negligencia imputable al poseedor (v. gr.: cosas que son remitidas a una mala dirección).

Vale recordar que quien halla una cosa perdida está obligado a restituirla, y únicamente tiene derecho a una recompensa (arts. 1955/1956). Si el hallador decide quedarse con la cosa estará expuesto a la reivindicación del verdadero propietario, y si decide enajenarla, también lo estarán los sucesivos subadquirentes (art. 2259).

Las cosas perdidas no deben ser confundidas con las abandonadas, cuyo dominio puede ser adquirido por apropiación (art. 1947, inc. a). En caso de duda, el Código presume que la cosa ha sido perdida, y no abandonada, si tiene algún valor (art. 1947, inc. b, i).

IV. Excepciones

a) *Dominio público*

Cabe entender, aunque la norma no lo dice, que el régimen del artículo 1895 no se refiere a aquellas cosas muebles que pertenezcan al dominio público del Estado (nacional o provincial), por ser éstas inalienables, inembargables, imprescriptibles (art. 237) y, sobre todo, porque no pueden ser poseídas. Así, por ejemplo, los libros de una biblioteca pública, las cosas exhibidas en un museo.

En cambio las que pertenezcan al dominio privado del Estado (art. 236) no caen dentro de dicha excepción, dado que se rigen por las normas del Derecho Privado, al igual que si pertenecieran a los particulares.

b) *Accesorios de un inmueble reivindicado*

Si el titular de un inmueble debe sufrir por alguna razón la reivindicación, no puede pretender quedarse con las cosas muebles accesorias a dicho inmueble escudándose en el régimen emergente del artículo 1895. A la inversa, no es posible reivindicar las cosas muebles accesorias si no se reivindica también el inmueble (art. 2253).

Ello es así por dos razones: 1) las cosas accesorias deben seguir la suerte de lo principal (art. 230); en este caso, el inmueble reivindicado; 2) tales cosas muebles accesorias habrían dejado de ser tales para convertirse en inmuebles por accesión física (arts. 226 y 2192).

Claro que, como advierte la doctrina, si tales cosas accesorias se separan del inmueble reivindicado, recobran su carácter de cosas muebles, así como el de cosas principales, y sería aplicable respecto de ellas lo dispuesto en el artículo 1895, en tanto dicha separación no hubiese sido indebidamente realizada.

c) *Cosas muebles registrables*

Esta clase de cosas, entre las cuales se encuentran los automotores, los buques, las aeronaves, los semovientes y los caballos de pura sangre de carrera, cuentan con un régimen específico que las sustrae

del principio establecido por el artículo 1895. Este último dice, en su primer párrafo, que se refiere a las cosas muebles no registrables.

d) *Cosas hurtadas, perdidas o abandonadas*

Se advirtió anteriormente que las cosas hurtadas (también las robadas) o perdidas están excluidas del sistema previsto por el artículo 1895. En cuanto a las cosas abandonadas por su dueño, o aquellas que directamente carecen de dueño, el artículo 1895 es innecesario habida cuenta de que el dominio de tales cosas se adquiere por apropiación (ver art. 1947). Cabe también recordar que los tesoros cuentan con un régimen especial (arts. 1951/1954).

e) *Muebles del hogar conyugal o convivencial*

Establece el artículo 462 del Código Civil y Comercial que "Los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por éste con terceros de buena fe, son válidos, excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión.

"En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad dentro del plazo de caducidad de seis meses de haber conocido el acto y no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial". En armonía, dice el artículo 456: "Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial..."

Una situación similar se presenta en el caso de las uniones convivenciales (ver arts. 518 y 522).

f) *Las universalidades*

El artículo 1895 requiere, entre otros recaudos, la posesión, y lo cierto es que la posesión tiene por objeto la cosa determinada (art. 1912). Si se trata de una universalidad de hecho (un rebaño), la atribución legal del derecho de propiedad emergente del artículo 1895 deberá ser valorada con relación a cada cosa individualmente. Si se trata de una universalidad jurídica, se advierte que el heredero ocupa el lugar del causante, de modo que si a éste no lo ampara la regla del artículo 1895, tampoco puede ampararlo al sucesor universal.

g) *Títulos valores*

Los títulos valores, aclara el Código, no son cosas muebles registrables (art. 1815); deben regirse por su ley de circulación. Los títulos valores nominativos y a la orden, por exigir endoso o cesión para su transmisión, es decir, que cuentan con un régimen específico, están excluidos del sistema previsto en el artículo 1895.

No obstante, también se protege al tercero de buena fe y a título oneroso, como se desprende de los artículos 1816, 1819, 1824, 1867 y concordantes.

V. *Reivindicación de cosas hurtadas o perdidas*

El tema se desarrollará al tratar en la parte pertinente de este libro las acciones reales.

VI. *Régimen de las cosas muebles registrables*a) *Buques*

El buque es una cosa mueble cuyo régimen especial lo establece la Ley de Navegación (20.094), por lo cual escapa al régimen del artículo 1895.

Dispone el artículo 155 de la ley 20.094 que los buques son bienes registrables, y el artículo 156 que la constitución de derechos reales sobre un buque de diez o más toneladas de arqueado total, debe ser hecha por acto que conste en escritura pública o por documento privado

autenticado. Para los buques menores se prescinde de la escritura pública, ya que es suficiente el instrumento privado con las firmas de los otorgantes certificadas (art. 159).

Contempla la Ley de Navegación una inscripción registral no constitutiva, pues su exigencia es al efecto de hacer oponibles las transmisiones a terceros (arts. 158 y 159).

b) *Aeronaves*

El régimen de las aeronaves lo determina el Código Aeronáutico (ley 17.285). Debe inscribirse en el Registro Nacional de Aeronaves y con ello se les confiere nacionalidad argentina.

Respecto de ellas también se impone la inscripción de los títulos en dicho Registro a efectos de su oponibilidad a terceros, es decir que se trata de una inscripción registral declarativa, no constitutiva. Para poder acceder al Registro se requiere formalizar el acto en instrumento público o privado debidamente autenticado (art. 49).

c) *Automotores*c.1) *Marco legal*

El sistema legal argentino que regula la propiedad del automotor está integrado por un conjunto complejo de normas de diversa jerarquía. Aquí interesa principalmente el sistema registral organizado por el decreto-ley 6582/58, ratificado por la ley 14.467 y luego modificado, entre otras normas, por la ley 22.977.

Dispone el artículo 5° que "serán considerados automotores los siguientes vehículos: automóviles, camiones, inclusive los llamados tractores para semirremolque, camionetas, rurales, jeeps, furgones de reparto, ómnibus, microómnibus y colectivos, sus respectivos remolques y acoplados, todos ellos aun cuando no estuvieran carrozados, las maquinarias agrícolas incluidas tractores, cosechadoras, grúas, maquinarias viales y todas aquellas que se autopropulsen. El Poder Ejecutivo podrá disponer, por vía de reglamentación, la inclusión de otros vehículos automotores en el régimen establecido".

Agrega el artículo 6°: "Será obligatoria la inscripción del dominio

en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, de todos los automotores comprendidos en el artículo anterior, de acuerdo con las normas que al efecto se dicten.

"La primera inscripción del dominio de un automotor, se practicará en la forma que lo determine la reglamentación.

"A todo automotor se le asignará al inscribirse en el Registro por primera vez, un documento individualizante que será expedido por el Registro respectivo y se denominará 'Título del Automotor'. Éste tendrá carácter de instrumento público respecto de la individualización del automotor y de la existencia en el Registro de las inscripciones que en él se consignen, pero sólo acreditará las condiciones del dominio y de los gravámenes que afecten al automotor, hasta la fecha de anotación de dichas constancias en el mismo".

La inscripción inicial del vehículo requiere la apertura del "legajo del automotor" (sistema del folio real), con su pertinente matriculación en el registro seccional del lugar de su patentamiento. En este legajo deben figurar todos los datos vinculados al dominio del rodado (propiedad, transmisiones, gravámenes, embargos, etc.). La inscripción inicial importa la emisión de dos documentos: el título, que sirve para probar las condiciones de dominio, y la cédula de identificación, que autoriza el uso.

c.2) *Efecto constitutivo de la inscripción*

Según el artículo 1º: "la transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor"²⁸. Se establece así un sistema registral constitutivo, dado que antes de la inscripción no se constituye o transmite el derecho real. La inscripción no resulta un formalismo sino que atiende al orden social, es una exigencia de orden público que trata de dar seguridad a las transacciones sobre automóviles; es imperativa y la voluntad de los particulares resulta indiferente.

Por aplicación del artículo 14 del decreto-ley 6582/58, para la transferencia de automotores no solamente es necesario presentar los for-

mularios respectivos, sino también el título de propiedad. El encargado debe verificar que las constancias del título de propiedad concuerden con las anotaciones que obren en el registro (art. 15).

Además, para lograr la transferencia es un requisito indispensable la exhibición del rodado para que se realice su verificación, trámite que es previo al patentamiento y a la entrega de las chapas, cédula y título.

c.3) *Carácter abstracto*

Se afirma que la inscripción en el Registro, ya sea en forma inicial o cualquier mutación posterior, tiene efectos jurídicos *per se*, con independencia de la causa o negocio jurídico que le precedió. Para decirlo más claramente, una persona no adquiere el derecho real de dominio porque realizó un contrato de compraventa del automotor —lo que sin duda le atribuirá los derechos personales derivados de dicho contrato—, sino porque inscribió la transferencia en el Registro correspondiente.

Otros autores no comparten esta interpretación. Sostienen que aunque la inscripción reemplaza a la tradición, ello no implica suprimir el requisito del título suficiente válido, pudiendo ser impugnado si adolece de algún vicio, de modo que no hay desvinculación de la causa (Moisset de Espanés, Mariani). Claro que los efectos de la nulidad se limitarán a las partes del acto viciado, sin afectar a terceros de buena fe que tuviesen su propio título inscripto.

c.4) *Adquisición del derecho real*

Establece el artículo 2º del decreto-ley 6582/58 que "La inscripción de buena fe de un automotor en el registro confiere al titular de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si el automotor no hubiese sido hurtado o robado".

Si se traslada al campo de los automotores la teoría de la distinción entre el título y el "modo" aplicable a los inmuebles, resulta que el título es ese contrato consensual, ese acuerdo de voluntades, que se puede formalizar por instrumento público o privado (art. 1º), mientras que el modo lo constituye la "inscripción registral", en lugar de la

tradicón prevista para las cosas inmuebles. Así lo sostuvo cierta doctrina, y esto dice expresamente el artículo 1892, cuarto párrafo, del actual Código Civil y Comercial. El citado artículo 2° sustituye la posesión del artículo 1895 por la inscripción. Dicho artículo 2° no menciona a las cosas perdidas, ya que es difícil o imposible concebir la pérdida de un automotor.

Esta norma funciona también en protección de subadquirentes de buena fe y a título oneroso, cuando el automotor fue enajenado por quien el dueño lo había confiado. Si el propietario entrega la cosa voluntariamente o mediante una negociación de compraventa y quien la recibe, la vende a un tercero de buena fe, ya no tiene lugar la acción reivindicatoria, debiendo resolverse la cuestión por medio de acciones personales del propietario contra quien abusó de su confianza. Tal como se señaló al analizar el artículo 1895, debe mediar "desprendimiento voluntario" para que funcione la protección prevista en el citado artículo 2°.

Deben darse ciertos requisitos: 1) inscripción registral a favor del subadquirente; 2) buena fe; 3) título oneroso; 4) que el rodado no sea hurtado o robado.

La ley no exige el título oneroso, sin perjuicio de lo cual el sistema del decreto 6582/58 debe ser integrado con las normas del Código Civil y Comercial, en tanto no se encuentren modificadas por disposiciones específicas. Lo cierto es que este recaudo se desprende de los artículos 392 y 2260, entre los más importantes.

En cuanto a la exigencia de buena fe, cabe advertir que la falta de inscripción registral a nombre del poseedor, importa su mala fe (art. 1895, segundo párrafo), pues es exigible del adquirente una investigación sobre la situación jurídica del objeto; y porque quien adquiere un automotor inscrito a nombre de otro sujeto distinto del vendedor, no actúa con la diligencia debida al no haber hecho esas averiguaciones que le hubieran permitido descubrir que no podía inscribir a su nombre el vehículo. Además, dicho poseedor no podría alegar con éxito la falta de necesidad de la inscripción, pues su creencia reposaría en un error de derecho, que no resulta excusable (arts. 8°, 1918; 16, decreto 6582/58, texto según ley 22.977). Si no

se inscribe la transmisión, el poseedor carece de modo, y si no tiene modo no puede haber buena fe.

En consecuencia, el adquirente debe obrar con diligencia para ser reputado de buena fe. Esto supone, en primer lugar, que exija al enajenante la exhibición del título y de la cédula de identificación. Pero esto solo no basta, ya que dichos documentos tienen un valor histórico, de modo que debe solicitar en el Registro un certificado (art. 16, decreto-ley 6582/58), del cual surgirán las condiciones de dominio, la existencia de gravámenes, así como todos los datos del rodado y que, además, provoca una reserva de prioridad por el plazo de 15 días. La solicitud de este certificado no es optativa sino obligatoria.

Además, antes de la inscripción registral, el adquirente debe realizar la "verificación física" con el objeto de constatar si coincide el vehículo con las constancias de los documentos (art. 6°, decreto 335/88; disposiciones 469/83 y 420/89, de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios).

Es claro el texto de los artículos 1895 y 1902 en tanto advierten que no basta con la inscripción para que haya buena fe, ya que es menester constatar que coincidan los elementos identificatorios de la cosa.

Si el adquirente es de mala fe, podrá adquirir el derecho real al cabo de diez o de veinte años de posesión, según las circunstancias (art. 1899).

c.5) Automotor hurtado o robado

Si el automotor ha sido hurtado o robado, el adquirente no puede impedir la reivindicación, aun cuando tenga a su favor la inscripción registral y haya adquirido de buena fe y a título oneroso.

Dice el artículo 3° del decreto-ley 6582/58 que "Si el automotor hubiese sido hurtado o robado, el propietario podrá reivindicarlo contra quien lo tuviese inscrito a su nombre, debiendo resarcirlo de lo que hubiese abonado si la inscripción fuera de buena fe y conforme a las normas establecidas por este decreto-ley". Por ende, no se puede impedir la reivindicación. Según las circunstancias, el adquirente de buena fe podrá tener derecho al reintegro de lo que pagó.

Si es de buena fe, podrá repeler la acción reivindicatoria del dueño luego de transcurridos dos años (arts. 4º, decreto-ley 6582/58; 1898 y 2254, Cód. Civ. y Com.). Es la usucapión *secundum tabulas*. Si es de mala fe, recién al cabo de veinte años (arts. 1897 y 1899); si no hubo inscripción, la usucapión será *contra tabulas*.

Si se ha suprimido la numeración identificatoria y el titular no pudiera ser ubicado, caso de los autos llamados "mellizos", tales autos serían considerados vacantes y de propiedad del Estado.

Estos temas serán examinados nuevamente al tratar la usucapión y las acciones reales.

d) Semovientes

Como se adelantó, su régimen no fluye de los artículos 1895 y concordantes, esto es, que no se considera propietario del animal al poseedor de buena fe, en tanto no fuese hurtado o perdido; tienen un régimen especial. Cuando se trata de ciertos animales, en especial el ganado, por el medio en que se hallan y por su cantidad, es difícil para el propietario controlar si le faltan algunos animales, así como su identificación.

Desde antiguo las provincias dictaron códigos o leyes rurales que incorporaron el requisito de la "marca" o "señal" para acreditar la propiedad del ganado mayor o menor, respectivamente, en algunos casos desde antes de la vigencia del Código Civil derogado. Por "marca" cabe la impresión que se efectúa sobre el animal de un dibujo o diseño, por medio de hierro candente, de marcación en frío, o de cualquier otro procedimiento que asegure la permanencia en forma clara e indeleble. La "señal" es un corte, o incisión, o perforación, o grabación hecha a fuego, en la oreja del animal. La primera se utiliza para el ganado mayor y la segunda para el menor. La "caravana" es un dispositivo que se coloca en la oreja del animal mediante la perforación de la membrana auricular. El "tatuaje" es la impresión en la piel del animal de números y/o letras mediante el uso de puntas aguzadas, con o sin tinta. El "implante" es un dispositivo electrónico de radiofrecuencia que se coloca en el interior del animal. Estos medios alternativos son para la especie porcina.

La sanción de la ley 22.939 en el año 1983, unifica el régimen de marcas y señales en todo el país. Dicha ley fue modificada en el año 2009 por la ley 26.478.

Es obligatorio para todo propietario de ganado mayor o menor tener registrado a su nombre el diseño que empleare para marcar o señalar, conforme a lo dispuesto en dicha ley (art. 5º). El registro del diseño de las marcas y señales del ganado en general y de los medios alternativos de identificación propuestos exclusivamente para la especie porcina confiere a su titular el derecho de uso exclusivo por el plazo que las respectivas legislaciones provinciales establezcan, pudiendo ser prorrogado de acuerdo con lo que dichas normas dispongan. Este derecho es transmisible y se prueba con el título expedido por la autoridad competente, y en su defecto por las constancias registrales. En los casos de transmisión, deberán efectuarse en el registro las anotaciones respectivas (art. 4º).

El artículo 9º dispone que "Se presume, salvo prueba en contrario [...] que el ganado mayor marcado y el ganado menor señalado, o en el caso exclusivamente del ganado porcino, señalado o identificado con alguno de los medios alternativos [...] pertenece a quien tiene registrado a su nombre el diseño de la marca o señal, o medio de identificación alternativo aplicado al animal". Se establece así la presunción *iuris tantum* en favor del titular de la marca o señal registrada y aplicada. También se presume *iuris tantum* que las crías no marcadas pertenecen al propietario de la madre, si aquéllas se encuentran al pie de ella.

A su vez, el artículo 12 establece que "Todo acto jurídico mediante el cual se transfiera la propiedad del ganado [...] deberá instrumentarse con un certificado de adquisición que, otorgado por las partes, será autenticado por la autoridad local competente".

La doctrina discute acerca de si la propiedad del ganado se transmite con la suscripción de los certificados de compraventa, o si a ello debe sumarse la tradición de los animales, cuestión que no surge con claridad del texto de la ley. Rebón se inclina por la segunda alternativa, habida cuenta de que el Mensaje de Elevación de la ley dice que "el certificado de adquisición no es suficiente por sí para transmitir la propiedad, es indispensable que vaya seguido de la tradición o entrega efectiva del ganado transmitido".

Cabe agregar que el ganado orejano (o sea, sin marcar), o cuya marca o señal no fuese suficientemente clara, o no estuviese registrada, queda sometido al régimen del artículo 1895. A su vez, en los ejemplares de pura raza, la marca o señal podrá ser sustituida por tatuajes o reseñas, según especies.

e) *Equinos de pura sangre de carrera*

Esta clase de animales se halla excluida de la ley 22.939 (art. 19), pues el régimen de su propiedad y tráfico jurídico está regulado por la ley 20.378. Con anterioridad a la sanción de esta ley, si bien existían registros genealógicos organizados por instituciones privadas, tales como el "Stud Book Argentino" llevado por el Jockey Club Argentino, por tratarse de registros privados no reconocidos por la legislación, todo lo atinente al dominio de estos animales debía regirse por el Código Civil. Sin perjuicio de lo expuesto, cabía interpretar que quien adquiría un caballo de pura sangre sin constatar lo informado por dicha institución, no podía alegar con éxito su buena fe.

El problema queda superado con la sanción de la ley 20.378, la cual excluye a los equinos de pura sangre de carrera del principio sentado por el Código y los somete a sus disposiciones. Esta ley establece una inscripción de carácter constitutivo, ya que la propiedad de estos animales se acredita con la inscripción en los registros genealógicos que reconoce, y la transmisión del dominio sólo se perfecciona entre las partes y con relación a terceros mediante la inscripción del respectivo acto jurídico en dichos registros (arts. 1º y 2º).

VII. Prescripción

La usucapión de cosas muebles, registrables y no registrables, será examinada en el capítulo dedicado a la prescripción adquisitiva.

CAPÍTULO V

DOMINIO MNR

SUMARIO: I. Propiedad y dominio. II. Filosofía del Código. III. Concepto. IV. Caracteres. V. Extensión. VI. Dominio del Estado. VII. Dominio internacional y eminente.

I. Propiedad y dominio

A veces se confunden los términos propiedad y dominio, o se usan de manera indistinta, pero lo cierto es que hay diferencias desde el punto de vista jurídico.

La Constitución Nacional, en el artículo 17, garantiza el derecho de propiedad. Dice esta norma que "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie". Además, el artículo 14 asegura a los ciudadanos el derecho "de usar y disponer de su propiedad".

Desde antiguo ha interpretado la jurisprudencia de la Corte Suprema; seguida por los distintos tribunales y también por la doctrina, que el concepto de propiedad es mucho más amplio, ya que abarca una serie de derechos y prerrogativas patrimoniales que pueden interesar a una determinada persona (humana o jurídica). La idea se vincula

con la teoría de los derechos adquiridos, que deben ser respetados. Esto trasciende al derecho de dominio sobre cosas que regula el Código Civil y Comercial. El derecho de propiedad abarca derechos reales, personales, intelectuales, administrativos, etcétera. La propiedad constitucional se refiere a todos los bienes, materiales o inmateriales que integran el patrimonio; esto es, todos los derechos susceptibles de apreciación económica y que no se confunden con la persona.

El concepto constitucional de derecho de propiedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia fue definido en el precedente "Don Pedro Emilio Bourdieu c/Municipalidad de la Capital". Allí la Corte Suprema concluyó que: El término "propiedad", cuando se emplea en los artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones de ese estatuto comprende, como lo ha dicho esta Corte, "todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad". Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de Derecho Privado sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de "propiedad" (*Fallos*: 145:307).

En cuanto a la idea de derecho adquirido, suele afirmar la Corte que si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria para que se haga efectivo. De no ser así, resultaría la inadmisibles consecuencia de que la titularidad de un derecho individual vendría a depender de la voluntad discrecional del obligado renuente en satisfacer ese derecho.

Los derechos adquiridos no pueden alterarse ni siquiera mediante una ley posterior porque, como enseñó el máximo tribunal, el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema.

Claro que los derechos no son absolutos sino que están sujetos a las leyes que los reglamentan. Pero la reglamentación no puede suprimirlos, desnaturalizarlos; debe ser razonable. En ocasiones, lamentablemente, se han aceptado fuertes restricciones a derechos adquiridos, por ocasión de alguna emergencia.

Aclarado lo anterior, como se verá más adelante, el concepto de dominio se restringe al derecho real que otorga a su titular importantes facultades sobre una cosa. En otros términos, si la propiedad es el género, el dominio es una de sus tantas especies.

II. Filosofía del Código

El Código anterior, derogado, se ubicaba en una posición individualista, que había suscitado críticas, dado que hasta permitía la destrucción o degradación de las cosas. En 1968, la reforma producida por la ley 17.711 atemperó ese rigor y buscó equilibrio, al disponer que el uso de la cosa debía ser regular y, especialmente, al legislar sobre el abuso del derecho.

El actual Código Civil y Comercial profundiza ese camino con diversas normas. Además de mantener la teoría del abuso del derecho, hace alusión a los tratados de derechos humanos, resguarda los derechos de incidencia colectiva incluso limitando los derechos individuales, reconoce la propiedad comunitaria indígena, protege la vivienda; dispone que hay que asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros.

En lo que hace al derecho real de dominio, el Código le pone límites a las facultades del titular. El equilibrio se encuentra también en la regulación de la usucapión, ya que si bien el referido derecho es perpetuo, cede ante la adquisición realizada por un tercero que posea la cosa durante el tiempo exigido. Se contempla así la situación de quien se despreocupó de su pertenencia, por un lado, y de quien aprovechó el bien, por el otro.

Por último, hay que tener presente que por razones de utilidad pública el Estado puede expropiar bienes, previo pago de la indemnización.

III. Concepto

El dominio como derecho real es el mayor sometimiento de que puede ser objeto una cosa a una persona, y correlativamente el mayor, más extenso y más completo poder que su titular puede tener sobre la misma cosa; los demás derechos reales no son sino cada uno de ellos un fragmento de esa totalidad que es el dominio.

Dice el artículo 1941 del Código Civil y Comercial que "El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario". El Código pone el acento en las facultades, y dice que otorga "todas" las potestades de usar, gozar y disponer, sin perjuicio de los límites legales. Se observa cierto equilibrio entre el individualismo y la función social. Si bien no se trata de una definición, lo cierto es que resulta muy difícil encontrar una definición legal inobjetable.

IV. Caracteres

a) *Absoluto*

En un primer sentido, el término "absoluto" implica que el dominio, al igual que los demás derechos reales, es oponible *erga omnes*. Pero aquí cobra otro significado. El dominio es un derecho real "absoluto", en el sentido de que confiere a su titular la mayor cantidad posible de facultades sobre una cosa. Se dice "posible", porque la cantidad e intensidad de tales facultades dependerá del ordenamiento jurídico de que se trate, conforme a los criterios filosóficos y políticos que le sirven de base.

Entendido así el carácter absoluto, es su corolario que no se puede concebir como derecho ilimitado, lo que constituiría una concepción antisocial. Al respecto, conviene no perder de vista el Capítulo 4 del Título III del Libro Cuarto del Código, donde se encuentran numerosas restricciones y límites al dominio, que constituyen su estatuto normal en nuestro Derecho. Tiene especial relación con este carácter la exigencia del artículo 10 de no amparar el ejercicio abusivo de los derechos.

Como se dijo, el derecho de dominio otorga facultades. El *ius utendi* o derecho de uso sobre la cosa. El propietario tiene el derecho a servirse de la cosa para sus intereses, siempre y cuando esas conductas no violen preceptos legales ya establecidos o causen lesiones a los derechos de otros.

El *ius fruendi*, o derecho de goce sobre la cosa, significa que el dueño tiene el derecho de aprovechar y disponer los frutos y productos que produzca una cosa. La regla general es que el propietario de una cosa es también propietario de todo aquello que la cosa genere y produzca, con su intervención o sin ella. Este derecho de goce implica la potestad de obtener algún provecho de la cosa.

El *ius abutendi* es el derecho de disposición sobre la cosa. El propietario, bajo la premisa de que la cosa está bajo su poder (fáctico y jurídico), puede hacer con ella lo que quiera, incluso destruirla, reconstruirla, etcétera (disposición material). Del mismo modo, puede disponer de su derecho real (disposición jurídica), así, puede enajenar la cosa, venderla, donarla, es decir, desligarse de su derecho de dominio y transmitirlo a otra persona.

a.1) *Facultades jurídicas*

El dueño tiene amplias facultades jurídicas, en tanto puede realizar actos de disposición (*ius abutendi*) y de administración. En principio, estas facultades son limitadas en su número, pero no taxativas. En primer lugar, existe aquí la limitación del *numerus clausus*.

El dueño puede: a) ejecutar todos los actos jurídicos de que la cosa pueda legalmente ser objeto (que incluye actos entre vivos y de última voluntad); así, aunque es redundante: alquilarla, enajenarla, gravarla, etcétera. Puede constituir derechos reales o personales; en este último ámbito rige el principio de la autonomía de la voluntad. Es evidente también que esos actos jurídicos pueden serlo tanto a título oneroso como a título gratuito; b) puede hacer abandono de la cosa, sin transmitirla a otra persona.

Claro está que también estas facultades sufren limitaciones, y habrá que estar en cada caso a lo que dispone su título o la ley que regula su derecho; por ejemplo en lo relativo a las cláusulas de inalienabilidad

(art. 1972), y en lo que respecta a limitaciones en materia sucesoria, ya que no se puede testar excediendo la porción disponible ni alterar el orden sucesorio. También se presentan limitaciones en las normas que protegen la vivienda (ver art. 250).

a.2) *Facultades materiales*

El artículo 1941 dice que es inherente al dominio el ejercicio de facultades. El dominio importa una potestad jurídica, el derecho de pleno señorío, o sea el derecho de poseer (*ius possidendi*), o derecho de ejercer sobre la cosa todos los actos conducentes a extraer de ella la utilidad que produzca. En cambio el que sólo es poseedor (y no propietario) tiene solamente el *ius possessionis*, es decir sólo los derechos derivados del hecho de su posesión. Claro que, cabe reconocer, otros titulares de derechos reales también tienen derecho de poseer.

Esas facultades que tiene el titular del derecho de dominio sobre la cosa, deben ser ejercidas en forma regular (art. 10), es decir dentro del marco normativo dispuesto por el Código para el ejercicio del Derecho, especialmente teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 1884 (imposibilidad de crear derechos reales o modificar los existentes por la sola voluntad de los constituyentes) y la normativa del Capítulo 4 del Título III (*Límites del dominio*).

El dominio es absoluto, como ya se dijo, dentro de los límites y bajo las condiciones determinadas por la ley, por una consideración esencial a la sociedad: el predominio del interés general y colectivo, sobre el interés individual.

El derecho que tiene el titular del dominio de "disponer" de la cosa tiene dos vertientes: por un lado el poder de disposición jurídica, y por el otro, el poder de disposición material.

La facultad de disponer materialmente es propia del dominio. El dueño tiene la potestad de derrumbar su casa y reconstruirla, hacer agregaciones, cambiar el destino, etcétera. Como se dijo, sin incurrir en un ejercicio abusivo.

Además, tiene las facultades de usar y gozar. Gozar significa que puede obtener provecho de la cosa.

a.3) *Abuso del derecho*

El ejercicio abusivo del dominio se configuraría, por ejemplo: productores de trigo que destruyen sus cosechas con el objeto de evitar que la acumulación de existencias en la plaza deprima los precios; o una persona que eleva una altísima pared sobre su inmueble al solo efecto de perjudicar a su vecino. Se visualiza la situación cuando un propietario decide con una bomba agotar el agua de un pozo existente en su predio, pero no para utilizarla sino para verterla en un río, con la intención de privar de dicho elemento al vecino.

El ejercicio de las facultades explicitadas (*ius utendi, fruendi y abutendi*) debe ser regular, porque si fuere abusivo no sería "un ejercicio regular" como lo exige el artículo 10. Se considera tal, según esta norma, "el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización".

Pero el ejercicio de las facultades que son inherentes a su dominio, por parte de un vecino, puede eventualmente privar de ciertas ventajas o comodidades a otro propietario vecino. Éste, en ese caso, no tiene acción alguna para impedirle el ejercicio de su derecho o, en su caso, para recuperar las ventajas o comodidades perdidas.

Un ejemplo aclarará la cuestión: desde su inmueble uno de los propietarios tiene una hermosa vista a través del fundo vecino, que no está edificado o tiene una edificación más baja. Este último, sin embargo, decide edificar o elevar su edificio, y como consecuencia de ello le priva al otro propietario de su magnífica vista.

Esto para el edificante es perfectamente lícito en tanto el ejercicio de su derecho no haya sido abusivo. Y el vecino perjudicado en su vista no puede oponerse porque él no tiene un derecho subjetivo, sino tan sólo una ventaja o comodidad. Si en cambio hubiese tenido una servidumbre de vista sobre el fundo vecino, tendría una acción para impedir la construcción.

El criterio que emplean los jueces para medir el abuso es variado.

En ocasiones se valoran pautas subjetivas (v. gr.: la intención de dañar), en otras se acude a criterios objetivos, cuando el acto es antifuncional, según los estándares de buena fe, moral o buenas costumbres. También los jueces suelen valorar si la conducta objetada causa, o no, algún perjuicio. Estas situaciones se presentan con mayor frecuencia en el ámbito de la propiedad horizontal.

a.4) *Elasticidad del dominio*

El que tiene el dominio perfecto sobre una cosa, ya no puede adquirir sobre ella ningún otro derecho real; pero si el título del dominio que adquirió reconoce, por ejemplo, una servidumbre a favor de otro fundo, él puede adquirir esta "parte" que le falta a su título (art. 1943), reduciendo por pago aquella servidumbre si el propietario del fundo dominante lo aceptase, o si ella hubiese sido declarada extinguida por alguna de las causas previstas en el Código.

A la condición de plenitud del dominio se conecta la de elasticidad, entendida como la idoneidad del derecho de expandirse automáticamente hacia su contenido normal, cuando desaparecen las limitaciones que lo comprimían. Así, por ejemplo, acabado el usufructo, el dominio que estaba desnudo se expande y recobra el uso y goce.

b) *Exclusivo*

Dice el Código en el artículo 1943: "El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Quien adquiere la cosa por un título, no puede en adelante adquirirla por otro, si no es por lo que falta al título".

El dominio es exclusivo porque no puede tener más de un titular. Dos o más personas no pueden tener cada una en el todo el dominio de una cosa; de haber más de un titular se configuraría un condominio.

La exclusividad configura una cualidad que también se presenta en otros derechos reales, verbigracia la propiedad horizontal, el usufructo, y también el uso y la habitación en tanto la utilidad extrafamiliar no supere la satisfacción de las necesidades de sus titulares y sus familias.

Corolarios de este carácter exclusivo son las facultades que tiene

el dueño de excluir a terceros del uso y goce o disposición de la cosa, de tomar al respecto todas las medidas que crea convenientes, de encerramiento (por medio de paredes, fosos o cercos), de prohibir que se introduzcan cosas ajenas en su inmueble y de removerlas sin previo aviso si hubieren sido introducidas sin su consentimiento, que se entre o pase por ella, todo lo cual es meramente ejemplificativo, pues sus facultades no se agotan en esa enumeración.

b.1) *Exclusividad en la adquisición del dominio*

Dice la última parte del artículo 1943 que "Quien adquiere la cosa por un título, no puede en adelante adquirirla por otro, si no es por lo que falta al título". Se trata de otra connotación del carácter exclusivo y que se conoce por la máxima *nemini res sua servit*. Así como no pueden coexistir dos derechos de dominio sobre la misma cosa (salvo que haya condominio), tampoco pueden concurrir el dominio y otro derecho real en cabeza de la misma persona. Así, por ejemplo, si alguien es dueño, no tiene sentido que también sea usufructuario de esa cosa. Ya por ser dueño tiene las más amplias facultades, no precisa de otras. Justamente, los derechos reales de disfrute o de garantía deben recaer sobre cosa ajena.

Lo que sí permite la norma es que adquiera en adelante la cosa por otro título, pero solamente "por lo que le falta al título". Por ejemplo, una persona que es dueña sujeta a resolución por estar subordinado el dominio a una condición resolutoria (dominio revocable), podría suscribir un nuevo contrato con quien tiene derecho a la restitución en el caso de cumplirse la condición, para suprimirla y consolidar su situación de manera definitiva. Seguirá siendo dueño, pero ahora su dominio pasa a ser perfecto, adquirió lo que a su título le faltaba.

b.2) *Facultad de exclusión*

Establece el artículo 1944: "El dominio es excluyente. El dueño puede excluir a extraños del uso, goce o disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos puestos en ella, y encerrar sus inmuebles con muros, cercos o fosos, sujetándose a las normas locales".

Se establece una connotación adicional del carácter exclusivo, cual es la facultad de exclusión, ya sea de terceros, de objetos, así como la posibilidad de encerrarse.

b.2.1) *Facultad de excluir a terceros*

Lo cierto es que nadie, si no media autorización, tiene derecho a ingresar en el inmueble de otro, máxime si se trata de "extraños", como dice el artículo 1944. Si ello ocurre, el dueño los puede excluir. En cambio, si se trata de personas autorizadas, o que tienen derecho al uso y goce por haberlo otorgado el dueño, esta facultad de excluir no es posible.

Así como el dueño puede excluir, también puede impedir a extraños que pasen o ingresen a su inmueble. Así, por ejemplo, se observan carteles con la leyenda "Prohibido pasar". Es muy común el que indica que no se debe colocar el automóvil frente a un garaje.

Este poder de excluir a terceros, así como el de remover objetos, es una manera de hacer justicia propia, autorizada de manera excepcional.

Desde otro ángulo, en algún caso el dueño no puede impedir el ingreso del tercero, como sucede con quien alega haber guardado un tesoro en predio ajeno (art. 1954), o quien persigue un enjambre (art. 1950). A la vez, está obligado a recibir agua, arena y piedras que se desplazan desde otro fundo, si no han sido degradadas ni hubo intervención del hombre (art. 1976).

Asimismo, se afirma que esta facultad de excluir debe ser ejercida en forma regular, y de acuerdo a la figura del "estado de necesidad".

b.2.2) *Derecho del dueño para remover objetos colocados en su cosa*

Esta disposición es una consecuencia de la relación directa e inmediata que tiene el titular del derecho real de dominio con la cosa sometida al mismo, que es el objeto del derecho. El dueño no necesita intermediarios ni hacer peticiones para actuar, ni depende de la autoridad pública para ello, ni debe requerir su ejecución forzosa; puede sacar la cosa de su predio por su propia autoridad, sin previo aviso.

Ello no le puede acarrear responsabilidad alguna, pues el ejercicio regular de un derecho propio no constituye ilicitud (art. 10).

Claro está que si hubiese prestado su consentimiento para que se introdujeran las cosas en su terreno, ya no podría removerlas antes de llenado el fin que se tuvo en cuenta al prestarlo.

b.2.3) *Cerramiento*

Menciona el artículo 1944 que el dueño "puede" encerrar su inmueble con muros, cercos o fosos. Se verá más adelante que en verdad, más que un derecho constituye una obligación. Se remite al capítulo sobre medianería.

c) *Perpetuo*

Este carácter lo expresa el artículo 1942: "El dominio es perpetuo. No tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades, o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva".

El derecho real de dominio, además de ser absoluto y exclusivo, se caracteriza por ser perpetuo. A diferencia de los dos primeros, en algunos casos puede faltar el carácter perpetuo, porque no es inherente a la esencia de dicho derecho sino tan sólo a su naturaleza; lo que posibilita que el dominio pueda ser temporario, como acontece en los casos de dominio revocable y fiduciario, que son especies -junto al dominio gravado- del dominio imperfecto.

Que el dominio sea perpetuo significa que él no se extingue porque su titular no use, no goce o no ocupe la cosa, a no ser que la deje poseer por otro por todo el tiempo legal requerido para la usucapión. En cambio, otros derechos reales se extinguen por el no uso, como sucede con la superficie, el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres.

Cabe aclarar: que el dominio sea perpetuo significa que no está sujeto a plazo, sin límite de tiempo, y que dura mientras exista la cosa ya que, si la cosa se destruye, el derecho también se extingue por falta de objeto. En cambio, la transmisión del derecho a otro -vo-

luntaria o involuntariamente— no afecta tal carácter, ya que el derecho continúa en cabeza del sucesor. Que sea perpetuo no significa que la cosa deba pertenecer siempre al mismo titular, lo cual es imposible ya que la vida humana termina en algún momento.

Del carácter perpetuo del dominio se pueden extraer algunas consecuencias: 1) no es un derecho vitalicio, como sucede con el usufructo; 2) no se extingue por la falta de ejercicio, como sí ocurre con otros derechos reales; 3) la acción reivindicatoria es imprescriptible, sin perjuicio de la prescripción adquisitiva (art. 2247).

c.1) *Abandono*

Se ha sostenido que el abandono implica una alteración del carácter perpetuo del dominio. Especialmente si se trata de cosas muebles no registrables.

Cuando el abandono de la cosa mueble es abdicativo, si bien se trata de un caso de extinción absoluta, entiendo que aquí tampoco se consagra una excepción al carácter perpetuo del dominio. Ello porque mientras el titular tiene la cosa bajo su poder, su derecho no está sujeto a extinguirse por el transcurso del tiempo —lo que sí acontece en los supuestos de dominio revocable y fiduciario—, sino que es perpetuo en tanto conserve la cosa. Su derecho no se extingue por el no uso, ni está subordinado al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición.

Lo que ocurre en la *derelictio* es que el titular ya no conserva la cosa bajo su poder, pero mientras la tuvo, su derecho era perpetuo, y si dejó de tenerla no es por efecto del tiempo sino como consecuencia del ejercicio de sus facultades, entre las que se comprende la de abandonar la cosa sin transmitirla a otra persona.

c.2) *Expropiación*

También se ha afirmado que la expropiación por causa de utilidad pública importa una limitación al carácter perpetuo del dominio.

En mi opinión, la expropiación por causa de utilidad pública no constituye una limitación al carácter perpetuo del dominio, sino una restricción al carácter absoluto del dominio. De lo contrario, la per-

petuidad sería inexistente, pues sobre cualquier inmueble se cierne la posibilidad o la amenaza de ser objeto, en cualquier tiempo, de una eventual expropiación.

d) *Dominio perfecto*

El artículo 1941 se refiere al dominio perfecto. Ocurre que cuando el dominio es imperfecto, pueden disminuir las facultades del dueño (v. gr.: el dueño fiduciario puede disponer sólo si lo requieren los fines del fideicomiso, y hasta es posible que se le limite esta facultad —art. 1688—).

V. *Extensión*

Dispone el artículo 1945: “El dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios.

“El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales.

“Todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a su dueño, excepto lo dispuesto respecto de los derechos de propiedad horizontal y superficie.

“Se presume que las construcciones, siembras o plantaciones las hizo el dueño del inmueble, si no se prueba lo contrario”.

Este artículo se refiere a la extensión física del derecho de dominio. Se trata de una regla general que consiste en la accesión.

a) *Dominio de los accesorios*

La primera parte del artículo 1945 dice que “El dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios”. Cabe aclarar que esta primera parte del artículo 1945 se refiere tanto a inmuebles como a cosas muebles. Así, por ejemplo, el dominio de un automóvil comprende la de sus ruedas; el de un vestido, el de sus adornos.

El artículo 1945 se refiere, en primer lugar, a los objetos que forman un todo con la cosa. Ocurre que cuando las cosas accesorias forman

parte integrante de la principal, no pueden ser poseídas en forma independiente sin que haya una alteración de la sustancia. Ahora, si son separadas, habrá tantos dominios independientes como cosas se hayan desprendido. Se trata de cosas que, al estar unidas a otra principal, han perdido su individualidad; justamente, forman parte de un todo. Así, por ejemplo, los tablones con los que se ha construido un navío. Cabe entender que se trata de una cosa indivisible.

En segundo lugar, es bien conocido el principio de que lo accesorio sigue la naturaleza de lo principal.

Cabe tener presente al artículo 230: "Son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa principal, excepto disposición legal en contrario. Si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que sea posible distinguir la accesoría de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del mismo valor no hay cosa principal ni accesorio".

Por lo tanto, no están comprendidas en la propiedad de la cosa aquellas que no estén realmente "adheridas" a la principal, o dependan de ella. Así por ejemplo, los útiles de labranza y animales de un predio destinado a esta actividad, no parece que puedan comprenderse en la propiedad del fundo, como si todo formara una sola cosa. Hipotecado el campo, ¿podría decirse que los animales, el tractor y la cosechadora forman parte de la garantía hipotecaria? Dice el artículo 226 que "No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario".

Cuando este artículo dice "adheridas", está diciendo físicamente adheridas al suelo (si se tratare de inmuebles) con carácter de perpetuidad, y no comprende las cosas por accesión moral. El artículo 226 se refiere a la "adhesión física".

b) *Extensión material del derecho de dominio inmobiliario*

El artículo 1945, en los últimos tres párrafos, se refiere a la extensión del dominio sobre un inmueble. Establece que el dominio del suelo se extiende al subsuelo, y al espacio aéreo sobre el suelo (*superficies solo cedit*). En ambos pone límites: en la medida en que su aprovechamiento

sea posible. Además, estos límites existen, especialmente en lo que hace al espacio aéreo, en los códigos (locales) de edificación, en el Código Aeronáutico y en otras disposiciones legales, mediante las cuales se les impide a los propietarios construir más allá de determinada altura o se los obliga a no poner obstáculos (p. ej., antenas), a dejar espacios de aire y luz, o a no plantar árboles que se desarrollan a gran altura, etcétera. Incluso, el propio Código Civil y Comercial le atribuye la propiedad del espacio aéreo sobre parte del territorio al dominio público del Estado (art. 235, inc. e). De manera entonces que prácticamente el derecho al "espacio aéreo" se limita a hacer en él las construcciones permitidas, aunque le quiten luz, vistas u otras ventajas a sus vecinos (art. 1981), y pueden también demandar —dice el artículo— la demolición de las obras del vecino que a cualquier altura avancen sobre ese espacio, aunque esto dependerá en realidad de lo que decida el juez en el caso concreto, porque estando muy avanzada la edificación invasora, puede resultar más equitativo condenar al pago de una justa indemnización que ordenar la demolición de las obras (ver art. 1963).

La admisión de los derechos reales de propiedad horizontal y de superficie importa excepciones a la regla que sienta este artículo.

Respecto al suelo, cabe tener presente que, según el artículo 225, son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran debajo sin el hecho del hombre. Se considera al suelo y al subsuelo como formando una sola cosa, y la propiedad del primero implica la del segundo y a todos sus componentes: agua, tierra, vegetales, etcétera. En cuanto a la profundidad del suelo, también hay excepciones como los tesoros y las minas (pertenecen al dominio privado del Estado; ver art. 236, inc. b, y el Código de Minería, especialmente arts. 7° y 11, porque ellas forman una propiedad distinta de la del terreno en que se hallan). También hay excepciones en materia de hidrocarburos, aguas subterráneas (art. 235, inc. c), ruinas y yacimientos arqueológicos (art. 235, inc. h), etcétera.

c) *Construcciones, siembras o plantaciones*

Una consecuencia de la proyección del dominio del suelo al espacio aéreo, y en especial de la regla de la accesión (artificial), es que "Todas

las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a su dueño, excepto lo dispuesto respecto de los derechos de propiedad horizontal y superficie" (art. 1945, párrafo tercero).

Este artículo incorpora el principio del Derecho Romano de que lo edificado o los edificios, y las plantaciones o siembra, siguen el derecho del suelo, es decir pertenecen al dueño del suelo. Esto no es una presunción *iuris tantum*, porque no se admite prueba en contrario; tampoco dice la norma que se presume —como lo hace en el párrafo siguiente— sino que directamente le atribuye la propiedad al dueño del suelo. Ello, claro está, sin perjuicio de que podría eventualmente consumarse a favor del dueño del terreno un enriquecimiento sin causa, si otro, de buena o mala fe, hubiese hecho las plantaciones o edificación a su costa. En cuanto a la situación que plantea la plantación o edificación en terreno ajeno, ver los artículos 1962 y 1963.

Esta atribución no es absoluta, como advierte el propio artículo, teniendo en cuenta la regulación de los derechos de propiedad horizontal y de superficie, especialmente este último. Aunque la norma no lo dice, la misma salvedad cabe hacer con relación a los conjuntos inmobiliarios, que se pueden regir por las reglas de la propiedad horizontal (art. 2075), y al derecho real de sepultura (ver art. 2112).

Cabe interpretar que el artículo 1945 se refiere a las construcciones que están adheridas al suelo de manera perdurable, como se desprende del artículo 226.

El artículo 1945, en cambio, presume que las obras las hizo el dueño, y aquí sí admite prueba en contrario. Se podría probar no sólo que no las hizo, sino que los materiales y su resultado no le pertenecían, lo que puede dar lugar a un resarcimiento (ver art. 1962). Cualquier medio de prueba sería admisible.

VI. Dominio del Estado

El Código Civil y Comercial trata la cuestión en los artículos 235 (bienes públicos) y 236 (bienes privados del Estado). A su vez, el dominio público puede ser nacional, provincial o municipal.

El dominio público ha sido definido como un régimen jurídico que comprende el conjunto de bienes, trátase de cosas muebles o inmuebles, de propiedad del Estado destinado a la utilidad común.

Las cosas del dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales. No están en el comercio, porque son absolutamente inenajenables (art. 233), y en consecuencia tampoco son susceptibles de posesión ni de ser gravadas con otros derechos reales, como usufructo, servidumbres, hipotecas. Por el contrario, el dominio privado del Estado está sometido al mismo régimen que el de los particulares; de ahí que las cosas del dominio privado del Estado sean susceptibles de usucapión, tal como las de los particulares (ver art. 2534).

VII. Dominio internacional y eminente

Se suele denominar dominio internacional al derecho soberano que tienen las naciones sobre su territorio, y al deber de los otros Estados de abstenerse de interferir en esa relación. Se trata de una obligación pasiva, de inercia, de respeto a la soberanía ajena. Se puede decir, entonces, que el dominio internacional es el derecho que pertenece a una Nación de usar, de percibir sus productos, de disponer de su territorio con exclusión de las otras naciones, de gobernar en dicho territorio sin interferencia de otro poder exterior. Este derecho crea para los otros Estados la obligación correlativa de no poner obstáculo al empleo que haga la Nación propietaria de su territorio, y de no arrogarse ningún derecho de mando sobre dicho territorio.

Esta propiedad soberana del Estado se denomina dominio eminente, que no es el dominio regulado por el Código, sino que apunta al poder que tiene el Estado sobre los bienes que están en su territorio.

El dominio eminente implica un poder supremo sobre el territorio, vinculado a la soberanía interna, la que se encuentra reservada por los Estados provinciales y sólo delegada en el Estado nacional en la medida de lo preceptuado por el ordenamiento constitucional.

Por otra parte, se suele denominar "dominio originario" al atributo

de soberanía que otorga derechos de pertenencia o propiedad sobre las cosas situadas en el territorio, mientras que el dominio eminente es un atributo de soberanía que se traduce en el derecho de tutela o regulación en cabeza del Estado sobre todas las cosas ubicadas en su territorio con prescindencia de la propiedad.

CAPÍTULO VI MODOS DE ADQUISICIÓN DEL DOMINIO

MNR

SUMARIO: I. Introducción. II. Apropiación. III. Tesoros. IV. Régimen de cosas perdidas. V. Transformación de cosas muebles. VI. Accessión de cosas muebles. VII. Accessión de cosas inmuebles.

I. Introducción

En la Parte General se indicó cuáles son los modos de adquirir los derechos reales (arts. 1892 y ss.). Además de los referidos modos generales (v. gr.: tradición, prescripción, sucesión, etc.), algunos derechos reales tienen modos especiales de ser adquiridos, y el Capítulo 2 del Título III del Código Civil y Comercial se ocupa de ellos con relación al derecho real de dominio.

II. Apropiación

La apropiación es un modo unilateral y originario de adquirir el dominio de las cosas muebles no registrables sin dueño. La apropiación es un modo de adquisición del dominio, pero no de otros derechos reales, porque así lo regula el Código, y por la necesidad de un acto o negocio jurídico para la constitución de derechos reales sobre cosa ajena.

El Código no define a la apropiación, pero puede decirse que se basa en la aprehensión material, en la toma de posesión, acompañada de la voluntad de sujetar la cosa al poder del adquirente. El Código regula la adquisición de las relaciones de poder (ver arts. 1922/1923) y, en el caso de cosas muebles sin dueño, se exige capacidad y *corpus*. Lo cierto es que en estos casos, así como se adquiere la posesión, se

adquiere a la vez el dominio. Ello es así si se tiene presente que el sujeto actúa voluntariamente, y que se es poseedor cuando la persona se comporta como titular del derecho real. Al no haber otro dueño a quien reconocer o representar, ambas adquisiciones se producen simultáneamente.

El artículo 1947 indica cuáles cosas son susceptibles de este modo y cuáles no. Cabe recordar que los inmuebles sin dueño pertenecen al dominio privado del Estado (art. 236, inc. a), al igual que "las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas" (art. 236, inc. d). Las cosas muebles registrables siempre tienen un dueño conocido, de allí que no tienen cabida en el régimen de apropiación, salvo que haya abandono explícito.

Dice el artículo 1947: "El dominio de las cosas muebles no registrables sin dueño, se adquiere por apropiación.

"a) son susceptibles de apropiación:

- "i) las cosas abandonadas;
- "ii) los animales que son el objeto de la caza y de la pesca;
- "iii) el agua pluvial que caiga en lugares públicos o corra por ellos..."

a) *Cosas sin dueño y abandonadas*

El primer inciso del artículo 1947 incluye, dentro de las cosas sin dueño (*res nullius*), a las cosas abandonadas (*res derelictae*). Estas últimas son las que alguna vez tuvieron dueño pero ya no lo tienen, mientras que las primeras nunca lo han tenido.

El abandono siempre debe ser voluntario, pues de lo contrario no será considerado abandono.

En principio, debe considerarse que todas las cosas tienen dueño; la excepción son aquellas a las que se refiere este capítulo. Como la intención de renunciar no se presume (art. 948) y el principio es que mientras no se trate de una *res nullius* todas las cosas tienen dueño, se dispone que si la cosa hallada es de "algún valor" se la presume perdida y no abandonada (art. 1947, inc. b-i). Por otro lado, si el dueño es desconocido, la cosa pertenece al dominio privado del Estado (art. 236, inc. d).

La persona que abandonó la cosa mueble puede volver a tomarla si se arrepiente, si no fue todavía apropiada por otro.

En un interesante caso se decidió que si el presentante que encontró en la caja de seguridad que alquilaba en un banco una cantidad de monedas de oro consideró en un primer momento que no estaba frente a una cosa abandonada y pretendió el pago de una recompensa, como si se tratara del hallazgo de cosas perdidas, pero ahondada la investigación ante lo obrado en el propio banco, donde no se presentó persona alguna que invocara la propiedad de los valores, cuyo efecto hubiera sido demostrar por parte de ella una falta de intención de abandonarlos, es admisible su posterior reclamo sobre la propiedad de los bienes, ante la conclusión de que se trata en la especie de cosas abandonadas. Existió un evidente desprendimiento material de la posesión de las monedas de oro por parte del presunto dueño, al introducir aquéllas en la caja de seguridad que alquilaba otra persona y resultó notoria la intención de no mantenerlas en su dominio, al no formularse ninguna reclamación en el banco donde ocurrió el hecho, además de que tampoco existe constancia alguna en ese sentido, a través de la sustanciación del proceso que insumió hasta ahora casi ocho años y medio (CNECC, sala V, 13-4-82, "Niemi, Reijo", L. L. 1982-D-521).

Finalmente, es susceptible de apropiación "el agua pluvial que caiga en lugares públicos o corra por ellos". Así, por ejemplo, el agua de lluvia puede ser apropiada en la medida en que haya caído en lugares públicos, o caído en un lugar privado (v. gr.: techo) pero corra por un lugar público; no la que caiga en terrenos de particulares y no salga de allí.

b) *Caza*

b.1) *Introducción*

Dice el artículo 1948 que "El animal salvaje o el domesticado que recupera su libertad natural, pertenece al cazador cuando lo toma o cae en su trampa. Mientras el cazador no desista de perseguir al animal que hirió tiene derecho a la presa, aunque otro la tome o caiga en su trampa.

"Pertenece al dueño del inmueble el animal cazado en él sin su autorización expresa o tácita".

La caza es una manera de apropiación. En efecto, el animal herido o muerto por el cazador recién le pertenecerá cuando "lo tome", cuando cobre la pieza. Lo mismo sucede con el que ha caído en las trampas puestas por él, pues el cazador tiene su posesión desde que tiene la posibilidad física de tomarlo (art. 1922, inc. b). No obstante, está ínsito en el sistema que debe concretar ese acto con la aprehensión; debe realizar un acto material, para que no se interprete que desistió.

El animal para ser cazado debe vivir en su libertad natural, es decir debe ser *res nullius*. Esto ocurre naturalmente con los salvajes, y circunstancialmente con los domesticados cuando recuperan esa libertad. Se excluye a los animales domesticados (mientras lo son), y también a los domésticos, porque no sólo ya no viven en su libertad natural sino también porque tienen dueño (art. 1947, inc. b, ii).

Cabe advertir, aunque el artículo 1948 no lo diga, que la caza puede y debe practicarse según los reglamentos de la policía, es decir, de acuerdo a las distintas normas dictadas por las administraciones provinciales en ejercicio del poder de policía que les es propio y a las leyes sancionadas a ese mismo efecto, como son por ejemplo los reglamentos de caza y las disposiciones contenidas a ese efecto en algunos códigos rurales. Por otra parte, no se puede cazar en terrenos ajenos sin permiso del dueño. Si esto ocurre, el animal cazado pertenece al dueño del inmueble.

b.2) Persecución del animal herido

El acto de caza, con armas, comienza cuando se dispara el tiro y se hiere al animal; sigue cuando es perseguido por el cazador, mientras huye, y finalmente termina cuando quien lo hirió lo toma, vivo o muerto. Es, pues, un acto en tres etapas; iniciado el mismo, nadie puede interrumpirlo: de ahí que, mientras el animal huye, nadie puede tomarlo; tampoco si hubiera caído, ya sin fuerzas para continuar su huida o hubiese muerto. Por eso, si alguien lo toma, o cae en su trampa, debe entregárselo al cazador, porque éste, mientras lo fuese persiguiendo, tiene preferencia para convertirse en el dueño del animal.

b.3) Lugares en los que se puede cazar

Cazar en terrenos propios no es más que ejercer el derecho de propiedad sobre su propio fundo, es uno de los tantos actos posibles de disposición material sobre la cosa. El único que puede cazar ahí es el dueño del terreno, a menos que preste autorización a otro para ello.

Por lo tanto, si alguien caza en terreno ajeno sin permiso, no tiene derecho a la presa, aunque la hubiese tomado o hubiese caído en sus trampas.

Sin perjuicio de lo expuesto, diversas normas prohíben la caza en ciertos lugares especialmente protegidos.

c) Pesca

En cuanto a la pesca, el artículo 1949, donde se establecen requisitos para adquirir una especie acuática, aclara que se puede apropiarse si se pesca en aguas de uso público o con autorización. Dice el artículo 1949 lo siguiente: "Quien pesca en aguas de uso público, o está autorizado para pescar en otras aguas, adquiere el dominio de la especie acuática que captura o extrae de su medio natural".

Esta norma es equivalente al artículo 1948, que se refiere a la caza de animales. El pez se hace del pescador cuando es aprehendido por éste, lo que ocurre cuando lo "captura o extrae de su medio natural".

Según lo que dispone esta norma, los peces de las aguas de uso público (mares, ríos y lagos navegables), o de las aguas privadas pero si se cuenta con permiso, serían *res nullius*; sin embargo, son del dominio de las provincias con litoral marítimo los recursos vivos que pueblen las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce millas marinas (art. 31, ley 24.922), y son del dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación los existentes en las aguas de la zona económica exclusiva argentina y en la plataforma continental argentina (art. 41, ley 24.922). Éstas se extienden hasta las 200 millas marinas, contadas desde la línea de base del "Anexo I" de la ley 23.968, entendiéndose por milla marina la milla náutica internacional, equivalente a 1.852 metros (art. 71, ley 23.968). El mar territorial argentino se extiende hasta las doce millas marinas, y la zona contigua argentina abarca desde ese límite hasta las veinticuatro

millas marinas, en ambos casos medidas desde aquellas mismas líneas de base (arts. 31 y 41, ley 23.968).

Si bien en principio la pesca es libre en aguas de uso público, como son las del mar territorial argentino (hasta 12 millas marinas), ríos navegables o no navegables, y lagos navegables, ello sólo puede hacerse conforme a las disposiciones del Código y reglamentaciones generales o locales, atento el poder de policía administrativa que tienen las provincias en sus respectivas jurisdicciones.

d) Enjambres

Aunque las abejas reciben, ya desde el Derecho Romano, la consideración de animales salvajes, de la regulación contenida en el Código se desprende que son merecedoras de un tratamiento diferenciado del que se dispensa a aquéllos, puesto que su huida —o su salida de la posesión de su dueño— no las convierte, de modo automático, en animales carentes de dueño, como ocurre con los que son objeto de la caza.

Establece el artículo 1950 los requisitos para que sea posible conservar o adquirir un enjambre: "El dueño de un enjambre puede seguirlo a través de inmuebles ajenos, pero debe indemnizar el daño que cause. Si no lo persigue o cesa en su intento, el enjambre pertenece a quien lo tome. Cuando se incorpora a otro enjambre, es del dueño de éste".

Si las abejas tienen dueño, éste no pierde su propiedad porque ellas escapan o posen en un árbol, o se introduzcan en un inmueble ajeno, mientras fuese en seguimiento del enjambre. Puede ingresar sin permiso a una propiedad privada, pero debe indemnizar el daño que cause. Se advierte aquí una excepción a la facultad de exclusión que tiene el dueño (art. 1944).

Si abandonare su búsqueda o no las reclamare, el Código entiende que las abejas se transforman en cosas sin dueño, y entonces podrán pertenecer al que las tome porque se hacen susceptibles de apropiación.

e) Cosas no susceptibles de apropiación

Dice el artículo 1947: "...b) no son susceptibles de apropiación:

- "i) las cosas perdidas. Si la cosa es de algún valor, se presume que es perdida, excepto prueba en contrario;

- "ii) los animales domésticos, aunque escapan e ingresen en inmueble ajeno;

- "iii) los animales domesticados, mientras el dueño no desista de perseguirlos. Si emigran y se habitúan a vivir en otro inmueble, pertenecen al dueño de éste, si no empleó artificios para atraerlos;

- "iv) los tesoros".

El inciso b, del artículo 1947 es la contracara del inciso a; en este último se mencionan las cosas que son susceptibles de apropiación, porque no tienen dueño o han sido abandonadas por sus dueños; aquél enumera las que no son apropiables. No menciona a los inmuebles, por ser innecesario, porque siempre tienen dueño (art. 236, inc. a). Y lo mismo sucede con las demás cosas que menciona, pues todas ellas tienen dueño: los *animales domésticos*, mientras no hayan sido abandonados por sus dueños; los *domesticados*, si son perseguidos por sus dueños; las *cosas perdidas*, porque pertenecen a alguien que no se desprendió voluntariamente de ellas.

El principio es, pues, que las cosas que tienen dueño nunca pueden ser apropiadas.

Las *cosas perdidas* deben ser restituidas. Si fuesen transmitidas a un sucesor de buena fe, el dueño las puede reivindicar (art. 1895), acción que sólo se detendría ante la usucapión (art. 1898).

Los *animales domésticos* son aquellos que viven con el hombre desde hace muchísimas generaciones, prestándole también una cierta utilidad, o simplemente haciéndole compañía y gozando de una relativa libertad, siendo alimentados y cuidados. Ellos normalmente tienen dueño, y en consecuencia no son susceptibles de apropiación; lo serían si hubieren sido abandonados.

Los *animales domesticados* son en realidad animales salvajes que, por medio de la domesticación, se los ha acostumbrado a la vista y compañía del hombre, para hacerlos útiles a él haciéndoles cumplir algún trabajo; a veces huyen y logran recuperar su antigua libertad. Mientras viven con el hombre, tienen la categoría de domesticados, tienen dueño y nadie puede apropiarse de ellos; pero, vuelven a ser *res nullius* si recuperan su antigua libertad.

Se puede perder el dominio de estos animales también "si emigran y se habitúan a vivir en otro inmueble". Esto es así siempre y cuando el dueño del otro inmueble no haya empleado "artificios para atraerlos". Si esto ocurrió, el dueño originario puede reivindicarlos.

III. Tesoros

a) *Concepto de tesoro*

Según el artículo 1951: "Es tesoro toda cosa mueble de valor, sin dueño conocido, oculta en otra cosa mueble o inmueble. No lo es la cosa de dominio público, ni la que se encuentra en una sepultura de restos humanos mientras subsiste esa afectación".

Este artículo define expresamente al tesoro. Dispone que debe reunir cuatro condiciones: 1) es "toda cosa mueble de valor", debiéndose entender por tal el objeto material que, además de poder desplazarse (art. 227), tenga un valor mayor al común, no quedando sin embargo circunscripto el concepto a las monedas, joyas y objetos preciosos; 2) "sin dueño conocido"; esto es, tiene dueño, pero no se sabe quién es; 3) "oculto en otra cosa mueble o inmueble"; esto es esencial para diferenciar al tesoro de la cosa perdida, y 4) "no estar en una sepultura". Puede ser de creación antigua o reciente porque nada dice el Código en este sentido, ha querido evitar discusiones, aunque la antigüedad es un dato relevante para entender que no hay dueño conocido, o para presumir esta circunstancia.

El tesoro, por definición, entonces, no tiene dueño conocido, o bien puede haber sido abandonado, como ha sucedido alguna vez. Pero no será tesoro si no ha desaparecido la memoria de su dueño.

Cuando se encuentra una cosa perdida, corresponde buscar al dueño o publicar avisos para encontrarlo, y ello genera derecho a una recompensa. Aquí no se lo busca ni se publican avisos, ya que el tesoro carece de "dueño conocido". La búsqueda se supone inútil ya que la cosa aparenta, por sus condiciones externas, la poca probabilidad de encontrarlo.

Los objetos que se encuentren en los sepulcros (bóveda, sepultura o nicho) están excluidos de la categoría de tesoro, porque se presume que tienen dueño, ya que no fueron puestos ahí por razones de ocul-

tamiento sino en homenaje a la memoria del muerto, por cumplimiento de promesas, creencias, motivos religiosos. Los dueños de esas cosas son los derechohabientes del muerto.

Tampoco configura un tesoro la cosa mueble oculta que pertenezca al dominio público (v. gr.: los documentos oficiales del Estado, art. 235, inc. f).

b) *Inmueble o mueble gravado*

Como el tesoro es cosa mueble, no pertenece al propietario del inmueble, es decir al propietario del suelo donde se encuentre enterrado, o al dueño de la casa donde se haya escondido: él pertenecerá al primero que lo haga visible (art. 1952). Por eso, porque es cosa distinta de lo hipotecado, y no es accesorio del suelo ni del edificio, él no está comprendido en la garantía real, sea ésta hipoteca o anticresis.

Igual conclusión cabe respecto de la cosa prendada, ya que su acreedor no tiene derecho a usarla (art. 2226), ni a buscar tesoros.

c) *Concepto de descubridor*

Dispone el artículo 1952 que "Es descubridor del tesoro el primero que lo hace visible, aunque no sepa que es un tesoro. El hallazgo debe ser casual".

Se apropia del tesoro, en la proporción que le corresponda, quien lo halle, y a éste se lo llama "descubridor"; él no necesita aprehenderlo (*corpus*) sino, simplemente, hacerlo "visible", y no necesita, en ese momento, tomar posesión de él, y lo hace suyo aun en el caso de que no haya tenido esa intención, pues lo hallado y hecho visible, lo ha adquirido (total o parcialmente, según el caso), aunque no haya reconocido que era un tesoro.

El descubridor es quien saca a la luz, revela la existencia.

Para ser considerado descubridor, el hallazgo debe ser "casual", esto es, sin querer, sin habérselo propuesto. No debe ser el fruto de trabajos destinados a buscar un tesoro determinado, ya sea que se tenga información o meras sospechas. Se busca así evitar que la gente se ponga a buscar y, especialmente, a excavar en predios ajenos con la intención de encontrar un tesoro.

MNR

d) *Personas que pueden buscar tesoros*

Según el artículo 1952: "Sólo tienen derecho a buscar tesoro en objeto ajeno los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, con excepción de la prenda". Pueden buscar tesoros: a) los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, ya sea un objeto propio, parcialmente propio, o ajeno, con excepción de la prenda; b) los terceros que tengan permiso del dueño.

Si el hallazgo no es casual, y la persona no tiene derecho a buscar, nada le corresponde. Esto es así para evitar que personas se introduzcan en lugares ajenos para buscar tesoros y causar severas incomodidades.

e) *Derechos del descubridor*

La cuestión la resuelve el artículo 1953 en los siguientes términos: "Si el tesoro es descubierto en una cosa propia, el tesoro pertenece al dueño en su totalidad. Si es parcialmente propia, le corresponde la mitad como descubridor y, sobre la otra mitad, la proporción que tiene en la titularidad sobre la cosa.

"Si el tesoro es descubierto casualmente en una cosa ajena, pertenece por mitades al descubridor y al dueño de la cosa donde se halló.

"Los derechos del descubridor no pueden invocarse por la persona a la cual el dueño de la cosa le encarga buscar un tesoro determinado, ni por quien busca sin su autorización. Pueden ser invocados si al hallador simplemente se le advierte sobre la mera posibilidad de encontrar un tesoro".

e.1) *Propiedad del tesoro*

Este artículo 1953 sigue la vieja tradición romana: a quien ha encontrado un tesoro en su propio fundo, le pertenece; pero si lo ha hallado en predio ajeno (ya sea un titular de un derecho real sobre cosa ajena, o un tercero descubridor o con permiso), la mitad es de él y la otra mitad del propietario del inmueble, que es lo que dispone este artículo.

El sistema romano ha tenido influencia en los códigos latinos. En

cambio, en el Derecho inglés, se atribuyó primero el tesoro al hallador (así sigue ocurriendo en los Estados Unidos de América), y desde el año 1276 a la Corona.

El hallador se queda con la mitad del tesoro, y el nudo propietario, con la otra mitad.

Así, por ejemplo, si un usufructuario encuentra un tesoro, le pertenece la mitad, y la otra al nudo propietario. Si es un tercero con permiso, también. Y si se trata de un tercero sin permiso y el hallazgo es casual, se aplica el mismo criterio.

e.2) *Situación de los cónyuges*

Si el marido o la mujer hallan un tesoro, éste para ellos es un bien ganancial (art. 465). Y si quien encontró el tesoro es un tercero, éste se hará dueño de la mitad, y la otra mitad pertenece como bien ganancial a los cónyuges, aunque el propietario del inmueble donde se halló el tesoro fuere solamente uno de ellos.

e.3) *Persona a la que se le encomienda buscar*

Tampoco puede pedir la mitad del tesoro el sujeto al cual el propietario del inmueble le encargó buscarlo, y lo mismo si el encargo se lo hubieran hecho otros sin autorización del propietario, porque en ambos casos no hay casualidad ni azar en el descubrimiento, lo que es condición esencial para tener derecho a la mitad de lo hallado como descubridor.

Además de faltar casualidad, la persona está cumpliendo un trabajo para quien lo empleó en esas labores, de manera que lo que halle no es para él sino para quien le encargó los trabajos.

La última parte del artículo 1953 introduce una variante. El caso, generalmente, es el del obrero que es llamado para realizar refacciones en un inmueble o excavaciones en el suelo, pero no con el objeto de encontrar un tesoro; sin embargo el propietario le advirtió que pusiese atención, porque podría encontrar un tesoro. No se sabe si esta advertencia fue en broma o en serio, pero el hecho fue que el obrero, trabajando para su patrón con otro objeto, por azar halla el tesoro. El

Tribunal de Rouen, en sentencia de enero de 1853, decidió la cuestión reconociendo la mitad de la propiedad del tesoro al obrero.

El Código sigue esta regla ya que dispone que le pertenece al tercero la mitad si "simplemente se le advierte sobre la mera posibilidad de encontrar un tesoro". Entonces, si la advertencia fue categórica, no habría casualidad, pero si es una "mera posibilidad", no segura, el sujeto tiene derecho a la mitad porque se considera que el hallazgo fue casual.

f) *Búsqueda por el propietario de un tesoro*

El caso está previsto por el artículo 1954: "Cuando alguien pretende que tiene un tesoro que dice haber guardado en predio ajeno y quiere buscarlo, puede hacerlo sin consentimiento del dueño del predio; debe designar el lugar en que se encuentra, y garantizar la indemnización de todo daño al propietario. Si prueba su propiedad, le pertenece. Si no se acredita, el tesoro pertenece íntegramente al dueño del inmueble".

Es un caso excepcional de quien dice ser propietario de un tesoro en predio ajeno y puede entrar a buscarlo.

Este artículo establece, como principio, pues, que cuando se conoce o presume la existencia de un tesoro en fundo ajeno, se puede buscar sin el permiso del propietario del predio bajo ciertas circunstancias.

El artículo 1954 prevé el caso de quien se atribuye la propiedad de cosas que están guardadas en un inmueble ajeno. Si éste fuera el propietario esas cosas no serían tesoro porque tienen dueño, y el tesoro por definición no tiene propietario conocido. Pero él va a tener que demostrar la propiedad; de lo contrario, no tendrá ningún derecho y le pertenecerá al dueño del inmueble.

Si no obtiene el consentimiento del dueño del terreno, no puede ingresar en éste sin el permiso (a pesar del texto legal), y deberá solicitarle la autorización al juez en lo civil que corresponda a la ubicación del inmueble, el que seguramente va a acceder al pedido, pero con citación del propietario del terreno. Se configura una excepción a la facultad de exclusión que asiste al dueño (art. 1944).

IV. Régimen de cosas perdidas

a) *Introducción*

El Código establece que si alguien encuentra y toma una cosa perdida, debe restituirla o entregarla a las autoridades. Dice el artículo 1955: "El que encuentra una cosa perdida no está obligado a tomarla, pero si lo hace asume las obligaciones del depositario a título oneroso. Debe restituirla inmediatamente a quien tenga derecho a reclamarla, y si no lo individualiza, debe entregarla a la policía del lugar del hallazgo, quien debe dar intervención al juez".

Como de las cosas perdidas no se desprendió voluntariamente el propietario, y, por otra parte, la intención de renunciar no se presume, ellas no son susceptibles de apropiación (art. 1947, inc. b, i). Pero podría tomarlas quien las halle con la sola intención de restituírselas a su dueño, aunque no lo conozca; si lo hace, tendrá las obligaciones del depositario a título oneroso, entre otras la de cuidar las cosas con la misma diligencia que pone en las propias, y la de restituirlas a su dueño.

Dispone el artículo 175 del Código Penal que "Será reprimido con multa de mil pesos a quince mil pesos:

"1°. El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca o un tesoro y se apropiare la cosa o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las prescripciones del Código Civil".

La tutela penal está dada a fin de garantizar la observancia de normas legales específicamente dadas en el Código Civil.

El hallador no tiene obligación de recoger las cosas perdidas por su dueño; por eso el Código, para premiar su honestidad y resarcirlo de algún modo de las incomodidades sufridas para hacer llegar las cosas a su dueño, pone a cargo de éste el pago de una recompensa.

b) *Concepto de cosa perdida*

Cabe entender por cosa extraviada (*res desperdita*) la que ha salido de la custodia de su propietario o poseedor, de modo que éste ignore dónde se encuentra. Estos dos elementos, el objetivo y el subjetivo, deben concurrir para que se considere que ha habido una pérdida.

En su consecuencia, la cosa hallada debe reunir los siguientes caracteres: a) ser ajena (*res aliena*), puesto que presupone un propietario o poseedor anterior; b) que no esté en poder de nadie (*res vacua possessionis*), es decir, que persona alguna ejerza sobre ella tenencia o situación de hecho semejante, pues de lo contrario se cometería un hurto o robo, y c) que no haya sido abandonada por su dueño (*res derelictae*) ni se trate de una cosa sin dueño (*res nullius*).

c) *Deber de avisar y restituir*

Quien halle la cosa perdida debe poner diligencia en informar a quien tenga derecho a la cosa (v. gr.: dueño, usufructuario, etc.), si lo conociere, o "individualiza"; esto último se refiere al hecho de que muchas veces en la misma cosa hallada se está indicando, o está grabado en ella, quién es el dueño o su dirección.

El término "inmediatamente" no debe interpretarse en forma demasiado literal, porque tal vez el que encontró la cosa debe hacer alguna averiguación para saber quién es el propietario; una demora de pocos días no lo puede privar de la recompensa sobre todo si estuvo investigando a quién podía corresponder la cosa.

Parecería que la obligación de entrega inmediata de la cosa, cuando eso fuera posible objetivamente, la impone el Código para que no haya ni siquiera una sombra de duda sobre las intenciones del hallador; así, si han transcurrido varios días del hallazgo sin que la cosa hubiese sido entregada a su titular, quien era fácilmente ubicable, y se la entregan recién después que ha puesto avisos ofreciendo recompensa, ella le puede ser negada y puede perder el derecho a ser compensado por los gastos en que hubiere incurrido, en la manutención de la cosa o para su entrega. Será en todo caso una cuestión de hecho que deberá decidir el juez.

Aunque el Código no lo diga expresamente, se entiende que no corresponde el pago de recompensa a quien halló la cosa cuando tiene obligación de guardarla para quien la extravió, por ejemplo en un vehículo de transporte público, o en un vestuario de un club donde el dueño se la olvidó o la perdió, cuando quien halló la cosa no fuese ajeno al servicio público o lugar en el que se extravió.

d) *Falta de individualización del sujeto con derecho a la restitución*

Si el hallador hubiese conocido, o podido conocer, al sujeto con derecho a la cosa hallada, debe dársela inmediatamente, pero si no supiese quién es, debe entregársela a la policía del lugar la que dará intervención al juez, que en este caso será el juez en lo civil que corresponda a la jurisdicción donde la cosa fue hallada, y que quedará encargado de concretar el procedimiento, que deberá ser impulsado de oficio, para hallar al dueño del objeto extraviado y recibido en el juzgado o puesto a su disposición.

e) *Transmisión de la cosa a un tercero de buena fe*

La persona que encuentra una cosa perdida, como se dijo, debe restituirla a quien corresponda, o entregarla a la policía. Ahora, si en lugar de seguir ese camino, decide transmitirle la cosa a un subadquirente, éste, aun cuando sea de buena fe y a título oneroso, está expuesto a la reivindicación del titular del derecho real, ya que no hay adquisición legal cuando se trata de cosas perdidas (art. 1895). La única posibilidad que le queda al tercero es la usucapión, breve o larga, según si es de buena o de mala fe.

f) *Derecho a la recompensa y a los gastos*

Dice el artículo 1956: "La restitución de la cosa a quien tiene derecho a reclamarla debe hacerse previo pago de los gastos y de la recompensa. Si se ofrece recompensa, el hallador puede aceptar la ofrecida o reclamar su fijación por el juez. Sin perjuicio de la recompensa, el dueño de la cosa puede liberarse de todo otro reclamo del hallador transmitiéndole su dominio..."

Como el que tiene derecho a la cosa hallada ha recibido un servicio, cuando el hallador ha debido incurrir en gastos de conservación, o de traslado para su entrega, etcétera, está justificada la exigencia de la norma de que quien se beneficia con ellos debe resarcir a aquel que los hizo, pues son gastos sin los cuales la cosa no podría haber sido conservada, y ello es concordante con lo que se dispone para quien

hace mejoras necesarias (art. 1938), pues de lo contrario el que recupera la cosa tendría un enriquecimiento sin causa.

La recompensa por el hallazgo se justifica también como un incentivo para que el hallador tome la cosa y la devuelva, para lo cual, como se dijo anteriormente, deberá ser diligente.

Sin embargo, podría ser que el dueño de la cosa perdida no tenga ya interés en ella, y en ese caso puede exonerarse de todo reclamo (gastos y otros) cediéndola a quien la halló, no pudiendo éste, en consecuencia, continuar con sus reclamos. Esta "transmisión" a favor del hallador es virtualmente un abandono de la cosa para persona determinada, porque no necesita aceptación del beneficiario, con lo que queda extinguido el dominio para el anterior propietario.

El Código no dice cuál debe ser la recompensa, de manera que si las partes, hallador y propietario, no se ponen de acuerdo en ella, deberían ocurrir a una mediación y en su defecto al juez en lo civil que corresponda, en principio, de la jurisdicción del lugar donde la cosa fue hallada.

En el caso de que se hubiese ofrecido una recompensa, quien formuló la promesa queda obligado en los términos de los artículos 1803/1806.

g) *Dueño que no se presenta. Subasta*

La segunda parte del artículo 1956 dispone que "Transcurridos seis meses sin que se presente quien tiene derecho a reclamarla, la cosa debe venderse en subasta pública. La venta puede anticiparse si la cosa es perecedera o de conservación costosa. Deducidos los gastos y el importe de la recompensa, el remanente pertenece a la ciudad o municipio del lugar en que se halló".

Aunque no lo dice la norma, deberán ponerse uno o más avisos, y como ellos deben ser puestos por el juez, pueden ser los edictos judiciales.

También el juez podría acudir a otros métodos para individualizar al titular, como librar oficios a la Policía, a la Secretaría Electoral, al Ministerio del Interior, entre otros. Puede ser que algunos objetos valiosos tengan registros a cargo de particulares que permitan la identificación.

El juez deberá esperar seis meses, período en el que el dueño de la cosa deberá presentarse. No se aclara desde cuándo corren los seis meses, si desde que se publica un aviso o desde que la Policía entregó el objeto perdido.

Si el dueño no apareciere, o no justificare su derecho, el juez procederá a la venta de la cosa en pública subasta, deduciéndose de lo producido por ella los gastos de conservación, la recompensa debida al hallador, los gastos de los avisos, de la subasta y la comisión del martillero, y cualquier otro que se hubiese generado. El saldo será entregado a la municipalidad del lugar en que se halló la cosa, o al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si correspondiese.

Según el artículo 236, inciso d, pertenecen al dominio privado del Estado "las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas". Aquí, en principio, no es la cosa sino el dinero obtenido en la subasta.

h) *Adelanto de la subasta*

El artículo 1956 prevé también que puede adelantarse el plazo para esperar al propietario, antes de ordenar la subasta judicial. En los casos previstos, cosa "perecedera" (en breve plazo) o de "conservación costosa", el juez puede disponer que la subasta se realice antes de los seis meses, y que la cosa se entregue al adquirente.

V. Transformación de cosas muebles

El Código regula distintos casos de transformación de una cosa ajena en una nueva, y las distintas soluciones según sea posible, o no, volver al estado anterior y la buena o mala fe del transformador. Para que se aplique la solución prevista por el Código es necesario que el especificador obre sin la conformidad del dueño de la materia. Si media un acuerdo (v. gr.: sastre al que se le lleva la tela para la confección de un traje), las partes se regirán por lo convenido.

En efecto, prevé el artículo 1957 que "Hay adquisición del dominio por transformación si alguien de buena fe con una cosa ajena, mediante su sola actividad o la incorporación de otra cosa, hace una nueva con

intención de adquirirla, sin que sea posible volverla al estado anterior. En tal caso, sólo debe el valor de la primera.

"Si la transformación se hace de mala fe, el dueño de la materia tiene derecho a ser indemnizado de todo daño, si no prefiere tener la cosa en su nueva forma; en este caso debe pagar al transformador su trabajo o el mayor valor que haya adquirido la cosa, a su elección.

"Si el transformador es de buena fe y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el dueño de la materia es dueño de la nueva especie; en este caso debe pagar al transformador su trabajo; pero puede optar por exigir el valor de los gastos de la reversión.

"Si el transformador es de mala fe, y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el dueño de la cosa puede optar por reclamar la cosa nueva sin pagar nada al que la hizo; o abdicarla con indemnización del valor de la materia y del daño".

a) *Transformación y cosa no reversible*

Este artículo regula la transformación como modo de adquirir el dominio, antes llamada también especificación. Para que haya transformación es necesario que una persona, con su trabajo sobre materia ajena, realice un objeto nuevo, distinto del material utilizado (v. gr.: una estatua con mármol ajeno), y que lo haga con intención de adquirirlo. Si falta este elemento subjetivo no hay especificación. Es posible que el transformador aporte sólo su trabajo, o que también incorpore otra cosa.

El Código adopta la solución de los proculyanos, si la transformación se hizo de buena fe y la materia prima no puede volver a su estado anterior. El transformador, en este caso, sólo debe pagar el valor de la cosa utilizada.

El transformador dispone de la materia de otro (tiene el *corpus*), sin saber que es ajena (buena fe), y la transforma en un nuevo objeto (le agrega trabajo y quizás material), y esto lo hace con intención de adquirirlo (*animus domini*).

Aquí el dominio sobre la materia se ha extinguido para su propietario, naciendo un crédito contra el especificador por el valor de la misma.

Este derecho de crédito sólo será posible cuando no se aplique el artículo 1895, pues según esta norma cuando el poseedor es de buena fe y a título oneroso de cosas no robadas ni perdidas, nada se le puede reclamar. Dado que, por hipótesis, el transformador obra de buena fe, la solución de la norma sólo parece viable cuando la materia ajena haya sido hurtada o perdida, o cuando falte el título oneroso. El transformador adeuda al propietario de la materia su valor, pues de lo contrario habría un enriquecimiento sin causa; y no podría escudarse en lo dispuesto por el artículo 1895 si la materia prima empleada era cosa perdida o hurtada.

Éste es el único caso en que el transformador se hace dueño de su obra directamente, sin opción: cuando transformó la materia prima de buena fe y ella no es reversible; porque si fuera reversible, quien se queda con la obra es el dueño de la materia prima (tercer párrafo).

Y cuando el transformador fuere de mala fe, no se queda con la cosa por su propia decisión sino por la elección que haga el dueño de la materia prima: si no es reversible, se aplica el segundo párrafo, y si pudiera volver a su estado anterior, el dueño de la materia puede optar entre quedársela o abdicarla (cuarto párrafo).

Como el especificador es de mala fe, porque sabía o debía saber que la materia prima era ajena, y ésta no vuelve a su forma anterior, él no adquiere la nueva especie si el propietario de la materia quiere quedarse con ella, pero en ese caso éste debe pagarle a aquél su trabajo o el mayor valor adquirido por la transformación. Y si el dueño de la materia no la quiere en su nueva forma, tiene derecho a ser indemnizado de todo daño. Obsérvese que si el transformador es de buena fe sólo debe pagar "el valor" de la cosa utilizada, mientras que si es de mala fe debe indemnizar "todo daño".

b) *Caso en que es posible volver al estado anterior*

Si la transformación se hizo de buena fe, como en el caso del primer párrafo, pero a diferencia de éste, la materia prima empleada puede volver a su estado anterior o ser separada de la cosa, en este caso, dice este artículo, "el dueño de la materia es dueño de la nueva

especie", pero debe pagar el trabajo al transformador o artesano. Pero él puede elegir la solución de que el transformador le pague los gastos de la reversión y volver todo a su estado anterior.

Si el transformador obró de mala fe, el dueño de la cosa empleada puede optar por quedarse con la cosa nueva sin pagar nada, ya que la mala fe le hace perder el derecho a cobrar su trabajo, o dejársela al transformador con derecho a recibir, además del valor de la materia, la indemnización del daño.

VI. Accessión de cosas muebles

a) *Accessión*

Debe tenerse en cuenta aquí que éste es un modo de adquirir el dominio por un título autónomo, distinto a la propiedad que se tiene sobre los accesorios de la cosa (art. 1945), porque el dominio de éstos es dado por la ley en virtud del dominio que se tiene sobre la cosa principal, y no por un título independiente. La adquisición de los frutos es consecuencia del ejercicio del *ius fruendi* (que generalmente asiste al dueño), mientras que la accesión contempla la adquisición de una cosa por el dueño de otra, luego de una unión o incorporación, lo que ocurre a veces naturalmente, y en otras por obra del hombre.

La accesión puede tener lugar cuando una cosa mueble se adhiere a un inmueble (plantación, etc.), a otra cosa mueble (art. 1958), o cuando la reunión es de dos inmuebles (aluvión). Se la clasifica en natural o artificial, según intervenga, o no, la mano del hombre.

La accesión se diferencia de la transformación porque en la primera se unen dos cosas distintas, mientras que en la segunda alguien aporta trabajo y realiza un objeto con la materia de otro.

b) *Accessión de cosas muebles*

El caso está previsto por el artículo 1958: "Si cosas muebles de distintos dueños acceden entre sí sin que medie hecho del hombre y no es posible separarlas sin deteriorarlas o sin gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al dueño de la que tenía mayor valor eco-

MNR

nómico al tiempo de la accesión. Si es imposible determinar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios adquieren la nueva por partes iguales".

Cuando dos o más cosas muebles que pertenecen a distintos dueños se unen de manera tal que vienen a formar una sola, el propietario de la cosa más valiosa adquiere la nueva pagándole al dueño de la otra su valor. Ello en el caso de no ser posible su separación sin deterioro, o de que ésta resulte excesivamente dificultosa o costosa (v. gr.: el motor de un barco). Si las cosas unidas pueden separarse, no hay accesión y cada dueño tiene derecho a pedir la separación.

La accesión debe producirse "sin que medie hecho del hombre", esto es, casual. Si hubiera hecho del hombre la situación debe resolverse por lo previsto en el caso del artículo anterior (transformación), o si ambos están de acuerdo habrá que sujetarse al contrato entre ellos.

Aquí se refiere el Código a la adquisición del dominio por accesión de cosas muebles, cuando siendo de distintos propietarios las cosas se adhieren (por ejemplo, granos, aceites, vinos, etc.). Se debe distinguir si hay, o no, cosa de mayor valor económico; si la hay el dueño de ella adquiere el dominio del todo, pagando a los otros el valor de la materia adherida. Si no la hay, los antiguos dueños de las cosas se convierten en condóminos de la nueva por disposición de la ley.

No dice el artículo 1957 que quien se queda con la cosa deba indemnizar al otro, pero a esta solución se puede llegar aplicando por analogía lo previsto en el artículo anterior para la transformación. De no ser así se generaría un enriquecimiento sin causa. La indemnización podrán pactarla las partes; si no hay acuerdo la cuestión será resuelta por un juez. Puede consistir en dinero o en la entrega de una cosa de la misma especie a la que se unió.

Cumplidas las tres condiciones previstas: a) accesión de cosas distintas por hecho casual; b) de cosas inseparables; c) donde no hay cosa más valiosa, se produce un condominio cuya fuente es la ley (art. 1894), y en el cual cada propietario adquiere una parte indivisa igual a la que corresponde a los demás.

Si las cosas han sido mezcladas o confundidas por un tercero (hecho del hombre), se estaría en la misma situación: se habría producido un

condominio cuya fuente es la ley. Ello, claro está, sin perjuicio de la responsabilidad de dicho tercero.

Se trata de un condominio que es de indivisión forzosa perdurable (art. 1894), de modo que cada propietario no puede pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común.

VII. Accesión de cosas inmuebles

a) *Aluvión*

Éste es un caso especial de accesión fluvial debida a hechos naturales. Dice el artículo 1959 que "El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación, pertenece al dueño del inmueble. No hay acrecentamiento del dominio de los particulares por aluvión si se provoca por obra del hombre, a menos que tenga fines meramente defensivos.

"No existe aluvión si no hay adherencia de la sedimentación al inmueble. No obsta a la adherencia el curso de agua intermitente.

"El acrecentamiento aluvional a lo largo de varios inmuebles se divide entre los dueños, en proporción al frente de cada uno de ellos sobre la antigua ribera.

"Se aplican las normas sobre aluvión tanto a los acrecentamientos producidos por el retiro natural de las aguas, como por el abandono de su cauce".

Cuando los acrecentamientos de tierra, que reciben los terrenos confinantes con la ribera de aguas durmientes o corrientes, se hacen en forma lenta, casi imperceptible, es decir de modo "paulatino e insensible" por efecto de la corriente de las aguas, se está en presencia del "aluvión por acarreo" o "aluvión" propiamente dicho, y el Código dice que pertenecen a los dueños de las heredades ribereñas.

Si ocurre en las costas del mar pertenecen al Estado (arg. art. 235), aunque cabe recordar que ésta es una cuestión controvertida.

Del artículo 1959 se desprenden las dos primeras condiciones para que haya aluvión: 1) que haya sido producido por un río, arroyo (corriente de agua), o por aguas durmientes, como lagos y lagunas, y 2)

los terrenos del dominio privado, que reciben los acrecentamientos de tierra de esas corrientes de agua, deben ser arcifinios.

El fundamento de esta solución se encuentra en la equidad. A veces la naturaleza da, otras veces quita. La adquisición de la nueva porción de terreno es instantánea, sin necesidad de que el dueño realice acto de ocupación alguno.

El río llega hasta la ribera externa, y ésta tiene su línea o límite en los ríos en las máximas crecidas ordinarias —*plenissimum flumen*— (arts. 235, inc. c, y 1960). Recién se puede hablar de terrenos aluvionales cuando éstos están definitivamente formados y consolidados en tierra firme (sedimentación), sin que estén separados por ninguna corriente de agua que forme parte del río (salvo que sea intermitente); es decir cuando esos terrenos ya no forman parte del río y están fuera de los límites del río, agregados en realidad a los fundos arcifinios.

Como señala el Código, "no obsta a la adherencia el curso de agua intermitente". Por regla, la tierra no debe estar separada del terreno por una corriente de agua que forme parte del río; se requiere la sedimentación. No obstante, cuando la corriente de agua es intermitente, ello no impide la adhesión. "Intermitente" significa que la corriente de agua es discontinua, esto es, que se interrumpe o cesa, y luego prosigue o se repite.

La accesión, esto es, la adquisición del terreno agregado, se produce de pleno derecho, sin necesidad de acto posesorio o jurídico alguno, ni de declaración judicial.

a.1) *El aluvión debe ser natural*

El aluvión es un fenómeno natural, y cuando el acrecentamiento de tierra sobre algunos terrenos no es consecuencia de fenómenos naturales sino de obras hechas por el hombre, ribereño o no, no se trata de la situación prevista por la ley para la anexión de esos terrenos, y en consecuencia los propietarios perjudicados pueden pedir la exclusión de sus terrenos de las aguas ilegítimamente invasoras, y si eso no fuere posible conseguirlo por la existencia de las obras realizadas por los ribereños causantes del perjuicio, pueden demandar la destrucción de esas obras, o el restablecimiento de las cosas a su estado anterior.

a.2) *Aluvión por abandono*

Dice el último párrafo del artículo 1959 que "Se aplican las normas sobre aluvión tanto a los acrecentamientos producidos por el retiro natural de las aguas, como por el abandono de su cauce".

En este artículo el Código prevé, por un lado, el caso del *alveus exciccatus*, es decir aquel en el que el río abandona parcialmente su cauce; se va retirando poco a poco de una de las riberas, para recostarse sobre la otra. El resultado es que sobre la ribera en que se ha retirado, ha quedado al descubierto parte de su cauce, el que se hace de propiedad de los ribereños. También contempla el llamado *alveus derelictus* o abandono de cauce, que recibe la misma solución.

El fundamento de esto es que ya no tiene sentido o razón de ser que los terrenos que formaban parte del cauce sigan siendo del dominio público del Estado, como dispone el artículo 235; primero porque ya no son cauce, y segundo, porque esto es una suerte de correlato con los inmuebles de la orilla de enfrente, que pierden el terreno que el río ocupa como cauce; y en tercer término, porque la situación podría haber sido al revés: ellos podrían haber perdido parte de su terreno que el río tomara como cauce, y los de la orilla de enfrente haberlo ganado.

Es un caso excepcional, pero se ha dado con alguna frecuencia en el país, aunque a veces no en forma lenta, insensible o paulatina, sino más bien en forma súbita, como consecuencia de grandes crecidas por copiosas lluvias.

El Código prevé la misma solución para los dos casos de abandono. Tanto en el caso del cauce parcialmente abandonado como en el supuesto del *alveus derelictus*. El cauce abandonado ya no cumple la finalidad de tal, queda desafectado del dominio público ya que por el cambio deja de ser cauce, mientras que otra parte de la superficie terrestre ha comenzado a serlo. El fenómeno tiene que producirse en forma natural y no por el hecho del hombre.

Se ha presentado esta situación, entre otras, con el río Bermejo, que a partir de 1871 abandonó su cauce y abrió uno nuevo.

a.3) *Aluvión formado a lo largo de varios inmuebles*

Lo que dispone el artículo 1959 parece sencillo y lo es realmente si todos los terrenos van en líneas paralelas hacia el río. Las dificultades comienzan cuando los terrenos tienen límites que van en distintas direcciones o ángulos, porque la distribución debe hacerse en proporción al frente que cada una de las heredades presente frente al río, pero no siguiendo la dirección de la línea de los límites, sino la que corresponda a la obtención del terreno proporcional a la anchura del fundo: para que se pueda cumplir con lo que la norma ordena. Será en todo caso un problema de trigonometría que deberán resolver los peritos agrimensores.

a.4) *Material comprendido en los límites del río*

Dice el artículo 1960: "No constituye aluvión lo depositado por las aguas que se encuentran comprendidas en los límites del cauce del río determinado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias".

Las partículas de tierra, arenas, fango u otros materiales que se encuentren dentro de los límites del río, no pueden nunca constituir aluvión, porque no ha habido adherencia a los terrenos del dominio privado, y además porque no forman parte de ellos sino del curso de agua. Nada de lo depositado que se encuentre dentro del límite del río o lago constituye aluvión.

b) *Avulsión*

Aquí se regula otra forma de accesión, la avulsión, la que opera por una fuerza súbita. Dispone el artículo 1961: "El acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita de las aguas que produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. También le pertenece si ese acrecentamiento se origina en otra fuerza natural."

"Si se desplaza parte de un inmueble hacia otro, su dueño puede reivindicarlo mientras no se adhiera naturalmente. El dueño del otro inmueble no tiene derecho para exigir su remoción, mas pasado el término de seis meses, las adquiere por prescripción.

"Cuando la avulsión es de cosa no susceptible de adherencia natural, se aplica lo dispuesto sobre las cosas perdidas".

b.1) *Concepto de avulsión*

Contrariamente a lo que sucede con el aluvión, en la avulsión el acrecentamiento de los terrenos, generalmente situados río abajo, con cosas susceptibles de adherencia natural, como tierra, arena o plantas, se produce no en forma lenta y paulatina sino por una fuerza súbita, como cuando una porción de terreno de un fundo es desprendida violentamente como consecuencia, por ejemplo, de una gran crecida o inundación, o por efecto de la corriente de las aguas (nunca del hecho del hombre) e incorporada, naturalmente, a otro predio, normalmente situado en la parte inferior del curso de agua o en la ribera opuesta, y que es el que se beneficia con la accesión. Esto ocurre por la fuerza súbita de las aguas o de otra fuerza natural (v. gr.: terremoto, tormenta).

En el primero el acrecentamiento se formó de manera lenta, paulatina, sin que pueda saberse qué inmueble aportó la tierra, mientras que en el segundo es posible saber de qué inmueble proviene el terreno desplazado.

Sin embargo, si se desplaza parte de un inmueble (v. gr.: tierra, arena, plantas), mientras no esté todavía adherido naturalmente al inmueble al cual fueron a parar, el dueño de ellas conserva su dominio y puede reivindicarla. El plazo para esto es de seis meses, plazo que se debe contar desde el día en que aquellas cosas fueron a parar al otro terreno, ya que mientras estén flotando no nace la expectativa de adquirir dominio ajeno. Transcurrido ese plazo, el dueño del inmueble disminuido ya no puede reivindicar, dado que el otro adquiere por prescripción. Claro que todo dependerá también de que la tierra desprendida sea reconocida por su dueño, aunque ya esto es una cuestión de prueba.

Si se tratase de una cosa mueble no susceptible de adherencia natural, por ejemplo las maderas de un muelle, la acción reivindicatoria no sufre esa limitación, ya que se trata de cosas perdidas; y sólo se le podría oponer la prescripción adquisitiva larga.

b.2) *No hay derecho a indemnización*

Si las cosas susceptibles de adhesión están adheridas naturalmente al otro terreno, ya el anterior propietario a quien ellas pertenecían no

puede reivindicarlas, porque aquella adhesión natural por el fenómeno de la avulsión ha sido un título de adquisición del dominio para el propietario del fundo donde ellas fueron a parar, y él no debe compensación ni indemnización alguna. Éste es un título independiente de adquisición del dominio para el propietario del fundo donde se adhirieron naturalmente.

Ahora bien, cabe admitir la posibilidad de que se indemnice al dueño del terreno invadido por los daños que pudiera ocasionar el retiro de las cosas segregadas, antes de la adherencia natural o del cumplimiento del plazo de prescripción.

b.3) *Situación del dueño del inmueble acrecido*

El propietario del terreno del cual las cosas se desprendieron por acción violenta de las aguas tiene el derecho a reivindicarlas mientras no se hayan adherido naturalmente al terreno donde fueron a parar, y cuenta para ello con el plazo de seis meses. Pero él tiene también el derecho de abdicar su propiedad, de abandonar la cosa simplemente. De ahí, pues, que el dueño del terreno donde las cosas fueron a parar no tiene derecho para exigir que ellas sean removidas.

Esto parece una excepción a las facultades materiales y de exclusión (arts. 1941 y 1944) que el propietario tiene sobre su predio, pero en realidad no lo es; porque aquellos artículos están previendo conductas humanas de terceros, por ejemplo cuando éstos ponen alguna cosa en terreno ajeno sin autorización de su dueño. Aquí en cambio se trata de un hecho de la naturaleza, fuerza súbita de la corriente de agua que produce los desprendimientos de aquellas cosas, lo cual constituye un verdadero caso fortuito o fuerza mayor.

Claro que si se produce la adherencia natural, cesa toda posibilidad de reivindicar. Aquí se produce la accesión, de pleno derecho, como modo de adquirir el dominio. Si no hay tal adherencia, entonces el modo de adquirir es la usucapión. El artículo 1961 dice expresamente "las adquiere por prescripción", de modo que se refiere a la prescripción adquisitiva, no a la liberatoria.

b.4) *Cosas no susceptibles de adherencia natural*

El tercer párrafo del artículo 1961 es coherente con el principio de que sólo las cosas susceptibles de adherencia natural, a los terrenos a los que acceden, son objeto de adquisición por avulsión, pues cualquier otra cosa mueble que no posea esa propiedad no puede acceder a ningún predio a ese título. Así, por ejemplo, si la inundación arrastrara muebles hacia otro fundo.

Con toda razón este artículo dispone que en esos casos se aplican las normas sobre cosas perdidas (arts. 1955/1956). Lo serán, pues, si son cosas de algún valor (art. 1947, inc. b, i). El que se apropie de esas cosas, además de ser condenado a restituirlas, deberá indemnizar los deterioros que ellas sufrieren. La acción sólo podría detenerse ante la usucapión larga, ya que no hay aquí buena fe.

c) *Construcción, siembra y plantación*

Cabe recordar que, desde el Derecho Romano, cuando una cosa mueble se incorpora a un inmueble de manera inseparable, se niega la separación de lo incorporado ya que el terreno es lo principal y la cosa mueble lo accesorio (*superficies solo cedit*). Además, en ocasiones se transforma en inmueble por accesión física. Por ende, debe haber una situación permanente, inseparable. Si se tratara solamente de objetos colocados en otro inmueble, su dueño podría retirarlos, pero no es así cuando se produce la incorporación.

Bajo esta óptica, el Código ofrece diversas soluciones a la construcción, siembra o plantación con materiales ajenos, por el dueño o por un tercero, y hasta con trabajo ajeno. Veamos.

Dice el artículo 1962: "Si el dueño de un inmueble construye, siembra o planta con materiales ajenos, los adquiere, pero debe su valor. Si es de mala fe también debe los daños.

"Si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero, los materiales pertenecen al dueño del inmueble, quien debe indemnizar el mayor valor adquirido. Si el tercero es de mala fe, el dueño del inmueble puede exigirle que reponga la cosa al estado anterior a su costa, a menos que la diferencia de valor sea importante, en cuyo caso

debe el valor de los materiales y el trabajo, si no prefiere abdicar su derecho con indemnización del valor del inmueble y del daño.

"Si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero con trabajo o materiales ajenos en inmueble ajeno, quien efectúa el trabajo o quien provee los materiales no tiene acción directa contra el dueño del inmueble, pero puede exigirle lo que deba al tercero".

Es claro que si alguien es dueño del terreno, también de los materiales, y construye, siembra o planta en su inmueble, no hay conflicto alguno. El problema se suscita cuando se trata de personas distintas.

La edificación, siembra y la plantación, como modos de adquirir el dominio, son casos de accesión, no ya por adherencia natural, como el aluvión y la avulsión, sino por adherencia artificial. Aquí sí está el hecho del hombre. También, como en el aluvión y en la avulsión, se verifica en cosas inmuebles.

En esta materia no ha de perderse de vista que siempre el que adquiere lo construido, sembrado o plantado es el dueño del suelo, porque el principio, que nos viene del Derecho Romano, es que "La superficie siempre cede al suelo" (*superficies solo cedit*); así está estructurado en el Código, acogido, entre otros, en el artículo 1945, donde se dejan a salvo los casos de propiedad horizontal y de superficie.

El artículo 1962 contempla, en primer lugar, el caso de que quien siembra, planta o construye, en finca de su propiedad, con materiales que no le pertenecen:

- 1) Si lo hace de buena fe, con semillas, plantas o materiales ajenos, adquiere la propiedad de ellos y de lo obtenido, pero está obligado a pagar su valor a quien era su propietario;
- 2) si lo hace de mala fe, también los hace suyos, pero el dueño de la finca, además de pagar el valor de los materiales, plantas o semillas, podrá ser condenado al resarcimiento de daños y perjuicios.

c.1) *Construcción, siembra o plantación hecha por un tercero*

Dice el segundo párrafo que los materiales pertenecen al dueño, lo cual es lógico, y el derecho del tercero es el de percibir "el mayor

valor adquirido". Parece más razonable que se abone el trabajo, y si correspondiere el valor de los materiales, pero no el mayor valor adquirido por el inmueble.

Ahora si el tercero obró de mala fe, el dueño tiene derecho a exigir que se reponga todo a su estado anterior, y a costa de aquél. Ésta es la regla, ya que nadie tiene derecho a invadir el terreno de otro para sembrar, plantar o construir. No obstante, si la diferencia de valor que resulta es "importante", puede quedarse con la obra y pagar el valor de los materiales y el trabajo, o abdicar su derecho a favor del tercero, en cuyo caso tendrá derecho a percibir el valor del inmueble y el daño sufrido.

Finalmente, si el tercero utilizó materiales o trabajo también ajenos, esto no impide la accesión, y él es responsable frente a quienes aportaron su trabajo o son dueños de los materiales, los que no tienen acción directa contra el dueño del inmueble, pero pueden exigirle lo que le deba al tercero.

Como se dijo, el propietario de las cosas empleadas no tiene acción contra el dueño del terreno para cobrar el valor de sus materiales; puede pedir el valor de la mano de obra, porque su importe pertenece a quien hizo la obra aprovechándose de sus materiales.

En el término "materiales", deben entenderse incluidas también las semillas y plantas o árboles que se hayan incorporado, porque no hay razón alguna para limitar los efectos de la norma únicamente al caso de las construcciones.

En este caso también, como en los anteriores, la obra, siembra o plantación accede al terreno y queda para el propietario del fundo, lo que está en armonía con el principio sentado por el artículo 1945.

c.2) *Invasión de inmueble colindante*

Esta situación está regulada por el artículo 1963 en los siguientes términos: "Quien construye en su inmueble, pero de buena fe invade el inmueble colindante, puede obligar a su dueño a respetar lo construido, si éste no se opuso inmediatamente de conocida la invasión.

"El dueño del inmueble colindante puede exigir la indemnización del valor de la parte invadida del inmueble. Puede reclamar su adqui-

sición total si se menoscaba significativamente el aprovechamiento normal del inmueble y, en su caso, la disminución del valor de la parte no invadida. Si el invasor no indemniza, puede ser obligado a demoler lo construido.

"Si el invasor es de mala fe y el dueño del fundo invadido se opuso inmediatamente de conocida la invasión, éste puede pedir la demolición de lo construido. Sin embargo, si resulta manifiestamente abusiva, el juez puede rechazar la petición y ordenar la indemnización".

Aquí se regula una especie de accesión inversa, ya que la obra no pertenecerá al dueño del suelo, bajo ciertas condiciones.

c.2.1) *Construcción en terreno ajeno de buena fe*

Aquí el Código sólo alude a la construcción, sin mencionar a la siembra o a la plantación, supuestos que entonces no tienen cabida en esta solución excepcional. La solución que implementa es totalmente novedosa, ya que resuelve de manera contraria a la prevista en el Código anterior —para el caso de invasión total del terreno—, donde el dueño del inmueble invadido se quedaba con la obra, previo pago de la indemnización, si no prefería la demolición. Se implementa la llamada "accesión inversa o invertida", reclamada por parte de la doctrina.

La invasión puede ocurrir sobre el suelo o en el subsuelo (v. gr.: un sótano). Podría ocurrir que debajo del suelo se extendiera un garaje, pasando el límite.

Para que funcione este régimen es menester que el constructor sea de buena fe.

Quien edifica en su inmueble, lo hace de buena fe y con materiales propios, pero invadiendo terreno ajeno colindante; sin consentimiento del dueño del inmueble vecino, puede obligarlo a respetar lo construido si no se "opuso inmediatamente de conocida la invasión". Por ende, si el invadido se opone y se lo hace saber al constructor, éste deberá meditar si sigue o no con la construcción, pero a sabiendas del riesgo que está asumiendo. También es posible que el vecino invadido inicie una acción de obra nueva, que detenga la obra iniciada.

Este último no puede destruir lo hecho, y sólo tiene un crédito por

el valor de la parte invadida. Esto es así si no se opuso inmediatamente, porque se supone que si dejó que su vecino avanzara e invirtiera dinero, de alguna manera lo consintió, y estaría obrando de mala fe si luego de terminada la obra exigiera su demolición.

Como se dijo, tiene derecho a que le indemnice el valor de la parte invadida, de modo que su derecho sobre el terreno se achica.

Ahora, "puede reclamar su adquisición total si se menoscaba significativamente el aprovechamiento normal del inmueble y, en su caso, la disminución del valor de la parte no invadida". Puede ocurrir que la venta de la parte invadida deje al inmueble menoscabado, y quizás difícil de aprovechar, en cuyo caso el invasor deberá adquirirlo en su totalidad, o compensar la pérdida de valor del resto del inmueble.

Si el invasor no paga lo que corresponde, entonces el dueño del inmueble invadido puede pedir la demolición de lo construido. La demolición está sujeta al pago de la indemnización.

Se trata de una suerte de venta forzosa, especialmente cuando la construcción se asentó en el terreno del constructor pero invadió parte del terreno vecino. El fundamento de esta solución es que optar por la demolición puede importar un caso de abuso del derecho. Tampoco parece justo, ni económico, adjudicarle la construcción al dueño del terreno invadido. Es una especie de accesión inversa, situación excepcional limitada al supuesto de que el edificante obre de buena fe.

Para que se aplique la norma el invasor debe ser dueño del terreno vecino, donde también se construyó. Obsérvese que el artículo 1963 comienza diciendo "Quien construye en su inmueble, pero de buena fe invade el inmueble colindante..." Es también necesario que terreno y construcción formen un todo inescindible.

c.2.2) Construcción en terreno ajeno de mala fe

Cuando el constructor es de mala fe se vuelve al régimen de la accesión. El dueño del suelo puede pedir la demolición de la obra y la reposición de las cosas a su primitivo estado, pero si no se ponen de acuerdo y el juez interpreta que la postura es "manifiestamente abusiva", puede obligarlo a indemnizar.

Téngase en cuenta aquí que el conocimiento que tiene que tener el propietario del fundo es un conocimiento cierto, efectivo, concreto, y no presumido. Será importante aquí la prueba de este conocimiento del dueño del fundo, porque si él sabía que se estaba construyendo en su terreno y no se opuso a ello, luego no podrá pedir la demolición de la obra y la restitución de las cosas a su estado anterior.

CAPÍTULO VII

LÍMITES AL DOMINIO

MNR

SUMARIO: I. Concepto y caracteres. II. Límites en interés público. III. Límites por razones de vecindad.

I. Concepto y caracteres

El Código Civil y Comercial trata en el Capítulo 4 del Título III del Libro Cuarto la materia relativa a los límites del dominio.

Cabe recordar que el artículo 1941, al definir al dominio perfecto, y señalar las facultades amplias del dueño, aclara "dentro de los límites previstos por la ley": ocurre que ningún derecho es absoluto, en el sentido de ilimitado; establece la Constitución Nacional que los derechos están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio, y eso es lo que acontece con el dominio. Es absoluto porque es el derecho real que otorga la mayor cantidad de facultades "posibles", pero siempre dentro de ciertos límites puestos en consideración al interés general. Claro que estos límites deben ser razonables, si desnaturalizan el derecho, afectarían el derecho de propiedad y serían inconstitucionales.

Establece el artículo 1970 que "Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo", con lo cual, se le reconoce al Estado un extraordinario poder de limitación del dominio, al instituirse el *numerus apertus* para las limitaciones impuestas en el interés público por el Derecho Administrativo.

Sin embargo, en el Código existen algunas limitaciones al dominio

fundadas también en el interés público, como sucede, por ejemplo, con el camino de sirga (art. 1974) o con las cláusulas de inenajenabilidad (art. 1972), aunque tal vez en ellos prevalezcan connotaciones de interés público, como ocurre asimismo con el principio del *numerus clausus*.

De todos modos, las limitaciones al dominio privado, en miras de salvar otros derechos de las propiedades contiguas, son el objeto principal de este capítulo. Estas disposiciones no tienen en realidad otro objeto que el de determinar los *límites* en los cuales debe restringirse el ejercicio *normal* del derecho de dominio, o de conciliar los intereses opuestos de los propietarios vecinos.

Se puede decir, entonces, que límites al dominio son las normas legales (nunca convencionales) que regulan ese derecho real, compatibilizando los derechos y obligaciones que por igual gozan los hombres en sus relaciones de vecindad (en interés predominantemente privado), o en miras de un interés público, para armonizar el derecho privado o individual con el interés general y colectivo.

Se aclara en los Fundamentos que "las normas que son subsidiarias frente a regulaciones administrativas son las relativas a la vecindad, pues las referidas a los márgenes a la disposición jurídica, jamás serían susceptibles de modificación por una norma de menor jerarquía".

Por ende, la norma que prevé la distancia a la que se puede tener "vistas", prevista en el Código (art. 1978), es subsidiaria de una posible norma local que reglamente este aspecto. En cambio, el *numerus clausus* sólo puede ser fijado por una ley nacional, al igual que lo vinculado a las cláusulas de no disponer.

a) *Fundamento*

En cuanto a las relaciones de vecindad, modernamente se han querido justificar los límites al dominio en interés recíproco de los vecinos en las doctrinas, entre otras, del abuso del derecho y del uso excepcional del fundo.

En las "XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil", la Comisión 5 concluyó que "3) El fundamento de los límites radica en la potestad

del legislador que condiciona el reconocimiento del dominio privado al recto ejercicio que de él se haga en función de sus fines individuales y sociales".

En esa comprensión del derecho de propiedad, las denominadas limitaciones a la propiedad privada se vislumbran necesariamente como manifestación y reflejo de su función social, presentándose como el modo de compatibilizar el derecho individual con el interés general y el bien común, siendo en definitiva la naturaleza social —en su sentido funcional— de ese derecho el fundamento de las referidas limitaciones.

b) *Los límites no son servidumbres*

Los límites al dominio son recíprocamente impuestos a los propietarios vecinos por su interés respectivo, y no suponen una heredad dominante, ni una heredad sirviente. En efecto, para que se pueda hablar de servidumbres prediales se requieren dos fundos, soportando la carga sólo el fundo sirviente, pero no el dominante; en cambio, en materia de limitaciones, la posición recíproca de los dos inmuebles es jurídicamente idéntica.

En las servidumbres no pueden tener cabida las obligaciones de hacer como carga del titular del inmueble en su carácter de tal, lo que sí sucede en los límites (por ejemplo: art. 1982).

Los límites son comunes a todos los inmuebles, lo que no sucede con las servidumbres, que pueden o no existir. Los límites no dan lugar a indemnizaciones (art. 1971); por el contrario, las servidumbres pueden generar un derecho al resarcimiento en favor del titular del fundo sirviente (v. gr.: arts. 2166, 2170). Los límites no se extinguen por el no uso.

Por último, cabe puntualizar que las servidumbres pueden originarse en una disposición de la ley (art. 2166) o en el contrato, y en cambio los límites no pueden ser sino legales al no poder modificar las particulares la reglamentación del derecho de dominio.

c) *Daño no indemnizable*

Dispone el artículo 1971 que "Los deberes impuestos por los límites al dominio no generan indemnización de daños, a menos que

por la actividad del hombre se agrave el perjuicio". Se establece la regla de que los límites deben ser aceptados, tolerados, sin derecho a indemnización alguna.

La idea es que los vecinos, al soportar límites al ejercicio de su derecho, sacrifican intereses que no son resarcibles. Es el precio que se paga por vivir en comunidad, en algún caso ello beneficia, en otros, perjudica.

Tampoco el ejercicio del derecho de dominio, en forma regular, genera un derecho al resarcimiento. Ocurre que las actividades que sin causar a los vecinos perjuicio, o ataque a su derecho de propiedad, tuviesen simplemente por resultado privarles de ventajas de que gozaban hasta entonces, no les dan derecho para ser indemnizados por daños y perjuicios. Así, por ejemplo, la elevación de un edificio que privase del sol, o disminuyese la luz.

Esta norma, prevista para conflictos entre vecinos, es también aplicable a la Administración Pública, la que no debe indemnizar las molestias derivadas de la realización de obras públicas, cuando sólo prive a los particulares de ventajas.

La excepción, obviamente, la constituye la hipótesis de que "por la actividad del hombre se agrave el perjuicio". Se podría agregar el caso de que se afecte el derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de la Constitución Nacional.

Claro que cuando se exceden los límites (v. gr.: se produce un ruido que excede la normal tolerancia), en el supuesto de que se cause un daño, el autor debe indemnizar al perjudicado.

II. Límites en interés público

El Código anterior decía que las limitaciones fundadas "sólo" en el interés público se rigen por el Derecho Administrativo. Se eliminó la palabra "sólo", ya que no era exacto, pues el Derecho Público, local, regula también cuestiones atinentes al interés de los vecinos.

El Código aclara, como lo sostenía la doctrina, que las normas que regulan cuestiones de vecindad también son supletorias de las normas administrativas.

El Derecho Administrativo, a diferencia del Código, es local, y

puede variar en cada provincia. Genera temor la idea de que en alguna localidad se limite excesivamente la potestad del dueño, o en forma más severa que en otros lugares. El temor a la variedad, a la constante politización, a la falta de uniformidad y, por qué no decirlo, a la posible arbitrariedad de algún gobernante, genera dudas.

A diferencia de los límites impuestos por razones de vecindad, aquellos impuestos por el interés público gozan de reciprocidad. Por otra parte, no es necesario que concurren dos inmuebles, como suele ocurrir entre vecinos.

Entre los que se fundan esencialmente en el interés público cabe mencionar:

a) *Reservados al Derecho Administrativo*

Como se dijo, reza el artículo 1970 que "Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción".

Este artículo indica que las limitaciones al dominio se rigen principalmente por el Derecho Administrativo, y que las de este capítulo, limitadas a las relaciones de vecindad, son subsidiarias de las normas administrativas de cada jurisdicción.

En las del Código Civil prevalece el elemento individual; en las de interés público, el elemento social, aunque esta división no es estricta.

Ahora bien, las limitaciones en interés público son *lato sensu* objeto del Derecho Administrativo. La Administración Pública regula todo lo relativo al urbanismo y a la edificación, por medio de los códigos de planeamiento (municipales y provinciales) y de los códigos de edificación referentes al uso, ocupación y subdivisión del suelo, etcétera, y que crean numerosas limitaciones a la propiedad privada, tales como la zonificación (zona residencial, comercial, industrial, etc.), donde se establece taxativamente qué tipo de edificios podrán ser construidos, hasta qué altura, para qué fines, superficie

mínima edificada por persona, actividad que podrá desarrollarse en ellos, fondo libre, línea de edificación, etcétera.

Las limitaciones administrativas son generales (rigen para todos los que se encuentren en una misma situación), tienden a proteger al público, actuales, constantes, no se extinguen por el no uso, y no generan derecho a indemnización.

Además de no poder la Administración ejercer su derecho en forma irrazonable, el único límite que en realidad reconocen estas limitaciones es la Constitución Nacional, porque so pretexto de defender el interés general, mediante el mecanismo de limitaciones, no se podría llegar, sin embargo, hasta el extremo de desnaturalizar las garantías constitucionales.

Se encuentran también las *servidumbres administrativas*. La servidumbre administrativa, según los claros términos de Marienhoff, es "el derecho real administrativo constituido por el Estado (*lato sensu*) sobre un bien del dominio privado o del dominio público, con el objeto de que tal bien sea usado por el público en la forma que resulte del acto o hecho constitutivo del gravamen". En cuanto al régimen jurídico, es eminentemente de Derecho Público, no obstante, como lo señala el autor citado, "tiene una obvia 'afinidad' substancial con la servidumbre de Derecho Privado, Civil. De ahí que muchos principios seculares establecidos por la ciencia jurídica respecto a las servidumbres de Derecho Privado, sean aplicables a las servidumbres administrativas". Son indemnizables.

b) Límites a la libre disposición jurídica.

Cláusulas de inenajenabilidad

Se prohíben las cláusulas de no enajenar en los actos a título oneroso (con excepción del contrato de fideicomiso), y se las permiten en los actos a título gratuito.

Dispone el artículo 1972: "En los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales. Estas cláusulas son válidas si se refieren a persona o personas determinadas.

"En los actos a título gratuito todas las cláusulas señaladas en el primer párrafo son válidas si su plazo no excede de diez años.

"Si la convención no fija plazo, o establece un plazo incierto o superior a diez años, se considera celebrada por ese tiempo. Es renovable de manera expresa por un lapso que no exceda de diez años contados desde que se estableció.

"En los actos por causa de muerte son nulas las cláusulas que afectan las porciones legítimas, o implican una sustitución fideicomisaria".

b.1) *Actos a título oneroso*

Conforme a lo establecido por el artículo 234, son casos de inenajenabilidad relativa y, por tanto, están fuera del comercio, las cosas cuya enajenación se hubiese prohibido "por actos jurídicos, en cuanto este Código permite tales prohibiciones". También dice el Código que es prohibida la cláusula de no enajenar a persona alguna, pero no a persona determinada (art. 1972).

Es decir, entonces, que si alguien enajena un inmueble, y en ese acto jurídico se incluye la prohibición de venta ulterior a una "persona determinada", esa cláusula es válida, y si está incluida en el título ella integra el dominio.

Ahora bien, ¿qué sucedería en el supuesto de violación de dicha cláusula? Si ella ha sido puesta como condición resolutoria, ninguna duda cabe de que el anterior propietario puede demandar, judicialmente, la nulidad del acto y reivindicar la cosa (arg. arts. 1966, 1967, 1969 y concs.). Si solamente se hubiere estipulado para el caso de violación una pena de multa, será el cobro de esta multa lo único que podrá perseguir el anterior propietario. Si la cláusula prohibitiva no estuviese pactada como condición resolutoria, ni tampoco impuesta como multa, y ella es violada, cabe interpretar que el anterior propietario puede demandar la devolución de la cosa a este tercer adquirente, porque al estar dicho acto jurídico inscripto en el Registro, éste no puede alegar su buena fe, y aun cuando la cláusula no estuviese registrada, de todos modos le sería oponible, pues su existencia surgiría del correspondiente estudio de títulos.

En cambio, es prohibida la cláusula de no enajenar a persona alguna en los actos a título oneroso; el artículo 1972 dispone la nulidad de la cláusula, y si lo hiciera la enajenación será válida. El artículo se refiere no sólo a la transmisión del dominio, sino a la constitución de derechos reales (así, por ej.: no se puede prohibir la constitución de una hipoteca).

Esto se aplica a inmuebles y a las cosas muebles, registrables o no.

En suma, la cláusula de no enajenar es ineficaz para impedir la transmisión porque la ley, por razones de orden público, procura garantizar la plena disponibilidad del dominio e impedir una vinculación disfrazada de los bienes. Se trata también de favorecer la circulación de la riqueza. El Código instrumentó un sistema contrario a la indisponibilidad ilimitada de los bienes, que se atenúa en los actos a título gratuito.

Lo expuesto encuentra una excepción en el ámbito del fideicomiso (art. 1688).

b.2) *La denominada "inhibición voluntaria"*

Además de las medidas cautelares ordenadas por los jueces, algunas personas, voluntariamente, deciden inhibirse para así protegerse o garantizar derechos de acreedores. Se trata de una autolimitación a la facultad de disponer, especialmente cosas registrables. Estas medidas carecen de efectos respecto de terceros, ya que contrarían lo dispuesto por el artículo 1972 y no encuadran en lo previsto por el artículo 30 de la ley 17.801, razón por la cual el Registro de la Propiedad Inmueble no admite su inscripción.

b.3) *Limitaciones a la libre disposición en los actos a título gratuito*

Si se trata de un acto a título gratuito (donación, testamento —art. 2330—) se admite la prohibición de enajenar. La prohibición no puede extenderse por mayor término que el de diez años (art. 1972, segundo párrafo).

Si a pesar de la cláusula de no transmitir, válida, la cosa se enajena, el acto será nulo por aplicación de los artículos 382 y siguientes, dando lugar a la pertinente acción real.

Finalmente, prevé el Código que el plazo puede ser renovado "de manera expresa" (no tácita), siempre que no se excedan los diez años que obran como máximo. Así, por ejemplo, si se impuso la cláusula de no enajenar por cinco años, podría ser renovada por otros cinco. El plazo se cuenta desde que "se estableció", esto es, desde que se otorgó el acto jurídico.

b.4) *Casos en los que se genere una comunidad*

En el Título IV, dedicado al condominio, el Código dispone en el artículo 2000 que los condóminos pueden pactar que la cosa quede indivisa por un término que no exceda de diez años, como máximo. También podría ocurrir que el condominio sea constituido por donación o testamento, con esa cláusula.

En materia sucesoria, cuando la cosa es dejada a dos o más herederos la ley (art. 2330) autoriza a toda persona a imponer a sus herederos, aun forzosos, la indivisión de los bienes hereditarios por un plazo de hasta diez años, que en algunos casos, cuando hay menores, y se trate de un bien determinado o de un establecimiento, o acciones de una sociedad, puede extenderse hasta su mayoría de edad, sin perjuicio de la facultad del juez de autorizar la división antes del plazo establecido cuando concurren circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad.

Otros casos de indivisión pueden verse en los artículos 2332/2333.

b.5) *Sustitución fideicomisaria*

Finalmente, el artículo 1972 pone otro límite a las cláusulas de no enajenar en los actos a título gratuito, que consiste en la prohibición de la sustitución fideicomisaria. Hay que tener en cuenta los artículos 1700 y 2491.

b.6) *Vivienda*

Si un inmueble destinado a vivienda es afectado al régimen previsto en los artículos 244 y siguientes del Código, para la protección de sus beneficiarios, existen importantes límites a los actos de transmisión.

b.7) *Tierras rurales y extranjeros*

La ley 26.737 impone limitaciones importantes para la transferencia de inmuebles rurales a personas extranjeras.

c) *"Numerus clausus"*

La limitación que el titular del dominio sufre en este aspecto se refiere a su falta de libertad para modificar, por sí o por acuerdo de partes, la regulación de sus derechos y obligaciones inherentes al uso y goce de aquél, o bien a su imposibilidad de crear por contrato otros derechos reales distintos de los reconocidos por la ley, o desmembrar su dominio con otros derechos reales no reconocidos por el Código.

d) *Camino de sirga*

El artículo 1974 regula el camino de sirga, que es la franja de terreno que el dueño debe dejar libre cuando su inmueble limita con un cauce de agua. Dice lo siguiente: "El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad.

"Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo".

La restricción para los dueños ribereños consiste en no poder utilizar ese espacio para ningún acto que menoscabe el transporte por agua, como hacer construcciones, ni deteriorar el terreno, ni realizar en él ninguna otra actividad (por ejemplo, sembrados o plantaciones) que puedan obstaculizar el libre tránsito de personas o animales, que se necesiten para ayudar a pasar por ahí a las embarcaciones, a efectos de la comunicación por agua. Ésta es una restricción que alcanza no sólo a los ríos y canales navegables, sino también a aquellos cursos de agua que, sin estar comprendidos entre aquéllos, formen cauces naturales y puedan servir, sin embargo, al "transporte por agua".

La limitación abarca no sólo a los propietarios limítrofes, sino a quienes no sean limítrofes pero sean dueños de un inmueble dentro

LÍMITES AL DOMINIO
MNR

de la franja de 15 metros. Cabe recordar que tales aguas forman parte del dominio público, lo que hace razonable que quienes no sean dueños de inmuebles colindantes también puedan tener acceso a sus beneficios.

Los 15 metros se cuentan, en el caso de los ríos, desde la terminación, configurada por la línea de ribera fijada por la que llega la crecida máxima ordinaria (art. 1960), y en el caso de los canales desde la línea exterior de las obras de mampostería.

d.1) *Finalidad*

La norma apunta, principalmente, a asegurar las necesidades de la navegación, flotación y pesca, máxime si se tiene presente el origen histórico de este instituto, cuando los barcos eran desplazados por cuerdas gruesas y arrastrados por la fuerza del hombre o de animales ubicados en la orilla. La "sirga" era una cuerda gruesa, y para su empleo era necesario que estuviese despejado un espacio vecino a la orilla.

El Estado sólo tiene derecho a reglamentar el uso de la franja de 15 m, con el único destino que marca la ley, que obedece a las necesidades de la navegación, de la flotación y pesca. Pero no puede utilizar el camino de sirga para la realización de otras obras, por ejemplo, muelles, puertos, astilleros, o para el ensanche de una calle destinada a la circulación por tierra; en estos supuestos, es indispensable la expropiación de la superficie necesaria.

d.2) *Naturaleza jurídica*

Las posturas son diversas:

- 1) *Dominio público*: Para esta corriente, el camino de sirga pertenece al dominio público.
- 2) *Límite al dominio privado*: Se puede afirmar que no hay sobre dicha franja dominio público, sino privado, ya que no está incluida en la enumeración del artículo 235, y el artículo 1974 alude a "dueño de un inmueble colindante"; si fuera público no tendría sentido imponer prohibiciones a los dueños. Por ende, se trata de una limitación al dominio, en tanto los propietarios de esa franja ven disminuidas sus facultades sin derecho a indemnización.

- 3) *Servidumbre administrativa*: Para esta corriente, también la franja pertenece a los particulares, pero pesa sobre ella una servidumbre administrativa, lo que ha merecido reparos por no haber fundado dominante ni indemnización.

d.3) *La restricción no es indemnizable*

El artículo 1974 obliga a los colindantes a dejar libre un espacio y les impide realizar en él actividades que impidan la navegación. Si bien no lo dice, la regla general en materia de limitaciones es que "no generan indemnización" (art. 1971).

d.4) *Legitimación*

Dice el último párrafo que "Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo". De tal modo, si no se respeta en forma total o parcial el deber de dejar libre la franja de 15 metros, cualquier persona que se sienta perjudicada puede pedir que se remuevan los obstáculos. La legitimación activa es muy amplia; no es necesario ser poseedor o tenedor. Puede ser cualquier ciudadano que invoque el derecho genérico de aprovechar los bienes públicos en su condición de habitante del país, en tanto demuestre menoscabo a su derecho o interés legítimo.

e) *Restricciones del Código Aeronáutico*

Existen normas de derecho de la aeronavegación que limitan el señorío del propietario. El artículo 6° del Código Aeronáutico establece que nadie puede, en razón de un derecho de propiedad, oponerse al paso de una aeronave. Si le produjese perjuicio, tendrá derecho a indemnización.

En los artículos 30 a 35 se encuentran las disposiciones tendientes a limitar la altura de los obstáculos a la circulación aérea. Según el artículo 35: "Es obligatorio en todo el territorio de la República el señalamiento de los obstáculos que constituyen peligro para la circulación aérea estando a cargo del propietario los gastos de instalación y funcionamiento de las marcas, señales o luces que corresponda. El señalamiento se hará de acuerdo con la reglamentación respectiva".

f) *Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico*

Se encuentran límites en la ley 26.743.

III. Límites por razones de vecindad

Los titulares de derechos reales (también poseedores y tenedores) deben usar el inmueble de manera regular, respetando la utilización ajena y esperando que se respete la propia. Se trata más de un problema entre "vecinos" que entre titulares de derechos reales. Se busca el más racional y económico disfrute de todos.

Las reglas de buena vecindad impiden extender una inmisión desde un inmueble hacia otro; en cambio, no prohíben privarlo de ciertas ventajas, tales como si un inmueble recibe luz y el vecino eleva su propiedad quitándosela, en tanto no haya *animus nocendi*.

a) *Inmisiones inmatrimoniales*

Los vecinos deben soportar molestias, en tanto sean razonables. Cuando no lo son, el juez puede adoptar diversas medidas (medidas cautelares, cese y/o indemnización). Establece el artículo 1973 que "Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquéllas.

"Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños. Para disponer el cese de la inmisión, el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción".

Como consecuencia propia de la relación de vecindad, otra limitación al dominio es la que se refiere a la obligación de soportar ciertas molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, siempre que ellos no excedan la "normal tolerancia".

Las inmisiones son propagaciones de factores que perturban causados por la obra del hombre; no están comprendidas en la norma las que tienen causas naturales. El Derecho no protege el uso anormal de las cosas cuando le generan al vecino una incomodidad intolerable. El Código requiere que las inmisiones provengan de un inmueble.

La palabra "inmisión" proviene del latín *immissio*, término que quedó acuñado por la doctrina romanista y que significa una idea de injerencia en la propiedad ajena, que deberá tolerarse o prohibirse dependiendo de la potestad del sujeto para el ejercicio de la actividad.

Debe haber cierta reiteración en la penetración de la inmisión. Lo cual determina que la inmisión debe producirse al menos más de una vez, esto no implica que necesariamente deba ser perpetua, pero sí han de corroborarse las afectaciones o perturbaciones con la repetición del acto.

Las inmisiones a las que alude esta norma son las que generan molestias, como el "humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones", pero pueden ser otras, ya que el artículo 1973 no formula una enumeración taxativa, puesto que alude también a "inmisiones similares" (v. gr.: esparcimiento de productos de combustión, la proyección de ondas radioeléctricas, rayos X, haces luminosos, las actividades bailables o de esparcimiento, emisiones o penetraciones calóricas, eléctricas, gaseiformes, corpusculares, hollín, carbón, cenizas, chispas, rayos, polvo, etc.).

La norma excluye a las inmisiones "materiales", pues éstas encuadran en situaciones distintas con sus respectivas soluciones (v. gr.: nadie tiene derecho a colocar objetos materiales en el inmueble ajeno). Tampoco parecen estar comprendidas las llamadas inmisiones "ideales", como ocurre con la exposición a la vista de cosas horribles o de mal gusto.

Deben provenir de "inmuebles vecinos", lo que no debe ser interpretado con estrictez teniendo en cuenta que el desarrollo de la actividad industrial expone a inmisiones a inmuebles lejanos (v. gr.: material contaminante).

Según la doctrina argentina, el tema no sólo involucraría a los daños producidos a las personas o cosas en su dimensión de vecinos, sino también a los daños al medio ambiente.

a.1) La normal tolerancia

Esas inmisiones inmateriales deben ser soportadas hasta el punto de lo que es "normal" para la generalidad, considerado ello objetivamente, teniendo en cuenta un lugar determinado, un momento histórico determinado, así como lo que es sentido por la conciencia social. Debe prescindirse de las condiciones subjetivas especiales de la persona que se queja (v. gr.: maniático que no soporta el mínimo ruido). Esa "normal tolerancia" es, en realidad, una fórmula abstracta, porque es el juez quien dirá cuál es esa "normal tolerancia" en cada caso concreto que se le presente. En muchos casos, los peritajes técnicos serán determinantes (v. gr.: si un ruido supera la cantidad de decibeles permitida, etc.).

Dice también el artículo 1973 que esa "normal tolerancia" será juzgada "teniendo en cuenta las condiciones del lugar", porque habrá que considerar particularmente la ubicación de los inmuebles involucrados en la litis, tipo de zona en que se hallan emplazados conforme al Código de Planeamiento o Edificación, etcétera. Es también importante valorar la actividad del fundo que se dice afectado.

En la determinación de la normal tolerancia pueden ser importantes, aunque no necesariamente decisivos, factores tales como la frecuencia, duración e intensidad, así como el lugar y momento de la inmisión, pero no puede incidir en la valoración de la tolerancia una eventual conducta del vecino perjudicado en el sentido de que éste podría haber adoptado medidas para evitar o disminuir los efectos de la inmisión.

Por otra parte, no incidirá que medie autorización administrativa (habilitación municipal) para el funcionamiento del establecimiento o comercio, pues es principio del Derecho Administrativo que las autorizaciones administrativas no se conceden sino bajo la condición implícita de no atacar los derechos de terceros y de reparar el perjuicio a los edificios vecinos o a las personas que los habitan.

a.2) Otras pautas que debe valorar el juez

Además de "las condiciones del lugar", el artículo 1973 dice que el juez deberá tener en cuenta otros elementos de juicio: a) el respeto

debido al uso regular de la propiedad; b) la prioridad en el uso; c) el interés general; d) las exigencias de la producción.

Por ejemplo, si se tratare de una fábrica instalada en el lugar diez años antes que el vecino quejoso, que da empleo u ocupación a varias personas, de la cual se hace un uso regular, pero que ocasiona ruidos u otras incomodidades para los vecinos, que exceden la normal tolerancia, y la producción de ella interesa socialmente, no sólo por el producto sino también por la fuente de trabajo que significa, el juez, tomando en cuenta todas estas circunstancias, tendrá que darle una solución a la litis ponderando esos elementos de juicio que se desprenden de la situación de la fábrica en cuestión, con el debido respeto, también, al uso regular de la propiedad de los vecinos afectados.

Según el artículo 1973, "el juez debe ponderar especialmente [...] las exigencias de la producción", lo que significa que las inmisiones industriales pueden ser admitidas, en ciertos casos, aun cuando superen la normal tolerancia. Hay razones económicas y de necesidad social que imponen también preservar los intereses de la industria. Pero esto tampoco debe ser llevado al extremo, ya que cabe interpretar que el juez, en estos casos, puede tener una mayor consideración, pero no tanta como para permitir inmisiones insoportables. En su decisión influirá también "la prioridad en el uso", cuyo valor es subsidiario, ya que no es razonable pensar que el hecho de abrir una fábrica haga adquirir el derecho de imponer exhalaciones intolerables a los inmuebles que se construyan después.

Coincidiendo con la prudencia que cabe exigir en la valoración de esta pauta para resolver sobre la obligación de tolerancia entre los predios, ciertamente la prioridad de uso no debe servir de presupuesto para imponer obligaciones a los afectados que excedan la medida de lo soportable, ello impondría el sacrificio del propio derecho en función del vecino que en virtud de este principio se tornaría una conducta nociva o perjudicial en lícita.

En todos los casos, las inmisiones deben ser prohibidas cuando se puedan eliminar con la adopción de arreglos técnicos de costo razonable. En ciertos casos, cuando el costo sea tan alto que implique el cierre de la actividad industrial, una solución posible puede ser la indemnización en favor del perjudicado por las inmisiones.

a.3) *Facultades del juez*

En su caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños. La ley le permite al juez disponer la indemnización de los daños producidos y, además, la cesación de las molestias o su disminución al límite que se considere normalmente tolerable. El juez puede disponer ambas cosas, sin tener que optar por una de las soluciones. Asimismo, aunque no surge de manera expresa de la norma, es claro que el juez puede actuar de manera preventiva.

El problema puede presentarse para indemnizar el daño cuando éste no consistió en un detrimento material del inmueble vecino sino en algo distinto. Así, por ejemplo, los olores o ruidos provenientes de un establecimiento industrial no dañan materialmente a los inmuebles vecinos, pero es evidente que disminuyen su valor locativo y su valor venal, sin perjuicio del reconocimiento de otros daños si los hubo (v. gr.: daño a la salud, costo de tratamientos médicos, etc.). En ciertos casos, la reparación puede consistir en la adopción de recaudos técnicos en el inmueble que sufre las inmisiones (v. gr.: aislación térmica o acústica), y a todo esto puede sumarse la reparación del daño moral, si se dan las circunstancias.

De más está decir que si la situación obligó a un vecino a soportar durante un largo tiempo molestias intolerables, que lo han mortificado, el reconocimiento del daño moral es innegable.

En cuanto a quienes pueden demandar y ser demandados como consecuencia de lo dispuesto por los artículos 1932 y 1933, pueden ser tanto los poseedores como los tenedores. Claro que el campo de la legitimación puede ser aún más amplio si se afectan los derechos de incidencia colectiva en general (art. 14).

También sería factible, antes de que se consume el daño, acudir a la acción preventiva prevista por el artículo 1711.

Puede establecerse astreintes para que se cumpla la orden de cese o adecuación, o la ejecución por otro a cargo del deudor de las obras necesarias (arts. 730, inc. b; 777, inc. b, Cód. Civ. y Com.).

En cuanto a la indemnización de daños, los rubros indemnizatorios no derivan de este artículo sino de los principios de responsabilidad.

a.4) *La legitimación*a.4.1) *La legitimación activa del poseedor y del tenedor*

El artículo 1932 del Código dispone que "El poseedor y el tenedor tienen derecho a [...] exigir el respeto de los límites impuestos en el Capítulo 4, Título III de este Libro". Esta norma extiende al poseedor y al tenedor –sin distinguir en categorías– la posibilidad de exigir que se respeten los límites al dominio impuestos en el capítulo respectivo, entre los que se encuentra el artículo 1973 sobre inmisiones.

Agrega el artículo 1933 que "El poseedor y el tenedor deben respetar [...] los límites impuestos en el Capítulo 4, Título III de este Libro". Estos deberes inherentes a las relaciones de poder (posesión y tenencia), determinan la existencia de los correlativos derechos inherentes a las relaciones de poder. Por lo tanto, si los poseedores y tenedores están obligados por los límites al dominio, consecuentemente también estarán habilitados a ejercer los derechos derivados de tales normas. Es lo que surge con claridad del artículo 1932 mencionado.

Los titulares de derechos reales (incluso el acreedor hipotecario) pueden intentar contra quien excede la normal tolerancia la acción confesoria (arts. 2248, 2264/2265), de naturaleza real.

a.4.2) *La legitimación pasiva*

La acción se tiene contra el que ejerce la actividad molesta, sea o no titular de un derecho real. El artículo 1933 antes citado es claro en el sentido de imponer deberes, entre los que se encuentran los límites al dominio, tanto al poseedor como al tenedor.

a.4.3) *Prescripción*

El plazo de prescripción de la acción varía en función de cuál sea la que se intente. La acción posesoria prescribe al año (art. 2564, inc. b), las acciones personales a los cinco años (art. 2560), mientras que la acción confesoria es imprescriptible (art. 2247). En todos los casos, cualquiera sea la acción, el reclamo indemnizatorio prescribe a los tres años (art. 2561, segundo párrafo), contados desde que el

damnificado conoció o pudo conocer el daño sufrido. Esto es así aun cuando se reclame el resarcimiento dentro de una acción confesoria.

b) *Obstáculo al curso de las aguas*

Esta limitación impide a los dueños de inmuebles que limitan con cauces de agua realizar obras que alteren su curso. Dice el artículo 1975 que "Los dueños de inmuebles linderos a un cauce no pueden realizar ninguna obra que altere el curso natural de las aguas, o modifique su dirección o velocidad, a menos que sea meramente defensiva. Si alguno de ellos resulta perjudicado por trabajos del ribereño o de un tercero, puede remover el obstáculo, construir obras defensivas o reparar las destruidas, con el fin de restablecer las aguas a su estado anterior, y reclamar del autor el valor de los gastos necesarios y la indemnización de los demás daños.

"Si el obstáculo se origina en un caso fortuito, el Estado sólo debe restablecer las aguas a su estado anterior o pagar el valor de los gastos necesarios para hacerlo". Esta norma impone diversas prohibiciones a los particulares respecto de los ríos y otras aguas que formen cauce.

Los particulares no pueden dar un uso a las aguas que de cualquier modo perjudique la navegación, ya que ésta es libre según la Constitución Nacional (arts. 26 y 75, inc. 10), y tampoco pueden "realizar ninguna obra que altere el curso natural de las aguas, o modifique su dirección o velocidad", por estar en juego el interés general, salvo que "sea meramente defensiva". Los linderos a un cauce, por el hecho de serlo, no tienen mejor derecho que el resto de la comunidad y, por lo tanto, no pueden realizar obras que afecten al uso común ni a sus vecinos. Tampoco –obviamente– los terceros tienen ese derecho. El artículo 1975 se refiere a los dueños de inmuebles, pero la prohibición abarca también a otros titulares de derechos reales o personales y, con mayor razón, a los ciudadanos sin derechos de ese tipo.

La excepción se encuentra en las obras meramente defensivas, las que están permitidas. Así, por ejemplo, un canal que tenga por objeto impedir que se inunde el inmueble, o proteger cultivos.

Puede ocurrir que el curso de las aguas sufra alteraciones, tales como que las aguas cambien su curso, "por trabajos del ribereño o

de un tercero". En tales situaciones, el dueño perjudicado se encuentra habilitado para tomar medidas con el objeto de "restablecer las aguas a su estado anterior".

Las medidas que se pueden tomar, según el Código, consisten en "remover el obstáculo, construir obras defensivas, o reparar las destruidas".

c) *Recibir aguas, arenas y piedras*

Dice el artículo 1976 que "Debe recibirse el agua, la arena o las piedras que se desplazan desde otro fundo si no han sido degradadas ni hubo interferencia del hombre en su desplazamiento. Sin embargo, puede derivarse el agua extraída artificialmente, la arena o las piedras que arrastra el agua, si se prueba que no causan perjuicio a los inmuebles que las reciben".

Como limitación a su dominio, los propietarios de los fundos inferiores están obligados a recibir las aguas, arenas o piedras, que "naturalmente" se desplazan o descienden de otros terrenos. Esas aguas son las de lluvia y las de los manantiales, de deshielo, que corren en forma natural desde los predios más elevados a los más bajos, lo que debe ser determinado por la propia inclinación del terreno y de sus accidentes, sin el hecho del hombre. Además, los de los terrenos inferiores están obligados a recibir las arenas y piedras que arrastren las aguas pluviales. Si sufren perjuicios, no tienen derecho a reclamar un resarcimiento. En cambio, no deben recibir las aguas que son sacadas artificialmente, por el hecho del hombre (aguas de pozo o servidas), salvo que se constituya una servidumbre.

A su vez, dispone la última parte de este artículo 1976 que los dueños pueden derivar el agua "extraída artificialmente", así como las arenas y piedras que arrastran, si no causan perjuicio a los inmuebles que las reciben. Esto significa que los dueños no están obligados a recibir las aguas de pozo, esto es, las que brotan por el trabajo del hombre (bomba de extracción, molino, etc.). No obstante, el artículo trae una excepción cuando "no causan perjuicio". Más aún, en algún supuesto hasta puede ser beneficioso para otro terreno recibir estas aguas.

d) *Obras, trabajos e instalaciones*

En determinadas circunstancias, no se puede impedir el paso de

ALÍENES AL DOMINIO
MNR

obreros que trabajan en una obra o la colocación de andamios, sin perjuicio de la indemnización de los daños. Dice el artículo 1977: "Si es indispensable poner andamios u otras instalaciones provisionales en el inmueble lindero, o dejar pasar a las personas que trabajan en la obra, el dueño del inmueble no puede impedirlo, pero quien construye la obra debe reparar los daños causados".

Esta norma no instituye una servidumbre de paso sino una limitación al dominio, al establecer que quien construye una obra (v. gr.: edificar o reparar su casa) tenga necesidad indispensable de hacer pasar sus obreros (u otras personas) por la del vecino, puede obligar a éste a sufrirlo (permitiendo el acceso y el trabajo que sea necesario hacer de su lado), con la condición de que satisfaga los perjuicios que cause.

Para soportar esta limitación, que no se puede impedir, la necesidad de poner andamios u otra instalación provisoria, o de hacer pasar obreros, debe ser "indispensable". Además, la molestia debe ser transitoria, ya que el artículo se refiere a "instalaciones provisionales".

"Quien construye la obra debe reparar los daños causados". La indemnización no se refiere a la puesta de los andamios (molestia que debe ser soportada), sino a otros eventuales daños que puedan resultar por el uso de una técnica defectuosa o de un actuar negligente, ya que por regla las limitaciones no generan indemnización (art. 1971).

e) *Luces y vistas*

e.1) *Vistas*

El artículo 1978 regula las distancias mínimas a las que se puede tener vistas sobre el inmueble vecino. Dice lo siguiente: "Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en los muros linderos no pueden tenerse vistas que permitan la visión frontal a menor distancia que la de tres metros; ni vistas laterales a menor distancia que la de sesenta centímetros, medida perpendicularmente. En ambos casos la distancia se mide desde el límite exterior de la zona de visión más cercana al inmueble colindante".

Esta norma se ocupa de las vistas como límite al dominio, e impone ciertas condiciones para que uno de los vecinos pueda observar al inmueble del otro. Ello sin perjuicio de la constitución de la servi-

dumbre de vista. El Código ha sido estricto en esta materia, en resguardo de la intimidad y seguridad de los vecinos. Esta norma parece referirse a muros privativos (ver art. 1981), pues para los medianeros rige el artículo 2021.

La vista sobre el inmueble vecino se ejerce generalmente a través de ventanas, balcones o cualquier tipo de abertura que permita la vista. Quedan fuera de este sistema las puertas de entrada y salida de los edificios, cuyo destino es completamente distinto, a lo que cabe agregar las terrazas.

Hay dos clases de vistas:

- 1) *Frontales*, son aquellas que se tienen en la dirección del eje vertical de una ventana, de modo que la persona parada frente a ella no necesita girar su cabeza para poder ver el fundo vecino. Siempre que haya un balcón la vista debe considerarse frontal, pues aunque el edificio esté al costado del fundo vecino, el interesado se puede parar en el balcón y mirar de frente al vecino.
- 2) *Laterales o de costado*, son las que sólo permiten ver de costado, de modo que la persona necesita girar la cabeza a la izquierda o a la derecha, según su ubicación. El Código es más estricto con las frontales o derechas que con las laterales.

e.2) *Requisitos*

La distancia mínima que exige esta norma varía según se trate de vista frontal o lateral. En el primer caso debe haber por lo menos tres metros entre la línea divisoria y la pared, mientras que en el segundo son suficientes sesenta centímetros de distancia, "medida perpendicularmente".

El artículo reglamenta la forma en que deben contarse las distancias dispuestas. Dice que "en ambos casos la distancia se mide desde el límite exterior de la zona de visión más cercana al inmueble colindante". Así, por ejemplo, si sobresale un balcón, se cuenta desde donde éste termina, no desde la pared.

e.3) *Luces. Concepto*

Las aberturas que pueden realizarse en una pared sobre el fundo del

vecino se distinguen en luces y vistas. Las luces son aquellas aberturas que permiten pasar la luz y el aire pero no permiten asomarse. Las vistas son, en sentido amplio, las ventanas que permiten asomarse o mirar (de manera frontal o de costado). La distinción se basa, esencialmente, en la posibilidad de asomarse u observar el inmueble vecino.

Dispone el artículo 1979 lo siguiente: "Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en el muro lindero no pueden tenerse luces a menor altura que la de un metro ochenta centímetros, medida desde la superficie más elevada del suelo frente a la abertura". Este artículo se refiere a la altura mínima que es posible tener luces.

El Código permite la apertura de ventanas o huecos en una pared, lindera al inmueble vecino, para recibir luces (no para tener vistas), siempre que se respeten determinadas condiciones, para no exponer al vecino a molestias intolerables en una buena vecindad.

e.4) *Ámbito de aplicación*

El artículo 1979 se refiere a las luces que puede abrir uno de los vecinos en un "muro lindero". Cabe advertir que el artículo utiliza la expresión "lindero", por lo que cabría entender que no se refiere a cualquier muro sino a aquel que linda inmediatamente con la línea separativa de ambas heredades (art. 2006, inc. a). Hay que tener presente que hasta la altura de tres metros, la pared es medianera cuando el cerramiento es forzoso, sea encaballado o contiguo (arts. 2009 y concs.).

Al tratarse de un muro medianero, lo cierto es que el otro vecino tiene derecho a adosar construcciones en él, quizás tapando esas aberturas (art. 2021).

Por lo tanto, cabe interpretar que esta norma se refiere a muros privativos. El artículo 1981 parece confirmar esta idea cuando dice que "Quien tiene luces o vistas permitidas en un muro privativo..." Esto es, se las puede permitir en uno privativo, el medianero se rige por otras reglas.

e.5) *Condiciones para abrir luces*

El artículo 1979 establece que la abertura puede ser colocada a una altura mínima de un metro con ochenta centímetros. Se trata de

una altura suficiente para impedir que se pueda observar al fundo vecino sin la ayuda de escaleras u otros medios.

e.6) *Excepción*

Dice el artículo 1980 que "Las distancias mínimas indicadas en los artículos 1978 y 1979 no se aplican si la visión está impedida por elementos fijos de material no transparente".

Las ventanas o aberturas deben ser guarnecidas con "elementos fijos de material no transparente". La imposición de un elemento fijo significa que no se puedan abrir, y que el material sea opaco es para que no se pueda ver.

El propósito es una vez más impedir la vista sobre el inmueble vecino, ya que al ser el material no transparente no se podría ver e impediría asomar la cabeza.

e.7) *Privación de luces o vistas*

Prevé el artículo 1981 que "Quien tiene luces o vistas permitidas en un muro privativo no puede impedir que el colindante ejerza regularmente su derecho de elevar otro muro, aunque lo prive de la luz o de la vista". Ni siquiera las luces o vistas permitidas pueden impedir que el otro vecino ejerza su propio derecho.

Queda claro que las luces y vistas son una limitación al dominio en lugar de servidumbres, en tanto no se haya creado una. Al ser así, quien goza de la luz o de la vista permitida, no puede impedir que su vecino, en ejercicio de sus facultades, levante una pared en su inmueble y cierre la ventana que permite el ingreso de aquélla. Se advierte que si el muro con luceras no fuera divisorio —el que se asienta en el límite de ambas heredades—, la pared que se levante en el inmueble lindero no impedirá la iluminación de manera total.

f) *Plantación de árboles y arbustos*

f.1) *Límites para la plantación de árboles, arbustos u otras plantas*

Nadie tiene derecho a plantar, construir o sembrar en el terreno

del vecino (arts. 1944, 1962). En cambio, sí tienen derecho los dueños a hacerlo en su propio inmueble pero, como se verá, el ejercicio de esta facultad tiene una limitación para proteger los inmuebles vecinos y favorecer la convivencia. La regla es siempre la misma, y se apoya en el sentido común: el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro.

El Código dedica al tema el artículo 1982, cuyo texto dice: "El dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causen molestias que exceden de la normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados, a menos que el corte de ramas sea suficiente para evitar las molestias. Si las raíces penetran en su inmueble, el propietario puede cortarlas por sí mismo".

Teniendo en cuenta que el artículo 1973 se refiere a las inmisiones inmatrimoniales, esta norma alude a inmisiones ya materiales, constituidas por árboles, arbustos, plantas o raíces.

Los dueños u otros titulares de derechos reales no pueden tener en sus inmuebles árboles, arbustos o plantas que causen "molestias que exceden de la normal tolerancia". La razón de esta prohibición no es tanto prevenir la intromisión de las raíces, que pueden ser cortadas por el dueño del otro inmueble (último párrafo), sino evitar algunos daños como la humedad que produce dicha vegetación, por la absorción de sustancias nutritivas del suelo del vecino.

En cuanto al concepto de "normal tolerancia", ver lo que se dijo sobre inmisiones inmatrimoniales reguladas por el artículo 1973. El Código se abstiene de fijar una distancia mínima y prefiere fijar un marco objetivo pero menos rígido. No importa la distancia a la que se encuentre el árbol, arbusto o planta del límite, sino si produce una molestia intolerable.

El propietario, poseedor o tenedor del fundo vecino puede pedir la remoción de los árboles, arbustos u otras plantas que causen molestias que superen la pauta legal, a menos que sea suficiente con el corte de las ramas que invaden el espacio aéreo de su predio. También puede, por sí mismo, cortar las raíces que se nutran de su suelo, que es una forma de hacer justicia por mano propia, distinta a la regulada por el artículo 2240. Pero esos derechos, de todas maneras, no pueden ser ejercidos en forma irregular o abusivamente (art. 10).

f.2) *Ramas y raíces*

Aun cuando los árboles no causen molestias, sus ramas y sus raíces no pueden invadir el terreno del vecino, ya se trate de construcciones, patios o jardines. En el caso de las ramas, este último puede pedir que se corten, mientras que si se extendieron las raíces, puede "cortarlas por sí mismo". En el segundo supuesto se puede apreciar un caso en que la ley permite hacer justicia por mano propia. La diferencia se justifica en que un inadecuado corte de las ramas podría dañar al árbol, mientras que el corte de raíces no exige tanto cuidado, máxime teniendo en cuenta que se reproducen fácilmente, y que no siempre es sencillo determinar de qué planta proviene una raíz. Se agrega que si un poseedor está preparando la tierra para la siembra y cosecha, debe remover en ese momento las raíces que encuentre, y que las raíces absorben las sustancias nutritivas del suelo.

CAPÍTULO VIII
DOMINIO IMPERFECTO
MNR

SUMARIO: I. Dominio imperfecto. II. Dominio revocable. III. Dominio fiduciario.

I. Dominio imperfecto

a) *Concepto*

Dice el artículo 1946 que "El dominio es imperfecto si está sometido a condición o plazo resolutorios, o si la cosa está gravada con cargas reales". Agrega el artículo 1964: "*Supuestos de dominio imperfecto*. Son dominios imperfectos el revocable, el fiduciario y el desmembrado..."

El dominio cuando es perpetuo se llama "perfecto", y se lo denomina "imperfecto" cuando no cumple esta condición porque debe resolverse al fin de un cierto tiempo o al advenimiento de una condición o si estuviere gravado respecto de terceros con un derecho real. Ejemplos del primer caso son el dominio fiduciario y el dominio revocable; y del segundo, el dominio gravado con derechos reales.

Vigente el Código anterior, no quedaba claro si todos los derechos reales sobre cosa ajena desmembraban al dominio. El Código actual supera esta discusión ya que es contundente: si la cosa (mueble o inmueble) está gravada con cargas reales, hay dominio imperfecto. Por ende, si hay una hipoteca, también para el dueño su dominio es imperfecto.

b) *Caracteres del dominio que resultan afectados*

El dominio se caracteriza por ser absoluto, exclusivo y perpetuo. Los tres casos de dominio imperfecto que se acaban de mencionar (fiduciario, revocable y gravado) afectan en alguna medida a dichos caracteres. Tratándose del dominio fiduciario y del revocable, es el carácter perpetuo el que se halla disminuido, pues aquí el derecho no está sujeto, en principio, a durar indefinidamente sino a extinguirse por el vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición resolutoria a la cual están subordinados.

Los diversos casos de cargas reales limitan al dominio en su absolutez, ya que, en mayor o menor medida, el propietario se halla impedido de usar, gozar o disponer de la cosa en la forma en que podría hacerlo si no se la hubiese gravado con algún derecho real.

c) *Presunción de perfección*

Establece el artículo 1941 el principio en materia de dominio que se presume perfecto, y en consecuencia quien pretenda ser titular de un derecho real que recaiga sobre la cosa de otro, debe probarlo, y hasta tanto ella no se dé el dueño tiene a su favor la presunción de perfección de su dominio.

En el mismo sentido, dice el artículo 1888 que "Las cosas se presumen sin gravamen, excepto prueba en contrario. Toda duda sobre la existencia de un gravamen real, su extensión o el modo de ejercicio, se interpreta a favor del titular del bien gravado".

II. Dominio revocable

a) *Concepto de dominio revocable*

El artículo 1965 prevé lo siguiente: "Dominio revocable es el sometido a condición o plazo resolutorios a cuyo cumplimiento el dueño debe restituir la cosa a quien se la transmitió.

"La condición o el plazo deben ser impuestos por disposición voluntaria expresa o por la ley.

"Las condiciones resolutorias impuestas al dominio se deben entender limitadas al término de diez años, aunque no pueda reali-

zarse el hecho previsto dentro de aquel plazo o éste sea mayor o incierto. Si los diez años transcurren sin haberse producido la resolución, el dominio debe quedar definitivamente establecido. El plazo se computa desde la fecha del título constitutivo del dominio imperfecto".

Esta norma define al dominio revocable, que es en términos generales el derecho de dominio sujeto a plazo o a condición resolutorios. Como se dijo, es uno de los tres supuestos en los que el dominio es imperfecto.

Al igual que el dominio fiduciario, el revocable es aquel cuya duración está subordinada al cumplimiento de una condición resolutoria, o de un plazo resolutorio. No obstante, cabe advertir que aquí la modalidad puede ser impuesta por las partes o por la ley (v. gr.: donación sujeta a resolverse), mientras que en el dominio fiduciario la condición y el plazo son fijados por las partes; no hay en este último condiciones implícitas.

Las condiciones resolutorias expresas están libradas a la autonomía de la voluntad. Así, por ejemplo, alguien puede transmitirle a otro el dominio de una cosa, y sujetar la duración a una condición. Tal sería si "mi hijo se recibe de abogado", "si el barco llega de Asia", etcétera. El único límite son las condiciones prohibidas por el artículo 344.

Existen, también, condiciones resolutorias tácitas o implícitas, es decir, no estipuladas expresamente por las partes sino que son impuestas por voluntad de la ley.

La condición o el plazo deben ser resolutorios, ya que si fueran suspensivos no habría adquisición del dominio.

b) *Diferencias con el dominio fiduciario*

Hay muchas diferencias por lo que aquí se señalarán las más significativas:

1. La principal diferencia es que la cosa siempre debe ser restituida a su primitivo dueño, mientras que en el dominio fiduciario debe transmitirse al fideicomisario, figura que puede recaer en el beneficiario, un tercero, o en el anterior propietario (fiduciante).
2. El dominio revocable no sólo puede nacer de la voluntad

de las partes (como es el dominio fiduciario), sino también de la ley, por ejemplo cuando la revocación de las donaciones está basada en la ingratitud del donatario, o la previsión respecto del pacto comisorio implícito para las cosas inmuebles.

3. En el dominio revocable, en principio, los efectos de la resolución operan con efecto retroactivo (art. 1967), excepto cuando se trate de adquirentes de buena fe y a título oneroso de cosas muebles no registrables, mientras que en el dominio fiduciario la regla es la contraria.
4. Las cosas transmitidas fiduciariamente forman un patrimonio separado del resto de los bienes del fiduciario, en tanto que las que ingresan en virtud de un dominio revocable, se confunden del resto del patrimonio de su titular.
5. El dominio fiduciario tiene un plazo máximo de 30 años (salvo excepciones), mientras que el dominio revocable está limitado a 10 años cuando se trata de una condición resolutoria.
6. En el dominio fiduciario se pueden establecer prohibiciones de enajenar.
7. El fiduciario sólo puede disponer cuando "lo requieran los fines del fideicomiso", limitación que no existe para el dueño revocable.
8. En el dominio revocable no se prevé la existencia del beneficiario.

c) *Sujetos*

En lo que atañe a los sujetos intervinientes, es dable señalar que en el dominio revocable interviene el transmitente o revocante, que es la persona que luego de producirse el evento resolutorio, volverá a tener el dominio perfecto de la cosa, y el dueño revocable, que es el titular del dominio sujeto a resolverse, obviamente, mientras éste dure. Claro que si la condición fracasa, el dominio se consolida en cabeza del hasta entonces dueño imperfecto.

d) *Duración máxima*

Como es sabido, el plazo es fatal, siempre llega, mientras que la

condición está sujeta al acaecimiento de un hecho incierto, que no se sabe si se producirá; puede ocurrir o no (v. gr.: que un sujeto se reciba de médico, que el barco llegue de Asia, etc.).

El Código para evitar la incertidumbre, la espera indefinida, pone un plazo máximo de espera. Si la condición se cumple antes de los diez años, allí acaba el dominio revocable. Si no se cumplió, se la tiene por cumplida al cabo de ese tiempo, y "el dominio debe quedar definitivamente establecido". Cabe entender que se la tiene por fracasada, y que el dueño revocable (sujeto a resolución) es quien se queda con la cosa pero ahora el dominio es perfecto.

El plazo se debe computar desde la fecha del título constitutivo.

Cabe advertir que ciertas compraventas sujetas a condición resolutoria y que transmiten el dominio revocable (art. 1169), no pueden durar más de cinco años si se trata de inmuebles, o de dos años en el caso de cosas muebles, ambos contados desde la celebración del contrato (art. 1167). Tal es el caso del pacto de retroventa, de reventa y de preferencia (arts. 1163/1165).

e) *Publicidad*

En el caso de los inmuebles, como es sabido, la transmisión del dominio debe ser formalizada en escritura pública. Si se pacta una condición o un plazo resolutorios, allí figurarán, y ello les da suficiente publicidad, ya que el adquirente debe realizar el estudio de títulos. Además, tales cláusulas deben tener publicidad registral si resultan del documento. El registrador dejará constancia de que el dominio es revocable.

En cuanto a las cosas muebles registrables, será indispensable la inscripción registral para que la cláusula resolutoria pueda ser oponible a terceros interesados de buena fe.

f) *Facultades*

Se indican cuáles son las facultades del titular y la suerte de los actos jurídicos que otorgue en el artículo 1966: "El titular del dominio revocable tiene las mismas facultades que el dueño perfecto, pero los actos jurídicos que realiza están sujetos a las consecuencias de la extinción de su derecho".

Pendiente el plazo o la condición resolutorios, el dueño revocable es dueño al fin, y por eso es que tiene las mismas facultades que el dueño perfecto: usar, gozar y disponer física y jurídicamente.

Lo importante es cuál será la suerte de los actos jurídicos que otorgue. Según el artículo 1966: "están sujetos a las consecuencias de la extinción de su derecho". Ocurre que, por regla general, nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas (art. 399).

También por su carácter de dueño, puede efectuar mejoras en la cosa, así como gozar de sus frutos. Los frutos percibidos no deben ser restituidos (art. 348).

También está legitimado para ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa de la cosa transmitida, contra terceros e incluso contra el dueño anterior.

g) Efecto de la revocación

El dominio revocable se extingue por las mismas causas por las que puede extinguirse el dominio perfecto (v. gr.: destrucción de la cosa). Además, se extingue por el cumplimiento o fracaso de la condición resolutoria (o el transcurso del plazo máximo), o por el vencimiento del plazo resolutorio. El Código regula los efectos de la extinción por esta causa.

Dice el artículo 1967: "La revocación del dominio de cosa registrable tiene efecto retroactivo, excepto que lo contrario surja del título de adquisición o de la ley.

"Cuando se trata de cosas no registrables, la revocación no tiene efecto respecto de terceros sino en cuanto ellos, por razón de su mala fe, tengan una obligación personal de restituir la cosa". Se establece como principio que la revocación tiene efecto retroactivo.

Los terceros no pueden alegar buena fe ya que, obrando con diligencia hubieran podido conocer la situación del transmitente, cuando se trata de cosas registrables. Además, en lo que hace a inmuebles, el subadquirente debe realizar el estudio de títulos para conocer el estado jurídico del inmueble. Esta idea emerge también del artículo 1166 cuando se refiere a los pactos agregados a la compraventa.

Además del principio general enunciado en la primera parte, el artículo 1967 —en el segundo párrafo— también establece una excepción que se corresponde con lo dispuesto por el artículo 1895 en materia de cosas muebles.

En efecto, si se trata de cosa mueble no registrable, que no sea hurtada o perdida, el poseedor de buena fe es su dueño, y si adquirió a título oneroso escapa a la acción reivindicatoria del propietario anterior. Por ende, si el dueño revocable de un reloj se lo transmite a un tercero de buena fe y a título oneroso, la revocación en este caso no tendrá efecto retroactivo, y el subadquirente habrá adquirido un derecho mejor y más extenso que el que tenía su antecesor. Si bien el artículo 1967 no menciona al título oneroso, este requisito se desprende de la regla general antes citada (ver también art. 1166).

Otras excepciones, según el primer párrafo de la norma que se comenta, son que la ley no fije lo contrario en un supuesto determinado, y que las partes no hayan pactado expresamente en los actos jurídicos una disposición en contrario.

El ejemplo típico de la primera es la revocación de una donación por inejecución de los cargos, en los términos y con el alcance previsto en el artículo 1570. Otro caso puede verse en la reaparición del declarado ausente con presunción de fallecimiento luego de concluida la prenotación, en cuyo caso el ausente puede reclamar los bienes en el estado en que se encuentren (art. 92).

En cuanto a la segunda excepción expresamente contemplada por la norma, corresponde decir que ello es una derivación del principio de autonomía de la voluntad. Si bien impera el orden público en los derechos reales, aquí el Código permite a las partes apartarse del principio general de la retroactividad y pactar lo contrario.

Otras dos excepciones surgen del artículo 348. El revocante debe respetar los *actos de administración* sobre cosas inmuebles o muebles, no caerán dichos actos, y el dueño revocable no tendrá obligación de restituir el objeto del contrato al revocante.

Esto tiene su razón de ser en que en los actos de administración son menos graves, y en ellos no existe obligación legal de exhibir

el título del transmitente, como ocurre, por ejemplo, cuando se presenta el locador como dueño.

La última excepción son los frutos percibidos, que no tendrán que ser restituidos, ni se ven afectados por la retroactividad.

Completa el panorama el artículo 1969: "Si la revocación es retroactiva el dueño perfecto readquiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados por el titular del dominio resuelto; si no es retroactiva, los actos son oponibles al dueño".

Lo concreto es que cuando se produce el efecto retroactivo, el dueño anterior readquiere el dominio "perfecto", esto es libre de los gravámenes que hubiese impuesto el dueño revocable. En caso de no ser retroactivo el efecto, los actos jurídicos deben ser respetados. Incluso, como se dijo, si la cosa fue enajenada a un tercero de buena fe y a título oneroso, el anterior dueño no podrá recuperarla y sólo podrá exigirle al revocado la indemnización del daño sufrido.

h) *Readquisición del dominio perfecto*

Dice el artículo 1968: "Al cumplirse el plazo o condición, el dueño revocable de una cosa queda inmediatamente constituido en poseedor a nombre del dueño perfecto. Si la cosa es registrable y el modo suficiente consiste en la inscripción constitutiva, se requiere inscribir la readquisición; si la inscripción no es constitutiva, se requiere a efecto de su oponibilidad". Este artículo regula el modo en el que el anterior dueño recobra el dominio de la cosa.

Dado que la resolución opera con efecto retroactivo, una vez cumplida la condición o vencido el plazo, el dominio revocable queda automáticamente extinguido y el dueño anterior se convierte nuevamente en dueño perfecto, sin necesidad de que se haga la tradición, pues la norma que se comenta establece un supuesto de *constituto posesorio*. En efecto, quien era dueño sujeto a resolverse, al verificarse el evento resolutorio se convierte en tenedor, y el anterior dueño pasa a ser nuevamente poseedor y, obviamente, dueño perfecto.

No se requiere de la tradición ni de actos materiales. Basta con la extinción provocada por el transcurso del tiempo. Sí, es necesario, para que la readquisición sea oponible a terceros interesados de buena

fe, que se realice la inscripción en el Registro correspondiente, si la cosa es registrable.

Ahora, si se trata de una cosa registrable y, además la inscripción es constitutiva (v. gr.: automotor), en este único caso no es suficiente con el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición. Para que el anterior dueño readquiera el derecho real será menester la inscripción en el Registro.

Extinguido el dominio revocable, el tenedor está obligado a restituir la cosa a su antiguo dueño (art. 1940, inc. c).

III. Dominio fiduciario

a) *Concepto*

El dominio fiduciario es una especie del género dominio imperfecto. Está tipificado por el artículo 1701: "Dominio fiduciario es el que se adquiere con razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento, y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley".

La fuente del dominio fiduciario es un acto o negocio fiduciario, en el cual el *pactum fiduciæ* se materializa mediante la condición o el plazo resolutorios, aunque ello también se puede lograr mediante un acto de última voluntad (testamento). Prevé el artículo 1669 que el contrato debe ser registrado en el Registro Público que corresponda.

Dispone el artículo 1964 que el dominio fiduciario se rige "por lo previsto en las normas del Capítulo 31, Título IV del Libro Tercero", y el artículo 1702 que "Son aplicables al dominio fiduciario las normas que rigen los derechos reales en general y, en particular, el dominio, previstas en los Títulos I y III del Libro Cuarto de este Código".

El método es criticable. No es correcto legislar sobre el dominio fiduciario, especie del dominio (derecho real), en la parte del Código dedicada a los contratos. Para colmo, cada uno remite al otro. Lo correcto hubiera sido legislar al dominio fiduciario junto al dominio revocable en el capítulo del dominio imperfecto.

También se acepta su constitución por testamento (art. 1699). Ello en tanto no se configure una sustitución fideicomisaria prohibida por el artículo 1972. En tal sentido, prevé el art. 1700 que "Es nulo el fideicomiso constituido con el fin de que el fiduciario esté obligado a mantener o administrar el patrimonio fideicomitado para ser transmitido únicamente a su muerte a otro fiduciario de existencia actual o futura". Habrá que respetar las normas del Código que rigen los requisitos de forma de los actos de última voluntad. Además, hay que respetar las normas del Código sobre la porción disponible (legítima) en el caso de haber herederos forzosos.

b) *Sujetos y objeto*

Al hablar de los sujetos, se trata de las partes de la relación jurídica, del negocio fiduciario que sirve de causa fuente al dominio fiduciario, pues en lo que concierne al derecho real no se puede hablar de partes, porque se establece una relación directa e inmediata entre el sujeto y la cosa; en el caso, entre el titular del dominio fiduciario y el objeto del fideicomiso.

Las partes intervinientes en el negocio fiduciario pueden ser dos, tres o cuatro: 1) el constituyente o fideicomitente, que es quien se desprende del dominio en favor de otra persona; 2) el fiduciario, que recibe el dominio transmitido temporariamente por el constituyente del fideicomiso; 3) el fideicomisario, que es el tercero a quien habrá que transmitirle el dominio si se cumple la condición resolutoria o cuando venza el plazo resolutorio establecido en el contrato, y 4) el beneficiario (pueden ser más de uno), que recibirá los beneficios de la gestión del fiduciario.

Parece preferible reservar la expresión dominio fiduciario cuando se transmitan cosas o bienes que puedan ser objeto del derecho real de dominio, y utilizar la de "propiedad fiduciaria" cuando se trate de otros bienes. Ésa es la idea que se desprende del artículo 1682 en tanto dispone que "sobre los bienes fideicomitados se constituye una propiedad fiduciaria, regida por las disposiciones de este Capítulo y por las que correspondan a la naturaleza de los bienes".

b.1) *Patrimonio separado*

MNR

Sobre los bienes fideicomitados se crea un *patrimonio separado o de afectación* en cabeza del fiduciario, con un régimen específico (arts. 1685, 1686). Los bienes fideicomitados quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario y tampoco pueden agredirlo los acreedores del fiduciante, quedando a salvo las acciones de fraude y de ineficacia concursal; y los acreedores del beneficiario sólo pueden ejercer sus derechos sobre los frutos de los bienes fideicomitados (art. 1686).

A su vez, también establece la ley que los bienes del fiduciario (tampoco los del fiduciante, del beneficiario ni del fideicomisario) no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con los bienes fideicomitados, y la insuficiencia de éstos no dará lugar a la declaración de su quiebra. En este supuesto, se deberá liquidar el fideicomiso, lo que estará a cargo del juez competente (art. 1687).

c) *Modos de adquisición del dominio fiduciario*

El dominio fiduciario se adquiere por actos entre vivos y, en forma derivada, por la concurrencia del título y el modo (tradición). El título está configurado por el llamado negocio fiduciario o *pactum fiduciæ*, el cual contiene una modalidad resolutoria que, al verificarse, obliga al fiduciario a retransmitir el dominio perfecto de la cosa al fideicomisario.

Para que la transmisión fiduciaria de inmuebles sea oponible a terceros, deberá ser inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble (arts. 1683, 1684, 1893, Cód. Civ. y Com.; arts. 2° y 20, ley 17.801). La inscripción es necesaria para terceros interesados de buena fe.

También se puede constituir el dominio fiduciario por actos de última voluntad, siempre y cuando no se configure una sustitución fideicomisaria prohibida.

d) *Duración*

El contrato de fideicomiso puede establecerse subordinado a un

plazo o a una condición resolutoria, con un límite máximo de treinta años, salvo que el beneficiario fuere un incapaz o con capacidad restringida, caso en que puede durar hasta su muerte o hasta la cesación de su incapacidad o de su restricción (art. 1668).

e) *Facultades del dueño fiduciario*

Habida cuenta de que, pendiente el plazo o la condición, el fiduciario es el dueño de la cosa transmitida, cabe reconocer que sus facultades son amplias, es decir, que goza de todas las prerrogativas y derechos con que cuenta el dueño pleno o perfecto (art. 1704). Ésta es, además, la solución prevista por el artículo 1966 para el dominio revocable, norma que debe ser aplicada por analogía.

Así, puede realizar actos de disposición (material y jurídico) y de administración sobre la cosa que le fue confiada. Tanto unos como otros, en principio, permanecerán incólumes. Puede también percibir los frutos, usar y gozar de la cosa (de acuerdo a lo estipulado), y ejercer acciones posesorias y reales en defensa de las cosas que adquirió.

Si en el título de transmisión se le hubiese prohibido al fiduciario enajenar, la cláusula es válida (arts. 1688 y 1703).

e.1) *Régimen de los frutos*

Dada su condición de dueño, el fiduciario tiene, en principio, derecho a los frutos (arts. 1941 y 1945), ya sean naturales, industriales o civiles, los que ingresarán en el patrimonio especial. Dispone el artículo 1684 que el fiduciario puede adquirir —cuando no se pacte lo contrario en el contrato— la propiedad fiduciaria de los frutos, productos y de otros bienes que adquiera con los frutos de los bienes fideicomitidos (subrogación real). De esto habrá que dejar constancia en el título y, de corresponder, en el Registro. Claro que, como no está en juego el orden público en este aspecto, habrá que remitirse a lo que las partes hayan dispuesto contractualmente.

e.2) *Actos de disposición*

El Código sienta la regla de que el fiduciario, en su condición de

dueño, puede enajenar o gravar la cosa. Es la lógica consecuencia de tener el *ius abutendi* que confiere el derecho real de dominio.

Sin embargo, también se le imponen limitaciones. Dispone el artículo 1688 que “El fiduciario puede disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines del fideicomiso, sin que sea necesario el consentimiento del fiduciante, del beneficiario o del fideicomisario. El contrato puede prever limitaciones a estas facultades, incluso la prohibición de enajenar, las que, en su caso, deben ser inscriptas en los registros correspondientes a cosas registrables. Dichas limitaciones no son oponibles a terceros interesados de buena fe, sin perjuicio de los derechos respecto del fiduciario”. Agrega el artículo 1704 que “El titular del dominio fiduciario tiene las facultades del dueño perfecto, en tanto los actos jurídicos que realiza se ajusten al fin del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas”.

Surgen así las siguientes restricciones a los actos de disposición: 1) los fines del fideicomiso; 2) la necesidad de consentimiento del fiduciante, beneficiario o del fideicomisario, si así se estableció en el contrato; 3) la prohibición de enajenar, si se hubiere pactado, y 4) la imposibilidad de transmitir su derecho por causa de muerte, pues si fallece la cosa fideicomitida no pasa a sus herederos sino que se le designa un fiduciario sustituto (arts. 1678, inc. b y 1679).

Los actos de disposición que realice el fiduciario a terceros no estarán sujetos a resolverse en forma retroactiva al verificarse el evento resolutorio, pues el artículo 1688, último párrafo, prevé que “Quedan a salvo los actos de disposición realizados por el fiduciario de conformidad con lo previsto en esta norma”. A su vez, el artículo 1705 dispone que “La extinción del dominio fiduciario no tiene efecto retroactivo respecto de los actos realizados por el fiduciario, excepto que no se ajusten a los fines del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas, y que el tercer adquirente carezca de buena fe y título oneroso”.

e.3) *Acciones*

El fiduciario puede ejercer acciones posesorias y reales en caso de

sufrir algún ataque en su derecho de propiedad. También, dada su condición de dueño, puede intentar la acción de deslinde en el caso de hallarse los límites del terreno confundidos con los de un terreno colindante.

e.4) *Derecho a una retribución*

El fiduciario tiene derecho a una retribución por su trabajo y al reembolso de los gastos, salvo estipulación en contrario, lo cual tiene relevancia en el plano obligacional, personal.

e.5) *Derecho a renunciar*

Según el artículo 1678, inciso e, el fiduciario cesará como tal si renuncia, siempre y cuando en el contrato se hubiese autorizado expresamente esta causa. En tal caso, corresponderá la designación de un sustituto.

e.6) *Prohibición*

Surge del artículo 1676 una prohibición consistente en que el fiduciario no puede adquirir para sí los bienes fideicomitidos. Esto significa que, al extinguirse el fideicomiso, la cosa o los otros bienes que lo integren deben necesariamente ser transmitidos a otra persona, que puede ser el fideicomisario, el beneficiario o el propio fiduciante. El fiduciario es titular de un dominio imperfecto, pero lo que transmitirá será el dominio perfecto.

f) *Extinción del dominio fiduciario*

Se extingue, principalmente, por el cumplimiento de la condición resolutoria o por el vencimiento del plazo resolutorio, y en ese caso el fiduciario debe transmitir la cosa a quien corresponda. El acaecimiento del evento resolutorio produce *ipso iure* el cambio de titularidad, pues para que el designado adquiera el dominio no es necesaria la tradición de la cosa.

En efecto, dispone el artículo 1706 que "Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario de una cosa queda inmediatamente cons-

tituido en poseedor a nombre del dueño perfecto. Si la cosa es registrable y el modo suficiente consiste en la inscripción constitutiva, se requiere inscribir la readquisición; si la inscripción no es constitutiva, se requiere a efecto de su oponibilidad". Por ende, si se trata de inmuebles, de cosas muebles no registrables, o de cosas muebles registrables pero que la inscripción no sea constitutiva, al extinguirse el contrato de fideicomiso, se produce una suerte de *constituto posesorio*, en virtud del cual el fiduciario queda convertido en tenedor a nombre del nuevo dueño de la cosa. Coincide la extinción del dominio fiduciario (derecho real sobre una cosa) con la extinción del negocio fiduciario (causa fuente de aquél).

g) *Efectos de la resolución*

Como se dijo anteriormente, la extinción del dominio fiduciario no opera con efecto retroactivo (art. 1705). En tales condiciones, ya se trate de muebles o inmuebles, si el tercer adquirente es de buena fe y a título oneroso, la resolución sólo producirá sus efectos hacia el futuro sin afectar el pasado, por lo que se mantendrán o quedarán subsistentes los diversos actos efectuados por el dueño fiduciario, esto es, la transmisión del dominio de la cosa a terceros y la perdurabilidad de los gravámenes constituidos (servidumbres, hipotecas, etc.).

Entonces, como dice el artículo 1707: "Cuando la extinción no es retroactiva son oponibles al dueño perfecto todos los actos realizados por el titular del dominio fiduciario. Si la extinción es retroactiva el dueño perfecto readquiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados".

La extinción tendrá efecto retroactivo cuando el tercero sea de mala fe o haya adquirido a título gratuito. Habrá mala fe cuando el fiduciario realice actos de disposición que sean ajenos a los fines del fideicomiso, o a pesar de una cláusula que limite sus facultades, y el tercero haya sabido o debido saber, actuando con diligencia, tal circunstancia. De ahí que es muy importante el debido estudio de títulos.

h) *Posibilidad de subrogación real*

Puede suceder que el fiduciario enajene la cosa y que en su lugar ingrese en el patrimonio fideicomitido su valor, esto es, el precio. Obviamente concluyó el dominio fiduciario como derecho real, pues la cosa cierta y determinada que era su objeto fue transmitida. De todas formas, cabe preguntarse si el fideicomisario tiene derecho a recibir, cuando corresponda, la cantidad equivalente en reemplazo de la cosa que ya no podrá ser recuperada. En primer lugar, habrá que observar lo que las partes hayan previsto en el contrato, el cual deberá contener "la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso..." (art. 1667, inc. b). En el mismo sentido, el artículo 1684 dispone que "...Excepto estipulación en contrario del contrato, el fiduciario adquiere la propiedad fiduciaria de los frutos y productos de los bienes fideicomitados y de los bienes que adquiera con esos frutos y productos o por subrogación real respecto de todos esos bienes, debiéndose dejar constancia de ello en el título para la adquisición y en los registros pertinentes".

Por ende, si nada se dispuso en el contrato, la solución debe ser la subrogación real, por tratarse de un patrimonio separado y porque si el fiduciario retuviera el dinero estaría burlando, indirectamente, la prohibición de adquirir para sí las cosas fideicomitidas (art. 1676). A idéntica conclusión corresponde llegar en los supuestos en que reciba una indemnización por expropiación, o de una aseguradora si la cosa se destruye.

i) *Fideicomiso testamentario*

Los fideicomisos testamentarios permiten designar al fiduciario para que, a la muerte del causante, reciba todo o parte de sus bienes con el objeto de destinarlos a ciertas finalidades, en beneficio de otro u otros. Decimos todo o parte pues debe respetarse la porción legítima de los herederos forzosos. Es muy útil para que el causante asegure la manutención de ciertas personas, ya sea su educación, gastos de salud, etcétera. Al concluir el fideicomiso, los bienes deben ser transmitidos a quien se hubiese designado en el testamento, o bien a quien supletoriamente indique la ley.

El plazo máximo de duración del fideicomiso se computa desde la muerte del fiduciante (art. 1699, último párrafo).

La transmisión fiduciaria por esta clase de actos encuentra limitaciones en el Código Civil y Comercial. Por un lado, están prohibidas las sustituciones fideicomisarias, en las que el traspaso de bienes está supeditado a la muerte del heredero (arts. 1700, 1972 y 2491); por otro, se debe respetar la porción legítima de los herederos forzosos (arts. 2493 y conchs.).

Las porciones legítimas están determinadas en el artículo 2445: "La porción legítima de los descendientes es de dos tercios, la de los ascendientes de un medio y la del cónyuge de un medio..."

El Código permite una excepción al respeto de la legítima, otorgando mayor flexibilidad, cuando se trata de proteger a personas más vulnerables. En efecto, dice el artículo 2448 que "El causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. A estos efectos, se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral".

CAPÍTULO IX

PROPIEDAD INDÍGENA

MNR

SUMARIO: I. La Constitución Nacional. II. El Código Civil y Comercial. III. La cuestión de la tierra. IV. Es un derecho real. V. El objeto de este derecho real. VI. Modos de constitución. VII. Caracteres. VIII. Aprovechamiento de los recursos naturales. Consulta.

I. La Constitución Nacional

El artículo 75, inciso 17, obliga al Congreso: "Reconocer la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".

Por su parte, el inciso 19 de dicha norma completa el panorama al indicar, respecto del "desarrollo humano", que debe el Poder Legislativo "Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de

los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.

"Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y la circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales".

Esto significó un gran avance en el camino de la igualdad real, ya que la Constitución argentina de 1853 preveía el sometimiento de los indígenas, su conversión al catolicismo. Ahora, como corresponde, se reconoce su derecho a una vida cultural que resguarde sus valores, su identidad. Igualdad no significa igualar, convertir, sino todo lo contrario, se alcanza la igualdad real (no formal) cuando se respeta la diferencia. Muchas veces también se necesitan medidas especiales de protección, y acciones positivas para alcanzarla.

La ley 23.302 (1985) define a las comunidades indígenas como los "conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización, y se denominará indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad".

En 1992, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169 de la OIT, donde no sólo se reconocen los derechos preexistentes de los indígenas, sino que se eleva jurídicamente a las comunidades al rango de Pueblos Indígenas.

Las palabras "comunidad" y "comunitario" en el texto constitucional no se refieren solamente a los asentamientos físicos, sino a las unidades sociopolíticas locales en las que se articulan las sociedades indígenas y los aspectos económicos de las mismas. No puede perderse de vista que los indígenas se articulan institucionalmente en "comunidades". La comunidad indígena entendida como unidad sociopolítica es un ente con personalidad jurídica propia, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto implica, a su vez, que el Estado en este caso no otorga la personería jurídica —como ocurre con otras formas societarias—, sino que la "reconoce". Esto significa el respeto de sus mecanismos de representación y toma de decisiones, distintos a los de la democracia representativa.

El reconocimiento constitucional de un sistema de valores, pautas y normas diferentes, conduce al ajuste de las reglas del Derecho positivo.

Si bien en casi todas las Constituciones nacionales de los países americanos (Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela), al igual que el nuestro, existe el reconocimiento de la propiedad indígena en cabeza de las comunidades aborígenes —en consonancia con la legislación y doctrina supranacional, verbigracia: tratados internacionales y la jurisprudencia de la CIDH—, como también lo hacen nuestras constituciones provinciales, lo cierto es que no hay en ninguna legislación nacional una regulación completa del instituto como derecho real.

Casi todas las modificaciones de las constituciones latinoamericanas del siglo XX están inspiradas en el Convenio 169 de la OIT —y su antecedente el 107—, donde en líneas generales se reconoce la preexistencia cultural, y se proclama que ninguna de las tierras ocupadas tradicionalmente por los pueblos indígenas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos, reconociendo las formas comunales de la propiedad indígena.

La ley nacional 25.799 modificatoria de la ley 23.302 (2003) dispone que el INAI gestione la habilitación de planes especiales para la construcción de viviendas rurales y urbanas, para los titulares de las tierras adjudicadas por la ley ante organismos nacionales e internacionales que desarrollen planes habitacionales de fomento. Propicia la conservación de la cultura y la inserción socioeconómica de comunidades aborígenes.

La ley 26.160 establece la obligación del Estado de demarcación de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas, y suspende los desalojos por el plazo de la emergencia declarada. Fue prorrogada por la ley 26.554, hasta el 23 de noviembre de 2013. Pone en cabeza del INAI el encargo de realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas. El decreto reglamentario 1112/2007 reglamentó la ley 26.160, y facultó al INAI a aprobar los programas necesarios para la correcta implementación del relevamiento, procediéndose en consecuencia con el dictado de la re-

solución INAI 587/2007 a través de la cual se crea el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RE-TECI)-Ejecución de la ley 26.160. Una nueva ley sancionada a fines de septiembre de 2013 proroga nuevamente la emergencia indígena, lo que –según Abreut– provoca una nueva dilación en la solución de los conflictos territoriales de las comunidades indígenas, con impacto en la seguridad jurídica de todos los habitantes, tanto particulares como indígenas. Es la ley 26.894.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en un meduloso pronunciamiento dictado el 31 de agosto de 2001, a través del voto del juez Salgado Pesantes, en los autos “Comunidad Mayagua (Sumo) Awas Tingni c/Nicaragua” que el derecho a la tierra reivindicado por los indígenas, se inscribe en el derecho a la propiedad, desbordando el concepto tradicional en el que prima la relación individual, toda vez que las culturas indígenas tienen una vinculación muy particular con la tierra secular de sus antepasados en la cual cumplen su ciclo vital y donde buscan alcanzar su plenitud humana espiritual y material.

II. El Código Civil y Comercial

El Anteproyecto del actual Código regulaba dentro del Libro IV de los Derechos Reales, a la propiedad indígena. Le dedicaba los artículos 2028 a 2036. Sin embargo, tales normas no fueron sancionadas al aprobarse el Código, sino eliminadas.

Desde hace años debate la doctrina si es conveniente, o no, la inclusión del tema en los proyectos de Código. El de 1998 no lo preveía, pero sí lo hacía el de 2012. Este último proyecto fue el aprobado, pero sin dicho contenido.

En el Anteproyecto se delineaba el concepto, su titular, los modos de constitución, caracteres del derecho, facultades, prohibiciones, aprovechamiento de los recursos naturales, con reenvío subsidiariamente en todo lo que no sea incompatible a las disposiciones del derecho real de dominio. La regulación completa del instituto en el Anteproyecto surgía de una premisa básica: la no discriminación, ya sea de raza, origen o religión, al reconocer los usos y costumbres de las

comunidades indígenas, y entre ellas, su forma de propiedad especial diferenciada de la propiedad individual o napoleónica. Se respetaba la identidad latinoamericana y la diversidad multicultural.

Expresó la Comisión redactora del Anteproyecto 2012 que “Esta incorporación constituye la manera adecuada de admitir la coexistencia de formas culturales distintas y de convertir en derecho positivo el ideario indígena junto al criollo. Se mantiene el estatus especial de la comunidad indígena protegida constitucionalmente y en consecuencia es inalienable, intransmisble, insusceptible de gravámenes de garantía, medidas cautelares o prescripción adquisitiva por parte de terceros. La titular es la comunidad organizada y registrada como persona jurídica con debido control estatal. El Anteproyecto indica cuáles son los modos de constitución del derecho real y sus caracteres, las facultades de la titular y hace referencia al aprovechamiento de los recursos naturales con incidencia en los hábitats indígenas. La Comisión cree cumplir un cometido acorde al reconocimiento de los derechos fundamentales de todos los habitantes, inclusive de los pueblos originarios que habían sido postergados y olvidados en la legislación general básica de todos los argentinos”.

No obstante, la cuestión quedó para más adelante. El Código dedica un solo artículo a esta cuestión, el 18, cuyo texto es el siguiente: “*Derechos de las comunidades indígenas*. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional”.

Parece poco para el Código. En verdad, se limita a reproducir lo que se desprende de la Constitución Nacional, sin avanzar mucho más.

III. La cuestión de la tierra

En la Constitución Nacional se reconoce la posesión de las tierras. Basta con detectar la ocupación, la realización de otros actos materiales (art. 1928) para tenerla por configurada.

Sin perjuicio de ello, existen marcadas diferencias con la idea de

dominio emergente del Código Civil y Comercial, pues aquí se trata de la propiedad "comunitaria", con el alcance cultural que cabe asignarle a este término. No hay que olvidar que la noción de propiedad para estos pueblos es diferente, pues en rigor suelen verse a sí mismos como pertenecientes a la tierra, más que ésta a ellos. Existe una unión indisoluble entre la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y los territorios que ocupan tradicionalmente.

El titular de este derecho es únicamente la comunidad indígena registrada. No hay en esta figura cotitulares, o condóminos (art. 1983, Cód. Civ. y Com.). La titularidad no recae sobre sus integrantes. No hay en la figura un condominio, es decir partes alícuotas en cabeza de los componentes de la comunidad.

El Código, al regular la posesión, el dominio y el condominio, no ofrece respuestas suficientes a esta cuestión dado que parte de la base y de la filosofía de la propiedad individual. La clave aquí es el reconocimiento de la "propiedad comunitaria", una propiedad que se encuentra al servicio de la comunidad real, pues no hay que soslayar que los pueblos indígenas son, por esencia, comunitarios y colectivistas, y que se encuentran adheridos a la naturaleza.

IV. Es un derecho real

Esta propiedad comunitaria es un derecho real extra-Código, autónomo, distinto a los enumerados en el Código Civil y Comercial. Los derechos reales pueden ser creados por la ley (art. 1884); en este caso se trata de un derecho real creado por la ley suprema: la Constitución Nacional.

Se trata de un derecho real que es principal (art. 1889), recae sobre cosa propia (art. 1888), registrable (1890) y se ejerce por la posesión (art. 1891).

V. El objeto de este derecho real

El objeto es un inmueble rural destinado a la preservación de la identidad cultural y el hábitat de las comunidades indígenas. Se trata de las tierras que tradicionalmente ocupan y las que adquieran ap-

tas para su desarrollo en los términos del artículo 75, inciso 17 de la CN, y los convenios internacionales vinculantes para la República Argentina.

Por un lado, quedan descartados los inmuebles urbanos o suburbanos. Por otro, el inmueble rural debe tener una afectación especial, un destino, cual es el de preservar la identidad cultural y el hábitat de estas comunidades.

Cabe apuntar que se dejó para una ley especial todo lo atinente a la regularización de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas porque ello no era materia para ser incluida en el nuevo Código.

La noción de territorio-hábitat implica una idea que surge de los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, por el cual se establece un espacio geográfico con fronteras inexactas —para el pensamiento jurídico hegemónico—, pero un espacio que permite el acceso a las no ocupadas tradicionalmente, según sus necesidades —para la cultura indígena—. Se trata de un territorio que no puede parcelarse sin medir el impacto cultural y afectar los recursos naturales, de manera drástica.

VI. Modos de constitución

La constitución de este derecho es siempre originaria, y nunca derivada, por cuanto no se apoya en el derecho de su predecesor.

La propiedad comunitaria indígena puede ser constituida:

- a) Por reconocimiento del Estado nacional o de los Estados provinciales de las tierras que tradicionalmente ocupen;
- b) por usucapión;
- c) por actos entre vivos y tradición;
- d) por disposición de última voluntad.

Una vez detectada la posesión de ciertas tierras, resulta innecesario que la comunidad indígena se someta al proceso de usucapión previsto por el Código, pues la propia Constitución le brinda un reconocimiento especial con efectos jurídicos. Al ser así, nada puede agregar una sentencia. Sin perjuicio de ello, si se pretendiese regularizar la situación mediante el otorgamiento de títulos de propiedad, es suficiente con

que las autoridades locales lo hagan a través de sus escribanías y, en el peor de los casos, podría recurrirse a las normas de la ley de regularización del dominio. En cuanto a las tierras que "tradicionalmente ocupan", el sentido de ocupación debe verse con criterio amplio, comprensivo de todas las tierras utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos naturales necesarios para su bienestar, sin las cuales no podrían desarrollarse ni sobrevivir, y no limitarse al territorio en el cual se hallan hacinados. A veces se encuentran en reservas que se asemejan a campos de concentración o a animales en un jardín zoológico.

El reconocimiento de la propiedad indígena por el Estado, sea nacional o provincial, cuando se trata de tierras fiscales, es el modo menos conflictivo, y que más aceptan las comunidades. Algunas leyes dispusieron la cesión de terrenos a determinadas comunidades (v. gr.: leyes 25.510, 25.325, 25.549, 25.811).

Al tratarse de un derecho real sobre un inmueble, para que sea oponible a terceros es necesaria la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.

VII. Caracteres

La propiedad indígena es exclusiva y perpetua, pero conforme a connotaciones diferenciadas del dominio y del condominio. Además, es inalienable e inembargable.

Esta propiedad no puede ser transmitida ni siquiera a otra comunidad indígena. Otra consecuencia de la inenajenabilidad es que no puede ser adquirida por usucapión por un tercero, así como su indivisibilidad.

No puede ser objeto de gravámenes, como la hipoteca, anticresis, etcétera. Tampoco puede ser embargada por eventuales acreedores. Se trata de normas tuitivas, consagradas por la Constitución Nacional, que pretenden preservar su identidad cultural.

Excepcionalmente, estas tierras podrían ser expropiadas por razones de interés público, en cuyo caso el Estado deberá proveer otras adecuadas para el traslado de la comunidad, y en tanto se cumplan los parámetros establecidos por el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT.

VIII. Aprovechamiento de los recursos naturales. Consulta

Se señaló anteriormente que existe una relación indisoluble entre la comunidad indígena y la tierra, y que ello, a su vez, forma parte de la cultura indígena. Esto se vincula con el medio ambiente, también integrante de dicha cultura y forma de vida.

Es claro que el problema de conservar el sistema ecológico atañe a todos los habitantes del planeta, pero no puede soslayarse que repercute aún más sobre quienes viven en contacto directo con la naturaleza. La Convención 169 de la OIT recuerda la contribución de los pueblos indígenas a la armonía ecológica, de ahí que haya propuesto, en el artículo 7º, que "Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan".

En este sentido, el artículo 15 de la Convención 169 de la OIT, luego de establecer en su primer párrafo que "Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente" y que éstos "comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos", dispone en su segundo párrafo que "En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar, siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades".

CAPÍTULO X

PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA

MNR

SUMARIO: I. Introducción. II. Naturaleza jurídica. III. El inmueble. IV. El constituyente. V. Beneficiarios. VI. Habitación efectiva. VII. Formas de constitución. VIII. Caracteres de la afectación. IX. Efectos de la afectación. X. Subrogación real. XI. Desafectación.

I. Introducción

El Código, siguiendo los lineamientos de la derogada ley 14.394, establece un régimen que tiende a proteger el inmueble destinado a vivienda. Es una institución que se orienta a la protección del núcleo familiar beneficiario, para asegurar su vivienda o su sustento, o ambas cosas.

La protección de la vivienda, y del núcleo familiar, se concreta, como se verá con detalle más adelante, al establecer una serie de recursos que ponen a cubierto a determinado inmueble de las contingencias o infortunios del titular, al no poder ser enajenado, ni gravado, ni hipotecado, ni ejecutado por deudas posteriores a su constitución; tener exención impositiva y no poder ser desafectado sino por causales estrictas y con el consentimiento del cónyuge o conviviente, salvo motivos atendibles.

La importancia en la protección posterior a la adquisición de un inmueble destinado a la vivienda se traduce como una herramienta fundamental para hacer operativas las previsiones constitucionales. De

nada sirve que se garantice el acceso, si no existen normas idóneas dentro del Derecho positivo destinadas a repeler las acciones tendientes a su pérdida.

II. Naturaleza jurídica

a) Situación del inmueble

Dado que el inmueble afectado no puede ser "objeto de legados o mejoras testamentarias", y que hay fuertes limitaciones para su enajenación o gravamen (art. 250), se puede decir que es, relativa o parcialmente, inenajenable.

b) Situación de los beneficiarios

Los beneficiarios tienen un derecho subjetivo, ubicado dentro de los derechos de familia patrimoniales, que se traduce en la facultad de exigir la inalienabilidad e inejecutabilidad del inmueble frente a quien intente desconocerlo, incluso contra el mismo propietario.

c) Situación del propietario constituyente

La afectación de un inmueble al régimen de bien de familia significa una modificación del derecho de dominio que sobre él tiene el constituyente.

Es claro que el régimen instituido al efecto por los artículos 244 y siguientes no implica un derecho real nuevo, pues no surge así de dicho ordenamiento. Basta tener en cuenta que, en materia inmobiliaria, la constitución de derechos reales debe ser instrumentada en escritura pública (art. 1017, inc. a), mientras que la afectación a dicho régimen hace optativa esa exigencia; sí, en cambio, es ineludible la inscripción en el Registro, pues a partir de ese momento la afectación es oponible a terceros (art. 244).

En suma, el régimen de la vivienda previsto en los artículos 244 y siguientes implica una restricción o límite al dominio constituida por el instituyente en beneficio de los familiares y parientes. Se podría objetar este criterio porque las limitaciones al dominio se originan en la ley, mientras que este régimen nace mediante un acto de voluntad

del interesado. La impugnación no es exacta por cuanto en el Título III del Libro Cuarto, Capítulo 4, del Código Civil y Comercial, existen restricciones a la libre disposición jurídica de las cosas (art. 1972).

Es entonces posible la existencia de limitaciones al dominio (o a la propiedad horizontal) cuyo origen no se encuentre sólo en la ley misma, sino también en la voluntad de los particulares, como ocurre en el régimen de vivienda, en tanto la ley los permita.

III. El inmueble

Sólo un inmueble puede ser afectado al régimen (art. 244). Según su ubicación puede ser urbano o rural, y debe estar afectado a vivienda (art. 248). Al menos, debe ser habitado efectivamente por uno de los beneficiarios (art. 247).

El Código no hace ninguna referencia al valor del inmueble *urbano*. Lo importante es que esté destinado a vivienda, lo que descarta inmuebles destinados a oficinas, locales comerciales, cocheras, turismo, etcétera. En cambio, si se trata de un inmueble *rural*, dispone el artículo 256 que no debe exceder "de la unidad económica, de acuerdo con lo que establezcan las reglamentaciones locales".

Si bien debe estar afectado a vivienda, no se pueden descartar *destinos mixtos*. Así, por ejemplo, en una casa podría habitar una familia en el piso alto, y la planta baja estar destinada a un local comercial. Con mayor razón si se trata de un inmueble rural, pues es muy factible que sea utilizado para la explotación agropecuaria o alguna otra.

Dice el artículo 244, en forma novedosa, que el inmueble puede ser afectado "por su totalidad o hasta una parte de su valor".

De todos modos, lo cierto es que admite la afectación parcial (no total). En tal caso, podría ejecutarse una parte del inmueble, y el adquirente en subasta pasaría a ser copropietario del inmueble afectado.

Aunque el Código se refiere a un inmueble habitable, vivienda, no puede descartarse la afectación de un *terreno vacío* en el que se construirá la vivienda.

Como se adelantó, "No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro

del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término" (art. 244, último párrafo). En la Ciudad de Buenos Aires se requiere una declaración jurada (art. 163, inc. b, dec. 2080/80).

IV. El constituyente

a) *Propietario. Copropietarios*

El constituyente debe ser dueño del inmueble. Si hubiere condominio, el artículo 245 exige que la afectación sea solicitada por todos los cotitulares conjuntamente, esto es, la decisión unánime de todos los condóminos, requisito que armoniza con las normas que rigen el condominio, según las cuales los actos de disposición deben ser realizados con el consenso de todos los condóminos (arts. 1990 y cons.).

También podría ser afectado un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal.

Bajo ciertas circunstancias, también está legitimado el usufructuario. La afectación durará hasta que se extinga el usufructo.

b) *Capacidad*

Teniendo en cuenta la índole del acto y las consecuencias que acarrea, la afectación, el constituyente debe tener capacidad para disponer a título oneroso. En el caso de una persona casada o en convivencia, podría afirmarse que es necesario el asentimiento del cónyuge (arts. 456, 457, 469 y 470) o del conviviente (art. 522), si pretende afectar un inmueble destinado a vivienda familiar.

Sin embargo, se sostiene lo contrario, pues la afectación del inmueble es un acto que beneficia al otro cónyuge, no se pone en peligro su conservación.

V. Beneficiarios

Establece el artículo 246 que "Son beneficiarios de la afectación:

"a) el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes;

"b) en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente".

Entre las novedades, cabe mencionar que puede ser beneficiario el propio "propietario constituyente". Al ser así, se puede concluir que el titular puede afectar el inmueble aun cuando viva solo y no tenga parientes. El Código pone el acento en la protección de la vivienda, incluso aquella unipersonal.

Otra novedad es que se incluye expresamente a la *conviviente*, lo cual no estaba previsto en la ley 14.394, aunque había sido reconocido el derecho en algunos fallos, máxime si tenían hijos menores.

Además del propietario, pueden serlo entonces su cónyuge o conviviente, sus ascendientes o descendientes. No es necesario que convivan con el constituyente. En defecto de ellos, pueden ser beneficiarios los parientes colaterales hasta el tercer grado (consanguíneos o no), pero aquí sí el Código exige que para serlo "convivan con el constituyente".

VI. Habitación efectiva

Dispone el artículo 247 que "Si la afectación es peticionada por el titular registral, se requiere que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble.

"En todos los casos, para que los efectos subsistan, basta que uno de ellos permanezca en el inmueble".

Es necesario que al menos uno de los beneficiarios aludidos en el punto anterior habite el inmueble. No tendría sentido este régimen de protección especial, que limita los derechos de eventuales acreedores, si el inmueble estuviese vacío.

Si se trata de colaterales beneficiarios, será también menester que al menos uno de ellos conviva con el constituyente (art. 246, inc. b).

VII. Formas de constitución

Este régimen de protección de la vivienda requiere un acto de afectación, esto es, que se inscriba en el Registro de la Propiedad Inmueble. A partir de allí surgirán los efectos previstos.

a) *Solicitada por el titular registral*

Como se señaló anteriormente, la afectación puede ser solicitada por el titular o cotitular del inmueble, se trate de dominio o de propiedad horizontal.

Los legitimados pueden presentarse directamente en el Registro, sin necesidad de formalidades especiales, o bien manifestar su voluntad por escritura pública, salvo el supuesto de constitución por donación (art. 1552, Cód. Civ. y Com.).

Si el legitimado acude directamente al Registro y solicita la afectación, ésta surtirá efectos desde el día de la presentación. Si la constitución se realiza mediante escritura pública, juegan entonces la retroprioridad y la prioridad indirecta consagradas por la ley 17.801, examinadas en el capítulo dedicado a la publicidad registral, donde se remite al lector. Los efectos surgirán, entonces, desde la expedición del certificado, si luego se cumplen los pasos siguientes dentro de los plazos correspondientes.

El trámite es gratuito, tanto en lo que concierne al pago de tasas y sellados, como al asesoramiento que deben prestar los representantes de la autoridad administrativa (arts. 252 y 253). De todos modos, los interesados, si lo desean, pueden hacer intervenir a profesionales, en cuyo caso sus honorarios —en conjunto— no podrán exceder del 1% de la valuación fiscal del inmueble (art. 254).

b) *Dispuesta por el juez*

También se puede efectuar la constitución por cualquier tipo de testamento y posterior inscripción registral por orden del juez del sucesorio, "...a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o del Ministerio Público, o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida" (art. 245, segundo párrafo). En este caso se prevé que el juez puede resolver incluso de oficio.

Agrega el artículo 245 que "La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida".

VIII. Caracteres de la afectación

La afectación del inmueble se caracteriza por ser:

- a) *Optativa*: el propietario, aun cuando estén dadas todas las condiciones, no está obligado a afectar su inmueble. Excepcionalmente, puede ser dispuesta por el juez.
- b) *Única*: no se puede afectar más de un inmueble propio al régimen de la ley; sí, en cambio, puede afectarse otro del cual sea condómino, quien ya afectó el suyo.
- c) *Imprescriptible*: no existe un plazo al cabo del cual caduque o se extinga la posibilidad de someterse al régimen de protección de la vivienda.
- d) *Irrenunciable*: ni el constituyente ni los beneficiarios pueden renunciar a los efectos y beneficios que derivan de la afectación.

IX. Efectos de la afectación

a) *Inejecutabilidad*

Una vez afectado, el inmueble *no puede ser ejecutado* por los créditos nacidos con posterioridad a la fecha de inscripción en el Registro; esto es, cuya causa sea posterior a la afectación. El Código no dice que el inmueble no pueda ser embargado, sino que "no es susceptible de ejecución" (art. 249, segundo párrafo), lo que no es exactamente lo mismo. Por ende, podría ser embargado pero no subastado.

En cambio, el inmueble puede ser embargado y ejecutado por créditos nacidos con anterioridad a esa fecha, en resguardo de los derechos adquiridos por terceros. La regla de la inejecutabilidad rige aun en caso de concurso o quiebra.

b) *Excepciones*

La inejecutabilidad reconoce excepciones en el artículo 249, cualquiera sea la fecha del crédito. Deja de tener importancia para estos acreedores que la deuda sea anterior o posterior a la afectación. Se trata de los siguientes:

b.1) *Obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que graven directamente el inmueble (inc. a)*

Ocurre que la obligación de pagar las expensas comunes surge del Código y del Reglamento de Propiedad Horizontal, de manera que su causa es anterior a la afectación.

Por otra parte, si no fuera así, muchas personas adquirirían un inmueble y luego, al afectarlo, podrían dejar de pagar las expensas sin consecuencias. La situación sería caótica si todos los consorcistas hicieran lo mismo.

En cuanto a los impuestos, tasas y contribuciones, han pesado más los intereses del Estado en la percepción de estos créditos que el interés de la familia.

b.2) *Obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituida de conformidad con lo previsto en el artículo 250 (inc. b)*

El artículo 250 permite gravar el inmueble con la conformidad del cónyuge o del conviviente, o en su defecto con autorización judicial, "si éste se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida..."

Ocurre que cuando el inmueble está afectado a este régimen, es probable que su titular se vea privado de la posibilidad de obtener crédito. Es poco probable que alguien le preste dinero si tiene este solo inmueble, y afectado. Por lo tanto, el Código le ofrece la posibilidad de gravarlo sin que al acreedor en cuestión le sea oponible la afectación, la que seguirá siendo oponible a otros acreedores, si los hay.

b.3) *Obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda (inc. c)*

Si la vivienda está afectada a este sistema, pero el titular introduce mejoras de cualquier tipo, sería un contrasentido que el inmueble sea mejorado pero que su acreedor no pueda ejecutarlo si no se le paga el crédito. El Código trata de evitar un enriquecimiento injusto.

b.4) *Obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces, o con capacidad restringida (inc. d)*

La afectación del inmueble tiene por objetivo asegurar la vivienda, ya sea del titular, ya de los beneficiarios. Es evidente, entonces, que no puede ser oponible este sistema a quienes deben recibir cuidados y alimentos por parte del titular, especialmente si se trata de menores o incapaces, quienes por su condición son más vulnerables.

c) *Las situaciones de excepción no se extienden a otros acreedores*

Como se ha visto precedentemente, ciertos acreedores pueden ejecutar el inmueble afectado aun cuando sus créditos sean de causa posterior a la afectación. Si se ejecuta el inmueble y hubiera un remanente, no puede ser agredido por los acreedores que no tenían derecho a ejecutar. La situación de estos últimos no mejora por el remate del inmueble. La solución es la misma sea la ejecución individual o colectiva. El remanente le corresponde al propietario y queda a salvo por obra de la subrogación real (art. 249).

d) *Frutos*

Según el artículo 251: "Son embargables y ejecutables los frutos que produce el inmueble si no son indispensables para satisfacer las necesidades de los beneficiarios".

e) *Cosas muebles*

Son inembargables "las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y de sus hijos" (art. 744, inc. a). Además, según el artículo 456: "Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de

seis meses de la extinción del régimen matrimonial". Si se trata de una unión convivencial inscripta, ver artículo 522.

f) *Límites a la enajenabilidad*

Establece el artículo 250 que "El inmueble afectado no puede ser objeto de legados o mejoras testamentarias, excepto que favorezcan a los beneficiarios de la afectación prevista en este Capítulo. Si el constituyente está casado o vive en unión convivencial inscripta, el inmueble no puede ser transmitido ni gravado sin la conformidad del cónyuge o del conviviente; si éste se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la transmisión o gravamen deben ser autorizados judicialmente".

En determinados supuestos la enajenación puede ser compulsiva; por ejemplo, en los siguientes casos:

- 1) Expropiación por causa de utilidad pública.
- 2) Si el inmueble fuese reivindicado por un tercero que acreditase tener un mejor derecho que el constituyente, quedaría sin efecto la afectación y dicho inmueble le sería restituido a aquél.
- 3) Pueden presentarse casos de ejecución judicial provocada por acreedores a los cuales la afectación no les sea oponible (p. ej., por haber nacido sus créditos con anterioridad a la afectación), o cuyos créditos estén comprendidos en las excepciones previstas por el artículo 249 (pago de tasas o impuestos, mejoras, etc.).

Otra situación en la cual el inmueble puede cambiar de titular se daría en el supuesto de morir el constituyente, en cuyo caso sus herederos se convertirían en los nuevos titulares del dominio.

g) *Actos de administración*

En principio, el titular del dominio puede realizar sobre el inmueble actos de administración, pues el Código no establece prohibiciones al respecto.

Cabe entonces preguntarse sobre la posibilidad de que el inmueble pueda ser alquilado, pues ello impediría que sea habitado por el titular y/o beneficiarios, fin que persigue esta figura.

MNR

Guastavino ha interpretado que el arrendamiento sólo puede ser admitido en forma excepcional y temporaria, como ocurriría en el caso de inmuebles que, reuniendo los recaudos legales, pueden ser explotados como hoteles, pensiones u hospedajes, directamente por el propietario y su familia; o en aquellos supuestos en que el propietario no pudiese residir transitoriamente en el inmueble (por ser nombrado embajador o tener que mudar su residencia por algún tiempo).

X. Subrogación real

Antes de la sanción del Código actual, se advirtió que si el inmueble sufriera un incendio o fuera objeto de una expropiación, la suma de dinero que ingresara en el patrimonio del constituyente en concepto de indemnización no gozaría del privilegio de la inembargabilidad, al no haber previsto la ley la subrogación real que hubiera permitido la continuidad de la protección de la familia durante el tiempo transcurrido entre la realización del inmueble afectado y su sustitución por otro.

El Código actual ha recogido estas inquietudes y consagra la subrogación real. Dispone el artículo 248: "La afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio". Es que, de no ser así, el constituyente estaba impedido de mudarse.

Por lo tanto, si el propietario decide vender el inmueble afectado para luego adquirir otro, no corre el riesgo de que, entre una operación y otra, el precio que obtenga pueda ser embargado. Tampoco habría consecuencias negativas en el hecho de que el nuevo inmueble sea afectado en una fecha posterior, pues se mantienen los efectos del primero. La afectación, como dice el Código, "se transmite", ya sea a la nueva vivienda o a las sumas de dinero.

Otras consecuencias están previstas en la última parte del artículo 249: "Los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado, ni sobre los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea ésta ordenada en una ejecución individual o colectiva."

"Si el inmueble se subasta y queda remanente, éste se entrega al propietario del inmueble.

"En el proceso concursal, la ejecución de la vivienda sólo puede ser solicitada por los acreedores enumerados en este artículo".

XI. Desafectación

La desafectación es el acto con el cual se cancela la inscripción del inmueble como afectado al régimen de vivienda.

Las causas de desafectación están claramente mencionadas en el artículo 255 del Código. Procede la desafectación y la cancelación de la inscripción en el Registro Inmobiliario, en los casos que a continuación se enumeran:

- "a) a solicitud del constituyente; si está casado o vive en unión convivencial inscripta se requiere el asentimiento del cónyuge o del conviviente; si éste se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la desafectación debe ser autorizada judicialmente;
- "b) a solicitud de la mayoría de los herederos, si la constitución se dispuso por acto de última voluntad, excepto que medie disconformidad del cónyuge supérstite, del conviviente inscripto, o existan beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, caso en el cual el juez debe resolver lo que sea más conveniente para el interés de éstos;
- "c) a requerimiento de la mayoría de los condóminos computada en proporción a sus respectivas partes indivisas, con los mismos límites expresados en el inciso anterior;
- "d) a instancia de cualquier interesado o de oficio, si no subsisten los recaudos previstos en este Capítulo, o fallecen el constituyente y todos los beneficiarios;
- "e) en caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por este Capítulo, con los límites indicados en el artículo 249".

Los tres primeros supuestos enumerados configuran causales de desafectación voluntarias, mientras que los dos últimos importan causales forzosas. En cuanto a esto último, también hay que recordar que

el artículo 10 del Código Civil y Comercial veda el abuso del derecho, que podría configurarse si el inmueble excede notoriamente las necesidades del deudor y de su familia o beneficiarios.

En el caso de los coherederos o de los condóminos, se puede advertir una excepción al principio sentado por el artículo 1990, pues no se exige la decisión unánime de los coparticipes sino sólo la de la mayoría absoluta.

Así como procede la afectación de una parte del inmueble (art. 244), aunque el Código no lo diga puede concluirse que la desafectación también podría ser parcial.

CAPÍTULO XI

CONDOMINIO

MNR

SUMARIO: A) Condominio sin división forzosa. I. Antecedentes históricos. II. Concepto. III. Facultades de los condóminos. IV. Obligaciones de los condóminos. V. Administración. VI. Conclusión del condominio. B) Condominio con división forzosa temporaria. I. Introducción. II. Convenio de suspensión de la partición. III. Partición nociva. C) Condominio con división forzosa perdurable. I. Condominio sobre accesorios indispensables. II. Condominio sobre muros, cercos y fosos.

A) CONDOMINIO SIN DIVISIÓN FORZOSA

I. Antecedentes históricos

En el Derecho Romano una antigua forma de comunidad era la que se reconocía en la primitiva forma de comunidad hereditaria. Este modelo se caracterizaba por la subdivisión ideal de la propiedad común en cuotas abstractas. Esto ocurría cuando eran más de uno los herederos o legatarios.

En cuanto al derecho real de dominio, en principio y como una consecuencia del carácter exclusivo, una cosa no podía pertenecer al mismo tiempo a varias personas. Pero desde los tiempos más remotos se admitía ya en el Derecho Romano que varias personas podían tener en conjunto la propiedad de una cosa: la cosa permanece indivisa, pero el derecho de propiedad se encuentra dividido o fraccionado entre esas personas y le pertenece a cada una de ellas por una cuota parte numéricamente determinada: un medio, un cuarto, etcétera. Este derecho se designaba con el nombre de condominio o copropiedad. Los juristas romanos miraban con disfavor al condominio, lo que se ponía

en evidencia con el *jus prohibendi*, y la idea de su carácter transitorio. Existían acciones tendientes a terminar con el Estado de indivisión, especialmente la conocida *communi dividundo*.

La institución de la copropiedad o condominio ha pasado del Derecho Romano a las legislaciones modernas.

En el Derecho germánico se encuentra también la copropiedad romanista (*Mitteigenthum*). Pero al lado de ella existe además otro tipo de copropiedad enteramente distinto: la propiedad en mano común (*Gesamnte Hand*), que se caracteriza esencialmente por la inexistencia, de parte de los copropietarios, de un derecho individual sobre la cosa: la parte indivisa no existe, sino solamente un derecho a lo que resulte el día de la liquidación. Las principales aplicaciones de ella se encuentran en la sociedad, en la sociedad conyugal y en la comunidad hereditaria, regidas cada una de ellas por principios y reglas especiales.

II. Concepto

a) Introducción

La comunidad es aquella situación jurídica que se produce cuando la propiedad de una cosa o la titularidad de un derecho corresponden en conjunto y proindiviso a varias personas. Hay distintas situaciones que generan una comunidad (v. gr.: comunidad hereditaria, el régimen de gananciales de los cónyuges, etc.).

En lo que aquí interesa, se puede decir en términos sencillos que el derecho real de condominio es una especie del género comunidad, que se refiere al derecho real de dominio que pertenece a más de una persona. El dominio es exclusivo, sólo tiene un titular, cuando la cosa pertenece a más de una persona se llama, entonces, condominio.

Del mismo modo, el usufructo es un derecho exclusivo, lo que no impide que pueda haber varios titulares, en cuyo caso habrá cousinguato, también una especie de comunidad.

En el caso de otras comunidades, ya sea de derechos reales (v. gr.: cousinguato) o de otros bienes (v. gr.: indivisión hereditaria), se regirán por sus propias reglas y, en subsidio, por las previstas por el Código para el condominio (art. 1984).

b) Definición. Caracteres

Dice el artículo 1983 que "Condominio es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción".

De la definición que ofrece el Código se desprenden sus elementos distintivos:

- 1) *El condominio es un derecho real.* Es un derecho sobre cosa propia, principal que se ejerce por la posesión.
- 2) *Tiene por objeto una cosa.* Como sucede con los derechos reales, y a diferencia de otros estados comunitarios, el objeto del condominio es una cosa, que puede ser inmueble o mueble (registrable o no).
- 3) *Pertenece a más de una persona.* Pueden ser dos o más, sin límite en cuanto a la cantidad. Pueden ser personas humanas o jurídicas, incluso combinadas.
- 4) *Cada titular tiene una cuota, cuya proporción puede ser igual o diferente.* La definición legal dice que "corresponde a cada una por una parte indivisa". La parte indivisa, también llamada cuota, cuota parte, parte ideal, parte imaginaria o abstracta, representa la proporción que cada uno de los titulares tiene sobre la cosa, desde el punto de vista jurídico (v. gr.: 50%, 30%, etc.). Desde el punto de vista material no tiene repercusión, dado que el derecho de cada uno se proyecta sobre toda la cosa, sobre cada partícula, de modo que la parte indivisa tiene efectos jurídicos.

Así, por ejemplo, si dos personas son titulares de un automóvil, no significa que uno de ellos es dueño de dos ruedas y que las otras dos le corresponden al otro condómino. Por el contrario, las cuatro ruedas les pertenecen a ambos, ya que la división es ideal, imaginaria, pero no material.

El segundo párrafo del artículo 1983 establece una presunción de igualdad de cuota que opera en los casos en que exista alguna duda

sobre el valor de la parte alícuota de cada comunero. La presunción es *juris tantum*, lo que determina que, como se aclara en la norma, pueda dejarse de lado cuando la ley o el título que sirve de causa al condominio prevean otra cosa.

El condominio se rige principalmente por las normas del Título IV del Libro Cuarto. En aquello que no esté previsto, habrá que acudir en primer lugar a las normas sobre el derecho real de dominio (art. 1984), luego a las *Disposiciones generales* sobre derechos reales (arts. 1882 a 1907) y, finalmente, a las restantes normas del Código, especialmente a aquellas que regulen situaciones similares, como las de la comunidad hereditaria (arg. art. 1996).

c) Constitución

El condominio puede nacer por título y modo, por la inscripción registral constitutiva, por un acto de última voluntad, por disposición de la ley, y por prescripción. Además, hay que tener en cuenta cuando corresponda a los modos especiales de adquirir el dominio (v. gr.: apropiación por más de una persona, aluvión que incremente un inmueble que pertenece a varias personas, etc.). Hay que tener presente que las normas que regulan el dominio son supletoriamente aplicables al condominio.

En ocasiones es la propia ley la fuente del condominio. Así ocurre con los condominios de indivisión forzosa perdurable (medianería; accesorios al uso común de varios inmuebles; accesión de cosas muebles inseparables; descubrimiento de un tesoro en cosa ajena).

c.1) Prolongación de la indivisión hereditaria

Durante la vigencia del Código anterior una importante doctrina y corriente jurisprudencial sostuvo que si bien la comunidad hereditaria no es un condominio, si se inscribe en el Registro la declaratoria de herederos, y la situación se prolonga en el tiempo, se puede inferir que se ha constituido un condominio, o bien que los coherederos lo han hecho tácitamente. Debía transcurrir un tiempo "prolongado", aunque era una cuestión de hecho determinarlo en cada caso.

Lo cierto es que el Código actual no menciona a la prolongación

de la indivisión hereditaria como un supuesto de constitución de un condominio, ni en los modos de adquisición de los derechos reales en general, ni en los modos de adquisición del dominio, ni en el capítulo dedicado al condominio. Por ende, cabe entender que se ha desechado esta interpretación pues, de lo contrario, se la hubiera previsto. Al ser así, la indivisión hereditaria sólo concluye por la partición. Su prolongación, por extensa que sea en el tiempo, no se convierte en un condominio.

El artículo 2363 es concluyente en este sentido: "La indivisión hereditaria sólo cesa con la partición..."

De la partición puede surgir un condominio, si una cosa fuera adjudicada a más de un heredero. En tal caso, la constitución del derecho es convencional y el título lo constituye la cuenta particionaria aprobada judicialmente, la que se inscribe para su oponibilidad.

d) Comparación con otros estados comunitarios

El condominio tiene por objeto una o más cosas, mientras que otros estados comunitarios recaen sobre otra clase de bienes, derechos personales, y cuentan con sus propias regulaciones. Así, por ejemplo, la herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante (art. 2277). El matrimonio genera un régimen patrimonial especial, ya sea convenido por los cónyuges o impuesto supletoriamente por la ley (arts. 446, 463). Las obligaciones pueden ser de sujeto plural, esto es, pueden tener varios acreedores y/o varios deudores. Estas comunidades, tienen sus propios modos de constitución, administración y extinción.

En cuanto al régimen aplicable, puede haber coincidencias, ya que dispone el artículo 1984 que las normas sobre condominio se aplican, en subsidio de disposición legal o convencional, a todo supuesto de comunión de derechos reales o de otros bienes.

e) Clasificación

Existen dos clases de condominio, por un lado el condominio normal, común o sin indivisión forzosa, que se caracteriza por la facultad de los condóminos de pedir la división en cualquier momento desde su constitución; y por otro el condominio anormal o con indivisión

forzosa, en el cual, la posibilidad de proceder a la división se encuentra limitada por diferentes causas (por ley, por pacto entre los condóminos o por voluntad del testador). En este último caso la indivisión puede ser temporaria o perdurable.

III. Facultades de los condóminos

a) *Sobre la parte indivisa*

a.1) *Poder de disposición sobre la parte indivisa*

En cuanto a la parte indivisa, las facultades de los condóminos son amplias, ya que se considera que son las propias de un dueño. En cambio con respecto a la parte común, son sumamente restringidas, salvo el derecho de solicitar la partición en cualquier momento. El principio general lo establece el artículo 1989: "Cada condómino puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. Los acreedores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición, que les es inoponible. La renuncia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos". Las únicas facultades que pueden admitirse a su respecto son las jurídicas. Por el contrario, el ejercicio de facultades materiales se encuentra vedado por ser ello físicamente imposible.

Consecuencia de este criterio es que cada condómino puede enajenar o gravar su parte indivisa o una proporción inferior (en verdad, la cosa, pero con ese límite), y sus acreedores pueden hacerla embargar y vender antes o después de hacerse la división de los comuneros. Por ende, cada condómino puede vender, donar, hipotecar, e incluso abandonar, entre otros actos, sin necesidad del concurso de los otros comuneros. Puede aun constituir un usufructo sobre dicha cuota (arts. 2130, inc. d, 2131), lo que tendrá por consecuencia colocar al usufructuario en su mismo lugar con relación a los demás comuneros en el ejercicio del derecho a usar y gozar de la cosa común.

En cambio, el condómino no puede constituir servidumbre pues dicho derecho real grava la cosa común y en ese sentido el artículo 2168 del Código es categórico al exigir la concurrencia del conjunto de los condóminos.

a.2) *Derechos personales*

En cuanto a la constitución de derechos personales, no se puede alquilar ni siquiera la parte indivisa sin consentimiento de los demás.

a.3) *Acreedores. Hipoteca*

El Código prevé en el artículo 2207 que "Un condómino puede hipotecar la cosa por su parte indivisa. El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. Mientras subsista esta hipoteca, la partición extrajudicial del condominio es inoponible al acreedor hipotecario que no presta consentimiento expreso". En la misma línea, el artículo 2196 consagra la inoponibilidad de los actos jurídicos celebrados en perjuicio de la garantía.

Se pretende restar eficacia a aquellos actos que pueden ser realizados por el condómino en perjuicio del acreedor hipotecario. Por un lado, cualquier condómino tiene derecho a pedir la partición de la cosa común, pero por el otro hay que respetar la situación de los acreedores, que no vean frustrados sus derechos.

Si el acreedor hipotecario ejecuta la cosa, por la parte indivisa, antes de la partición, la situación es sencilla. Quien adquiera en el remate ocupará el lugar del condómino que había hipotecado, y el acreedor hipotecario cobrará del producido en el remate. Si el dinero sobra, le corresponde al condómino que sufrió la ejecución, si no alcanza, dicho excondómino seguirá siendo deudor, aunque ahora sin garantía hipotecaria. Los derechos reales de garantía se extinguen por efecto de la subasta pública del bien gravado (art. 2203).

Si ya se hizo la partición, aun cuando no le haya tocado en lote el inmueble al condómino que gravó su parte con hipoteca, cabe entender que ello no perjudica al acreedor hipotecario, quien puede igualmente perseguir la cosa, ya que se desprende del texto de los artículos 1989 y 2207 que el acto de partición le es inoponible.

Distinta será la solución si el acreedor hipotecario participa en la partición realizada por los comuneros y presta su conformidad con lo resuelto. De igual modo, si la partición se hace "judicialmente", será totalmente oponible al acreedor hipotecario lo que se resuelva, ya que el artículo 2207 dispone que es inoponible la "partición extrajudicial".

El Código no exige la notificación al acreedor, pero se puede deducir esta obligación tácita de hacerlo, pues de lo contrario será inoponible lo que se decida.

Ahora bien, cabe interpretar que no basta con que se lo cite, sino también que el acreedor tiene derecho a oponerse al acto de división que lo perjudique. De no ser así, la citación sería una mera formalidad sin consecuencias. El artículo 2195 faculta al acreedor a tratar de impedir aquellos actos que disminuyan el valor de la garantía.

a.4) *La renuncia*

Concluye el artículo 1989 señalando que "la renuncia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos".

El Código establece expresamente que el abandono beneficia a los demás condóminos, cuyas cuotas de ese modo se ven acrecidas con motivo de la renuncia. En el caso de inmueble, la renuncia deberá ser formalizada en escritura pública.

a.5) *Acciones*

El condómino puede ejercer, tanto contra otro condómino como respecto de terceros, todas las defensas posesorias.

En cuanto a las reales, puede promover la acción reivindicatoria. Si es contra otro condómino, la medida de la acción es la parte indivisa. Cuando se dirige contra terceros puede tener por objeto la totalidad o una parte material de la cosa, o puede reducirse a la medida de su parte indivisa.

También puede incoar la acción de deslinde (art. 2267).

b) *Sobre toda la cosa*

b.1) *Actos de disposición*

La regla general es que la disposición jurídica o material de la cosa, o de alguna parte determinada de ella, sólo puede hacerse con la conformidad de todos los condóminos (art. 1990). Ninguno de los condóminos puede sin el consentimiento de todos, ejercer sobre la parte común ni sobre una parte de ella, físicamente determinada, actos

materiales o jurídicos que importen el ejercicio exclusivo del derecho de propiedad. La oposición de uno bastará para impedir lo que la mayoría quiera hacer a este respecto.

Así, si pretende vender o hipotecar toda la cosa, será necesaria la conformidad de todos los titulares. Si alguno de ellos lo hiciera sin el consenso de los otros, el acto les será inoponible (art. 382). Esto es lógico, ya que por regla general nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene (art. 399). Asimismo, la conformidad de todos es necesaria para los actos de disposición material, como, por ejemplo, derribar una casa para reconstruirla, etcétera. El Código autoriza al condómino, cabe aclarar, la realización de mejoras necesarias o útiles sin el consentimiento previo de los otros.

b.2) *Uso y goce*

En lo que respecta al uso y goce, el Código es más flexible que con relación a los actos de disposición. Dice el artículo 1986: "Cada condómino, conjunta o individualmente, puede usar y gozar de la cosa común sin alterar su destino. No puede deteriorarla en su propio interés u obstaculizar el ejercicio de iguales facultades por los restantes condóminos".

Como surge del artículo, el uso y goce puede ser conjunto o individual. En el primer caso, a veces es complicado, otras es sencillo. Depende de lo que pacten los condóminos y de su buena disposición y respeto hacia el otro. Si no es posible el uso entre todos, o hay oposición, se aplica lo previsto en el artículo 1993.

b.3) *Convenios de uso y goce*

Los condóminos se encuentran facultados a pactar el uso y goce de la forma que estimen más conveniente. El Código les permite establecer un uso y goce alternado, o exclusivo y excluyente, e incluso sobre una parte material (arts. 1987/1988).

El uso y goce alternado se configuraría, por ejemplo, si pactan que la cosa la use una semana o un mes cada uno, o modalidades similares. Sería exclusivo si permiten que sólo uno de ellos use la cosa, o una

parte material de ella. Pueden establecer que tal uso y goce exclusivo sea remunerado o gratuito.

La resolución debe ser adoptada por unanimidad (arg. arts. 1990 y 1993).

b.4) *Uso y goce exclusivo y excluyente*

Puede suceder que uno de ellos practique un uso y goce excluyente de toda la cosa, sin permiso, o en medida mayor o calidad distinta a la convenida. Ello no da derecho a indemnización a los restantes condóminos, sino a partir de la oposición fehaciente y sólo en beneficio del oponente (art. 1988). Mientras no haya oposición, se entiende que hay un consentimiento tácito con la situación.

El Código recoge una reiterada jurisprudencia cuando uno de los condóminos de un inmueble notifica al otro el cese de la voluntad de admitir el uso gratuito del bien, y le reclama un monto por el uso exclusivo. El derecho al cobro nace a partir de la oposición. Asimismo, el derecho a la compensación sólo beneficia a quien se opone y en proporción a su parte, no a los restantes condóminos que guardan silencio. Esta indemnización se suele fijar teniendo en cuenta el valor locativo del inmueble. Los intereses corren desde la oposición.

b.5) *Mejoras*

Dice el artículo 1990 que "...No se requiere acuerdo para realizar mejoras necesarias. Dentro de los límites de uso y goce de la cosa común, cada condómino puede también, a su costa, hacer en la cosa mejoras útiles que sirvan a su mejor aprovechamiento".

El Código distingue entre las mejoras necesarias y las útiles. Las primeras pueden hacerlas entre todos, y también pueden ser realizadas por uno o algunos de ellos, ya que no es necesario un acuerdo previo. En tal caso, tiene el que hizo el gasto derecho al reembolso proporcional, siempre y cuando no se haya originado en su culpa (arts. 1938, 1991).

En cambio, el artículo 1938 permite reclamar el pago de las mejoras útiles pero sólo hasta el mayor valor adquirido por la cosa.

IV. Obligaciones de los condóminos

a) *Gastos*

Los condóminos están obligados a contribuir a los gastos de reparación y conservación, y las mejoras necesarias, y reembolsar a los otros lo que hayan pagado en exceso con relación a sus partes indivisas (art. 1991). Como se dijo en relación con las mejoras, si uno de los condóminos hizo el gasto, tiene derecho al reembolso de los otros, en proporción a las respectivas cuotas, con más los intereses desde la fecha del pago.

En el Código derogado, cualquiera de ellos podía librarse de esa obligación por el abandono de su derecho de propiedad (art. 2685).

El Código actual, si bien le permite al condómino abandonar su parte (art. 1989), aclara expresamente que "No puede liberarse de estas obligaciones por la renuncia a su derecho" (art. 1991). Se ha apartado del régimen anterior, y le ha quitado a esta obligación el carácter de *propter rem*, al no producirse la liberación por el abandono. Coincide con lo regulado para la propiedad horizontal, donde el abandono carece de efecto liberatorio (art. 2049).

b) *Deudas en beneficio de la comunidad*

Puede ocurrir que se obligue uno solo de los comuneros, o que lo hagan todos. Dispone el artículo 1992 lo siguiente: "Si un condómino contrae deudas en beneficio de la comunidad, es el único obligado frente al tercero acreedor, pero tiene acción contra los otros para el reembolso de lo pagado.

"Si todos se obligaron sin expresión de cuotas y sin estipular solidaridad, deben satisfacer la deuda por partes iguales. Quien ha pagado de más con respecto a la parte indivisa que le corresponde, tiene derecho contra los otros, para que le restituyan lo pagado en esa proporción".

En el primer caso, si quien contrató lo hizo por propio derecho, sin invocar y tener representación alguna, sólo él responde frente al acreedor, dado que el condominio no es una persona colectiva y no pueden los demás ser alcanzados por los efectos de una obligación de

fuente contractual en cuya génesis no intervinieron. Claro está que el condómino que contrató y cumplió con su obligación, según el artículo 1992, tiene el derecho de reembolso el que puede ejercer con los alcances de los artículos 1990 y 1991 (aspecto interno). Se considera una suerte de gestión útil (arts. 1781 y ss.).

Si la deuda ha sido contraída por todos sin expresarse la participación que a cada uno pertenece en la comunidad y sin pactarse la solidaridad, frente al acreedor responden todos por partes iguales, sin perjuicio de acción de reembolso de unos contra otros para que les abonen lo que hayan pagado de más, en relación a la cuota que les corresponde.

V. Administración

a) Imposibilidad de uso y goce en común

Si no es posible el uso y goce en común por razones atinentes a la propia cosa o por la oposición de alguno de los condóminos, éstos reunidos en asamblea deben decidir sobre su administración (art. 1993, Cód. Civ. y Com.).

Situaciones que pueden conducir al régimen de administración:

- 1) Cuando la cosa no es susceptible de uso común, en razón de su propia naturaleza, como por ejemplo, una casa con reducidas comodidades y las respectivas familias son numerosas.
- 2) Cuando la cosa es susceptible o no de uso común, pero algunos condóminos ejercen el *ius prohibendi*.

Si se da una de las situaciones citadas y si ninguno opta por la partición rige el artículo 1993. Esta norma no propone soluciones sino que deja a los interesados decidir lo que más les convenga. Las alternativas más usuales son: explotación por administración o arrendamiento de la cosa común. La decisión se tomará en una asamblea.

Podrían decidir, entre otras posibilidades, que administre un tercero o que uno de ellos sea el administrador.

Otra alternativa muy común es poner la cosa en alquiler. El Código no consagra una preferencia para algún condómino interesado en ser locatario, pero tampoco lo impide.

b) Asamblea

Prevé el artículo 1994 que "Todos los condóminos deben ser informados de la finalidad de la convocatoria y citados a la asamblea en forma fehaciente y con anticipación razonable.

"La resolución de la mayoría absoluta de los condóminos computada según el valor de las partes indivisas aunque corresponda a uno solo, obliga a todos. En caso de empate, debe decidir la suerte".

En primer lugar, "todos" deben ser informados y citados. Esto significa que si no se cumple con este recaudo la asamblea será nula. La citación debe ser hecha en forma fehaciente. La citación, además, debe contener información sobre la finalidad de la asamblea, para que no haya sorpresas y todos asistan debidamente preparados; debe ser comunicada con una anticipación razonable. Además deben indicarse otros datos sin los cuales no podrá tenérsela por satisfecha, como el lugar donde se celebrará la reunión, la fecha y hora en que se llevará a cabo, etcétera.

La mayoría requerida para decidir es la absoluta, esto es, más de la mitad (art. 1994, segunda parte, Cód. Civ. y Com.). Por ende, el quórum mínimo será ése, ya que de no reunirse, no podría haber mayoría. Dicha mayoría no es numérica, o sea que no se cuenta por persona, sino en proporción al valor de la parte de cada condómino en la cosa común, aunque corresponda a uno solo. Cabe entender que la mayoría se calcula sobre el total, y no sólo sobre los que asistieron a la reunión, ya que el Código se refiere a la mayoría "absoluta", no a la simple.

Si hubiera empate, decide la suerte. No obstante, les queda a los condóminos la alternativa de solicitar la partición.

c) Frutos

Dice el artículo 1995 que "No habiendo estipulación en contrario, los frutos de la cosa común se deben dividir proporcionalmente al interés de los condóminos".

Respecto de la división de los frutos, el artículo 1995 establece la correspondencia entre su reparto y los valores de las partes de los condóminos, en ausencia de estipulación en contrario (o disposición de última voluntad), que dispusiera otra manera para practicar esta división.

VI. Conclusión del condominio

a) *Modos generales*

Algunos modos generales de extinción de los derechos reales pueden ser aplicados al condominio, como por ejemplo, la destrucción de la cosa o el abandono. En lo que aquí interesa, existe una forma especial de concluir el condominio, cuando no está sujeto a una indivisión, que es la partición. Consiste en la conversión de la parte ideal que le corresponde a cada comunero en una porción o lote material, o en la adjudicación de toda la cosa, o en dinero, equivalente a su interés en la cosa.

b) *Partición*

Cuando el condominio es sin indivisión forzosa, dispone el artículo 1997 que "Excepto que se haya convenido la indivisión, todo condómino puede, en cualquier tiempo, pedir la partición de la cosa. La acción es imprescriptible". Esta norma se refiere a la "acción", pero lo cierto es que la división puede hacerse en forma privada, sin intervención judicial. Pedir la división es un derecho potestativo. Si los comuneros no se ponen de acuerdo, cualquiera de ellos puede acudir a la justicia a través de la "acción de división de condominio".

Éste es el principio general, que cede cuando se pactó lo contrario (art. 1997), o cuando cualquiera de los copartícipes pida que la partición se postergue total o parcialmente por el tiempo que fije el juez si su realización inmediata puede ser nociva (arts. 2001 y 2365).

Si bien la acción es imprescriptible, puede ocurrir que uno de los condóminos intervierta el título y posea en forma exclusiva, en cuyo caso puede adquirir el dominio de la cosa entera si transcurre el plazo de veinte años.

Por otro lado, no sería válida una renuncia a pedirla por tiempo indefinido o perdurable, ya que el Código sólo autoriza a suspenderla por un plazo que no exceda de diez años (ver arts. 2000 y 2001). Aquí juega el orden público (arts. 12 y 13). El artículo 1999 prohíbe en forma expresa la renuncia a ejercer la acción de partición "por tiempo indeterminado".

En cuanto a las reglas aplicables, rigen para el condominio las reglas de la división de la herencia, en tanto sean compatibles (art. 1996). Por ende, hay que acudir a lo dispuesto por los artículos 2363 y siguientes.

c) *Formas de hacer la partición*

c.1) *Privada o judicial*

Para dilucidar este tema hay que acudir a las normas sobre partición de la herencia, a las que el Código remite.

Según el artículo 2369: "Si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes. La partición puede ser total o parcial". De tal forma, además de la capacidad, la ley exige que haya "unanimidad" para decidir libremente el modo de hacer la partición, el que incluso puede ser judicial, si así lo desean. Esta partición es un contrato autónomo.

Ahora, establece el artículo 2371 que la partición debe ser judicial:

- "a) si hay copartícipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes;
- "b) si terceros, fundándose en un interés legítimo, se oponen a que la partición se haga privadamente;
- "c) si los copartícipes son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la partición privadamente".

El caso del inciso b, se vincula con lo señalado anteriormente respecto de los acreedores, especialmente el hipotecario, para quienes la partición es inoponible si no participa. Se trata de evitar que los condóminos resuelvan a sus espaldas y frustren sus derechos.

En este proceso judicial, todos los condóminos deben ser citados. Se trata de un litisconsorcio necesario.

La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que este proceso consta de dos etapas. En la primera, el juez declara disuelto el condominio; en la segunda, se ejecuta la sentencia y se decide la forma de partición si no fue convenida por los interesados.

c.2) *En especie o por venta o licitación*

La licitación consiste en el derecho que se reconoce a aquel de los herederos que considera que uno de los bienes había sido tasado por debajo de su valor real o afectivo, a ofrecer un valor mayor y a que ese bien pasase a integrar su hijuela.

Este último procedimiento, que consistía en una suerte de remate privado entre los condóminos disconformes con la tasación que se hubiera hecho de la cosa, fue eliminado por la reforma de 1968 (ley 17.711).

El Código Civil y Comercial actual reimplanta a la licitación como una de las vías posibles. De tal forma, hay tres maneras que pueden seguir los condóminos para dividir la cosa común, aunque, como se verá, una de ellas es la preferida.

En efecto, el artículo 2374 sienta el principio de partición en especie. Dispone que "Si es posible dividir y adjudicar los bienes en especie, ninguno de los copartícipes puede exigir su venta.

"En caso contrario, se debe proceder a la venta de los bienes y a la distribución del producto que se obtiene. También puede venderse parte de los bienes si es necesario para posibilitar la formación de los lotes". Cabe una aclaración: prevalece lo que decidan por unanimidad, pero si no hay acuerdo, y por ejemplo uno quiere vender y el otro quiere la partición en especie, este último podrá imponer su voluntad. Si es necesario, podrá acudir a la justicia para hacer valer su criterio. Esta disposición entra en funcionamiento por la voluntad de uno solo de los condóminos que así lo requiera aunque la mayoría prefiera la venta.

Por lo tanto, hay que determinar, en primer lugar, si es posible dividir en especie. Así, por ejemplo, si se trata de un campo de buenas dimensiones, podría ser dividido en lotes que se adjudiquen los comuneros. La cuestión es "si es posible". No siempre lo será.

No podrán dividirse en especie las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso o aprovechamiento. Las autoridades locales pueden reglamentar, en materia de inmuebles, la superficie mínima de la unidad económica, lo que debe ser respetado. La posibilidad tiene que ser física y jurídica. La doctrina ha señalado que, para preferir la división en especie, además de posible, tiene que ser "cómoda", expresión tomada del Derecho italiano.

De ser posible la división en especie, si las partes resultantes no fueran equivalentes a las cuotas de los condóminos, quien recibiera una fracción material que supere el valor de su parte indivisa, se vería precisado a compensar en dinero a quienes recibieran una de menor valor en comparación a su cuota. Esta solución —partición en especie con saldo— no puede imponerse a los condóminos. Necesariamente, debe haber acuerdo general entre ellos para que resulte factible.

El Código también prevé que la partición puede ser "mixta", esto es que se vendan algunos bienes, para luego formar lotes con los restantes y dividirlos en especie (art. 2374, último párrafo).

La división en especie también puede ser la vía para la constitución del derecho real de propiedad horizontal, como cuando una casa de varias plantas es sometida a ese sistema, porque se pueden cumplir los requisitos que pide el Código (v. gr.: unidades independientes, salida a la vía pública, etc.).

Si los condóminos prefieren, o no es posible la división en especie, deberá ser hecha por "venta". La división por venta, cualquiera que sea la naturaleza de la cosa, podrá ser llevada a cabo mediando acuerdo unánime. En este caso podrá arbitrarse la venta privada o en subasta, pública o particular. Si no hay acuerdo, intervendrá el Poder Judicial. Una vez vendida, los comuneros se reparten el dinero de acuerdo a su proporción.

Otra posibilidad es la "licitación". Hay que acudir al artículo 2372, previsto para la división de la herencia, al que el artículo 1996 remite.

Por ende, aquel condómino que pretenda quedarse con la cosa, deberá ofrecer un precio superior al de la tasación.

c.3) *Provisional o de uso*

La llamada partición provisional o del uso se produce cuando los condóminos recurren a este instituto, no con la finalidad de concluir el condominio, sino con el objeto de dividir el uso y goce de la cosa, ya que consiste en una reglamentación de sus facultades en tal sentido. El artículo 2370 llama a esta situación "partición provisional", y la resolución debe ser adoptada por unanimidad (arg. arts. 1990 y 1993). La partición provisional no obsta al derecho de pedir la partición definitiva.

c.4) *Partición parcial*

Nada impide que la partición sea parcial, ya sea porque hay varias cosas en condominio y sólo se concluye el condominio respecto de algunas, o bien se trata de una sola, pero se la divide materialmente y sólo una parte es dividida. Otra posibilidad, prevista en el artículo 2367, consiste en que una parte de los bienes no es susceptible de división inmediata, se puede pedir la partición de los que son actualmente partibles.

d) *Efectos de la partición*

En el Derecho Romano, ya se trataba de la *communi dividundo* (división de condominio) o de la familia *erciscundæ* (división de herencia), la partición tenía efecto constitutivo, es decir, traslativo de propiedad, por medio de la adjudicación que otorgaba extensos poderes a la autoridad judicial. La idea era que los condóminos se hacían recíprocas transmisiones.

En cambio, en el Derecho argentino, tanto el Código anterior como el actual, siguiendo al Derecho francés, han dispuesto que la partición tenga efecto declarativo. Sus efectos son declarativos y no traslativos de derechos (art. 2403), lo que significa que se considera que los derechos atribuidos al adjudicatario le han pertenecido desde el origen mismo del condominio y que los demás condóminos jamás han tenido parte alguna en la propiedad de la cosa común. Por el contrario, si fuera traslativo de la propiedad, sólo a partir de su realización quedaría constituido el derecho real en cabeza del adjudicatario.

Se trata de una ficción, que reconoce ciertas excepciones, como se dijo antes respecto de los acreedores y en especial del acreedor hipotecario. La fundamental de las excepciones consiste en la garantía por evicción y vicios redhibitorios que se deben entre sí los condóminos (arts. 2404/2407).

Otra excepción se encuentra en la situación de los acreedores del condómino, a los que el resultado de la partición les resulta inoponible (art. 1989).

El efecto declarativo sólo rige entre condóminos. Sólo tiene lugar cuando la cosa que estaba en condominio le toca en lote a alguno de los

condóminos, pero no cuando la cosa o cosas pasan a manos de un tercero (v. gr.: por una compraventa o una subasta, etc.). Es que no hubo partición sino un acto jurídico distinto. El artículo 2403, que establece el efecto declarativo, se refiere a los herederos, no a los extraños.

El efecto declarativo también se extiende al supuesto de una licitación.

e) *Adquisición por un condómino*

El condominio también cesa cuando alguno de los condóminos se hace dueño de la cosa común (v. gr., por la venta o la cesión de las partes indivisas realizada en su favor por la totalidad de los restantes comuneros, o la adquisición de la cosa en una subasta, o por licitación —art. 1998—).

Esta norma dispone que, de suceder tal supuesto, ello será considerado partición. Esto es importante ya que, como se vio, por regla la partición tiene efecto retroactivo, de modo que el condómino que adquirió las otras partes del condominio será considerado como propietario exclusivo de la cosa desde el origen de la indivisión (cfr. arts. 1906 y 2403).

El artículo 1998 dice que hay partición cuando toda la cosa pasa al dominio de sólo uno de los condóminos, por lo que surge la duda de si la hay cuando la división es parcial, o sea que subsiste el condómino pero entre menos personas. El segundo párrafo del artículo 2403 dice que también hay efecto declarativo "...respecto de los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido por efecto hacer cesar la indivisión totalmente, o de manera parcial sólo respecto a ciertos bienes o ciertos herederos".

B) CONDOMINIO CON INDIVISIÓN FORZOSA TEMPORARIA

I. Introducción

Tal como se ha visto hasta ahora, el condominio generalmente es sin indivisión forzosa, de modo que los condóminos, cuando lo deseen, pueden pedir la partición. Sin embargo, en ciertos casos no es posible

pedir la indivisión, porque una causa lo impide. Puede ser por voluntad de los propios condóminos, por decisión de un juez, o por imposición legal.

Los dos primeros casos son temporarios, en un tiempo desaparecen, que no puede exceder de los 10 y de los 5 años, respectivamente. Habría que agregar el caso de la indivisión forzosa que se produce cuando hay un condominio fiduciario (art. 1688), que puede durar poco o hasta 30 años, y a veces más (ver art. 1668); es temporaria pero puede ser prolongada. Otra alternativa es que la indivisión sea impuesta por un testamento, como ocurriría si una persona hace un legado de cosa cierta a más de una persona e impone la veda de la partición por un plazo que no puede exceder los diez años (art. 2330). Cuando la indivisión forzosa surge de la voluntad de la ley, es perdurable. Esto ocurre en el caso del condominio sobre accesorios indispensables (art. 2004), y en el de muros, cercos y fosos (arts. 2006 y ss.).

II. Convenio de suspensión de la partición

a) *Concepto*

En los casos de condominio normal, sin indivisión forzosa, no pueden renunciar los condóminos a pedir la división por tiempo indeterminado (art. 1999), es una disposición de orden público. En cambio, pueden convenir su suspensión por un tiempo determinado y máximo. Dice el Código que "Los condóminos pueden convenir suspender la partición por un plazo que no exceda de diez años. Si la convención no fija plazo, o tiene un plazo incierto o superior a diez años, se considera celebrada por ese tiempo. El plazo que sea inferior a diez años puede ser ampliado hasta completar ese límite máximo" (art. 2000).

Requiere la voluntad de "todos" los condóminos. Si sólo uno se opone, no será válida la decisión del resto.

b) *Plazo*

El plazo máximo por el que puede convenirse la indivisión es de diez años, lo que importa una elevación con relación al tope de cinco años que contemplaba el artículo 2693 del Código derogado. Si se pacta uno inferior, el convenio puede ser prorrogado hasta alcanzar

CONDÓMINOS
MNR

dicho límite máximo. La "renovación" de la indivisión, en cambio, si está permitida para los coherederos (art. 2331), pero no lo está para los condóminos, cuyas facultades quedan limitadas a lo que estrictamente conceden los artículos 1999 y 2000 del Código.

La fijación de un plazo máximo obedece a la necesidad de favorecer la libre circulación de los bienes y la libertad de disponer.

Si se establece un plazo superior, el convenio no es nulo, mantiene su valor, y la cláusula se reduce al plazo máximo permitido.

La misma solución (considerarlo celebrado por diez años) se aplica si "la convención no fija plazo, o tiene un plazo incierto".

Claro que si están todos de acuerdo, pueden dejar sin efecto lo convenido y realizar la partición cuando lo estimen conveniente. El problema surgirá cuando haya divergencias entre los condóminos, y entonces habrá que esperar diez años, aun cuando no haya sido lo que originalmente tuvieron en mente.

El Código no aclara a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo del referido plazo.

Resulta más conveniente considerar que dicho cómputo debe hacerse a partir de la fecha en que se celebró el convenio.

c) *Partición anticipada*

A pesar de haber convenido la indivisión, en determinadas circunstancias los condóminos pueden anticiparla, sin esperar el transcurso del plazo pactado. Si están de acuerdo, no hay inconveniente alguno. Si no coinciden, uno de ellos puede pedirle a un juez que la anticipe sin respetar lo convenido.

Dice el artículo 2002 que "A petición de parte, siempre que concurren circunstancias graves, el juez puede autorizar la partición antes del tiempo previsto, haya sido la indivisión convenida u ordenada judicialmente".

La medida de anticipar la partición no puede ser resuelta de oficio, sino "a petición de parte": un condómino o un tercero interesado (v. gr.: acreedor). Justamente, el artículo 2003 exige la inscripción registral de las cláusulas de indivisión, o la anticipación, para que sean oponibles a terceros.

Para que se justifique el pedido, deben mediar "circunstancias graves". Así, por ejemplo, podría ocurrir que esperar el plazo convenido haga perder oportunidades de venta, que luego no se conseguirán porque la cosa perderá su valor, o se deteriorará.

d) *Publicidad*

El Código exige, cuando sea posible, la publicidad de los convenios de indivisión o su cese. El artículo 2003 prevé lo siguiente: "Las cláusulas de indivisión o el cese anticipado de la indivisión sólo producen efecto respecto de terceros cuando se inscriban en el respectivo registro de la propiedad".

La norma se refiere obviamente a aquellas cosas que, además de estar en condominio, sean registrables, como los inmuebles, automóviles, etcétera. Estos convenios, o la decisión judicial de anticipar el plazo convenido, deben ser inscriptos en el Registro respectivo. Es sano que los terceros que puedan contratar con los condóminos sepan que los bienes están, o no, sujetos a un convenio de indivisión.

III. Partición nociva

a) *Concepto*

En esta hipótesis los condóminos no convinieron suspender la partición, ni están de acuerdo en seguir tal camino, pero uno o algunos de ellos, por motivos graves, considera que en ese momento dividir el condominio sería contraproducente. Dice el artículo 2001 que "Cuando la partición es nociva para cualquiera de los condóminos, por circunstancias graves, o perjudicial a los intereses de todos o al aprovechamiento de la cosa, según su naturaleza y destino económico, el juez puede disponer su postergación por un término adecuado a las circunstancias y que no exceda de cinco años. Este término es renovable por una vez". Aquí la indivisión es impuesta por el juez.

El artículo 2001 da algunos motivos: "circunstancias graves, o perjudicial a los intereses de todos o al aprovechamiento de la cosa, según su naturaleza y destino económico". Lo que da sustento principal a

esta postergación es la idea de nocividad. "Nocivo", según el *Diccionario* de la Real Academia quiere decir dañoso, pernicioso, perjudicial.

El artículo 2001 autoriza a pedir la postergación cuando la partición sea perjudicial para todos, o para cualquiera de los condóminos. La nocividad que se invoque para impetrar la demora de la división, debe estar fundada en perjuicios que ella acarrearía a los propios condóminos.

Cuando se argumente que la partición es perjudicial a los intereses de todos los condóminos —ya no exclusivamente del reclamante de la indivisión— o al aprovechamiento de la cosa común —medido éste en función de su naturaleza y destino económico—, el Código no exige la concurrencia de "circunstancias graves" sino que deja el asunto en manos del juez.

Claro que debe haber motivos importantes, no cualquier causa justifica la postergación. Debe suscitar algún perjuicio de relieve al menos para uno de los condóminos.

La postergación de la partición, por ser reputada nociva, no ha tenido mucha aplicación en la jurisprudencia. El criterio ha sido generalmente estricto. Pocos precedentes han aceptado la necesidad de aplicar el instituto. Ello es debido al supuesto disfavor con que es mirado el condominio por la ley.

Se decidió que corresponde diferir la división del condominio por venta del bien hasta tanto cese el derecho de habitación de la viuda, si el precio a obtenerse mientras exista el mencionado derecho fuera indudablemente inferior, en evidente perjuicio de los condóminos.

b) *Plazo*

Si el juez considera que la partición es, en ese momento, nociva, y decide su postergación, debe hacerlo por "un término adecuado a las circunstancias y que no exceda de cinco años" (art. 2001).

Este plazo es renovable por una sola vez, de modo que diez años será el tope máximo. A la vez, si hay circunstancias graves, se le puede pedir al juez que anticipe el plazo que hubiere fijado.

c) *Partición anticipada*

Dice el artículo 2002 que "A petición de parte, siempre que con-

curran circunstancias graves, el juez puede autorizar la partición antes del tiempo previsto, haya sido la indivisión convenida u ordenada judicialmente”.

d) *Publicidad*

El Código exige, cuando sea posible, la publicidad de los convenios de indivisión o su cese. El artículo 2003 prevé lo siguiente: “Las cláusulas de indivisión o el cese anticipado de la indivisión sólo producen efecto respecto de terceros cuando se inscriban en el respectivo registro de la propiedad”.

Por ende, la decisión judicial de postergar la división por un plazo determinado, o la posterior anticipación si concurren los requisitos del artículo 2002, debe ser inscripta en el Registro correspondiente si se trata de cosas registrables, para que sea oponible a terceros interesados de buena fe.

C) CONDOMINIO CON INDIVISIÓN FORZOSA PERDURABLE

I. Condominio sobre accesorios indispensables

Éste es un caso de condominio nacido de la voluntad de la ley (art. 1894) y cuya indivisión forzosa también es de origen legal. Se trata de una indivisión forzosa “perdurable”, esto es, que mientras subsista la afectación no se puede pedir la partición.

Dice el artículo 2004 que “Existe indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común de dos o más heredades que pertenecen a diversos propietarios. Mientras subsiste la afectación, ninguno de los condóminos puede pedir la división”.

En esta situación hay al menos dos inmuebles que pertenecen a propietarios distintos. Cada inmueble puede también pertenecer a más de una persona en condominio. A su vez, hay cosas afectadas “como accesorios indispensables” al uso de dichos inmuebles. Sobre dichas cosas accesorias se configura un condominio respecto del cual ninguno de los dueños puede pedir la partición, al menos mientras dure la

afectación. Son ejemplos de este supuesto los bebederos o pozos que sirven para el riego de dos o más campos, la canaleta de desagüe entre dos fábricas, un patio o jardín fuente de aire y luz, la calle entre dos o más fundos, etcétera.

En cuanto a los actos de disposición, los condóminos pueden disponer de su parte indivisa si al mismo tiempo enajenan el inmueble al que sirven los accesorios, pero no pueden hacerlo por separado ya que tales accesorios son necesarios e imprescindibles para los diversos fundos que se aprovechan de ellos. El condominio sobre tales accesorios es inseparable de los inmuebles. El criterio de la inseparabilidad está ínsito en su naturaleza.

Sobre el uso de toda la cosa común (no de una parte), dispone el artículo 2005 que “Cada condómino sólo puede usar la cosa común para la necesidad de los inmuebles a los que está afectada y sin perjudicar el derecho igual de los restantes condóminos”.

Esta norma se refiere a la facultad de usar. Nada dice sobre las obligaciones de los condóminos, lo que impone recurrir —por vía de la analogía— a lo que se dispone en el condominio sin indivisión forzosa y para el supuesto de indivisión forzosa de muros, cercos y fosos. Por ello, cada condómino estará obligado a pagar los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias, contando con una acción de reembolso de lo que hubiere pagado en exceso de su alícuota (arts. 1991 y 2027).

II. Condominio sobre muros, cercos y fosos

En esta situación hay al menos dos inmuebles que pertenecen a propietarios distintos. Cada inmueble puede también pertenecer a más de una persona en condominio. A su vez, hay un muro, cerco o foso que los divide. Sobre dichas cosas accesorias se configura un condominio respecto del cual ninguno de los dueños puede pedir la partición. Este condominio es inseparable del derecho sobre el inmueble, no se puede enajenar este último sin que a la vez se transmita la parte proporcional del muro, cerco o foso. No pueden extraños tener derecho sobre el muro, deben ser titulares o cotitulares de los inmuebles colindantes.

a) *Distintas clases de muros*

De acuerdo a como fueron construidos, esto es según su emplazamiento físico, los muros reciben distintos nombres en el Código, que conviene tener presente por sus proyecciones. También se los clasifica desde el punto de vista jurídico.

Dice el artículo 2006: "*Muro, cerco o foso*. El muro, cerco o foso se denomina:

- "a) lindero, separativo o divisorio: al que demarca un inmueble y lo delimita del inmueble colindante;
- "b) encaballado: al lindero que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes;
- "c) contiguo: al lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo que el filo coincide con el límite separativo;
- "d) medianero: al lindero que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes;
- "e) privativo o exclusivo: al lindero que pertenece a uno solo de los colindantes;
- "f) de cerramiento: al lindero de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo;
- "g) de elevación: al lindero que excede la altura del muro de cerramiento;
- "h) enterrado: al ubicado debajo del nivel del suelo sin servir de cimiento a una construcción en la superficie".

En cuanto a la primera clasificación, según cómo fueron constituidos: es la de *divisorios* o *no divisorios*. El muro divisorio (también llamado separativo o lindero) es el que toca el límite que separa a un inmueble del otro inmueble vecino. Puede haber distintas paredes dentro de un terreno, pero sólo aquella que toca o está sobre la línea separativa es la que recibe el nombre de divisoria.

A su vez, las paredes divisorias pueden ser *encaballadas* o *contiguas*. Ambas tocan el límite, pero la primera está asentada sobre ambos, teóricamente mitad sobre cada terreno. El muro encaballado debe tener su epicentro exacto en la línea demarcadora de los límites de los fundos

lindantes, de manera que las mitades del muro se asienten de manera ecuaníme en ambos terrenos colindantes. Está construido de tal manera que su eje, en el sentido de plano vertical que pasa por el centro del mismo, coincide exactamente con el límite demarcatorio de ambos fundos. Vale decir, que se halla ubicado a caballo sobre el límite, tomando una franja de terreno, de ambos fundos colindantes.

En cambio, la contigua, si bien toca la línea divisoria, está asentada sobre uno solo de los inmuebles vecinos: su borde toca el límite. Tanto las encaballadas como las contiguas deben tener una altura mínima de 3 metros, como se verá más adelante. Pero pueden ser más altas, en cuyo caso el excedente recibe el nombre de "muro de elevación"; hubiera sido más prolijo llamarlo "elevado" para que guarde armonía con los otros nombres. A su vez, mirando hacia abajo del nivel del suelo, las paredes tienen cimientos que las sostienen. Ahora, si se construyó una prolongación que exceda los cimientos, esa parte de la pared recibe el nombre de "muro enterrado".

Desde el punto de vista jurídico, las paredes linderas pueden ser *medianeras* o *privativas*. La pared se llama *medianera* cuando hay un condominio, es decir, le pertenece a los titulares de los inmuebles vecinos. Es *privativa* cuando le pertenece exclusivamente sólo a uno de los vecinos. El muro de cerramiento, sea contiguo o encaballado, hasta los 3 metros de altura es medianero, salvo casos excepcionales de renuncia. El de elevación y el enterrado pueden ser una especie u otra.

Cuando existe la obligación de encerrarse entre paredes, como se verá más adelante, la pared divisoria, sea encaballada o contigua, recibe el nombre de "muro de cerramiento".

b) *Derecho y obligación de encerramiento*

El Código Civil y Comercial, así como atribuye el derecho de encerrarse entre paredes (art. 1944), también obliga a los colindantes a hacerlo cuando viven en centros de población urbanos o suburbanos. Esta obligación tiene su fundamento en la necesidad de separar las heredades por medio de un solo muro, debido a razones de higiene, seguridad, embellecimiento edilicio, economía de terreno y para asegurar la garantía de la privacidad de los actos humanos.

Dice el artículo 2007 que el cerramiento urbano es forzoso, en los siguientes términos: "Cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en un núcleo de población o en sus arrabales tiene frente al titular colindante, el derecho y la obligación recíprocos, de construir un muro lindero de cerramiento, al que puede encaballar en el inmueble colindante, hasta la mitad de su espesor".

No se trata tan sólo de una facultad, sino también de una obligación. La obligación que surge del artículo 2007, que es posible incluir dentro de las llamadas "obligaciones reales" es, a su vez, una verdadera restricción legal al dominio, establecida en el interés recíproco de los propietarios colindantes. El cerramiento de las heredades sitas en los centros de población y sus arrabales es forzoso, en el sentido de que cualquiera de los propietarios linderos puede obligar en todo momento a su vecino a contribuir a la construcción y conservación de la pared. Este último, a su vez, sólo puede liberarse de tal obligación haciendo uso de la facultad de abandono con respecto a la franja de terreno sobre la cual se apoya el muro y renunciando a la medianería.

La norma alude a centros de población urbana y sus suburbios o aledaños. En las zonas rurales el cerramiento forzoso es diferente, sin necesidad de que se trate de un muro (art. 2031).

Es una obligación de orden público.

Se regula aquí el derecho de encaballar el muro divisorio, esto es, asentar la mitad en el terreno del vecino.

Esta posibilidad que el Código otorga a quien construye primero en los centros de población facilita la adquisición de la medianería por parte del vecino que no ha contribuido a la construcción de la pared, que no deberá soportar la adquisición de la franja de terreno; promueve el cerramiento de los fundos mediante una sola pared a gastos comunes; limita el dominio promoviendo su adecuada explotación económica mediante el ahorro de espacio, materiales y mano de obra y fomenta el progreso edilicio con toda equidad, pues si el vecino constructor no pudiera hacer uso de esta facultad, perdería parte de su propio terreno, circunstancia sumamente gravosa en construcciones de considerable altura.

c) *Muro de cerramiento forzoso*

En los centros de población existe el deber de encerrarse entre paredes. El cerramiento es forzoso, no voluntario. Esta obligación no se puede satisfacer libremente, sino de acuerdo a las reglas que sienta el Código sobre sus características. No es suficiente con colocar un toldo, un cartón o una sábana, sino que debe ajustarse la construcción a determinados requisitos. Dice el Código en el artículo 2008 que "El muro de cerramiento forzoso debe ser estable, aislante y de altura no menor a tres metros contados desde la intersección del límite con la superficie de los inmuebles. Esta medida es subsidiaria de las que disponen las reglamentaciones locales".

Los 3 metros de altura mínima se cuentan "desde la intersección del límite", lo que no es tan claro. Cabe entender que tenga una altura desapareja, de modo que los 3 metros deben al menos existir en la zona de la línea divisoria. Si los terrenos son desaparejos, y uno es más alto que otro, deben contarse los 3 metros desde el más elevado.

El muro debe tener, como mínimo, 3 metros de altura, pero puede tener más. Cabe advertir que hasta los 3 metros el muro será medianero, es decir, le pertenecerá a ambos vecinos. Por encima de esa altura, le pertenecerá a quien lo construyó, si es que no fue construido por ambos de común acuerdo.

Es relevante tener en cuenta lo que dispongan las reglamentaciones locales sobre las características de la pared divisoria, ya que el Código es supletorio. Generalmente exigen un espesor de 30 cm, de modo que si el muro se construye encaballado, debería ocupar 15 cm de cada inmueble. En cuanto al material, además de piedra o ladrillo, un muro puede construirse en hormigón o con bloques huecos o macizos de hormigón. Habrá que consultar el Código de Edificación de la localidad respectiva.

En cuanto a la altura, también el Código es subsidiario. Los distintos códigos de la edificación de la Argentina no contienen alturas iguales, generalmente oscilan entre los 1,80 y 2,20 m.

d) *Derecho del que construye el muro*

Es posible que ambos vecinos se pongan de acuerdo y que a costa

de ambos decidan la construcción de la pared divisoria. Si no es así, uno solo de ellos puede tomar la decisión e iniciar la construcción del muro. Quien construye primero tiene la opción de hacerlo encaballado o contiguo, es decir, asentarlos mitad en su terreno y mitad en el predio lindero, o bien todo en su terreno (art. 2007). No debe exceder de la mitad.

e) *Adquisición de la medianería*

Ya sea que uno de los dueños de uno de los inmuebles construya el muro encaballado o contiguo, esta pared es medianera hasta los tres metros, cualquiera sea su altura. El muro de cerramiento forzoso no puede tener menos de 3 metros, pero sí es posible que se lo construya más alto, nada lo impide. Hasta los 3 metros será medianero (art. 2009).

Si el muro es más alto, lo que recibe el nombre de "muro de elevación", esta parte que sobresale en altura puede ser medianera o privativa. En efecto, dice el artículo 2009 que "...También es medianero el muro de elevación, si el titular colindante de un derecho real sobre cosa total o parcialmente propia, adquiere la copropiedad por contrato con quien lo construye, o por prescripción adquisitiva".

Entonces, hasta los 3 metros el muro construido es medianero. Por encima de esa altura, es privativo, le pertenece a quien lo construyó, pero puede ser medianero también si el titular colindante adquiere el condominio. Puede adquirir el condominio de dos maneras: por contrato o por usucapión.

Otra posibilidad es que el colindante sea obligado a adquirir, si utiliza el muro de elevación, y si el constructor de la parte elevada lo demanda judicialmente antes de que se cumpla el plazo de prescripción.

Lo dicho sobre el muro de elevación es aplicable también al muro enterrado (art. 2017).

f) *Cobro de la medianería*

f.1) *Hasta los tres metros de altura*

Como se dijo, aunque el muro sea construido por uno solo de los colindantes, encaballado o contiguo, es medianero desde su construcción hasta la altura de 3 metros. Por lo tanto, el dueño del inmueble vecino debe contribuir con el costo.

Condómino
MNR

Dispone el artículo 2014 que quien afrontó la construcción tiene derecho a que su condómino le pague: 1) la mitad del valor de muro y de sus cimientos; 2) además, la mitad del valor del terreno en el que se apoya el muro, teniendo en cuenta que si es contiguo, está asentado íntegramente en el terreno de quien lo construyó. Hay también condominio sobre el suelo que se encuentra debajo del muro, pero en el caso del muro contiguo, esa franja de terreno era privativa porque le pertenecía al dueño del inmueble que aportó todo su terreno para construir el muro.

Cabe suponer que quien construye primero preferirá hacerlo encaballado, para sacrificar menos de su terreno. Pero puede ocurrir que prefiera hacerlo contiguo, todo en su terreno, para luego poder vender una parte de su terreno que quizás no precisaba y obtener algún dinero.

La obligación del pago de la medianería, una vez determinado su "valor" en la sentencia, se convierte en obligación de dar dinero, por lo que será el juez el encargado de decidir cuáles rubros componen la cuenta de medianería (y adecuar las sumas en litigio), para lo que tendrá en consideración —además del costo de los materiales y de la mano de obra— que el reembolso debe comprender las mermas del poder adquisitivo de la moneda y otros elementos que también integrarán ese "valor", como por ejemplo el estado de conservación actual del muro, las ventajas que le reportará al adquirente, la confección de los planos y la amortización por antigüedad. La prueba pericial reviste una importancia primordial y debe prevalecer su opinión fundada sobre la aplicación rígida de las tablas o procedimientos de depreciación por antigüedad.

f.2) *Mayor valor por características edilicias*

Dice el artículo 2015 que "No puede reclamar el mayor valor originado por las características edilicias del muro y de sus cimientos, con relación a la estabilidad y aislación de agentes exteriores, que exceden los estándares del lugar".

Si por algún motivo el que construyó el muro le asignó atributos especiales, para hacerlo más estable o reforzó su aislación, pero excediendo "los estándares del lugar", no tiene derecho a reclamar del colindante ese plus agregado.

Al tratarse de un cerramiento forzoso, regido por el orden público, y que hace nacer un condominio desde la construcción, el Código pretende evitar que quien construye primero se pueda aprovechar de su vecino construyendo una pared con características fuera de lo común. Distinto es el caso, como se verá, del muro de elevación o del enterrado.

f.3) *Adquisición y cobro de los muros de elevación y enterrado*

Cabe recordar que “El que construye el muro de elevación sólo tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del muro, desde que éste lo utilice efectivamente para sus fines específicos. El mismo derecho tiene quien construye un muro enterrado, o quien prolonga el muro preexistente en profundidad mayor que la requerida para su cimentación” (art. 2017).

Cuando uno de los colindantes construye por su cuenta la pared divisoria, ya sea encaballada o contigua, hasta los 3 metros de altura se genera un condominio. En cambio, por encima de esa altura, o por debajo del suelo, la construcción es privativa, le pertenece a quien la hizo. Quien construyó nada puede reclamar. El otro titular, si lo desea, puede adquirir la medianería de la parte alzada o de la enterrada, pagando el valor correspondiente, y el primero no puede oponerse; sería una especie de venta forzosa.

Ahora, si el vecino que no contribuyó, “utiliza efectivamente” la parte elevada o el muro enterrado, estará obligado a adquirir. Ya no se trata de un derecho imprescriptible, sino de una obligación. Al ser una obligación, si no paga, el que construyó le puede reclamar. Aquí el condominio nacerá cuando pague (contrato) o cuando se cumpla el plazo de prescripción adquisitiva (20 años).

Esta obligación nace con la utilización efectiva, que es un concepto amplio. Significa una utilización directa e inmediata de la pared, una utilización específica, cualquiera que sea su forma (apoyo de construcciones, instalación de cañerías, abrir armarios, empotramiento de tirantes, etc.). Al contrario, no implica servirse de la pared el simple hecho de arrimar construcciones sin apoyarlas de ninguna forma, colocar clavos para colgar ropa, colgar jaulas, revocar la pared, etcétera.

En cuanto a la determinación del valor, hay una diferencia con los

primeros tres metros de altura, ya que dispone el artículo 2016 que “El titular colindante de un muro de elevación o enterrado, sólo tiene derecho a adquirir la medianería como está construido, aunque exceda los estándares del lugar”.

La diferencia radica en que en el primer caso el condominio nace con la construcción, y satisface la obligación legal de encerramiento. En cambio, cuando el muro es elevado o enterrado, el colindante no está obligado a pagar y convertirse en condómino, ni a utilizarlo. Si decide hacerlo, entonces debe pagarlo tal como fue construido. Cabe también suponer que quien lo construyó, si hizo un muro más alto de lo que pide el Código, o lo hizo en profundidad, habrá tenido buenos motivos para hacerlo y entonces tiene derecho a que se le pague el valor real, aunque supere al estándar.

Además, si el muro no reúne los requisitos de solidez que necesita el adquirente, puede luego reconstruirlo (art. 2024).

f.4) *Legitimación*

Están legitimados para adquirir la parte alzada o enterrada del muro quienes sean condóminos del muro de cerramiento forzoso, que por hipótesis se extiende desde el nivel del suelo hasta los tres metros de altura, a lo que cabe agregar a los cimientos.

El Código menciona al “titular colindante” (arts. 2016, 2018), que puede abarcar al dueño del inmueble lindero, o a sus condóminos, si son más de uno. Además de titular colindante, como se dijo, es menester ser condómino del muro de cerramiento forzoso, de manera que quien abandonó el derecho de medianería (art. 2029), si luego pretende adquirir la parte elevada o enterrada, debe también adquirir el muro de cerramiento (arg. art. 2028, segunda parte).

También se encuentran legitimados para adquirir (y cobrar) la medianería los titulares del derecho real de propiedad horizontal. Si bien el muro es una parte común de propiedad de los titulares (art. 2041, inc. i), la jurisprudencia ha aceptado la legitimación activa y/o pasiva del consorcio a través de su representante legal. El muro es propiedad de los titulares, no forma parte del patrimonio del consorcio, pero hay que admitir que la solución de reconocerle legitimación al consorcio

es muy práctica, ya que de lo contrario habría juicios con múltiples intervinientes, con todos los inconvenientes que ello trae aparejado.

El artículo 2009 alude a titulares de un derecho real sobre cosa total o parcialmente propia. Además del dominio, condominio y propiedad horizontal, también son derechos reales sobre cosa propia los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, y el derecho de superficie si existe propiedad superficiaria (art. 1888). Por ende, cabe reconocer a estos titulares también la facultad de adquirir la medianería, o de reclamar su cobro al titular del inmueble colindante.

f.5) Medida de la obligación

Dice el artículo 2018: "El titular colindante tiene la obligación de pagar el muro de cerramiento en toda su longitud y el de elevación sólo en la parte que utilice efectivamente".

El Código distingue y trata de diferente forma lo que concierne al largo de la pared (longitud) y lo vinculado a la altura.

En cuanto a la longitud, el titular colindante tiene que pagar toda la extensión. Es lógico que así sea ya que sobre el muro hay un condominio que nació con la construcción, ya sea que se haya levantado en forma encaballada o contigua. Por ende, el condómino debe pagar todo el valor de lo que le pertenece. Esto significa la mitad del valor de la pared y de los cimientos, más la mitad del valor del terreno si es que el muro es contiguo.

En resumen, si la pared divisoria se extiende por cuarenta metros, el vecino no constructor del muro deberá adquirir esa longitud o la menor que tenga su terreno, aunque sólo lo cargue con su edificación a lo largo de veinte metros, o no lo utilice de ninguna forma, ya que el artículo 2018 no le permite limitar la adquisición de una pared de encerramiento a la porción que utiliza.

En cuanto a la altura, por encima de los 3 metros el muro le pertenece a quien lo construyó; es privativo. El titular colindante puede adquirir la medianería de la parte elevada, o estará obligado a hacerlo si la utiliza efectivamente. En este último caso, sólo está "obligado" a pagar "la parte que utilice efectivamente".

Así, por ejemplo, si la pared tiene 20 metros, y el colindante utiliza

efectivamente 5 metros por encima de los 3, está obligado a pagar lo que utiliza efectivamente. También deberá abonar los 3 metros si no lo hizo antes. No obstante, si lo desea, puede adquirir toda la altura (art. 2009), en tanto no se configure un caso de abuso del derecho. De la misma manera se resuelve el caso del muro enterrado.

f.6) Época en la que se determina el valor de la medianería

El valor del muro puede variar por diversas circunstancias. Cuando es nuevo tiene un valor que luego puede depreciarse por el paso del tiempo, el desgaste, etcétera. Pero esto no es definitivo, ya que también el valor puede oscilar en determinada época por cuestiones de mercado. Es posible que en un momento los materiales de construcción y los inmuebles tengan precios elevados y que en otro su cotización caiga (v. gr.: falta de demanda, depresión económica).

Dice el artículo 2019 que "El valor computable de la medianería es el del muro, cimientos o terreno, según corresponda, a la fecha de la mora". Por lo tanto, habrá que establecer cuándo incurrió en mora el colindante obligado a pagar, para fijar el valor del muro, cimientos y terreno.

En cuanto al momento de la mora, dice el artículo 2014 que "El que construye el muro de cerramiento contiguo tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor..." Por ende, la mora se producirá a partir del reclamo y del vencimiento del plazo que a tal fin fije el acreedor.

f.7) Cesión del crédito

Es válida la cesión del derecho a la percepción del crédito proveniente del muro medianero que separa un fundo del vecino.

f.8) Obligación "propter rem"

El artículo 2028 permite la liberación de esta obligación de pagar la mitad del valor del muro, cimientos y, en su caso, terreno, mediante el abandono de la medianería. Por ende, se trata de una obligación *propter rem*.

Al ser así, se puede afirmar que el crédito se transmite activa y pasivamente con la transmisión del inmueble separado por el muro.

f.9) *Caso de la pared próxima*

Se ha planteado en la doctrina el caso de la pared próxima, que sería aquella que no toca el límite que separa a un inmueble de otro, pero se encuentra cerca. La construcción se levanta íntegramente dentro de un predio, pero no en el preciso linde que lo separa del vecino, sino guardando una distancia retirada del mismo. Se deja un espacio libre intermedio entre el filo externo de la pared o paramento exterior del muro del edificio, y el límite que lo separa con su convecino lindero.

Sobre tal pared no hay condominio (medianería), ya que éste nace cuando se construye un muro de cerramiento forzoso, encaballado o contiguo, hasta los 3 m de altura (ver arts. 2007/2009).

Podrá configurarse un condominio, en tal caso, si el titular colindante se pone de acuerdo con quien construyó semejante pared, y le abona la mitad del valor de la pared, de los cimientos, y de toda la franja de terreno. Si no hay acuerdo, no hay medianería.

El problema puede suscitarse cuando la distancia que separa a dicho muro de la línea divisoria sea ínfima, sin respetar los reglamentos locales, e impidiendo el derecho del otro vecino a construir su pared encaballada, si así lo desea. Si bien cada dueño, en su inmueble, tiene el derecho de construir las paredes que quiera, lo cierto es que su derecho acaba donde comienza el derecho ajeno. Al ser así, el colindante podría exigirle que derrumbe su construcción antirreglamentaria, que frustra su propio derecho, o bien que le transmita el condominio de la construcción y del terreno para no llegar a ese extremo.

g) *Prescripción*

g.1) *Prescripción liberatoria*

El que construye primero el muro de cerramiento forzoso, medianero hasta los 3 m de altura y en toda su longitud, tiene derecho a

reclamarle al colindante el reembolso de la mitad del valor de la pared, de los cimientos y, en su caso, del terreno.

Esta obligación prescribe al cabo de cinco años (art. 2560), contados desde la construcción del muro.

En el caso del muro de elevación o del enterrado, dicho plazo corre desde que la obligación es exigible, lo que sucede cuando el colindante realiza actos de utilización efectiva del muro, ya que esa actividad lo obliga a adquirir la medianería de la parte alzada o enterrada (art. 2020).

Cabe interpretar que si prescribió la acción para exigir el cobro de la construcción del muro de cerramiento forzoso (hasta los 3 m), dicha obligación no renace en el supuesto de que el condómino que no pagó comience a realizar actos de utilización efectiva sobre el muro de elevación o el enterrado. Lo prescripto ya no se puede reclamar, y a partir de la utilización efectiva se puede exigir el pago del valor de la parte utilizada.

g.2) *Prescripción adquisitiva*

En el caso del muro de elevación o del enterrado, cuando el colindante realiza actos de utilización efectiva de esas partes del muro, sin haberlas adquirido por compra, esa actividad lo obliga a adquirir la medianería de la parte alzada o enterrada (arts. 2009, 2017, 2018, 2020).

Pues bien, si no media un contrato de adquisición, y el dueño de dicha parte del muro no reclama el cobro, transcurridos veinte años de utilización efectiva de la parte elevada o enterrada se adquiere la medianería por prescripción adquisitiva (arts. 1897, 2565 y cons.).

h) *Prueba. Presunciones*

El Código Civil y Comercial, para facilitar la prueba de la medianería o de su inexistencia, establece presunciones, que admiten prueba en contrario.

Dispone el artículo 2010 que "A menos que se pruebe lo contrario, el muro lindero entre dos edificios de una altura mayor a los tres metros, se presume medianero desde esa altura hasta la línea común

de elevación. A partir de esa altura se presume privativo del dueño del edificio más alto". Esta norma alude al "muro lindero", de modo que las presunciones funcionan tanto si el muro es encaballado como contiguo.

Las presunciones allí contenidas únicamente se aplican respecto del muro de elevación y no del de cerramiento construido en los términos indicados en el artículo 2008, pues la medianería resulta de la propia disposición de la ley, sin que pueda presumirse otra cosa, a menos, claro está, que se verifique el supuesto de abdicación previsto en el artículo 2028.

h.1) Presunciones de medianería y de privacidad

Como se sabe, hasta la altura de tres metros, el muro no se presume sino que "es" medianero (salvo abdicación). A partir de esa altura se presume la medianería "hasta la línea común de elevación", esto es, hasta la altura del edificio más bajo. La presunción se justifica por la circunstancia de que los dos edificios aprovechan por igual dicho muro, y por tal situación se presume que ambos propietarios han contribuido a su levantamiento, ya que de lo contrario, si tal construcción fue afrontada por uno solo de ellos, no es presumible que quien la hizo permita el uso por el otro sin el consiguiente pago.

Por encima de esa línea, se presume que el muro es privativo del edificio más alto (se sigue a Aubry y Rau). En tal caso, como ese sector de la pared no es utilizado sino por el edificio de mayor altura, se presume que sólo al dueño del edificio más alto le pertenece.

Obviamente, si ambos edificios son de la misma altura, la pared se presume medianera en toda su elevación.

h.2) Deben ser dos edificios

El artículo 2010 establece las presunciones para "el muro lindero entre dos edificios", de modo que no se aplican si el muro no divide dos edificios. Agrega el artículo 2012 que "Las presunciones de los artículos anteriores no se aplican cuando el muro separa patios, huertos y jardines de un edificio o a éstos entre sí".

En cambio, si un edificio comparte la pared con un patio, jardín

o huerto, no se aplican las presunciones. Tampoco si divide patios, jardines o huertos entre sí.

Aquí también impera el sentido común, ya que no es razonable pensar que el dueño de un patio o jardín haya contribuido a levantar un muro más alto de lo que exige la ley para cumplir con el cerramiento forzoso.

En el caso de patios, huertos o jardines, entre sí o con un edificio, el que alega la medianería o lo contrario, carga con la prueba, sin el beneficio de presunción alguna.

h.3) Época de las presunciones

Dice el artículo 2011 que "Las presunciones del artículo 2010 se establecen a la fecha de construcción del muro y subsisten aunque se destruya total o parcialmente".

h.4) Prueba

Cuando no rigen las presunciones, corresponde probar el carácter medianero o privativo del muro. A su vez, cuando son aplicables las presunciones, se puede probar lo contrario ya que son *juris tantum*. El Código privilegia ciertos medios probatorios, por encima de otros, siendo la prueba por excelencia la que emana de un título.

En este sentido, dice el artículo 2013 que "La prueba del carácter medianero o privativo de un muro o la que desvirtúa las presunciones legales al respecto, debe provenir de instrumento público o privado que contenga actos comunes a los dos titulares colindantes, o a sus antecesores, o surgir de signos materiales inequívocos.

"La prueba resultante de los títulos prevalece sobre la de los signos".

No cualquier medio de prueba se admite para combatir la eficacia de las presunciones, sino que la propia norma indica en forma limitativa los únicos medios hábiles.

Los medios probatorios admitidos son:

1) Instrumento público o privado.

El instrumento es la especie del género "documento". El artículo 2013 exige que tales documentos sean "comunes a los dos titulares colindantes" o -lo que es lo mismo- "a sus antecesores".

No tendría efecto alguno una declaración unilateral en la que uno de los colindantes manifieste que la pared le pertenece. Así, por ejemplo, si alguien vende su casa y en el contrato de compraventa declara que el muro de elevación le pertenece y se lo transmite a su comprador, todo ello es inoponible al otro vecino e ineficaz para desvirtuar la presunción, pues no puede aceptarse que alguien constituya por sí mismo un derecho a su favor.

2) *Signos materiales* inequívocos. Es otra prueba que puede oponerse a la presunción y que podría acreditar la medianería de toda la pared o la privacidad de su parte más baja. Se trata de señales materiales consistentes en huecos en vigas, vestigios de revoques, canaletas de cañerías, etcétera, que desmientan, ya la medianería, ya la privacidad del muro, o simplemente que su determinación queda librada a la determinación judicial.

Si la contradicción se verifica entre un signo y un instrumento, el artículo 2013 otorga a estos últimos mayor valor. Se tiene en cuenta que los signos no son más que simples indicios que deben ceder en presencia de pruebas directas, como las emanadas de instrumentos públicos o privados.

i) *Facultades de los condóminos*

i.1) *Facultades materiales. Regla general*

La regla general la sienta el artículo 2021: "El condómino puede adosar construcciones al muro, anclarlas en él, empotrar todo tipo de tirantes y abrir cavidades, aun en la totalidad de su espesor, siempre que del ejercicio regular de ese derecho no resulte peligro para la solidez del muro".

Se trata de un condominio, en el que ambos condóminos están en un pie de igualdad, de modo que tienen facultades materiales sobre el muro en todo su espesor. Hay dos límites claros: 1) el derecho igual del otro; 2) no afectar la solidez del muro. El ejercicio de estas facultades materiales debe ser "regular", lo que implica sin excesos ni abusos.

La enumeración que hace el artículo 2021 no es taxativa, ya que nada impide que el condómino pueda realizar otros actos fuera de los

Condómino
MNR

expresamente enunciados, como por ejemplo pintar o realizar una pintura sobre la pared.

i.2) *Prolongación del muro*

Dice el artículo 2022: "El condómino puede prolongar el muro lindero en altura o profundidad, a su costa, sin indemnizar al otro condómino por el mayor peso que cargue sobre el muro. La nueva extensión es privativa del que la hizo".

La norma comienza señalando que "El condómino puede prolongar el muro lindero", de modo que para ejercer esta facultad, primero hay que ser condómino del muro lindero ya existente. El condominio nace con la construcción, pero si por hipótesis uno de los condóminos hubiera abdicado su derecho (art. 2029), para ejercer esta facultad de prolongar deberá primero readquirir la medianería y convertirse en condómino (art. 2030).

Es probable que uno de los titulares colindantes necesite prolongar el muro, ya sea elevarlo o hacerlo más profundo. La hipótesis más común sería porque quiera construir un edificio más alto, o bien extender una construcción bajo la superficie (v. gr.: hacer un garaje).

El Código lo faculta a hacerlo y, obviamente, "a su costa". Se supone que es una necesidad de uno de los dos vecinos, pero bien puede ocurrir que ambos deseen hacerlo y costearlo.

Esta prolongación seguramente implicará, como prevé el artículo 2022, que se cargue sobre el muro "mayor peso". Mientras no se ponga en peligro la solidez del muro, que es el límite fijado por el Código (art. 2021), el otro condómino no puede oponerse.

Aquí también cabe exigir, como lo hace el artículo 2021 para otras facultades materiales, como la de abrir cavidades, que el ejercicio sea regular. El Código establece que no se indemniza el "mayor peso", para evitar discusiones y litigios. Tampoco se resarcen las meras molestias, pero si por negligencia se causare un daño, el perjudicado podrá reclamar la indemnización (arg. art. 2026).

La nueva extensión, en altura o en profundidad, le pertenece a quien la hace, quien fue el que la solventó. El titular colindante, si lo desea, puede adquirir la medianería de esa parte elevada o enterrada.

Si utiliza efectivamente dichas partes privativas, estará obligado a adquirir las.

i.3) *Restitución del muro al estado anterior*

Si el condómino realiza actos materiales de los previstos en los artículos 2021 y 2022, y causa un perjuicio al colindante, éste podría pedir la indemnización del daño sufrido. Además, dispone el Código que “Si el ejercicio de estas facultades genera perjuicio para el condómino, éste puede pedir que el muro se restituya a su estado anterior, total o parcialmente” (art. 2023).

i.4) *Reconstrucción*

Se ha visto anteriormente que cada condómino tiene amplias facultades materiales sobre el muro, entre otras la de elevarlo o prolongarlo en profundidad. Puede ocurrir que el muro, tal como está construido, no sirva a sus fines, en cuyo caso el Código lo autoriza a demolerlo y reconstruirlo. Esto es posible cuando necesite uno más firme, porque no pueda soportar el mayor peso que se le imponga, o la construcción que se pretende adosar, etcétera.

Dice el artículo 2024 que “El condómino puede demoler el muro lindero cuando necesite hacerlo más firme, pero debe reconstruirlo con altura y estabilidad no menores que las del demolido. Si en la reconstrucción se prolonga el muro en altura o profundidad, se aplica lo dispuesto en el artículo 2022”.

El artículo 2024 dice que puede demoler y reconstruir el muro existente el “condómino”. No podría obrar así quien no lo sea. Por ende, si el vecino hubiera abdicado la medianería, no podrá reconstruirlo sin adquirir previamente el condominio. A igual conclusión se puede arribar en el caso del muro elevado o enterrado que fuera privativo del otro colindante.

No obstante, surge alguna duda sobre la justicia de la solución, ya que lo cierto es que quien demuele y reconstruye afronta de su peculio todo el gasto, y si previamente debe adquirir la medianería, el muro le cuesta el doble. Por otra parte, el colindante, dueño exclusivo del

muro que es reconstruido, se beneficiaría por ser condómino de un muro mejor al que él había construido en su momento.

Si es más alto o más profundo, será medianero hasta la altura del anterior y el excedente le pertenecerá a quien reconstruyó (art. 2022, al que remite el art. 2024).

En cuanto al espesor, si es necesario hacerlo más ancho, quien reconstruye deberá tomar superficie de su propio terreno. Dice el artículo 2025 que “Si para la reconstrucción se utiliza una superficie mayor que la anterior, debe ser tomada del terreno del que la realiza y el nuevo muro, aunque construido por uno de los propietarios, es medianero hasta la altura del antiguo y en todo su espesor”.

Dicho muro reconstruido ahora es más ancho e igualmente medianero “en todo su espesor”. La superficie que se necesite agregar debe ser aportada por quien tuvo la necesidad de demoler y reconstruir. Es lógico que así sea ya que el colindante había cumplido con la obligación de cerramiento, y es el otro condómino quien tiene la necesidad de hacer uno nuevo.

No dice el artículo 2025 que recaiga un condominio sobre esa porción de terreno que debió agregar el interesado en la reconstrucción, ya que se limita a decir que “el nuevo muro [...] es medianero [...] en todo su espesor”. Ante el silencio de la ley, cabe interpretar que el terreno agregado le pertenece exclusivamente a quien lo aportó.

El ejercicio de la facultad consagrada en la norma no da derecho al vecino a indemnización alguna, a menos, claro está, que la pared no sea efectuada “con la diligencia adecuada según las reglas del arte” (art. 2026).

j) *Gastos y mejoras*

Establece el artículo 2027 que “Los condóminos están obligados, en la proporción de sus derechos, a pagar los gastos de reparaciones o reconstrucciones de la pared como mejoras necesarias, pero no están obligados si se trata de gastos de mejoras útiles o suntuarias que no son beneficiosas para el titular colindante”.

Lo aquí previsto para la medianería urbana se aplica también a la medianería rural (art. 2033).

En cambio, si el muro medianero ha sido dañado o destruido por un hecho culpable de uno de los condóminos, sólo éste está obligado a su reparación o reconstrucción.

k) *Abdicación de la medianería*

k.1) *Concepto*

Los derechos reales se pueden extinguir por el abandono de la cosa (art. 1907), figura que es aplicable a la medianería. El tema está previsto en el Código de la siguiente forma: artículo 2028: "El condómino requerido para el pago de créditos originados por la construcción, conservación o reconstrucción de un muro, puede liberarse mediante la abdicación de su derecho de medianería aun en los lugares donde el cerramiento es forzoso, a menos que el muro forme parte de una construcción que le pertenece o la deuda se haya originado en un hecho propio. No puede liberarse mediante la abdicación del derecho sobre el muro elevado o enterrado si mantiene su derecho sobre el muro de cerramiento".

k.2) *Alcance de la abdicación*

Artículo 2029: "La abdicación del derecho de medianería por el condómino implica enajenar todo derecho sobre el muro y el terreno en el que se asienta". Como dice esta norma, se enajena "todo derecho", de modo que el titular colindante se convierte en dueño exclusivo del muro y del terreno en el que se asienta. Se abdica también el condominio sobre el muro de elevación y/o el enterrado, en caso de existir. Estas partes del muro son inseparables del muro de cerramiento forzoso (hasta los 3 m), no se puede abdicar una y conservar la otra.

k.3) *Efecto de la abdicación*

El efecto que produce la abdicación es la liberación del pago de los créditos originados en la construcción, reparación o reconstrucción. Al ser así, se trata de una obligación real.

k.4) *Forma del abandono*

Producido el abandono, la pared desde el punto de vista físico pasa a ser contigua, y jurídicamente de propiedad exclusiva (privativa) del vecino. Si en el futuro el que abandonó necesitara utilizarla efectivamente (art. 2017) o deseara readquirir su medianería (art. 2030), deberá pagar su valor, el de los cimientos y el de la mitad del terreno en que se asienta. Dice el artículo 2030 que "El que abdicó la medianería puede readquirirla en cualquier tiempo pagándola, como si nunca la hubiera tenido antes".

La forma instrumental exigida es la escritura pública (art. 1017, inc. a), y a efectos de su oponibilidad a terceros, el título respectivo debe ser inscripto en el Registro de la Propiedad.

k.5) *Condiciones del abandono*

El muro no debe ser parte de una construcción que pertenezca a quien pretende abdicar. De otro modo, se estaría renunciando a las cargas y conservando las ventajas de la propiedad.

La exigencia de que las obras de reparación o reconstrucción no se hayan hecho necesarias a causa del obrar de quien pretende renunciar se funda en que, en este caso, la obligación de cargar con tales gastos, no es propiamente una obligación derivada de la propiedad, sino del acto ilícito que creó tal necesidad.

k.6) *Readquisición de la medianería*

Prevé el artículo 2030: "El que abdicó la medianería puede readquirirla en cualquier tiempo pagándola, como si nunca la hubiera tenido antes". Se trata de una facultad imprescriptible, ya que puede ejercerse "en cualquier tiempo". Hay que pagar todo, la mitad del valor del muro, de los cimientos y del terreno.

Dice el artículo 2030 que como si antes no se hubiera tenido ningún derecho, de modo que el adquirente no puede pretender que se le descuente alguna suma que ya hubiera abonado cuando fue condómino. Cuando tomó la decisión de abandonar, sabía que éstas son las consecuencias.

En el supuesto de que realice sobre el muro, ahora privativo, actos de utilización efectiva (v. gr.: cargar una construcción, pasar tirantes, etc.), estará obligado a adquirirla. Esa facultad se convierte en obligación, y se hará condómino cuando pague o cuando se cumpla el plazo de prescripción adquisitiva.

l) *Cerramiento forzoso rural*

Fuera de un núcleo de población, o de sus aledaños, el cerramiento es "rural". También aquí el cerramiento es forzoso, pero la obligación se satisface de manera diferente.

Dispone el artículo 2031 que "El titular de un derecho real sobre cosa total o parcialmente propia, de un inmueble ubicado fuera de un núcleo de población o de sus aledaños, tiene el derecho a levantar o excavar un cerramiento, aunque no sea un muro en los términos del cerramiento forzoso. También tiene la obligación de contribuir al cerramiento si su predio queda completamente cerrado".

El titular del derecho real puede construir un muro que cumpla con los requisitos exigidos por el artículo 2008, o bien puede levantar o excavar un cerramiento más simple. El Código es más flexible, menos exigente, en la campaña. A la vez, si el cerramiento lo provoca el otro titular colindante, y su predio queda completamente cerrado, estará obligado a contribuir. Se trata de grandes extensiones, por lo que no es imaginable la construcción de muros, como en los centros de población.

Puede ser un muro u otro tipo de cerramiento. Así, por ejemplo, alambrados, cercos vivos, zanjas, fosos, etcétera. Cualquiera sea la modalidad, el cerramiento es medianero (art. 2032).

La obligación de contribuir al cerramiento sólo existe cuando la heredad queda totalmente cerrada, y no es dable exigirla cuando se tratare de un cercado incompleto, situación que queda equiparada al supuesto de faltar en absoluto el cerco.

m) *Condominio de árboles y arbustos*

Dice el artículo 2034 que "Es medianero el árbol y arbusto contiguo o encaballado con relación a muros, cercos o fosos linderos, tanto en predios rurales como urbanos".

Esta norma rige tanto en predios rurales como urbanos. Este artículo estima medianeros a los árboles y arbustos que existan en muros, cercos o fosos linderos, sea en forma contigua o encaballada. La solución es lógica pues los árboles y arbustos, en tanto son cosas unidas de manera orgánica al suelo, son inmuebles por su naturaleza (art. 225) y, por tanto, quedan sujetos a la condición del terreno.

En la hipótesis de perjuicio debido a un árbol o arbusto medianero, prevé el artículo 2035 que "Cualquiera de los condóminos puede exigir, en cualquier tiempo, si le causa perjuicio, que el árbol o arbusto sea arrancado a costa de ambos, excepto que se lo pueda evitar mediante el corte de ramas o raíces".

Por último, dice el artículo 2036 que "Si el árbol o arbusto se cae o seca, sólo puede reemplazarse con el consentimiento de ambos condóminos".

CAPÍTULO XII

PROPIEDAD HORIZONTAL

MNR

SUMARIO: I. Antecedentes. II. Concepto. III. Constitución. IV. Objeto. V. Consorcio. VI. Facultades de los propietarios. VII. Obligaciones. VIII. Expensas. IX. Prohibiciones. X. Procedimiento para el cese de infracciones. XI. Reglamento. XII. Asambleas. XIII. Consejo de propietarios. XIV. Administrador. XV. Subconsorcios. XVI. Prehorizontalidad.

I. Antecedentes

El Código Civil derogado, en el artículo 2617, vedaba la posibilidad de este derecho real, ya que no permitía que personas diferentes pudieran ser propietarias de la parte más baja o la parte más alta. Consideraba Vélez que esa situación generaría muchos conflictos. Si bien esto era cierto, también lo es que el crecimiento de la población, y su concentración en las ciudades, tornó necesario aprovechar mejor los espacios, construyendo hacia arriba, lo que hizo imperioso un régimen de propiedad horizontal. Ha quedado lejos en el tiempo la época de las grandes extensiones, o de las grandes casonas. El problema de la vivienda es serio y, lamentablemente, la gente vive en espacios cada vez más reducidos.

La propiedad horizontal tiene ventajas y desventajas. Entre las primeras: se aprovecha mejor un terreno, puede haber mayor confort en el aprovechamiento de servicios y sectores comunes, difíciles de sostener para una sola persona, de higiene, de seguridad, entre otras. Por otro lado, aumentan las obligaciones de vecindad, hay que pagar expensas, puede haber problemas de administración, abusos en la redac-

ción del reglamento. Lo cierto es que se trata de una realidad consagrada, y hay que procurar el uso de la manera más eficiente posible.

Casi 80 años después, en 1948, se aprobó la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal. Esta ley fue exitosa, ya que permitió la regulación eficiente de este nuevo derecho real, y se adecuó a la realidad imperante.

El Código Civil y Comercial enumera expresamente a la propiedad horizontal entre los derechos reales permitidos y regula minuciosamente su funcionamiento.

En cuanto al nombre de este derecho real se observan diferencias en el Derecho Comparado. En muchos países se la denomina "condominio", "copropiedad" (Francia), o bien "condominio edilicio" (Italia). También se la conoce por "propiedad por pisos o por departamentos", que actualmente es antigua si se piensa en los diversos usos que tiene este régimen. Otros países adoptan, al igual que la Argentina, la calificación de propiedad horizontal (Portugal, España).

II. Concepto

El artículo 2037 del Código define a este derecho real: "La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este Título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble así como las facultades que sobre ellas se tienen son interdependientes y conforman un todo no escindible".

De la definición legal, y de las sucesivas normas, surgen las siguientes características:

- a) *Es un derecho real.* Figura en la enumeración del artículo 1887 y esta norma lo reitera.
- b) *Sobre cosa propia.* Así lo dispone el artículo 1888 y esta norma también repite. Además, es principal (art. 1889), recae sobre una cosa registrable (1890) y se ejerce por la posesión (art. 1891).
- c) *Objeto.* Este derecho real tiene por objeto un inmueble. Se verá más adelante que hay un objeto inmediato, que son las partes

propias, y otro mediato constituido por las partes comunes. La base objetiva del derecho la constituye la "unidad funcional".

- d) *Facultades.* Dice la definición que el titular de este derecho real tiene las "facultades de uso, goce y disposición material y jurídica". Sin embargo, como se verá más adelante, las limitaciones son más fuertes que en el caso del dominio, especialmente en lo que concierne a la facultad de disponer materialmente, ya que se requiere el concurso o consentimiento de los demás. Estas facultades se ejercen de acuerdo al régimen especial constituido por estas normas, luego por las vinculadas a los derechos reales, las previstas para las personas jurídicas en lo que concierne al consorcio (art. 150), y por lo regulado en el reglamento, el que en algunos casos puede completarlas o ser aplicado en subsidio.
- e) *Interdependencia.* Tanto las partes del inmueble (privativas y comunes), como las facultades que se ejercen sobre ellas, son interdependientes. Esto significa que no se pueden separar, de modo que si se enajena una parte privativa se transmite en forma conjunta el derecho sobre las partes comunes. Hay una inescindible relación entre los sectores privativos y los comunes.
- f) *Estatuto.* Es obligatorio el dictado de un reglamento que regule la vida del conjunto.
- g) *Consortio.* Además de los titulares del derecho real, nace una persona jurídica distinta de ellos, que es el consorcio, con su propio patrimonio y con derechos y obligaciones específicos.
- h) *Administración.* Debe existir una administración; a veces una persona jurídica, que presta los servicios, toma las decisiones que hacen a su función, representa a los propietarios frente a los organismos públicos o personas privadas y cobra los gastos de mantenimiento y conservación del edificio, entre sus deberes más importantes.
- i) *Destino.* En el reglamento se fija el destino del inmueble, que debe ser respetado por los titulares de este derecho real. Puede ser apto para vivienda, actividad profesional, mixto, garaje, galería comercial, etcétera.

III. Constitución

Dispone el artículo 2038 que "A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos deben redactar, por escritura pública, el reglamento de propiedad horizontal, que debe inscribirse en el registro inmobiliario.

"El reglamento de propiedad horizontal, se integra al título suficiente sobre la unidad funcional".

El artículo 2038 se refiere a la división jurídica del inmueble. Ocurre que mientras una persona es dueña de un inmueble puede hacer las construcciones que desee, pero seguirá siendo dueño; allí habrá derecho de dominio. Si se trata de un condominio, la conclusión es la misma, por más diversas edificaciones que realicen el derecho real no cambiará.

Ahora, si deciden someter el inmueble al régimen del derecho real de propiedad horizontal y salir del dominio o del condominio, deberán cumplir una serie de recaudos. No cualquier inmueble puede pasar de régimen, sólo aquellos que satisfagan determinados requisitos "físicos" y "jurídicos".

En cuanto a los de orden físico, cabe mencionar que las unidades a construir tienen que cumplir las exigencias del artículo 2039 (independencia funcional, comunicación con la vía pública). Además, deberán existir las partes comunes adecuadas.

Como paso previo a la inscripción del reglamento, hay que hacer que la construcción sea aprobada por la Municipalidad tras la presentación de un plano de construcción. Luego habrá que confeccionar el plano de subdivisión del inmueble y su legajo parcelario.

Finalmente, corresponde la redacción del reglamento de propiedad horizontal en escritura pública y su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble. El reglamento es el estatuto fundamental que contiene la regulación de los derechos y obligaciones de los titulares de departamentos bajo el régimen de propiedad horizontal.

El otorgamiento del reglamento —ha dicho la doctrina— crea el denominado "estado de propiedad horizontal", que posibilita la división jurídica del inmueble en propiedades autónomas.

En suma, una vez redactado e inscripto, el inmueble está afectado

al sistema de propiedad horizontal y en adelante se podrán adquirir las unidades bajo este sistema. Se requiere al menos la existencia de dos titulares, pues el Código no ha recibido la figura del consorcio de un solo propietario (arg. art. 2044). Claro que, una vez constituido, si en el futuro alguno de los propietarios adquiere todas las unidades, puede interpretarse que subsiste el consorcio, ya que esta circunstancia no está mencionada como causal de extinción de dicho ente en el segundo párrafo del artículo 2044.

Las unidades se pueden adquirir por algunos de los modos generales previstos por el Código para la adquisición de derechos reales (v. gr.: título y modo, usucapión, sucesión). No se inscribirán en el Registro de la Propiedad Inmueble los títulos por los que se constituyan o transfieran el derecho real de propiedad horizontal, si no se encuentra inscripto el reglamento. Se puede otorgar en forma simultánea el reglamento y el o los títulos que contienen el acto o negocio causal de transmisión o constitución de derecho real respecto de las unidades que integran el edificio para su inscripción por tracto abreviado.

Nuestra jurisprudencia y doctrina han sostenido reiteradamente que las cláusulas del reglamento integran el título de cada uno de los copropietarios y resultan obligatorias por el solo hecho de ser titulares del derecho. Esta postura fue recogida por el actual Código Civil y Comercial.

Al ser así, cada vez que una unidad es enajenada, el adquirente se encuentra en la misma situación que su antecesor en lo que concierne al reglamento. Además, al estar inscripto en el Registro, es oponible *erga omnes*.

a) Caso de la partición en especie del condominio

Los condóminos de un inmueble cuyo edificio cumple las condiciones materiales previstas por la ley pueden disolver el condominio mediante una partición en especie, basada en adjudicarse en propiedad las unidades funcionales (pisos, departamentos, locales de negocio, etc.) que integren la finca, lo cual supone, desde luego, la incorporación del predio al régimen de propiedad horizontal. Además se comprometen a ejecutar todos los actos necesarios para que la finalidad

prevista se concrete, como ser, construcción necesaria para adaptarse a los requisitos del Código, financiación de la obra, reglamento, etcétera.

Si hay acuerdo la cuestión no suscita muchos problemas. Los inconvenientes surgen cuando no se ponen de acuerdo los condóminos. Unos prefieren la venta, y otros la partición en especie. Como se dijo al estudiar el condominio, la partición en especie, si es posible, es la preferida. Por ende, si el inmueble está en condiciones y a cada condómino le tocara una o más unidades funcionales equivalentes a su proporción en el condominio, este criterio se impone. Si no hay acuerdo, puede llevarse el asunto ante la justicia, y seguramente el juez decidirá de esta forma.

No es factible si es menester realizar importantes modificaciones estructurales del bien atento la cantidad de condóminos, sin que ninguno de ellos hubiera demostrado disponibilidad para afrontar los gastos que ello generaría.

b) *Constitución por el superficiario*

Prevé el artículo 2120, entre las facultades del superficiario, que "...El superficiario puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal, con separación del terreno perteneciente al propietario excepto pacto en contrario; puede transmitir y gravar como inmuebles independientes las viviendas, locales u otras unidades privativas, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad de consentimiento del propietario".

Un ejemplo podría ser el siguiente:

Una persona tiene un terreno interesante en el que se pueden construir dos torres; no le sirve dividir la tierra porque le baja el FOT, y así se construye menos y pierde valor la tierra. Como nadie le compra todo el terreno porque es muy costoso, enajena el derecho de superficie sobre parte del terreno para que algún desarrollador construya una torre. Éste hace el edificio y lo afecta al régimen de propiedad horizontal.

IV. Objeto

El objeto del derecho real de propiedad horizontal es un inmueble edificado, cuyas unidades funcionales reúnan ciertas características: independencia funcional, y salida a la vía pública. Tradicionalmente se ha identificado un objeto inmediato que es la unidad funcional (v. gr.: departamento, cochera, local, etc.), y un objeto mediato constituido por las partes comunes (v. gr.: escalera, ascensores, etc.).

No se trata de dos objetos sino de uno (el inmueble propio), integrado por sectores cuya interdependencia funcional hace imposible separarlos. Es por esta razón que la última parte del artículo 2037 enuncia que "Las diversas partes del inmueble así como las facultades que sobre ellas se tienen son interdependientes y conforman un todo no escindible".

El Código distingue esencialmente entre cosas y partes propias, y cosas y partes comunes. Lo principal es la unidad funcional, que es propia, y que confiere un derecho accesorio, indivisible e inescindible sobre el resto del inmueble (excepto las partes propias de otros), integrado por partes comunes. Dicho derecho es equivalente a un porcentual que se determina en el reglamento.

Por lo tanto, cuando hubiere transmisión, constitución de gravámenes, actos de administración, traba de medidas cautelares, etcétera, en relación con una unidad funcional, quedan comprendidos los derechos que su titular tiene en los bienes comunes, prohibiéndose la realización de los mencionados actos sólo con relación a éstos, es decir independientemente de la unidad a que accedan (art. 2045).

a) *Cosas y partes propias*

a.1) *Unidad funcional*

Dice el artículo 2039 que "El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional, y comunicación con la vía pública, directamente o por un pasaje común.

"La propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble o indis-

pensables para mantener su seguridad, y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirla".

Por ende, el objeto principal de este derecho real es lo que se llama "unidad funcional". El Código es amplio en cuanto a su destino, ya que puede consistir en un departamento, local, "u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino". Así, por ejemplo, cocheras, guarderías náuticas, entre otros.

Por otra parte, no es necesario que se trate de una construcción en altura. Puede ser de una sola planta, e incluso una construcción subterránea.

La unidad funcional, para que el inmueble pueda ser sometido al sistema de propiedad horizontal, debe satisfacer ciertos requisitos: 1) independencia funcional; 2) comunicación con la vía pública.

a.1.1) *Independencia funcional*

Esta exigencia se relaciona con la autonomía necesaria para cumplir con el destino previsto en el reglamento.

De esta manera, si el destino previsto es vivienda, deberá tener baño, cocina, dormitorio, etcétera, requisitos éstos que no serán necesarios si la unidad tiene como destino servir de oficina o cochera, pues en estos casos no se exige la existencia de baños en exclusividad, que tengan cocina, etcétera. Si se trata de una cochera, es suficiente con que tenga las medidas mínimas que permitan el ingreso y egreso de un automóvil.

Por eso la independencia es "funcional", pues hay que determinar si la unidad es apta para cumplir la función asignada.

a.1.2) *Comunicación con la vía pública*

Cada unidad funcional debe tener franqueada su vinculación con el exterior, de tal forma que su titular, ocupante o usuario disponga, respecto de ella, de ingreso y egreso libres, es decir sin tener que atravesar otros sectores privativos.

Es directa cuando todas o algunas unidades funcionales cuentan con ingreso propio o que dan a la calle, como los locales ubicados en la planta baja con acceso directo desde la vereda.

En el caso del pasaje común, las unidades se comunican con el exterior a través de sectores comunes previstos con ese fin, tales como escaleras, pasillos, ascensores, palieres, caminos o calles internas, parques, jardines, etcétera.

a.2) *Unidades complementarias*

También se ha previsto la existencia de unidades complementarias en edificios que se sometan al régimen de propiedad horizontal, es decir sectores cuyo destino sea el de servir a las unidades funcionales (art. 2039), tales como cocheras individuales, guardamuebles, bauleras, etcétera.

Pueden pertenecer a todos o a algunos propietarios, e incluso el titular de una unidad puede adquirir una o más unidades complementarias de cualquier destino.

Como también un titular puede pretender la venta de una de sus unidades complementarias a otro propietario o a un tercero, el artículo 2056 exige que el reglamento de propiedad y administración contenga no sólo la "determinación de las unidades funcionales y complementarias" (inc. b) sino también la "determinación de eventuales prohibiciones para la disposición o locación de unidades complementarias hacia terceros no propietarios" (inc. q).

a.3) *Cosas y partes propias*

Completa el panorama el artículo 2043: "Son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los balcones.

"También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada".

El Código, en cuanto a las partes propias, aclara que puede haber otras además de la unidad funcional.

El Código aclara que son propias las puertas y las ventanas. Asi-

mismo, advierte el artículo que los balcones no lo son (salvo la capa superficial constituida por el revestimiento). Tampoco las paredes que dividen a las distintas unidades, pero sí son propios los tabiques divisorios internos.

También son propios los cables que recorren internamente el espacio de la unidad funcional (art. 2041, inc. f).

Finalmente, puede haber otras partes propias, si así lo dispone el reglamento. Así, por ejemplo, un patio o un jardín, naturalmente comunes, podrían ser propios de uso exclusivo, si el reglamento así lo establece.

a.4) Cocheras

Pueden darse distintos supuestos respecto del uso, goce y propiedad de las cocheras, por ejemplo: 1) cochera de propiedad común, de uso exclusivo con delimitación; 2) cochera de propiedad común, de uso exclusivo y sin delimitación: los vehículos se ubican según el orden de llegada y cuando obstruyen la libre circulación debe dejarse la llave al encargado; 3) cochera de propiedad privativa, delimitada y con título de propiedad autónomo: se rige por principios similares a los indicados en el punto 1, pero, además, el propietario puede vender la cochera con independencia de la unidad principal a quien le plazca; 4) cochera de propiedad privativa, no delimitada y con título autónomo, rige lo indicado en el punto 2 y el titular cuenta con derechos sobre la parte indivisa de las cocheras; 5) cochera delimitada e independiente (en espacio cerrado, con llave y entrada individual; sea con título autónomo de propiedad o en propiedad con uso exclusivo): en este caso el acceso a la cochera es privativo del propietario o del usuario exclusivo. En el caso de que el reglamento no lo prohíba, es posible dar en locación la cochera a terceros, sin embargo cuando la cochera fuere sin delimitación ha de entenderse que se trata de un espacio para la guarda de un automóvil y que no pueden depositarse allí otros bienes muebles ni ser usada —a cualquier título— por terceros.

No en todos los casos las cocheras existentes en el edificio de viviendas u oficinas son complementarias, ya que en algunos son independientes de las unidades, se adquieren y se escrituran por separado,

se pueden gravar, no acceden a ninguna unidad principal, reúnen los requisitos del artículo 2039 (salida directa o por pasaje común) y, en consecuencia, constituyen una verdadera unidad funcional. También es posible que se trate de un edificio destinado a cocheras o que existan uno o varios pisos para tales fines.

b) Partes comunes

b.1) Concepto

Puede decirse de manera sencilla que todas aquellas cosas y partes que no sean propias, son comunes, es decir, pertenecen a todos los titulares, quienes tienen un derecho accesorio sobre ellas, representado por un porcentual o parte indivisa.

La cuota parte ideal que cada propietario tiene sobre las partes comunes es proporcional al valor de su unidad y se fija de acuerdo a su superficie, ubicación y detalles de confort, por lo cual, en líneas generales, a mayor superficie propia, mayor participación en la copropiedad. Esta proporción queda fijada en el plano de subdivisión y establecida luego en el reglamento. Este valor porcentual puede ser modificado, pero ello implica modificación del reglamento que deberá ser votada por unanimidad por tratarse de una cláusula estatutaria cuya alteración afecta derechos individuales de cada propietario.

El artículo 2040 dice que "Son comunes a todas o a algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado, se consideran comunes".

Por ende, cabe seguir los siguientes criterios:

- *Uso común.* Se consideran comunes aquellas cosas y partes que sean de uso y beneficio común de los consorcistas y de las unidades. Así, por ejemplo, la escalera, el ascensor, el sillón del hall de entrada, un jardín, etcétera.
- *Indispensables para mantener la seguridad.* Es claro que deben ser comunes ya que la seguridad debe estar en manos de todos, y no de alguno o algunos. Así, por ejemplo, una caldera, etcétera.
- *Las que determine el reglamento.* El artículo 2040 hace esta

mención que parece innecesaria, pues es probable que las cosas y partes comunes entren en alguno o ambos de los criterios anteriores. Más aún, el propio artículo dice que "Las cosas y partes cuyo uso no está determinado, se consideran comunes", de modo que no es tan relevante lo que diga el reglamento, al haber una presunción de comunidad.

b.2) *Clasificación de las cosas y partes comunes*

A las cosas y partes comunes el Código las clasifica en dos grupos: 1) las necesariamente comunes (art. 2041); 2) las no indispensables (art. 2042).

Cabe interpretar que las "necesariamente" comunes son aquellas que sí o sí deben ser tales, es decir, que no podrían convertirse en propias. El artículo 2041 las enumera, en forma similar al derogado artículo 2° de la ley 13.512, y lo efectúa sin carácter taxativo. Se puede interpretar que estas últimas son "indispensables", teniendo en cuenta que en el artículo siguiente se enumeran las "no indispensables".

Considerar que "necesario" quiere decir que sólo pueden ser comunes no es exacto, ya que el artículo 2041 en el inciso g, menciona a la vivienda del encargado, y lo cierto es que puede haber edificios que no cuenten con tal local. Si es así, no es indispensable. También puede suceder que exista dicho departamento, y que en algún momento sea convertido en parte privativa si la mayoría lo decide. En suma, no todas las partes comunes enumeradas en el artículo 2041 son "necesariamente" comunes, ni "indispensables".

b.3) *Enumeración de las cosas y partes necesariamente comunes*

El artículo 2039, último párrafo, menciona entre las partes comunes al terreno. Luego, el artículo 2041 dice lo siguiente: "*Cosas y partes necesariamente comunes*. Son cosas y partes necesariamente comunes:

- "a) el terreno;
- "b) los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a éstas con el exterior;
- "c) los techos, azoteas, terrazas y patios solares;
- "d) los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y

demás estructuras, incluso las de balcones, indispensables para mantener la seguridad;

- "e) los locales e instalaciones de los servicios centrales;
- "f) las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, y los cableados, hasta su ingreso en la unidad funcional;
- "g) la vivienda para alojamiento del encargado;
- "h) los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas;
- "i) los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con cosas y partes comunes;
- "j) las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional, y las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros;
- "k) todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común;
- "l) los locales destinados a sanitarios o vestuario del personal que trabaja para el consorcio.

"Esta enumeración tiene carácter enunciativo".

Se trata de una enumeración de carácter enunciativo, como dice el último párrafo. La técnica de redacción es defectuosa, ya que en el inciso k, se alude a "todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común", lo que resta sentido a la larga enumeración no taxativa de la misma norma.

Nada se dice sobre el *espacio aéreo* y el *subsuelo*. Dado que el terreno es común (art. 2041, inc. a), y teniendo en cuenta que la propiedad del suelo se extiende a dichos espacios (art. 1945), fácil es concluir que pertenecen a todos. Son comunes. Además, el artículo 2052 exige la unanimidad para elevar nuevos pisos.

b.4) *Enumeración de las cosas y partes comunes no indispensables*

Completa el cuadro el artículo 2042: "*Cosas y partes comunes no indispensables*. Son cosas y partes comunes no indispensables:

- "a) la piscina;
- "b) el solárium;

- "c) el gimnasio;
 - "d) el lavadero;
 - "e) el salón de usos múltiples.
- "Esta enumeración tiene carácter enunciativo".

Se refiere a los llamados *amenities*.

Es una norma que sorprende, pues no sólo es innecesaria, sino que contempla el caso de una minoría de edificios que tienen esta clase de servicios. Por otra parte, es obvio que su descripción se acerca al referido inciso k, del artículo anterior.

b.5) ¿Conversión?

El anterior artículo 2° de la ley 13.512 decía que "Los sótanos y azoteas revestirán el carácter de comunes, salvo convención en contrario". Esto permitió a la doctrina señalar que ciertas cosas comunes, además de los sótanos y azoteas podían convertirse en privativas, en tanto su uso no sea necesariamente común o que no se tratase de aquellas cosas, partes o bienes indispensables para la seguridad del edificio, y siempre que la decisión se tome por unanimidad, al estar en juego el patrimonio de todos y cada uno de los consorcistas.

El Código no contiene una disposición similar, por lo que cabe preguntarse si es posible llegar a una conclusión semejante. La respuesta es afirmativa, pues la segunda parte del artículo 2043 dice que "También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada". De modo que si se reforma el reglamento, la conversión sería factible.

Cabe advertir que sólo podrán ser convertidas en partes propias aquellas cosas comunes que no se vinculen con la seguridad del inmueble (v. gr.: una caldera, un muro maestro), ni con la viabilidad del sistema. Así, por ejemplo, el ascensor no podría dejar de ser común ya que es la vía de comunicación con el exterior lo que repercute en la independencia funcional de las unidades. Si se trata de cosas imprescindibles para el uso común, no pueden perder este carácter.

Fuera de estos límites, nada impide que puedan transformarse en privados la unidad funcional destinada a vivienda del encargado, los

locales comunes con destino de arrendamiento, cocheras, el mobiliario de los palieres (sillones, espejos, cuadros, adornos, etc.), inclusive un pasillo común, en la parte contigua a la puerta de ingreso a un departamento, puede integrarse a éste, corriendo hacia adelante la ubicación de aquella, siempre que tal desplazamiento no genere obstrucciones a las otras unidades.

En cuanto a la mayoría necesaria, hay que tener presente que el artículo 2061 dice: "*Conformidad expresa del titular*. Para la supresión o limitación de derechos acordados a las unidades que excedan de meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad expresa de sus titulares". La conversión de una parte común en privativa significa que todos los titulares verán disminuir su patrimonio, pues son titulares de esa parte por un porcentaje. Se trata de la supresión de un derecho. Como el derecho pertenece a todos, se impone la conclusión de que se requiere la conformidad de todos, es decir, la unanimidad.

En cambio, interpretando dicha norma, podría pensarse que no sería necesaria la unanimidad si se decidiera que una parte privativa se convierta en común, ya que ello amplía el derecho de casi todos. Obviamente, será indispensable la conformidad del titular de la parte exclusiva que se pretende convertir en común. Bastaría con la mayoría de dos tercios, pues hay que reformar el reglamento (art. 2057).

Sin embargo, lo razonable es pensar en la unanimidad. La mayoría calificada se justifica en que la transformación provocará, además, una modificación en los porcentuales, o sea en la participación que corresponde a cada propietario sobre los bienes comunes, la que se verá aumentada.

b.6) Uso exclusivo

El Código prevé la posibilidad de que algunas cosas y partes comunes, sobre las que ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, tengan una afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales (art. 2040). Estos sectores comunes de uso exclusivo se caracterizan por estar ubicados de modo que su aprovechamiento sólo puede beneficiar a uno o a algunos propietarios, tal el caso de los balcones-terraza.

El Código admite que el uso exclusivo pueda ser de una o varias unidades. Así, por ejemplo, un espacio destinado a guardar automóviles podría afectarse al uso exclusivo de algunos, y no de todos.

b.7) Presunción de comunidad

Como novedad, dispone el Código la presunción de comunidad (art. 2040, primer párrafo, *in fine*).

De esta manera, en casos de duda u omisión normativa, sea ésta legal o reglamentaria, sobre el carácter de ciertos bienes, éstos serán tenidos por comunes. Así se evitarán muchos de los diversos y frecuentes conflictos que surgen entre copropietarios a consecuencia de no poder determinar, con certeza, si una cosa o sector es privativo o común y, por lo tanto, a quién corresponde efectuar (si a un propietario o al consorcio) tareas de mantenimiento, de reparación por roturas, fisuras, filtraciones, etcétera y, consiguientemente, quién debe cargar con los gastos del caso.

c) Bienes del consorcio

El Código, al aceptar expresamente la personalidad del consorcio (art. 2044), es coherente y señala que el consorcio tiene bienes (art. 2048). El patrimonio del consorcio, así como su uso y goce, deben figurar en el reglamento (art. 2056, incs. e, e i). Además, el artículo 2067, inciso 1, se refiere al certificado de "deudas y de créditos del consorcio".

V. Consorcio

El Código admite que el consorcio tiene personalidad jurídica, siguiendo la opinión de la doctrina mayoritaria.

Atribuir personalidad jurídica al consorcio tiene consecuencias diversas. Entre las más notables, cabe señalar que el administrador no representa a los titulares, sino al ente consorcio. El encargado no es empleado de cada uno de los consorcistas, sino de esta persona jurídica distinta de sus miembros.

Dice el artículo 2044: "*Consorcio*. El conjunto de los propietarios

de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador".

El artículo 148 enumera al consorcio "de propiedad horizontal" (para diferenciarlo del consorcio "de cooperación", que es regulado como contrato) dentro de las personas jurídicas privadas (inc. g).

Entre sus órganos se menciona al Consejo de Administración, hasta ahora no instaurado legalmente, pero sí en la práctica. Es un acierto que sea optativo ya que hay edificios que no lo necesitan, o les complicaría la vida. Basta pensar en los inmuebles de pocas unidades, algunos conocidos como "PH", en los que la constitución de este órgano sería un trastorno.

Reconocer que el consorcio tiene personalidad implica admitir que tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones: en el primer aspecto puede reclamar el cobro de expensas y fondo de reserva, así como los créditos por rentas que tenga derecho a percibir. También contrae obligaciones frente a terceros cuando contrata trabajos o respecto de deudas con cajas previsionales, aportes a sindicatos, o frente a los consorcistas cuando aquéllos emprenden reparaciones necesarias o urgentes. Estos derechos los ejerce a través del administrador que, como representante legal del consorcio (art. 2065), puede poner en marcha las acciones judiciales contra los consorcistas que violaran el reglamento.

a) Nombre y domicilio

En cuanto al nombre, se suele denominar al consorcio con el nombre de la calle y número en el que está ubicado el inmueble (v. gr.: "consorcio calle Santa Fe 3000"), aunque algunos edificios tienen nombre que los distingue. El del asiento del inmueble es el domicilio del consorcio, según lo dispone el artículo 2044.

b) Patrimonio

Cabe mencionar al fondo de reserva, recaudaciones, créditos contra los consortes o terceros, las unidades que adquiriera, y en general las cosas y bienes afectados en su beneficio dentro de los fines que jus-

tifican su existencia. El Código omite esta descripción, y lo deja librado a lo que prevea el reglamento. No obstante, la doctrina suele atribuir a los referidos bienes tal calidad. Cabe incluir a los intereses que devenguen tales sumas de dinero.

c) *Capacidad*

Como sucede con las personas jurídicas, el consorcio tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones: en el primer aspecto puede reclamar el cobro de expensas y fondo de reserva, así como los créditos por rentas que tenga derecho a percibir. También contrae obligaciones frente a terceros cuando contrata trabajos, o respecto de deudas con cajas previsionales, aportes a sindicatos, o frente a los propietarios cuando se hubieran generado perjuicios por los que el consorcio debe responder.

d) *Capacidad para adquirir unidades*

Se ha dicho que: 1) el consorcio puede ser titular de unidades funcionales tanto por atribución hecha en el propio reglamento, como por su posterior adquisición; 2) la adquisición de la unidad por parte del consorcio no implica modificación ni de planos, ni de reglamento dado que no troca su carácter de cosa privativa a cosa en condominio de los titulares de unidades funcionales; 3) la compra de la unidad funcional por parte del consorcio puede perfectamente encajar dentro de los propósitos propios de su existencia (por ejemplo para obtener renta que ayude a afrontar las expensas, o para evitar el fracaso de una subasta con efectos ruinosos para los consorcistas); 4) la decisión de la compra de la unidad por parte del consorcio debe admitirse con la sola aprobación en asamblea de la mayoría absoluta de los consorcistas, al no regir la exigencia de unanimidad propia del condominio.

El artículo 2085 dice expresamente que el reglamento puede prever un derecho de preferencia en la adquisición de unidades funcionales "a favor del consorcio de propietarios". Por ende, se reconoce aquí en forma expresa la potestad del consorcio para adquirir una unidad funcional.

e) *Concurso o quiebra*

La doctrina no se ha puesto de acuerdo sobre si es posible, o no, la convocatoria o declaración de quiebra de un consorcio.

Se trata de un problema más ficticio que real, pues si el consorcio es insolvente para atender sus obligaciones, ellas finalmente serán cubiertas por los propietarios al pagar las expensas, cuyo concepto incluye a las obligaciones impuestas al administrador (art. 2048).

f) *Extinción*

Dice la última parte del artículo 2044 que "La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública o por resolución judicial, inscrita en el registro inmobiliario".

De ocurrir tal desafectación, los titulares pasarán a ser condóminos, y su parte indivisa dependerá de lo que acuerden, o de la proporción que tenían bajo el régimen de la propiedad horizontal.

g) *Responsabilidad por las deudas del consorcio*

El consorcio puede ser deudor de diversas obligaciones, como cuando contrata servicios de personas determinadas, o la realización de ciertas obras. Es claro que dicha persona jurídica está obligada por sus deudas y responde con su patrimonio (fondo de reserva, cuentas bancarias, etc.). El problema se presenta cuando el patrimonio del consorcio es insuficiente para atender estos créditos. Desde hace tiempo, buena parte de la doctrina señala la responsabilidad subsidiaria de los consorcistas, luego de ejecutados los bienes del deudor. Para algunos respondían de acuerdo a su cuota, para otros por el todo con la posibilidad de repetir contra los demás.

La ausencia en el Código de una solución específica y la remisión a las normas que regulan las personas jurídicas privadas (art. 150) podría hacer pensar que la voluntad del legislador fue la exoneración de la responsabilidad de los propietarios por las obligaciones del consorcio (art. 143).

Dice el artículo 143 que "...Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial". La ley especial, en este caso la regulación del derecho real de propiedad horizontal, dispone que los consorcistas deben pagar las expensas, y éstas incluyen las obligaciones impuestas al administrador (art. 2048), lo que seguramente incluirá a las deudas del consorcio insatisfechas. Por lo tanto, los propietarios son responsables en forma personal y subsidiaria por estas deudas que hayan sido válidamente contraídas por el administrador en ejercicio de sus facultades, o bien impuestas por la ley, el reglamento, o la asamblea.

h) *Consortio de hecho*

En ocasiones sucede que se construyen edificios y cuando están terminados, o en estado avanzado de construcción, se entrega la posesión a los compradores. Éstos sólo cuentan con un derecho personal (generalmente un boleto de compraventa), ya que aún no se redactó el reglamento ni se otorgó la escritura pública. No hay propiedad horizontal, el inmueble sigue perteneciendo al dueño o condóminos del terreno en el que se edificó.

La doctrina suele reconocer en esta situación a lo que se denomina un "consorcio de hecho". Funciona en la medida de lo posible con reglas similares a la propiedad horizontal: hay un administrador, se pagan expensas, se imponen reglas y prohibiciones, se realizan asambleas, etcétera.

VI. Facultades de los propietarios

Como es sabido, en mayor o en menor medida, los derechos reales confieren a su titular facultades. El artículo 2037, al dar el concepto de propiedad horizontal, dice que este derecho real "otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio..."

a) *Facultades jurídicas*

Dice el artículo 2045 que "Cada propietario puede, sin necesidad

MNR

de consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece, o sobre ella constituir derechos reales o personales. La constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional, comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria, y no puede realizarse separadamente de éstas".

Como se puede apreciar, las facultades jurídicas son amplias, similares a las que cuenta un dueño y hasta superiores a las de un condómino sobre su parte indivisa. Se refieren a la unidad funcional, lo que abarca a las unidades complementarias, y las cosas y partes comunes, en la proporción que corresponda al titular. Unas y otras son inseparables, forman un todo inescindible. Hay una relación de principal-accesorio, ya que los actos que recaigan sobre la unidad funcional arrastran a lo accesorio.

Como se desprende del artículo 2045, respecto de la unidad funcional, cada titular puede "sin necesidad de consentimiento de los demás", enajenar a título oneroso o gratuito, gravar con derechos reales (v. gr.: hipoteca, usufructo), afectarla al régimen de protección de la vivienda (arts. 244 y ss.), constituir derechos personales. Incluso, puede abandonarla (art. 2049). La enajenación también puede ser forzosa.

b) *Facultades materiales*

b.1) *Sobre la unidad funcional*

El titular la puede usar, gozar y disponer materialmente, con algunas limitaciones. Por un lado, debe respetar el destino impuesto en el reglamento. Si el destino autorizado es el de vivienda, no puede instalar un consultorio médico.

Por otro lado, no puede causar perjuicio a los demás. El Código lo obliga a conservar en buen estado su unidad (art. 2046, inc. b); permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y de bienes del consorcio, como asimismo para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas o para controlar los trabajos de su instalación (art. 2046, inc. e); no puede ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble (art. 2047), etcétera.

No hay que olvidar que su derecho se ejerce prácticamente sobre un "cubo de aire" que está rodeado de partes comunes, lo que justifica severas restricciones. Los actos de disposición material se limitan a los revestimientos y no mucho más, teniendo en cuenta que las paredes, pisos, techos que dividen a la unidad son comunes. Claro que, dentro de lo razonable, sin afectar la seguridad, se pueden atravesar las paredes para pasar cables, caños, soportar equipos de aire acondicionado, etcétera.

b.2) *Sobre cosas y partes comunes*

También el titular de este derecho real tiene derecho de poseer, usar y gozar de las partes comunes, pero con importantes limitaciones. Dice el artículo 2040 que "Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios".

Nuevamente, un límite importante es el "destino". Así, por ejemplo, si el destino de la terraza es el de lavar y colgar ropa, no puede el titular organizar allí reuniones.

A la vez, no puede restringir el derecho igual que tienen los demás. No podría, por ejemplo, usar incansablemente el ascensor sin permitir que los demás también puedan usarlo, ni guardar una moto en el hall de entrada, por dar ejemplos burdos.

Párrafo aparte merece la *facultad de disponer materialmente*.

El Código organiza un complejo sistema de asambleas y mayorías para que se puedan realizar modificaciones en las partes comunes que nadie puede decidir en forma individual (arts. 2051/2055).

c) *Modificaciones en partes comunes*

c.1) *Principio*

La regla general la sienta el artículo 2051, según el cual "Para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento de la mayoría de los propietarios, previo informe técnico de un profesional autorizado".

El Código se refiere a aquellas mejoras que no sean indispensables, ya que aquellas que son necesarias para la conservación de las cosas

y partes comunes en buen estado las debe realizar el administrador y luego los propietarios solventan el costo mediante el pago de las expensas (art. 2048).

Aquellas mejoras u obras nuevas sobre partes comunes que se estimen convenientes, útiles, o quizás suntuarias, no las puede decidir algún titular por su cuenta sino que requieren la conformidad de los demás, al menos de una mayoría. En algunos casos bastará con la mayoría absoluta, en otros será necesaria la unanimidad.

Deben afrontar su costo entre todos, de acuerdo a su porcentual. Pero como no son indispensables, la decisión no la puede tomar el administrador sino que debe surgir de una asamblea legalmente convocada al efecto.

Por regla, se necesita la mayoría absoluta, esto es, más de la mitad de votos, "con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto" (art. 2060).

Así, por ejemplo, si se pretende mejorar el revestimiento del ascensor, o bien decorar nuevamente el hall de entrada al edificio, o construir un quíncho en la terraza, la decisión deberá ser aprobada por mayoría absoluta. Se trata de mejoras u obras que —se supone— benefician al conjunto.

Además, es necesario el "previo informe técnico de un profesional autorizado", normalmente un ingeniero o un arquitecto.

c.2) *Mejoras u obras nuevas que requieren unanimidad*

Dice el artículo 2052 que "Si la mejora u obra nueva, realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios..."

La regla que se desprende del Código es la siguiente: si la obra o mejora beneficia a todos, basta con la mayoría absoluta; si beneficia a uno solo se precisa la unanimidad. Sin embargo, hay un supuesto en que de todas maneras se necesita la unanimidad, aunque la obra o mejora beneficie a todos: cuando "gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial".

El Código brinda como ejemplos "elevar nuevos pisos o hacer excavaciones", pero luego agrega que aun cuando ello no ocurra, es necesaria la unanimidad. Cabe imaginar que los propietarios decidan achicar la entrada del edificio para ensanchar el garaje, o viceversa; aun cuando esta obra nueva pueda ser beneficiosa para el conjunto, se estaría alterando sustancialmente la estructura del edificio, y entonces es necesario el acuerdo unánime.

Agrega el citado artículo 2052 que "También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que sólo beneficia a un propietario".

Este segundo párrafo debió estar al principio de dicho artículo 2052, ya que se trata de un principio general. Así, por ejemplo, cuando un propietario pretende techar un patio de uso exclusivo, o cerrar un balcón.

Si la obra es autorizada, el costo debe ser afrontado por su beneficiario. Dice el artículo 2053 que "Si la mejora u obra nueva autorizada sobre cosas y partes comunes es en interés particular, el beneficiario debe efectuarla a su costa y soportar los gastos de la modificación del reglamento de propiedad horizontal y de su inscripción, si hubiera lugar a ellos".

c.3) *Acción judicial*

Establece el artículo 2051 que "...Quien solicita la autorización si le es denegada, o la minoría afectada en su interés particular que se opone a la autorización si se concede, tienen acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la asamblea.

"El juez debe evaluar si la mejora u obra nueva es de costo excesivo, contraria al reglamento o a la ley, y si afecta la seguridad, solidez, salubridad, destino y aspecto arquitectónico exterior o interior del inmueble. La resolución de la mayoría no se suspende sin una orden judicial expresa".

En protección del abuso en el que podría incurrir la mayoría, el Código admite que cualquier copropietario disconforme con las modificaciones que se hayan ordenado, está habilitado para formular su reclamo por vía judicial, siempre que se trate de aquellas que, a su

juicio, resulten excesivamente costosas, que se opongan al reglamento vigente o sean contrarias a la ley o a las normas municipales de aplicación, o que afecten la seguridad y solidez, salubridad, destino o aspecto arquitectónico exterior o interior del edificio.

Cabe aclarar que si se decidió una modificación que afecte la seguridad o la salubridad, al tratarse de actos prohibidos y, por ende, nulos, la decisión la pueden impugnar incluso aquellos que hubiesen votado a favor.

Por último, el Código también habilita a demandar judicialmente a quien solicitó la autorización y le fue denegada. Deberá acreditar que es arbitraria la decisión de la mayoría, y el juez deberá ser prudente, ya que por regla debe respetar lo que decida la mayoría.

c.3.1) *Supuestos que autorizan el reclamo*

I. *Costo excesivo.* Esto podría ocurrir si se aprobase una innovación por un valor superior al que puede obtenerse en la plaza, o desproporcionado para la categoría del edificio.

La situación debe valorarse con un criterio objetivo, no subjetivo.

II. *Contrarias al reglamento.* Si el reglamento prohíbe determinada obra o innovación, la mayoría no puede aprobarla aun cuando implique una mejora. Para ello será necesario que previamente reformen el estatuto.

III. *Contrarias a la ley.* Si bien el artículo 2051 se refiere a la ley, cabe incluir en esta prohibición a aquellas obras que sean contrarias a una ordenanza municipal, decreto, código de edificación u otra.

Se han presentado algunos casos de apertura de ventanas en medianeras sin respetar las disposiciones vigentes.

IV. *Contrarias a la seguridad.* El artículo 2047, inciso c, veda ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble. En esta hipótesis, lo que no puede hacer uno de los propietarios, tampoco lo puede hacer la mayoría.

Esto podría ocurrir, por ejemplo, si se decidiera hacer una abertura en el muro maestro, o una modificación en la caldera, que pusiera en peligro la seguridad del edificio.

Lo mismo cabe decir si está en juego la solidez o la salubridad (v. gr.: innovación que facilitara la contaminación).

V. *Contrarias al destino*. Como es sabido, el destino de las unidades funcionales y de las partes comunes está fijado en el reglamento de propiedad horizontal. Al menos, así debiera ser (art. 2056, incs. j, y k). El artículo 2051 se refiere a modificaciones dispuestas en partes comunes, y el artículo 2040 establece que los bienes comunes podrán ser usados "conforme a su destino".

VI. *Perjudiciales para el aspecto arquitectónico*. No es posible cambiar la forma externa del frente, o decorar las paredes o recuadros exteriores con tonalidades distintas a las del conjunto, con el objeto de mantener una concepción integral del aspecto arquitectónico. Esto es lo que se conoce vulgarmente como obligación de "no alterar la fachada". Esto ocurriría, por ejemplo, si se autorizara que partes del frente tuviesen un color diferente al resto y ello afeara y desvalorizara el edificio.

No se incurre en esta prohibición cuando se colocan macetas, plantas, aparatos de aire acondicionado, antenas de poco tamaño, etcétera. La alteración debe ser de cierta envergadura. Se han presentado problemas con la colocación de toldos en balcones, con algunos cerramientos, y con carteles luminosos en edificios que admiten actividades comerciales.

c.3.2) *Caducidad*

El derecho a promover acción judicial de nulidad de la asamblea caduca a los treinta días contados desde la fecha de la asamblea (art. 2060, último párrafo).

c.3.3) *Medida cautelar*

Finaliza el tercer párrafo del artículo 2051 estableciendo que "La resolución de la mayoría no se suspende sin una orden judicial expresa", lo que descarta la posibilidad de que la mera presentación del disconforme que acciona, implique la automática suspensión de la decisión adoptada por la mayoría, sea aprobatoria o denegatoria.

c.3.4) *Sentencia*

Si por la valoración de la prueba aportada se hiciere lugar a la demanda, corresponderá ordenar la destrucción de lo realizado para recomponer las cosas a su estado anterior, bajo apercibimiento de hacer ejecutar las obras necesarias por un tercero a costa del demandado o, directamente, prohibir que se lleve a cabo la obra si ésta no hubiere tenido principio de ejecución. Si se reclama por no haberse aprobado determinada modificación, el juez, si lo considera, podrá autorizarla.

En su caso, si se dieran las condiciones, pueden reclamarse también los perjuicios ocasionados, y ello deberá ser resuelto en el fallo.

c.4) *Obras realizadas sin autorización*

Como se señaló anteriormente, cuando una obra nueva o mejora beneficia a un determinado consorcista, debe ser aprobada por todos, la decisión debe ser unánime (art. 2052, último párrafo).

No es sencillo obtener la aprobación de todos, por lo que ocurre con alguna frecuencia que un consorcista, en lugar de someter su pedido a la decisión de los demás en una asamblea, opta por realizar directamente la obra (por ej.: techar un patio), sin pedir permiso. Luego, el consorcio demanda judicialmente el retiro o demolición de la obra antirreglamentaria.

La doctrina y la jurisprudencia son variadas, especialmente con el caso más frecuente, que es el del cerramiento del patio de aire y luz. Hay dos extremos: fallos estrictos que obligan a demoler la obra realizada en infracción y otros más contemplativos que valoran si la obra causa algún perjuicio, así como no destruir valores económicos, para concluir que incurre en abuso del derecho el consorcio que pretende la destrucción.

Para un criterio más estricto, que debe ser el que prevalezca, no es admisible adoptar como regla general de interpretación la subsistencia del valor económico de lo construido, cuando la obra se ha llevado a cabo en violación al reglamento o la ley, ya que se terminaría admitiendo *a priori* el mantenimiento de obras ejecutadas ilegítimamente y esto afecta gravemente un orden que resulta esencial para el sistema de la propiedad horizontal. Recurrir a la teoría del abuso debe ser excepcional.

Se observa en algunos fallos, y también en algunas opiniones doctrinarias, que si transcurrió cierto tiempo desde que se está cometiendo la infracción, especialmente cuando ésta consiste en una obra nueva, y nada se reclamó, hubo una suerte de "consentimiento tácito" que impediría el reclamo que se formula con posterioridad.

No se comparte este criterio pues implicaría suprimir la necesidad de que transcurra el plazo de prescripción. Además, ofrece mucha inseguridad, ya que no se sabría cuál es el tiempo que debe transcurrir para que se repunte operado el consentimiento tácito. Tampoco el hecho de que el consorcio haya omitido demandar a quien violó el reglamento, autoriza a otro consorcista a hacerlo con apoyo en tal circunstancia. La infracción de una persona no puede servir de permiso para que otro también la cometa.

d) Reparaciones urgentes

Establece el artículo 2054 que "Cualquier propietario, en ausencia del administrador y de los integrantes del consejo de propietarios puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes, con carácter de gestor de negocios. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negar el reintegro total o parcial y exigir, si corresponde, la restitución de los bienes a su estado anterior, a costa del propietario".

Las reparaciones necesarias, de conservación, las realiza el administrador, y luego los propietarios se hacen cargo al pagar proporcionalmente las expensas.

Puede ocurrir que el administrador esté "ausente". Esto quiere decir que momentáneamente no se encuentra, o el cargo está vacante, pero también que no presta atención al reclamo. El concepto de "ausencia" debe ser amplio.

En una situación normal, habrá que esperar que aparezca o se designe el administrador. Ahora, si hay que hacer una reparación "urgente" en las cosas y partes comunes, la puede realizar "cualquier propietario", y luego solicitar el reintegro. Obrará como un gestor de negocios. Cabe entender que es urgente cuando el transcurso del tiempo agravaría la situación, causando perjuicios adicionales, inne-

cesarios y hasta graves. Basta pensar en un caño roto que esté inundando una parte o toda la unidad funcional.

Luego de realizada la reparación, corresponde el reintegro, el que será solventado por todos al pagar las expensas ordinarias, ya que se trata de gastos de conservación. Dicho derecho al reintegro puede perderse si "el gasto resulta injustificado", ya sea porque era innecesario, la situación no era urgente, e incluso si se pagó un valor por encima del costo razonable. El artículo 2054 menciona que se puede negar el reintegro total o "parcial", lo que ocurriría si se pagó en demasía, o hubo exceso en la reparación.

Además, el consorcio puede exigir la restitución al estado anterior, si corresponde, a costa del propietario que realizó la reparación.

El artículo 2054 se refiere a la ausencia del administrador y "de los integrantes del consejo de propietarios". Dice el artículo 2064, inciso d, que le compete al Consejo "ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador, y convocar a la asamblea si el cargo está vacante dentro de los treinta días de producida la vacancia". No es un órgano obligatorio (arts. 2056, inc. u; 2058, inc. d, y 2064), pero si está constituido, el interesado sólo podrá obrar por su cuenta en el caso de ausencia de ambos.

e) Grave deterioro o destrucción del edificio

Dispone el artículo 2055 que "En caso de grave deterioro o destrucción del edificio, la asamblea por mayoría que represente más de la mitad del valor, puede resolver su demolición y la venta del terreno y de los materiales, la reparación o la reconstrucción.

"Si resuelve la reconstrucción, la minoría no puede ser obligada a contribuir a ella, y puede liberarse por transmisión de sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra. Ante la ausencia de interesados, la mayoría puede adquirir la parte de los disconformes, según valuación judicial".

El edificio puede estar destruido o con graves deterioros por el desgaste del paso del tiempo, o por algún acontecimiento especial como un terremoto, incendio, explosión, etcétera. Por hipótesis, sólo queda en pie una construcción precaria, además del terreno.

Lo cierto es que en caso de "grave deterioro o destrucción del edificio", la asamblea debe tomar una decisión por mayoría de más de la mitad del valor: a) demolición y venta del terreno y los materiales; b) reparación; c) reconstrucción. La reparación, dada la gravedad de la situación, es de una envergadura importante, que supera las reparaciones corrientes que se hacen en todos los edificios y se pagan a través de las expensas.

La decisión debe ser aprobada por mayoría absoluta, computada por "más de la mitad del valor". La regla general la fija el artículo 2060 para computar la mayoría: "se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto". Aquí el Código se aparta de la regla y se inclina por la mayoría del valor, seguramente porque si se decide la reparación o reconstrucción hay que hacer una inversión importante, que recae con más peso en quienes tienen porcentuales más altos.

Si se resuelve reconstruir el edificio, seguramente el costo será importante, y quizás no todos estén en condiciones de aportar para semejante gasto. Por eso prevé el artículo 2055 que "la minoría no puede ser obligada a contribuir". En tal caso, los propietarios que integran la minoría pueden ceder sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra, quienes ocuparán su lugar. Si no hay interesados, "la mayoría puede adquirir la parte de los disconformes, según valuación judicial". Se trata de evitar el abuso por parte de la mayoría que pretenda adquirir la parte de los otros propietarios a precio vil. De ahí que se exija la valuación judicial y que se dé preferencia a terceros extraños.

Puede ocurrir que no haya terceros interesados, y que tampoco la mayoría quiera comprar la parte de los propietarios disconformes. Parece que en tal caso no quedará más remedio que la demolición y venta, a menos que la mayoría decida soportar íntegramente el costo de la reconstrucción.

VII. Obligaciones

Según el artículo 2046: "El propietario está obligado a:

- "a) cumplir con las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal, y del reglamento interno, si lo hay;

MNR

- "b) conservar en buen estado su unidad funcional;
 - "c) pagar expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la proporción de su parte indivisa;
 - "d) contribuir a la integración del fondo de reserva, si lo hay;
 - "e) permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y de bienes del consorcio, como asimismo para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas o para controlar los trabajos de su instalación;
 - "f) notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial si opta por constituir uno diferente del de la unidad funcional".
- También repite esta obligación el primer párrafo del artículo 2048.

a) *Conservar en buen estado la unidad*

Impone el Código el deber de conservar en buen estado la unidad funcional. El derecho exclusivo que la ley le otorga a cada propietario sobre su unidad conlleva, como le ocurre al dueño de una propiedad ordinaria, que se deba hacer cargo de los gastos necesarios para conservarlo, comprensivos de las reparaciones y/o reposiciones que correspondan efectuar.

Claro que nadie podrá exigir el cumplimiento de esta obligación, pues cada titular tiene libertad de mantener su unidad en las condiciones que le plazca. El problema se presentará si con su descuido puede causar perjuicio en los sectores comunes o a otras unidades. Si como consecuencia de un desperfecto originado en un sector privativo se produjeran daños en bienes comunes, salvo pacto en contrario, el propietario debe cargar con los costos totales de la reparación integral.

Por tal razón, dispone el artículo 2046, inciso e, que el titular debe "permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y de bienes del consorcio, como asimismo para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas o para controlar los trabajos de su instalación".

b) *El fondo de reserva*

En primer lugar, cabe señalar que la existencia del fondo de reserva

no está impuesta por el Código. El inciso d, del artículo 2046 dice "si lo hay". De ese modo, su vida dependerá de la previsión que al respecto contenga el reglamento, o de su establecimiento por resolución válida de la asamblea de consorcistas.

Está destinado *prima facie* a cubrir tres clases de gastos: extraordinarios, especiales o imprevisibles e indemnizaciones y despidos. Claro está que dicha clasificación es meramente enunciativa. El artículo 2067, inciso d, alude a su utilización para cubrir gastos imprevistos y mayores que los ordinarios, en cuyo caso el administrador necesitará la autorización del Consejo de Propietarios, si lo hay. Si no lo hubiere, cabe entender que será menester la aprobación de la asamblea para que el administrador pueda disponer de tales fondos.

El fondo de reserva debe quedar depositado en una cuenta bancaria a nombre del consorcio, ya que forma parte de su patrimonio.

VIII. Expensas

Dice el artículo 2046, inciso c, que el propietario tiene la obligación de "pagar expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la proporción de su parte indivisa". Así como el propietario tiene la obligación de atender los gastos vinculados con su unidad funcional, también debe contribuir al mantenimiento y administración de las cosas y partes comunes.

El pago regular de las expensas comunes es fundamental para el normal desenvolvimiento del edificio. Si los consorcistas no pagan puntualmente, y lo hacen de manera anárquica, sería muy difícil el mantenimiento de las cosas y partes comunes. La falta de cumplimiento oportuno de aquellas cargas sería susceptible de trastornar e inclusive de poner en peligro la existencia misma del consorcio.

a) Concepto

Son todas las erogaciones que deban efectuarse con motivo de la utilización y conservación de las partes comunes del edificio. Sobre la base del concepto esbozado se puede citar a título ejemplificativo: gastos de combustibles para calefacción y agua caliente centrales, *service* de los ascensores, iluminación de las partes comunes, provisión

de artículos de limpieza a ser utilizados en el edificio, honorarios del administrador, retribución del portero y demás gente de servicio, instalación de cerraduras, instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros, etcétera.

Dice el artículo 2048 que cada propietario "debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea.

"Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros.

"Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la asamblea".

Se trata de mejoras necesarias. Como puede observarse se trata de erogaciones que según dice el texto legal tienen por objeto "mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro", pero este objetivo encuentra un límite en la propia norma: deben ser "necesarias", esto es indispensables. Cuando la reparación o sustitución no es indispensable, se trata de mejoras u obras nuevas reguladas en el artículo 2051.

En cuanto al criterio para determinar la "necesidad", siguiendo las pautas que brinda el Código (arts. 1934, inc. d, 1991, 2027, 2146, entre otros) deberá ceñirse a aquellos gastos imprescindibles tendientes a evitar la destrucción o deterioro de la cosa común, o a conservarla en buen estado, a repararla, independientemente de que aquéllos redunden en un mayor valor para el edificio. Nos referiremos indistintamente a mejoras necesarias, reparaciones y gastos, pues, entre ellos no hay diferencias sustanciales y a veces absoluta coincidencia. Así, por ejemplo: reparaciones requeridas para el apuntalamiento de una pared que amenaza caerse, mantenimiento de los pisos en buen estado, funcionamiento adecuado del sistema de desagüe, etcétera. Cabe incluir

también a las mejoras de mero mantenimiento, que comprenden la reparación de deterioros menores originados por el uso ordinario de la cosa (art. 1934, inc. c).

Como novedad, obliga a todos a mantener las instalaciones para personas con discapacidad, aunque la solución sería la misma más allá de que no lo dijera, ya que son partes comunes.

Se incluyen en el concepto de expensas de las "obligaciones impuestas al administrador".

Cabe entender que el Código se refiere a aquellas obligaciones impuestas al administrador en beneficio de los consorcistas, tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias vinculadas al personal de servicio, el pago del seguro integral de consorcios u otros seguros (ver art. 2067), y contribuciones similares.

También integran las expensas las reparaciones urgentes que realice en partes comunes un propietario, en ausencia del administrador, y del Consejo si lo hay, y que deben ser reembolsadas.

El Código divide a las expensas en *ordinarias* y *extraordinarias*. Generalmente se le atribuye este carácter a aquellos gastos importantes e imprevistos que no ocurren regularmente, como la indemnización por despido del encargado o la necesidad de hacer una reparación de cierta envergadura. También comprende a aquellas obras nuevas y mejoras decididas para un uso y goce más cómodo del inmueble, que benefician a todos (v. gr.: elevaciones o excavaciones, construcción de un gimnasio, etc.). A diferencia de las expensas ordinarias, las extraordinarias deben ser decididas en una asamblea.

b) Medida de la contribución

En lo que hace a la distribución entre los copropietarios del *quantum* de esas contribuciones, el Código deja librado al reglamento la determinación del porcentaje por el que cada copropietario responde por dichas "expensas" y su artículo 2056, inciso g, exige como cláusula obligatoria del estatuto la "determinación de la proporción en el pago de las expensas comunes". En defecto de tal previsión el propio Código establece que cada propietario lo hará en proporción de su parte indivisa (art. 2045, inc. c).

Por ende, salvo disposición diferente del reglamento, el Código fija el criterio de la proporcionalidad, por lo que resulta indiferente para su determinación el efectivo aprovechamiento que alguno de los consorcistas haga de dichas cosas comunes (art. 2049), salvo que hubiere convenido su liberación (art. 2049), o que ésta fuese dispuesta judicialmente.

El Código ha recogido estas inquietudes. En este sentido, dice el artículo 2049, último párrafo, que "El reglamento de propiedad horizontal puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generan dichas erogaciones".

Sobre el punto, deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: en el reglamento debe obligatoriamente proveerse la forma y proporción de la contribución de los propietarios, ergo, la alteración de los porcentuales a través de una decisión adoptada en asamblea requiere el voto de quienes reúnan dicha calidad y la mayoría necesaria será la unanimidad, por tratarse de una cláusula estatutaria. En efecto, se afecta el estatus patrimonial de cada consorcista, ya que si se libera a una unidad total o parcialmente de contribuir, esa merma la deben absorber los restantes titulares, lo que afecta a su patrimonio.

c) Defensas

Dispone el Código, en el artículo 2049: "Los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional.

"Tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones ni oponer defensas por cualquier causa, fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación, sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente..."

c.1) No hay liberación del propietario por no uso, enajenación o abandono

El propietario puede usar y gozar de los bienes o servicios comunes,

conforme a su destino y respetando el derecho igual de los demás. Este uso puede ser más o menos intenso, y hasta puede no existir, pero no permite liberarse de contribuir. Cada uno debe pagar de acuerdo a la proporción que fije el reglamento, de modo que el uso mayor o menor es indiferente.

Así, si una persona no usa el ascensor porque prefiere subir las escaleras, o no usa el agua caliente, o tiene su unidad desocupada, no puede pretender pagar menos de expensas. La única posibilidad es que, como se dijo anteriormente, se lo libere expresamente en el reglamento. Es que de no ser así el edificio sería caótico, ya que cada uno estaría reclamando por el pago de servicios que no usó, o usó en menor medida que otros.

Agrega el artículo 2049 que tampoco se libera el propietario si enajena la unidad. Si el titular adeuda expensas, puede enajenar su unidad a terceros, nada lo impide, pero no se libera de la deuda devengada hasta ese momento y generada durante su titularidad. El consorcio podrá exigirle el pago aun cuando haya dejado de ser propietario de la unidad funcional.

Esto sucede tanto si la enajenación es voluntaria o forzosa. Esto es, si le rematan la unidad, y no alcanza el dinero obtenido para solventar la deuda de expensas, quien hasta ese entonces era propietario sigue siendo deudor, no se libera.

Lo mismo ocurre con el abandono. El abandono es un modo de extinguir un derecho real (art. 1907). El titular de la unidad funcional puede abandonarla, en cuyo caso pasará al dominio privado del Estado (art. 236, inc. a), pero no se libera de las expensas devengadas hasta ese momento y generadas durante su titularidad.

c.2) Deudas devengadas antes de la adquisición

La primera parte del artículo 2049 dice que no se liberan ni siquiera de las "devengadas antes de su adquisición", lo que parece que está mal, que se trata de un error.

El artículo 2049 no dice que el adquirente de una unidad con deuda responda sólo con la cosa. No obstante, a esta conclusión puede arribarse en función de lo dispuesto por el artículo 1937 del Código:

"*Transmisión de obligaciones al sucesor.* El sucesor particular sucede a su antecesor en las obligaciones inherentes a la posesión sobre la cosa; pero el sucesor particular responde sólo con la cosa sobre la cual recae el derecho real. El antecesor queda liberado, excepto estipulación o disposición legal".

Ahora bien, si se acepta que por las obligaciones devengadas durante la titularidad del antecesor se responde sólo con la cosa, no tiene sentido establecer que el titular de la unidad no se libera de ellas "por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional". Respecto de las devengadas antes de su titularidad, sí o sí debe liberarse, pues sólo responde con la cosa y ésta ya salió de su poder. ¿Con qué va a responder? El consorcio acreedor ya no tiene garantía sobre la cual ejecutar el crédito, por lo que es absurdo que no se libere.

Distinta es la situación de las devengadas durante su titularidad. Aunque enajene la unidad, de tales deudas no se libera, y responderá con el resto de su patrimonio.

Cabe entender que ha habido un error en la redacción del artículo 2049, en su primera parte.

c.3) Situación de los adquirentes

Si bien el titular que adeuda expensas no se libera por la enajenación de la unidad funcional y sigue siendo deudor, aparece un nuevo deudor de tales obligaciones impagas que es el nuevo adquirente. Ello es así porque según el artículo 1937: "El sucesor particular sucede a su antecesor en las obligaciones inherentes a la posesión sobre la cosa; pero el sucesor particular responde sólo con la cosa sobre la cual recae el derecho real".

Esto es así aun cuando el sucesor adquiera en una subasta o remate público, si el dinero obtenido no alcanzó para pagar la deuda de expensas. Éste era un tema controvertido en doctrina, y que en la Capital Federal fue resuelto de manera obligatoria por un fallo plenario de la Cámara Nacional en lo Civil: No corresponde que el adquirente en subasta judicial afronte las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones, devengadas antes de la toma de po-

sesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcanza para solventarlas. No cabe una solución análoga respecto de las expensas comunes para el caso de que el inmueble se halle sujeto al régimen de la propiedad horizontal (CNCiv., en pleno, 18-2-99, "Servicios Eficientes SA c/Yabra, Roberto", L. L. 1999-B-384, RCyS 1999-606, D. J. 1999-1-881).

El sucesor, por la eventual deuda que se genere durante su titularidad, no se libera por el no uso, enajenación o abandono, y responde con todo su patrimonio. En cambio, por las devengadas antes de su adquisición, sólo responde con la cosa, y a pesar del texto legal cabe interpretar que sí se libera de ellas si enajena o abandona la unidad.

En cuanto a la información de subadquirentes sobre las deudas de expensas existentes a ese momento, el artículo 2067, inciso 1, prevé que el administrador, a pedido de parte interesada, debe expedir dentro del plazo de tres días hábiles el certificado de deudas y de créditos del consorcio por todo concepto con constancia de la existencia de reclamos administrativos o judiciales e información sobre los seguros vigentes.

Puede ocurrir que el vendedor de la unidad convenga con el comprador que este último se hará cargo de las expensas adeudadas. El pacto es válido, pero inoponible al consorcio, el que de todos modos le puede exigir la deuda al primero. Luego, éste podrá repetir de su contratante.

c.4) *Compensación*

El segundo párrafo del artículo 2049 aclara que ser acreedor del consorcio no exime de pagar, salvo compensación. Dice que "tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones ni oponer defensas por cualquier causa, fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación, sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente".

Puede ocurrir que el titular de una unidad reclame al administrador que le efectúe alguna reparación dentro de su unidad funcional, y que esto no se lleve a cabo. Eso no le da derecho a no pagar las expensas: no es una excusa válida. A todo evento, deberá hacer valer sus derechos por la vía que corresponda pero no se pueden mezclar las pretensiones.

La única excepción que permite el Código es la compensación. Parece un caso de "compensación legal". Serían requisitos: a) reciprocidad; b) título diferente; c) fungibilidad y homogeneidad; d) liquidez; e) exigibilidad. La compensación legal está tratada en el artículo 923 del Código.

c.5) *Prescripción*

El plazo de prescripción de estas obligaciones es de dos años (art. 2562, inc. c).

d) *Obligados al pago de expensas*

Dice el artículo 2050: "*Obligados al pago de expensas*. Además del propietario, y sin implicar liberación de éste, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título". Además, el artículo 2148 obliga al usufructuario al pago de las expensas, lo que se extiende al uso y la habitación (arts. 2155, 2159 y 2161).

Por un lado, los titulares de otros derechos reales. El ejemplo típico es el del usufructuario que tiene el uso y goce del inmueble.

En cuanto a los titulares de derechos personales poseedores, es claro que la norma debe aludir al que tiene un boleto de compraventa. Es razonable que el poseedor con boleto de compraventa, así como tiene ciertas prerrogativas, también soporte estas obligaciones. No incluye el artículo 2050 al poseedor sin derecho, aunque es probable que éste tenga interés en pagar las expensas, si pretende adquirir por usucapión, pero no está obligado a hacerlo; deben ser poseedores ligados al propietario por algún vínculo contractual. Tampoco incluye al locatario ni al comodatario, si bien titulares de derechos personales, pues no son poseedores.

La obligatoriedad de pagar expensas por parte de los poseedores mencionados en el artículo 2050 no implica conferirles derechos para participar en la conformación del consorcio (art. 2044), de la asamblea (art. 2058) o del consejo de propietarios, en este caso, tal como el nombre del órgano lo indica (art. 2064).

Por último, la existencia de otros obligados, si los hay, no libera al propietario, quien sigue siendo responsable frente al consorcio.

e) *Procedimiento para perseguir su cobro*

La ley 13.512 nada disponía sobre el particular, de modo que al respecto cabía estar a lo que establecían las normas adjetivas locales. Con buen criterio, tanto el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 524) como su par de la Provincia de Buenos Aires (art. 522) establecen expresamente la procedencia de la vía ejecutiva a tal efecto.

Según el artículo 2048, último párrafo, "El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el consejo de propietarios, si éste existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones". La jurisprudencia ha extendido la vía ejecutiva al cobro de los intereses, lo que seguramente figurará en dicho certificado, ya que lo accesorio sigue la suerte de lo principal (arts. 856 y 857).

f) *Privilegio*

Este crédito tiene privilegio, ya que dice el artículo 2582 que "Tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso se indica:

"a) los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa, sobre ésta. Se incluye el crédito por expensas comunes en la propiedad horizontal..."

g) *Intereses*

Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la vida del consorcio el pago regular de las expensas, han sido admitidas por la jurisprudencia cláusulas de los reglamentos que fijan la tasa de los intereses punitivos a abonar, en los supuestos de mora, en porcentajes relativamente altos o, al menos, más altos que los que corrientemente se admite para los otros tipos de deudas.

No obstante, cuando las tasas pactadas exceden límites razonables, aunque valoradas con el criterio flexible referido, los jueces las han morigerado.

IX. Prohibiciones

MNR

Además de las obligaciones ya vistas, el Código impone a los propietarios prohibiciones concretas, en aras de la buena vecindad y de preservar la seguridad del inmueble.

Dice el artículo 2047: "Está prohibido a los propietarios y ocupantes:

- "a) destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral o a fines distintos a los previstos en el reglamento de propiedad horizontal;
- "b) perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia;
- "c) ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble;
- "d) depositar cosas peligrosas o perjudiciales".

Como surge de su texto, estas prohibiciones comprenden tanto a los propietarios como a otros ocupantes, ya se trate de poseedores con derecho (usufructuarios), tenedores (v. gr., locatario), o quienes ocupen por algún otro título.

a) *Respetar el destino*

Todos los que habiten de alguna manera la unidad funcional, propietarios o no, deben usarla y gozarla de acuerdo a su destino. El destino está fijado en el reglamento (v. gr.: vivienda, oficina, etc.). En caso de omisión del reglamento (lo cual es raro que suceda), se determinará por la naturaleza del inmueble o por el uso al cual estaba afectada de hecho.

Si se pretende cambiar el destino, habrá que modificar el reglamento. La mayoría necesaria es la unanimidad, teniendo en cuenta que se trata de una cláusula estatutaria, ya que afecta el estatus patrimonial de cada consorcista. En el supuesto de que un propietario enajene su unidad y convenga con el comprador determinado destino, ello es inoponible al consorcio. No hay que olvidar que el reglamento integra el título de adquisición. Lo mismo ocurre con otros ocupantes.

b) *Moral y buenas costumbres*

También impide el inciso a, del artículo 2047 realizar actos contrarios a la moral y buenas costumbres, concepto que no siempre es fácil de medir, ya que inciden posturas filosóficas personales. El caso más evidente sería el funcionamiento de un prostíbulo en una unidad privativa.

c) *Tranquilidad*

El artículo 2047 prohíbe perturbar la tranquilidad de los vecinos, por encima de la normal tolerancia. Se trata de una limitación similar a la contenida en el artículo 1973, pero que debe ser apreciada con mayor rigor, dada la cercanía entre los distintos titulares.

El propietario puede realizar sus actividades, y éstas seguramente provocarán ruidos, humo, olor, entre otras molestias. El límite es la normal tolerancia. La valoración tiene que ser objetiva, es decir, lo que es normal, razonable, para el común de la gente, y no para una persona determinada. A su vez, la convivencia obliga a ser tolerante con la actividad ajena. Se trata de cuestiones de hecho que deben ser apreciadas en cada caso, y en función de la estructura del inmueble, el horario, etcétera.

Así, por ejemplo, no es lo mismo escuchar música durante el día que en la madrugada. También es un dato que los edificios modernos cuentan con muros menos sólidos que los antiguos. En suma, se trata de ser razonable.

d) *Tenencia de animales*

En algunos edificios se encuentra prohibida la tenencia de animales en el reglamento. Otros no tienen previsión al respecto.

Pienso que aun cuando el reglamento lo prohíba, no pueden los consorcistas o el administrador pretender válidamente el retiro de las mascotas. Si bien para el Código son cosas, es sabido que los animales domésticos gozan de leyes protectoras, son una buena compañía y brindan mucho afecto a sus dueños. Reciben un trato especial dado que comen, duermen, se enferman, se bañan, etcétera.

Entiendo que hace a la dignidad de la persona humana vivir, si lo desea, con un animal doméstico, y que este derecho no puede ser lesionado. Desde otro ángulo, la mera invocación de una cláusula del reglamento, sin atender a circunstancias particulares, configuraría una conducta abusiva.

e) *Depositar cosas peligrosas o perjudiciales*

Ésta es otra prohibición expresa del artículo 2047. Así, por ejemplo, no se puede en una unidad almacenar material explosivo, o que pueda perjudicar de alguna forma a los demás (v. gr.: virus que puedan contagiar alguna enfermedad).

X. *Procedimiento para el cese de infracciones*

Establece el artículo 2069: "*Régimen*. En caso de violación por un propietario u ocupante de las prohibiciones establecidas en este Código o en el reglamento de propiedad horizontal, y sin perjuicio de las demás acciones que corresponden, el consorcio o cualquier propietario afectado tienen acción para hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el ordenamiento local. Si el infractor es un ocupante no propietario, puede ser desalojado en caso de reiteración de infracciones".

a) *Ámbito*

Corresponde aplicar el procedimiento y régimen que prevé esta norma, no sólo a la violación de lo que prohíbe el artículo 2047, sino también a las conductas que no acatan las obligaciones de los artículos 2040, 2046, incisos a, b, y e, y 2052, además de las que imponga el reglamento (art. 2056, incs. h, i, j, k, y q), por lo que la acción contra el infractor podrá intentarse también en el caso de que se altere la estética del edificio, o se trate de actos que importen modificaciones realizadas sin autorización, cuando ésta es requerida.

Esto significa que se puede iniciar este procedimiento cuando se cometa una infracción dentro de la unidad privativa (v. gr.: ruidos molestos, depósito de mercadería peligrosa, etc.), como cuando se rea-

lice una violación en las partes comunes (v. gr.: cerramiento de un patio, uso indebido de la terraza, etc.).

Además de disponer el cese de la infracción, el juez puede aplicar sanciones conminatorias, tanto al propietario como al ocupante que no lo es.

En cuanto a las aplicables al ocupante no propietario, además de las ya indicadas, cabrá también la de desalojo, en el caso de que cometa cualquier otro tipo de infracción toda vez que haya sido condenado por la primera. La norma alude a la "reiteración de infracciones", lo que no requiere que sea una segunda infracción idéntica; basta con cualquier violación de la ley o del reglamento.

No era necesario indicar que los propietarios perjudicados pueden reclamar la reparación de los daños sufridos como consecuencia de las infracciones cometidas, mediante la acción civil resarcitoria. Por tal motivo, el artículo 2069 no dice nada al respecto, limitándose a decir que lo aquí regulado es "sin perjuicio de las demás acciones que corresponden". Por ende, además de reclamar el cese de la infracción, por aplicación de los principios generales se puede también reclamar la indemnización del daño sufrido.

b) *Legitimación activa*

El artículo 2069 faculta al consorcio o a cualquier propietario afectado a formular la demanda ante el juez competente. Si bien el artículo se refiere al consorcio, lo cierto es que deberá actuar el administrador, que es su representante legal.

No es necesario que el representante del consorcio cuente con una autorización especial y expresamente otorgada por sus integrantes para entablar las acciones tendientes a hacer cesar la infracción, porque si bien no contar con ella demostraría que los propietarios no tienen interés en resolver la transgresión, esa falta no podría ser invocada en su defensa por quien ha violado las prohibiciones establecidas.

En cuanto a quién o quiénes son los propietarios legitimados para accionar se postula establecerlo de acuerdo con la naturaleza de la infracción, porque sólo aquel que demuestre que la violación afecta su interés particular tendrá legitimación procesal propia para intentarlo.

Así, si la infracción concierne a una norma legal o del reglamento —tal por caso el uso de la unidad contrario a su destino— cualquiera de los copropietarios estará facultado para reclamar judicialmente su cesación; mientras que si aquélla consiste en el uso irregular o abusivo de una unidad —verbigracia: provocando perturbaciones que exceden la normal tolerancia— sólo estará legitimado el propietario que resulte "afectado" por la infracción, quien además deberá justificar el daño inferido. Se dice que así se evitan pleitos inútiles motivados en cuestiones personales.

c) *Legitimación pasiva*

Obviamente estas obligaciones y prohibiciones que afectan a los propietarios, son también válidas para quienes ocupan unidades en el edificio, sin ser titulares del derecho de propiedad horizontal. El reglamento de propiedad horizontal y sus cláusulas son ley (art. 959), no sólo para los consorcistas sino para todos los habitantes del inmueble, y un consorcista no puede transmitir a su ocupante un derecho mejor o más extenso (art. 399), y, por tanto, el ocupante, tenedor o poseedor, también está obligado a respetar las cláusulas del reglamento y no a variar del destino allí establecido, ni incurrir en otras infracciones.

En el caso de que se intente el desalojo del ocupante que no es propietario, debe ser parte, también, el titular del inmueble, limitación esta última que se explica porque es éste quien mantiene relación con aquel tercero.

En suma, el artículo 2069 permite desalojar al "ocupante no propietario", en caso de que reitere las infracciones. El caso del locatario es claro. Surge alguna duda si se trata de otra clase de no propietario, como un poseedor con boleto de compraventa o un usufructuario. Si bien la situación suscita alguna perplejidad, lo cierto es que donde la ley no distingue no hay que distinguir, y el artículo 2069 sólo pone la condición de no ser propietario, esto es, no ser titular del derecho real de propiedad horizontal.

d) *Procedimiento*

El artículo 2069 dispone que la acción que promueva el adminis-

trador o el propietario afectado, con el objeto de cese la infracción, "debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el ordenamiento local". La referencia a ese tipo de juicio tuvo por finalidad acotar lo más posible los tiempos procesales.

El artículo dispone la aplicación del trámite más abreviado, generalmente el juicio sumarísimo o el de los incidentes, aunque esto dependerá de la legislación local, variable en cada provincia.

e) *Prescripción liberatoria*

Ante la ausencia de una disposición expresa en el artículo 2069, corresponde aplicar el plazo genérico de cinco años del artículo 2560, debiendo computarse el plazo desde que nace la acción.

XI. Reglamento

a) *Concepto*

El reglamento de propiedad horizontal es el estatuto fundamental que contiene la regulación de los derechos y obligaciones de los titulares de unidades funcionales bajo el régimen de propiedad horizontal. Se denomina "de propiedad horizontal" porque describe las partes del edificio y la proporción en que las privativas participan en las comunes, y para diferenciar a este derecho del condominio.

El reglamento debe ser redactado por escritura pública e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble. Como se dijo anteriormente, lo que produce el reglamento es el "estado de propiedad horizontal", pero no el nacimiento de los diversos derechos de propiedad horizontal que coexistirán en el inmueble. Este nacimiento de los derechos de propiedad horizontal, aun cuando requiere como requisito indispensable el previo o simultáneo registro del reglamento, sólo operará al cumplirse los requisitos comunes exigidos por el Código (título suficiente y modo suficiente), requiriéndose al menos la existencia de dos titulares.

Puede ser otorgado por el dueño único, o por los condóminos. En este último caso, deberán acordar por unanimidad (art. 1990). Prevé el artículo 2120 que "El superficiario puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal". Por ende, si el dueño del terreno

o los condóminos lo gravan con superficie, y el superficiario realiza una construcción que afecta al régimen de propiedad horizontal, no habría razones para impedirle al superficiario dictar el reglamento "A los fines de la división jurídica del edificio..." (art. 2038).

b) *Naturaleza*

El reglamento de propiedad horizontal es considerado en cuanto a su naturaleza jurídica un contrato. El Código permite que el reglamento sea redactado por el dueño único del inmueble que pretende dividir por este sistema, o por los condóminos si el inmueble tiene más de un dueño (art. 2038). En el segundo caso se aprecia fácilmente la naturaleza contractual, mientras que el primero puede suscitar alguna duda, pero la doctrina coincide en que, aun cuando sea redactado por una sola persona, se trata de una oferta de contrato que luego es aceptada por los respetivos adquirentes del derecho real de propiedad horizontal (ver arts. 971 y ss.).

La circunstancia de que la ley establezca cláusulas imperativas en el reglamento no obsta a la referida naturaleza, pues es frecuente en los contratos la existencia de normas de orden público que limiten la voluntad de las partes.

c) *Contenido*

Generalmente pueden distinguirse tres partes en el reglamento: 1) la que se refiere a la afectación del inmueble al sistema con la correspondiente descripción de las partes privativas y comunes, la proporción que cada unidad tiene en éstas y su destino; 2) las que establecen las normas de convivencia entre los integrantes del consorcio; 3) las referidas a los órganos del consorcio, funcionamiento, derecho y obligaciones.

El Código impone el contenido mínimo y obligatorio del reglamento, sin perjuicio de la libertad de los propietarios para incluir otras cláusulas, o de modificarlas.

Dice el artículo 2056 que "El reglamento de propiedad horizontal debe contener:

"a) determinación del terreno;

- "b) determinación de las unidades funcionales y complementarias;
- "c) enumeración de los bienes propios;
- "d) enumeración de las cosas y partes comunes;
- "e) composición del patrimonio del consorcio;
- "f) determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad;
- "g) determinación de la proporción en el pago de las expensas comunes;
- "h) uso y goce de las cosas y partes comunes;
- "i) uso y goce de los bienes del consorcio;
- "j) destino de las unidades funcionales;
- "k) destino de las partes comunes;
- "l) facultades especiales de las asambleas de propietarios;
- "m) determinación de la forma de convocar la reunión de propietarios, su periodicidad y su forma de notificación;
- "n) especificación de limitaciones a la cantidad de cartas poderes que puede detentar cada titular de unidad funcional para representar a otros en asambleas;
- "ñ) determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones;
- "o) determinación de las mayorías necesarias para modificar el reglamento de propiedad horizontal;
- "p) forma de computar las mayorías;
- "q) determinación de eventuales prohibiciones para la disposición o locación de unidades complementarias hacia terceros no propietarios;
- "r) designación, facultades y obligaciones especiales del administrador;
- "s) plazo de ejercicio de la función de administrador;
- "t) fijación del ejercicio financiero del consorcio;
- "u) facultades especiales del consejo de propietarios".

Algunas de estas cláusulas obligatorias también están previstas en otras normas del Código, como lo que concierne al uso y goce de las partes comunes, las obligaciones del administrador, etcétera. No obstante, el reglamento puede completar o agregar regulaciones, agravar

mayorías, limitar el ejercicio de facultades, etcétera. Así, por ejemplo, puede prever los intereses moratorios y punitivos para quien se atrase en el pago de las expensas, multas para el caso de violación del reglamento, la existencia de un Consejo de Propietarios, creación de un fondo de reserva, etcétera.

d) *Modificación del reglamento*

El principio general lo sienta el artículo 2057: "El reglamento sólo puede modificarse por resolución de los propietarios, mediante una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios".

Esta mayoría de dos tercios es mínima, ya que el reglamento puede agravarla. Cabe inferir que no puede disminuirla, ya que si ésa hubiera sido la intención del legislador no hubiera fijado ninguna mayoría y lo habría dejado librado a la voluntad de los interesados.

Dice el artículo 2057 que esta mayoría de dos tercios se computa sobre el total de los propietarios, pero no se dice cómo se cuentan los votos. Al tratar las asambleas, dice que la mayoría absoluta se calcula "con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto" (art. 2060, primer párrafo), mientras que en caso de grave destrucción o deterioro del edificio, la mayoría debe superar "más de la mitad del valor" (art. 2055).

Ahora bien, el artículo 2056 dice que el reglamento debe establecer la "forma de computar las mayorías" (art. 2056, inc. p), por lo que se puede arriesgar que, en primer lugar, esta mayoría especial de dos tercios se calcula en la forma que prevea el reglamento. Si nada dice, pareciera que habrá que acudir al doble cálculo de número de unidades y de valor, para mantener armonía con el resto de las decisiones, aunque hubiera sido preferible una mayor claridad sobre el punto.

Sin perjuicio de lo expuesto, la doctrina ha elaborado una clasificación de las cláusulas del reglamento que permite dividir las en estatutarias y reglamentarias. La afectación de tipo patrimonial que provoca la modificación de una cláusula, ha sido el criterio utilizado por los distintos autores para distinguir si adquiere o no el carácter de estatutaria, y por ende, si se requiere la unanimidad para decidir su reforma.

Son cláusulas estatutarias, entonces, aquellas que se vinculan con los derechos patrimoniales de los distintos propietarios, tal como ocurre con las que expresan la distribución porcentual sobre los bienes comunes, la proporción con que cada propietario solventa los gastos por expensas o el destino de las unidades. Estas cláusulas, aun cuando forman parte del reglamento, no pueden ser modificadas sino por unanimidad. Todas las demás –las reglamentarias– admiten ser modificadas por resolución de los propietarios mediante una mayoría “de dos tercios de la totalidad de los propietarios” que exige la ley (art. 2057). Aunque el Código no la recoge expresamente, esta clasificación de las cláusulas aparece en el artículo 2061, según el cual para la supresión o limitación de derechos a los propietarios “que excedan de meras cuestiones de funcionamiento cotidiano”, la mayoría debe integrarse con la conformidad expresa de sus titulares.

Las modificaciones al reglamento deben ser instrumentadas también en escritura pública, pero no todas tienen vocación registral, ya que sólo la tendrán los cambios de aquellas estipulaciones del estatuto original de las que el Registro de la Propiedad Inmueble haya tomado razón.

e) *Modificación judicial*

Aun en los asuntos que exigen unanimidad, podría requerirse judicialmente la modificación que se considera justa y necesaria, para evitar arbitrariedades, cuando, por ejemplo, no es posible obtener la modificación por unanimidad en asamblea, ya que el que puede resultar afectado con la modificación, pues se beneficia con el mantenimiento de la situación arbitraria, habría de oponerse.

No hay que olvidar que el reglamento puede ser redactado por el único dueño del inmueble, que construyó el edificio para luego enajenar unidades. Es posible que dicha persona se quede con alguna unidad y que inserte en el reglamento cláusulas en su exclusivo beneficio (v. gr.: que se reserva la elección del administrador por 10 años, que no se puede remover al administrador sin su voto, entre otras). Sería una situación abusiva.

Se trata de una facultad excepcional, ya que los jueces no pueden

MNR

suplir a los contratantes. Hay que tener en cuenta el artículo 960 del Código, sobre las facultades de los jueces: “Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de modo manifiesto, el orden público”.

Antes de iniciar la vía judicial hay que intentar agotar la vía de la asamblea.

f) *Reglamento interno*

A fin de reglar sus derechos y obligaciones, los propietarios también pueden pactar la existencia de un reglamento interno. Se suelen incluir en dicho convenio cuestiones menores, como el horario de uso de la terraza, recomendaciones para el retiro de la basura, etcétera. Su creación es voluntaria.

Se lo podrá modificar con la mayoría absoluta, salvo que en el reglamento se haya previsto una mayoría superior.

XII. *Asambleas*

a) *Concepto y facultades de la asamblea*

El consorcio es una persona jurídica distinta de sus integrantes. Como sucede con las personas jurídicas, actúa a través de órganos. La asamblea es uno de ellos, junto al administrador (representante legal), y al consejo de propietarios, si lo hay (art. 2044). Se trata de un órgano, esencialmente, *deliberativo*, aunque el Código permite en ocasiones la toma de decisiones sin la reunión de los propietarios. En cambio, el administrador es un órgano con funciones ejecutivas.

Esencialmente la asamblea es deliberativa, ya que comienza diciendo el artículo 2058 que “La asamblea es la reunión de propietarios”.

Es el ente supremo, soberano e idóneo, apto para resolver todas las cuestiones de interés común, previa deliberación de los consorcistas, convocados a tales efectos, siguiendo pautas legales y reglamentarias, en cuanto a la convocatoria, deliberación y decisión.

Dice el Código en el artículo 2058: "La asamblea es la reunión de propietarios facultada para resolver:

- "a) las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal;
- "b) las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando le son sometidas por cualquiera de éstos o por quien representa el cinco por ciento de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto;
- "c) las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio;
- "d) las cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o del consejo de propietarios, si lo hubiere".

Por otra parte, el artículo 2056, inciso 1, dice que el reglamento debe contener, entre otras cuestiones, las "facultades especiales de las asambleas de propietarios".

El artículo 2058 le asigna a la asamblea competencia sobre determinadas cuestiones. Así, por ejemplo, el inciso b, dice que está habilitada para resolver "las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando le son sometidas por cualquiera de éstos o por quien representa el cinco por ciento de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto".

Pareciera entonces que no es tan soberana, ya que no podría inmiscuirse en las cuestiones que le competen al consejo o al administrador, si no le son sometidas por los legitimados. Sin embargo, cabe interpretar que no es así, sino que puede resolver tales cuestiones, y otras, aun cuando no les sean sometidas por los involucrados.

Lo cierto es que la asamblea puede remover al administrador (art. 2066) y al consejo de propietarios (arg. art. 2064), y que el administrador debe "ejecutar las decisiones de la asamblea" (art. 2067, inc. b). Por lo tanto, no es posible aceptar que quien tiene la potestad de remover y de tomar decisiones para que sean cumplidas por el administrador, no puede resolver temas que sean propios del mencionado representante.

a.1) *Cuestiones atribuidas por la ley o el reglamento*

Hay cuestiones concretas que el Código atribuye directamente a la asamblea. Así, por ejemplo, la aprobación de una obra nueva (art. 2051), o la decisión de demoler el edificio y vender los materiales en caso de grave deterioro (art. 2055), designar el consejo de propietarios (art. 2064).

a.2) *Cuestiones que someta el administrador, el consejo, o por quien o quienes representan más del 5%*

El inciso b, del artículo 2058, también permite tratar cuestiones cuando son pedidas por "quien representa el cinco por ciento". ¿Qué pasa si nadie tiene ese porcentaje pero se juntan varios? Cabe entender que el vocablo "quien" admite también que sean más de uno los que obtengan ese porcentaje. No pide el doble cómputo de valor y unidades, como sí lo hace el artículo 2060, de modo que ese 5% se calcula sobre valores porcentuales.

a.3) *Designación y remoción del personal de consorcio*

El artículo 2067, inciso f, dispone que le compete al administrador "nombrar y despedir al personal del consorcio, con acuerdo de la asamblea convocada al efecto". Durante la vigencia de la ley 13.512, ésta era una facultad que ejercía el administrador, muchas veces de manera inconsulta, lo que trajo problemas en varios consorcios que luego se veían enfrentados a demandas cuantiosas de indemnización por despido.

Lo mismo se puede decir del nombramiento, especialmente del encargado del edificio, quien debe tratar diariamente con los propietarios. El Código, para evitar estos inconvenientes, con buen criterio limita el poder del administrador en forma expresa, imponiendo que esa decisión debe ser consentida por la asamblea.

b) *Clases de asambleas*

Se las suele clasificar en ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias son las que se celebran con periodicidad, el plazo está fijado en el reglamento, para tratar temas que hacen al funcionamiento normal y

habitual del consorcio; como la rendición de cuentas del administrador, la aprobación del presupuesto de gastos para el próximo ejercicio, la renovación de los miembros del consejo de administración, etcétera.

Las asambleas extraordinarias, en cambio, están destinadas a solucionar asuntos de interés común que surjan en cada caso. Se citan ante situaciones imprevistas. Son temas de especial importancia o urgencia, como la remoción del administrador, la necesidad de hacer una reparación que importe una erogación muy grande, etcétera.

c) *Legitimados para participar*

Están habilitados para intervenir y decidir en la asamblea los propietarios de las unidades funcionales. El Código advierte que las mayorías se calculan sobre la "totalidad de los propietarios" (arts. 2059 a 2061). Además, el artículo 2056, inciso m, se refiere a la "reunión de propietarios". En ocasiones, podrán hacerlo también los titulares de unidades complementarias, si el reglamento permite su adquisición por quienes no cuentan con una unidad funcional y les confiere derecho a intervenir en la reunión (art. 2056, inc. q).

Si la unidad pertenece a más de una persona en copropiedad, todos ellos sólo tienen un voto. Si hay desacuerdo entre ellos, deberá aplicarse lo previsto en el artículo 1994.

No es necesario que los propietarios concurren personalmente, ya que pueden hacerlo a través de un apoderado, o bien ser representados por otro titular a través de una "carta poder".

El Código no limita la cantidad de cartas poderes, sino que deja librada la cuestión a lo que decida el reglamento.

Los poseedores por cualquier título, si bien están obligados al pago de las expensas (art. 2050), no tienen derecho a votar en la asamblea. Menos aún los tenedores.

d) *Convocatoria*

d.1) *Concepto y forma*

El primer paso para que pueda reunirse válidamente la asamblea, es la convocatoria. Dice el artículo 2059 que "Los propietarios deben

ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa; es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema".

La convocatoria la debe realizar el administrador (art. 2067, inc. a) y, en su defecto, el Consejo de Propietarios si lo hay (art. 2064, inc. a). Si éstos omiten hacerlo, y no se da un supuesto de autoconvocatoria (art. 2059, segundo párrafo), se puede promover la asamblea judicial prevista en el artículo 2063, salvo que el reglamento prevea otras alternativas.

Debe ser hecha a través de un medio fehaciente, para impedir que algún titular alegue no haberse enterado; es necesario procurar que quede constancia de la recepción. Es ideal una carta documento, un telegrama o una notificación notarial, pero se trata de medios un tanto costosos. Se suele utilizar el método del aviso individual que se reparte en cada unidad, y se pide la firma de haber recibido la citación.

No obstante, la cuestión debe estar prevista en el reglamento. El artículo 2056, inciso m, dice que el estatuto debe prever la forma de convocar a la reunión, así como la forma de notificación. Pueden preverse sistemas más modernos, como la notificación electrónica, procurando un sistema que asegure la recepción, sin posibles cuestionamientos.

Las irregularidades acerca de la citación para la asamblea quedan convalidadas con la concurrencia de los propietarios a la misma sin objetar en absoluto la forma y modo en que fueron convocados.

d.2) *Orden del día*

Dice el artículo 2059 que la convocatoria debe ser confeccionada "con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa". Es una cuestión muy importante, para evitar que los asistentes se vean sorprendidos con temas suscitados durante el transcurso de la asamblea, sin haber tenido tiempo para reflexionar sobre ellos. También para proteger a los ausentes, que quizás decidieron no asistir por no estar interesados en los temas a tratar y luego se enteran de que se adoptaron decisiones sobre otros asuntos.

El orden del día consiste en la enumeración "precisa y completa" de los temas que serán objeto de tratamiento y debate en la asamblea. La asamblea, por regla, sólo puede tratar esos temas y no otros, bajo pena de nulidad.

Finalmente, culmina el primer párrafo del artículo 2059 advirtiendo que "es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema".

No es válido el tratamiento de temas no previstos en el orden del día, ni siquiera por tener la mayoría necesaria. Ello se debe a que muchos pueden haber votado el tema sin haberse preparado o informado suficientemente, y porque algún consorcista puede haber dejado de ir sin saber que el tema se trataría. Quizás, de haber asistido, hubiera influido en la decisión que tomaron los demás.

Hay una excepción que permite tratar temas no incluidos en el orden del día si a la reunión asisten todos y por unanimidad aceptan tratarlo. Si no asistieron todos, y si estando todos uno solo se opone, ya no sería válida la decisión.

d.3) *Autoconvocatoria*

El segundo párrafo del artículo 2059 prevé la autoconvocatoria (sin citación previa). Dice que "La asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios".

La norma pide dos tercios para aprobar el temario, por lo que se puede inferir que esa mayoría especial no es requerida para el momento de votar y decidir.

d.4) *Decisiones tomadas sin reunión*

Culmina el artículo 2059 estableciendo que "Son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios aunque no lo hagan en asamblea". Este tercer párrafo, si hay unanimidad, otorga validez a las decisiones tomadas fuera de la asamblea (v. gr.: por escrito).

e) *Quórum y mayorías*

El quórum es la cantidad mínima de personas que deben estar presentes para que la asamblea pueda sesionar válidamente. Teniendo en cuenta que los votos se cuentan sobre el total y no sobre los presentes, el quórum mínimo coincide con la mayoría necesaria para la decisión que se pretende tomar. Una vez reunido el quórum, es necesario que se vote y que la decisión cuente con la mayoría suficiente. Sin perjuicio de otras que pueden ser previstas en el reglamento, surgen de la ley tres mayorías posibles: absoluta (más de la mitad), dos tercios y unanimidad. El reglamento puede agravarlas (art. 2056, incs. ñ, y o).

La novedad está en el cálculo de dicha mayoría absoluta: "computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto" (art. 2060).

Esta solución parece más justa y equilibrada, ya que no resulta razonable que quien tiene una unidad pequeña tenga en la asamblea la misma fuerza al votar que quien tiene una unidad más grande y afronta mayores gastos. Pero tampoco sería justo que el segundo impusiera su voluntad, de ahí que la solución instaurada, al combinar ambos elementos, se muestra más equilibrada con los intereses en juego.

También el Código apunta a solucionar un problema que se presenta con frecuencia en casi todas las asambleas. Generalmente, y lamentablemente, la mayor parte de los consorcistas no suele asistir a estas reuniones, las que se terminan realizando igual pero sin quórum. Al ser así, se corre el riesgo de que algún ausente pida la nulidad de la decisión, pero la otra alternativa es no hacer nada y que quede paralizado el edificio, a menos que se den supuestos que permitan la convocatoria a una asamblea judicial.

Para afrontar este problema, el Código trae una norma novedosa. Dice el segundo párrafo del artículo 2060 que "La mayoría de los presentes puede proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los quince días de notificados, excepto que éstos se opongan antes por igual medio, con mayoría suficiente".

Entonces, si hay quórum, pero no mayoría absoluta, porque no todos coinciden a la hora de votar, o directamente no hay siquiera quórum, la mayoría de los presentes (mayoría relativa) propone una decisión y la comunica a los ausentes por un medio fehaciente. Luego se aprueba, salvo que éstos —antes de 15 días—, se opongan con una “mayoría suficiente”. Cabe entender que son más los que se oponen que los que propusieron la decisión. Entre los opositores se puede contar también a los que asistieron a la asamblea y votaron en contra, pues de no ser así, a pesar de haber asistido, tendrían menos poder que aquellos que ni siquiera concurrieron.

Pero la cuestión no termina ahí, pues habrá que ver cuántos ausentes no dicen nada. Si se trata de un número importante de ausentes que guarda silencio, cabe inferir que tácitamente aprueban lo que decidió la mayoría de presentes. Por ende, para determinar si hay una “mayoría suficiente” de opositores, además de contar a los que votaron en contra en la asamblea, también habrá que contar a los que se opongan posteriormente, y a los que guarden silencio, para hacer la cuenta final y ver quiénes tuvieron mayoría.

Con buen criterio exige el artículo 2060 que la decisión de la mayoría de presentes se comuniqué de manera fehaciente a los ausentes.

f) *Actas*

El Código impone la necesidad de la constancia en actas de lo ocurrido y resuelto por la asamblea. Se denominan actas los documentos que tienen por objeto la comprobación de hechos y de actos. Dice el artículo 2062 del Código: “Sin perjuicio de los restantes libros referidos a la administración del consorcio, es obligatorio llevar un Libro de Actas de Asamblea y un Libro de Registro de firmas de los propietarios.

“Debe labrarse acta de cada asamblea en el libro respectivo, en el que los presentes deben firmar como constancia de su asistencia. Las firmas que suscriben cada asamblea deben ser cotejadas por el administrador con las firmas originales registradas.

“Las actas deben confeccionarse por un secretario de actas elegido por los propietarios; éstas deben contener el resumen de lo deliberado

y la transcripción de las decisiones adoptadas o, en su caso, propuestas por la mayoría de los presentes, y ser firmadas por el presidente de la asamblea y dos propietarios. Al pie de cada acta, el administrador debe dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes, de las oposiciones recibidas y de las eventuales conformidades expresas”.

g) *Nulidad de la asamblea. Caducidad*

Si se realiza la asamblea sin una debida convocatoria, o si se tratan temas no incluidos en el orden del día, o se realiza la autoconvocatoria sin superar la cantidad de dos tercios, o se aprueban decisiones sin quórum y/o sin mayoría, o se suprime el derecho de un titular sin su conformidad, o se adoptan decisiones ilegales o antirreglamentarias, o irrazonables, abusivas o arbitrarias, o ajenas a la competencia de la asamblea, o de objeto ilícito o imposible, o contrarias al orden público o a las buenas costumbres, quien no haya asistido o haya votado en contra, y que no la haya consentido expresa o tácitamente, puede pedir su nulidad. También se puede impugnar la decisión tomada fuera de la asamblea si no hubo unanimidad o medió algún vicio.

Se trata, en estos casos, de una nulidad relativa (art. 386), susceptible de confirmación (art. 393). Se aplican las normas sobre nulidad de los actos jurídicos. La demanda debe dirigirse contra el consorcio, no contra los que participaron en la asamblea.

Dispone el artículo 2060, último párrafo, que “El derecho a promover acción judicial de nulidad de la asamblea caduca a los treinta días contados desde la fecha de la asamblea”.

El plazo fijado por el Código parece demasiado breve, si se piensa que algún afectado, en especial si es lego, debe empaparse de la situación, consultar un profesional, o a más de uno, y finalmente tomar la decisión de promover una acción judicial, hecho de relevancia y de importantes efectos.

El plazo se cuenta “desde la fecha de la asamblea”. Esto también es criticable, ya que generalmente los plazos (de prescripción) se cuentan desde que el afectado conoció o pudo conocer el vicio.

h) *Asamblea judicial*

El artículo 2063 del Código dice: "*Asamblea judicial*. Si el administrador o el consejo de propietarios, en subsidio, omiten convocar a la asamblea, los propietarios que representan el diez por ciento del total pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. El juez debe fijar una audiencia a realizarse en su presencia a la que debe convocar a los propietarios. La asamblea judicial puede resolver con mayoría simple de presentes. Si no llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Asimismo, y si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio".

Lo que la justificaría es la falta de convocatoria por parte de quienes deben hacerlo: el administrador o el Consejo de Propietarios.

Pueden pedirle al juez que la convoque si superan el 10%.

La citación a la asamblea la hará el juez. Delante del juez, resuelve la mayoría simple de presentes (mayoría relativa), o en su defecto el juez. No exige que se trate de medidas urgentes, pero se puede inferir que la asamblea judicial debe estar reservada para cuestiones de cierta importancia.

Se aclara expresamente que el juez puede dictar medidas cautelares (v. gr.: designación de un administrador provisorio, suspensión de una obra nueva, etc.).

XIII. Consejo de propietarios

Según el artículo 2064: "La asamblea puede designar un consejo integrado por propietarios, con las siguientes atribuciones:

- "a) convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo;
- "b) controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio;
- "c) autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios;
- "d) ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador, y convocar a la asamblea si el cargo está vacante dentro de los treinta días de producida la vacancia.

"Excepto los casos indicados en este artículo, el consejo de propietarios no sustituye al administrador, ni puede cumplir sus obligaciones".

Es principalmente un órgano que sirve de nexo entre los consorcistas y el administrador; tiene la función de control de las tareas del administrador y el de recomendación y colaboración con el representante legal.

Se trata aquí de uno de los órganos de la persona jurídica consorcio (art. 2044). Se trata de un órgano consultivo y de control. No es obligatorio, lo que sería especialmente incómodo e innecesario en edificios de pocas unidades. El Anteproyecto de la Comisión lo imponía en forma obligatoria, pero afortunadamente eso fue corregido, y queda librado a lo que disponga el reglamento o una asamblea posterior.

Dice el artículo 2064 que lo designa la asamblea, lo que ocurrirá con quórum y mayoría absoluta, o por alguna de las vías alternativas ya examinadas.

El reglamento debe fijar sus facultades (art. 2056, inc. u), de modo que, además de lo previsto en esta norma, puede tener otras atribuciones.

La facultad de convocar a la asamblea es subsidiaria para la hipótesis de que no lo haga el administrador; en cuyo caso redactará también el orden del día. La regla es que no sustituye al administrador, sino que lo supervisa, salvo casos de excepción (omisión, ausencia o vacancia).

En ocasiones, debe autorizarlo, por lo que serían actos complejos y extraordinarios como disponer del fondo de reserva. Esto es un acierto, ya que a veces, durante la vigencia de la ley 13.512, el administrador tomaba la decisión de usar esos fondos, y luego los propietarios se veían sorprendidos y enfrentados a problemas de solvencia. El uso del fondo de reserva por parte del administrador es conveniente que sea controlado.

Si está vacante el cargo de administrador, debe convocar a la asamblea dentro de los 30 días para que se lo designe.

XIV. Administrador

Es de suma importancia, para la viabilidad y funcionamiento del sistema, la figura del administrador, sobre todo en edificios con varias unidades. Es el representante legal del consorcio y su órgano ejecutivo. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o jurídica (art. 2065). A su vez, la administración puede ser unipersonal o colegiada.

a) *Designación, remoción, duración*

Dice el artículo 2066: "*Designación y remoción*. El administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los noventa días de cumplidos los dos años del otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas el cincuenta por ciento de las unidades funcionales, lo que ocurra primero.

"Los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la asamblea, sin que ello importe la reforma del reglamento de propiedad horizontal. Pueden ser removidos sin expresión de causa".

El primer administrador está designado en el reglamento (ver art. 2056, inc. r). Los demás son designados —y también removidos— por la asamblea. El primero cesa si no es ratificado por la primera asamblea.

Generalmente el primer administrador es elegido por quien redacta el reglamento, que puede ser el dueño de todo el inmueble, sus condóminos y en ciertos casos el superficiario (art. 2120). Suele ocurrir que designan a alguien de su confianza, pero que luego es resistido por los propietarios, o no se encuentran enteramente satisfechos. Claro que es difícil removerlo, pues para ello hace falta contar con una mayoría, y porque es posible que se lo haya designado por largo tiempo (v. gr.: 5 o 10 años). Para aliviar la situación, dispone el artículo 2066 que el administrador designado en el reglamento necesita ser ratificado en una asamblea a realizarse dentro de los 90 días, contados desde: 1) cumplidos 2 años de otorgado el reglamento; 2) ocupadas más del 50% de las unidades, lo que ocurra primero.

Se aclara expresamente que la nueva designación no importa la

reforma del reglamento, lo que implica que basta con la mayoría absoluta, en lugar de dos tercios, salvo que en el reglamento se exija una mayoría superior.

El reglamento puede prever la duración del mandato (art. 2056, inc. s), aunque el primero necesita imperiosamente ser ratificado.

Cabe destacar que el Código no menciona, como lo hacía el artículo 9º, inciso b, de la derogada ley 13.512, que su nombramiento deba ser hecho por escritura pública, por lo que entonces basta para acreditar la representación extrajudicial y la legitimación procesal ante propietarios y frente a terceros, con copia certificada del reglamento o del acta de su designación.

Como se desprende del párrafo final del artículo 2067, puede ser removido sin causa. Con mayor razón todavía si hubiera algún motivo para hacerlo.

b) *Derechos y obligaciones*

El administrador tiene los derechos que le otorguen la ley, el reglamento y la asamblea (art. 2067). Así, por ejemplo, percibir una retribución por su tarea, demandar a un consorcista que viole la ley, etcétera.

Entre sus principales obligaciones, de manera sintética, puede decirse que debe administrar el edificio, conservar en buen estado las cosas y partes comunes, ocuparse de las reparaciones, recaudar los fondos necesarios para atender los gastos de funcionamiento, procurar el cese de infracciones a la ley o al reglamento, dirigir al personal de servicio, convocar a las asambleas, rendir cuentas, llevar libros, cumplir y ejecutar lo que resuelva la asamblea, etcétera. Además, teniendo en cuenta que debe velar por la seguridad del inmueble, debe tener presentes las normas locales sobre seguridad e higiene.

El Código, en el artículo 2067, contiene una larga enumeración de obligaciones del administrador. La enumeración no es taxativa ya que dice "en especial, debe".

Dice lo siguiente:

"a) convocar a la asamblea y redactar el orden del día;

"b) ejecutar las decisiones de la asamblea;

- "c) atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las reglamentaciones locales;
- "d) practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas. Para disponer total o parcialmente del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios, el administrador debe requerir la autorización previa del consejo de propietarios;
- "e) rendir cuenta documentada dentro de los sesenta días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal;
- "f) nombrar y despedir al personal del consorcio, con acuerdo de la asamblea convocada al efecto;
- "g) cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y tributaria;
- "h) mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcios que incluya incendio, responsabilidad civil y demás riesgos de práctica, aparte de asegurar otros riesgos que la asamblea resuelva cubrir;
- "i) llevar en legal forma los libros de actas, de administración, de registro de propietarios, de registros de firmas y cualquier otro que exija la reglamentación local. También debe archivar cronológicamente las liquidaciones de expensas, y conservar todos los antecedentes documentales de la constitución del consorcio y de las sucesivas administraciones;
- "j) en caso de renuncia o remoción, dentro de los quince días hábiles debe entregar al consejo de propietarios los activos existentes, libros y documentos del consorcio, y rendir cuentas documentadas;
- "k) notificar a todos los propietarios inmediatamente, y en ningún caso después de las cuarenta y ocho horas hábiles de recibir la comunicación respectiva, la existencia de reclamos administrativos o judiciales que afecten al consorcio;
- "l) a pedido de parte interesada, expedir dentro del plazo de tres

días hábiles el certificado de deudas y de créditos del consorcio por todo concepto con constancia de la existencia de reclamos administrativos o judiciales e información sobre los seguros vigentes;

- "m) representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como mandatario exclusivo con todas las facultades propias de su carácter de representante legal".

Es interesante lo relativo al deber de informar la existencia de juicios. Hasta ahora, no había norma que alertara al adquirente de un bien sujeto a propiedad horizontal sobre la eventual existencia de reclamos judiciales o de otra índole contra el consorcio. Es obvia la consecuencia patrimonial que para aquél puede derivarse al ponerse al cobro la deuda del consorcio, de cuyo riesgo no se le advirtió. El comprador en virtud de una transmisión privada deberá entablar juicio contra su vendedor o contra el enajenante originario para recuperar el gasto que frente al consorcio se vio obligado a realizar.

El inciso e, del artículo 2067 obliga al administrador a rendir cuenta documentada dentro de los sesenta días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento. "En caso de renuncia o remoción, dentro de los quince días hábiles debe entregar al consejo de propietarios los activos existentes, libros y documentos del consorcio, y rendir cuentas documentadas" (art. 2067, inc. j).

Por esa razón, el administrador ingresa en el conjunto de personas que deben rendir cuentas "por disposición legal" (art. 860, inc. c) y no sólo porque actúen en interés ajeno (art. 860, inc. a) y le sean aplicables las normas del mandato.

c) *Representación en juicio*

Durante la vigencia de la ley 13.512 se sostenía que el administrador podía representar al consorcio ante las autoridades administrativas, pero que en lo que respecta a la representación en juicio, sólo estaba legitimado para hacerlo en el juicio de cobro de expensas, despido del personal y para obtener el cese de infracciones a la ley o al reglamento. En los demás casos, debía ser investido especialmente.

El Código ha modificado esta situación en tanto dice el artícu-

lo 2067 que está facultado (y obligado) a "representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como mandatario exclusivo con todas las facultades propias de su carácter de representante legal" (inc. m). Dice "todas las gestiones [...] judiciales", sin distinción de lo que surge del criterio amplio del Código en este aspecto.

Esto es así, ya sea el consorcio actor o demandado. Cabe aclarar que representa al consorcio y no a los propietarios individualmente, de modo que si estos últimos son actores o demandados como titulares del derecho real (v. gr.: juicio de expropiación), no está legitimado el administrador para representarlos, a menos que le confieran un poder para ello.

Además de representar al consorcio en juicio debe informar la existencia del juicio. Prevé el artículo 2067, inciso k, que está obligado a "notificar a todos los propietarios inmediatamente, y en ningún caso después de las cuarenta y ocho horas hábiles de recibir la comunicación respectiva, la existencia de reclamos administrativos o judiciales que afecten al consorcio". El término de 48 h, si bien breve, es apropiado, teniendo en cuenta que los plazos para contestar una demanda son perentorios. Incluso, en ciertas cuestiones, sería aconsejable que consulte a la asamblea sobre los pasos a seguir.

Por lo demás, como era antes, puede y debe el administrador actuar ante las autoridades administrativas. Así, por ejemplo, para gestiones ante la autoridad impositiva, previsional, etcétera. También, obviamente, puede actuar ante entidades o personas privadas.

Por excepción se ha admitido que frente a la inexistencia de administrador debidamente designado y la imposibilidad de hecho de representar al consorcio en el juicio, es posible que la mayoría reglamentaria de los integrantes del consorcio se presente por su propio derecho a contestar demanda con el patrocinio de un letrado designado en asamblea extraordinaria por unanimidad.

d) Responsabilidad de los administradores

"Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión" (art. 160).

XV. Subconsorcios

Durante la vigencia de la ley 13.512 algunos edificios se dividían en distintos sectores, con su propio régimen de administración y asambleas; pero esto no era legal, la ley sólo admitía un único consorcio. Semejante división funcionaba de hecho, pero podía traer problemas diversos, especialmente si había varios administradores y distintas asambleas por sector. Ahora es diferente, pues el Código expresamente admite y regula la situación.

Dispone el artículo 2068 lo siguiente: "*Sectores con independencia*. En edificios cuya estructura o naturaleza lo haga conveniente, el reglamento de propiedad horizontal puede prever la existencia de sectores con independencia funcional o administrativa, en todo aquello que no gravita sobre el edificio en general.

"Cada sector puede tener una subasamblea, cuyo funcionamiento y atribuciones deben regularse especialmente y puede designarse a un subadministrador del sector. En caso de conflicto entre los diversos sectores la asamblea resuelve en definitiva.

"Frente a terceros responde todo el consorcio sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran".

Puede haber sectores independientes con sus asambleas, subadministradores. Debe estar previsto en el reglamento, aunque el artículo 2056, que se refiere al reglamento, no dice nada sobre esto; es sólo para edificios con estructuras especiales (v. gr.: torres separadas).

La división no opera frente a terceros. Frente a terceros responde el consorcio general.

Esta norma permite la existencia de subconsorcios dentro de una propiedad horizontal, es decir, sectores interdependientes que se administren y hasta puedan tener un subadministrador, realizando subasambleas. En la actualidad hay reglamentos que suelen establecer asambleas en primer grado para la designación de delegados para una asamblea general para la designación del administrador general como para tratar asuntos generales. También el sistema puede funcionar con una asamblea general con el quórum que se fije en el reglamento. Otra característica radica en la interdependencia económico-financiera que el Código prevé, la necesidad de realizar balances consolidados de

carácter general colocando el estado patrimonial y de resultado de cada uno de los subconsorcios.

De acuerdo a la redacción del artículo 2068 cabe interpretar que el administrador será uno solo para todo el inmueble. Lo que prevé dicha norma son "subadministradores" distintos. Cabe inferir que reportarán a un administrador principal, el administrador del consorcio que integran. Sería entonces una suerte de administración con cuentas de gestión separadas, los diversos sectores del consorcio tendrían contabilidades de gastos comunes en cuentas de gestión separadas y soportaría particularmente cada sector sus propios gastos. De esta forma, cada sector del consorcio podrá decidir y resolver sobre sus gastos y soportarlos pero bajo una misma administración y sin división alguna del consorcio.

Tales subadministradores no son representantes legales del consorcio; se trata sólo de una división interna de funciones. Como aclara el artículo 2068, la división no produce efectos frente a terceros, por lo que el administrador sigue siendo el representante legal.

XVI. Prehorizontalidad

Hace muchos años se dictó la ley 19.724, de prehorizontalidad, con la finalidad de proteger a los adquirentes de unidades aún no construidas. Ello se debió a que en una época algunos adquirentes vieron frustrados sus derechos, ya sea por estafas, ventas de la misma unidad a diferentes personas, quiebra de la vendedora, etcétera. Dicha ley, si bien no solucionó todos los problemas, fue sin duda un avance en la búsqueda de mayor seguridad. Uno de sus mayores logros fue la inscripción registral de los boletos de compraventa.

Lo cierto es que esta ley ha caído en desuso. En los últimos años se construyeron muchos edificios en las principales ciudades del país, pero muy pocos se ajustaron a ese régimen. También su aplicación generó inconvenientes.

Por tal motivo, se ideó un sistema de seguro obligatorio a favor del adquirente, que lo cubra ante el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido, por cualquier razón.

El Código Civil y Comercial prevé un seguro obligatorio en los si-

guientes términos: "Para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal, el titular del dominio del inmueble debe constituir un seguro a favor del adquirente, para el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por cualquier razón, y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas abonadas con más un interés retributivo o, en su caso, la liberación de todos los gravámenes que el adquirente no asume en el contrato preliminar.

"El incumplimiento de la obligación impuesta en este artículo priva al titular del dominio de todo derecho contra el adquirente a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones, pero no priva al adquirente de sus derechos contra el enajenante" (art. 2071).

Los contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal están alcanzados: "Los contratos sobre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad horizontal están incluidos en las disposiciones de este Capítulo" (art. 2070).

Por su parte, el artículo 2072 menciona qué contratos no están alcanzados por este sistema: "Están excluidos los contratos siguientes:

- "a) aquellos en los que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la partición o liquidación de comuniones de cosas o bienes, o de la liquidación de personas jurídicas;
- "b) los que versan sobre inmuebles del dominio privado del Estado;
- "c) los concernientes a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso de organismos oficiales o de entidades financieras especialmente calificadas por el organismo de control, si de sus cláusulas resulta que los contratos definitivos con los adquirentes deben ser celebrados por el ente financiador o fiduciario, a quien los propietarios deben otorgarle poder irrevocable a ese fin".

CAPÍTULO XIII

CONJUNTOS INMOBILIARIOS

MNR

SUMARIO: I. Introducción. II. Concepto y caracteres. III. Marco legal. Derechos reales. IV. Cosas y partes necesariamente comunes. V. Cosas y partes privativas. VI. Facultades y obligaciones del propietario. VII. Protección al consumidor.

I. Introducción

Desde hace muchos años una gran cantidad de personas optó por adquirir un derecho en los llamados clubes de campo o *country*. Las razones son variadas: esparcimiento, seguridad, disfrute de la naturaleza fuera del cemento de las grandes ciudades, mayor espacio y comodidades, aprovechamiento de instalaciones deportivas, sociabilidad, estatus, moda, etcétera. Algunas personas optaron para utilizar tales espacios los fines de semana, y otras por asentar definitivamente su vivienda. Además de los clubes de campo, hay variantes tales como barrios cerrados, barrios privados, clubes náuticos, etcétera. Todas ellas entran en la categoría de "conjuntos inmobiliarios".

Los primeros clubes de campo y barrios cerrados aparecen en nuestro país hacia 1930 en la Provincia de Buenos Aires. La primera norma específica sobre esta materia en el ámbito del Derecho Público fue el decreto 2489/63. Siguieron la ley 8912 (año 1977), decretos 9404/86 para clubes de campo y 27/98 para barrios cerrados, todos de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el punto de vista jurídico, hace tiempo la doctrina debate sobre cómo encasillar a esta figura y otras semejantes. A falta de previsión legal, ya que el Código Civil de 1871 y la ley 13.512 nada preveían sobre el punto, la doctrina se dividió en dos sectores. Para la gran mayoría, y así ocurrió en la práctica, se trataba de un derecho

personal, lo cual no suscitaba grandes problemas ya que en ese ámbito rige la autonomía de la voluntad. Otra parte de la doctrina postuló la necesidad de adecuar la figura al campo de los derechos reales. Dentro de este grupo, algunos veían posible la utilización de la Ley de Propiedad Horizontal, o del condominio y las servidumbres, mientras que otros reclamaban el dictado de una regulación especial.

En la Provincia de Buenos Aires y en algunas otras que la han seguido se permitió la solución del problema mediante la aplicación del régimen anterior de la Ley de Propiedad Horizontal. En efecto, allí el decreto 2489/63, en consonancia con el artículo 1° del decreto 18.734/49, reglamentario de la derogada ley nacional 13.512, autorizó la inscripción en el Registro de la Propiedad de los títulos de constitución, transferencia, modificación o extinción de derechos reales, si las partes exclusivas, unidades a construir o en construcción, constituyen cuerpos independientes de edificación o si las unidades de dominio exclusivo sin independencia tienen concluidos los servicios y cumplen ciertos requisitos. El artículo 7° de dicho decreto dispone que a medida que se habiliten las unidades, previa ratificación del plano de división, se solicitará al registro la actualización del legajo especial, lo que se puede realizar por escritura de obra nueva. "Si al ratificar el plano de división las medidas lineales y de superficie de las unidades de dominio exclusivo difieren de las tolerancias en vigencia, deberá procederse a modificar el reglamento de copropiedad y administración y las escrituras de adjudicación correspondientes. El plano de subdivisión debe reflejar que hay unidades construidas, a construir o en construcción, y ser aprobado por Catastro en el carácter de definitivo para las primeras y de proyecto para las segundas y terceras. El plano así aprobado autoriza para dictar el reglamento que refleja la existencia de unidades proyectadas". Este decreto 2489/63 de la Provincia de Buenos Aires, y la interpretación que se le dio al mismo, permitió la comercialización de porciones (o subdivisiones) de terrenos baldíos como futuras unidades funcionales, al tratarse de unidades de propiedad exclusiva que constituyen cuerpos independientes de edificación, ya que en cada terreno se construirá una casa totalmente separada y diferente de la del vecino.

En Mendoza se regularon los barrios privados, las "urbanizaciones

especiales" o "conjuntos inmobiliarios" de las siguientes tres formas: a) dominio sobre lotes y calles de dominio público; b) dominio sobre lotes y accesos en condominio de indivisión forzosa, y c) fraccionamientos rurales, donde sobre los accesos los adquirentes sólo tienen una servidumbre de paso o condominio de indivisión forzosa.

En la práctica, la falencia de la inexistencia de un consorcio que nucleee obligatoriamente a todos los copropietarios, con capacidad suficiente para llevar adelante el objeto de mantenimiento, conservación y administración de la urbanización, en algunos casos se ha suplido con la creación de una persona jurídica encargada de la administración del complejo, debiendo revestir los adquirentes de los lotes, en forma ineludible, la calidad de accionistas o socios de la misma, para poder ser titular dominial. Generalmente se acude a diversas formas societarias, que varían según la decisión de cada emprendedor, siendo las más usadas las sociedades anónimas (sin fines de lucro), y las simples asociaciones.

Por las observaciones que tuvo la aplicación del encuadre de la propiedad horizontal, la Provincia de Buenos Aires dictó el decreto 9404/86 (reglamentario de la ley 8912 -de ordenamiento territorial y uso de suelo-), que organiza un sector residencial (derecho de dominio para cada parcela) y un área recreativa, deportiva, social y común (dominio en cabeza de una entidad jurídica, en la que participan todos los titulares del sector residencial y que es la administradora del complejo). Se establece la necesidad de constituir servidumbre real sobre los inmuebles que sirven como áreas comunes a favor de cada una y de todas las parcelas residenciales, para lograr el cumplimiento propuesto en el referido decreto y en la ley provincial 8912/77 (capítulo *Clubes de campo*), conformando un conjunto funcional y jurídico inescindible. La aplicación de la propiedad horizontal y del decreto 9404/86 sufrió observaciones doctrinarias y algunas jurisprudenciales.

En concreto, hasta la sanción del Código Civil y Comercial, no había ley nacional para las modernas urbanizaciones, que ya son muy numerosas en todo el país. El actual Código termina con las discusiones ya que crea un nuevo derecho real, denominado "conjuntos inmobiliarios" (art. 1887, inc. d) e instaura para estos emprendimientos el régimen del derecho real de propiedad horizontal, lo que se muestra muy conveniente, como lo había sugerido parte de la doctrina.

Se trata de un derecho real sobre cosa propia (art. 1888), principal (art. 1889), sobre cosa registrable (art. 1890) y que se ejerce por la posesión (art. 1891). Si bien es un derecho real autónomo, es a la vez una especie o modalidad del derecho de propiedad horizontal (art. 2075).

Se puede adquirir por actos entre vivos, cumpliendo con los recaudos de título suficiente y tradición, por causa de muerte, y por prescripción adquisitiva (larga o breve). Dado que el objeto es un inmueble, la adquisición, transmisión o extinción requiere de la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble para que el acto sea oponible a terceros interesados de buena fe.

II. Concepto y caracteres

a) *Concepto*

Dice el Código que "Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales" (art. 2073).

La enumeración no es taxativa, puede haber otros emprendimientos, además de los mencionados, que son los más usuales.

La característica típica y común denominador de estos complejos, especialmente cuando se trata de clubes de campo o barrios, es la conformación de emprendimientos integrados por áreas con destino residencial, áreas para brindar recreación y deportes en contacto con la naturaleza, y áreas de servicios comunes para atender el conjunto. Estos sectores diferenciados deben conformar funcional y jurídicamente un todo inescindible, en forma tal que los derechos sobre la propiedad residencial no puedan ser enajenados independientemente de las áreas recreativas comunitarias. Del mismo modo, las áreas recreativas no podrían ser objeto de disposición jurídica independientemente de las áreas residenciales a las que prestan utilidad.

a.1) *Variantes*

Se dice que el "barrio privado" es el género de todos estos emprendimientos. Suele ser cerrado si está delimitado perimetralmente, no por un muro, sino por otro medio transparente, cercos, forestación, alambrados, etcétera. Otra variante es el "club de chacras", cuya extensión es mucho mayor que la del club de campo y tiene menor urbanización; es más campestre. Los clubes náuticos se caracterizan por contener un espejo de agua natural o artificial, o estar cerca de cursos de agua, con amarradero y destinados a deportes náuticos. Algunos cuentan con viviendas, otros sólo sirven para guardar la embarcación (camas náuticas).

b) *Caracteres*

Agrega el Código que "Son elementos característicos de estas urbanizaciones, los siguientes: cerramiento, partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, reglamento por el que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos particulares y régimen disciplinario, obligación de contribuir con los gastos y cargas comunes y entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las unidades privativas. Las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible" (art. 2074).

Pueden señalarse entonces los caracteres principales:

- 1) Existencia de una pluralidad de partes de un inmueble (lotes), con vocación de pertenecer a una multiplicidad de titulares en forma exclusiva, conectados entre sí a través de elementos, bienes y/o servicios comunes, y/o de un régimen de limitaciones y deberes entre los mismos; para la consecución y aseguramiento de los intereses comunes y particulares de los partícipes;
- 2) cerramiento, que puede ser a través de forestación u otras modalidades (cercos, alambrados, etc.). En la Provincia de Buenos Aires, el artículo 3°, inciso e, del decreto 27/98, para los barrios cerrados, dice que "El cerramiento del perímetro deberá ser transparente y tratado de manera que no conforme para el en-

torno un hecho inseguro, quedando expresamente prohibida su ejecución mediante muro aun en condiciones de retiro respecto de la línea municipal".

- 3) inescindible relación entre los sectores privativos y los comunes;
- 4) indivisión forzosa perpetua de las partes comunes;
- 5) reglamento que regula la vida del conjunto: órganos de funcionamiento, restricciones, régimen disciplinario;
- 6) existencia de una administración;
- 7) expensas comunes por los gastos de mantenimiento y conservación del complejo;
- 8) entidad jurídica que agrupe a los propietarios, en el caso el consorcio;
- 9) independencia de la causa generadora o su destino: "residenciales", "turísticos", "agrarios", "comerciales", "industriales", etcétera.

III. Marco legal. Derechos reales

a) Orden público

"...Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el Título V de este Libro, con las modificaciones que establece el presente Título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial.

"Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real" (art. 2075).

El Código: 1) impone que se regulen como derechos reales, incluso los preexistentes; 2) adopta en forma imperativa el régimen del derecho real de propiedad horizontal, con variantes; 3) se trata de legislación nacional, aplicable en todo el territorio.

Las ventajas prácticas que reporta la aplicación del régimen de propiedad horizontal son:

1. Concepto de "Unidad Funcional": sobre la que se tiene un de-

- recho exclusivo y perpetuo de uso, goce y disposición; al que se le suma un derecho de copropiedad de indivisión forzosa perpetua (porcentaje indiviso) sobre las partes de uso común;
2. inescindibilidad entre lo privativo y lo común;
3. copropiedad de indivisión forzosa *sine die* sobre las partes comunes. La nómina de partes o sectores comunes es, evidentemente, distinta a la de un edificio, ya que no se trata de muros, ascensores, etcétera, sino de piscina, canchas de polo, *club house*, etcétera;
4. asegura el destino de las áreas comunes, que no podrá ser alterado;
5. crea un consorcio, con capacidad suficiente para administrar el complejo y representación;
6. reglamento equitativo de derechos u obligaciones de los consorcionistas;
7. oponibilidad del reglamento. Integra el título de los adquirentes;
8. la necesidad de asambleas y mayorías torna al sistema más democrático y participativo;
9. crédito por expensas comunes, transmisible a sucesores, privilegiado y con carácter de título ejecutivo para su cobro.

b) Situación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes

El problema se suscita con los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubieren constituido con moldes jurídicos diferentes. Será harto complejo y costoso adaptar clubes de campo constituidos como parcelas de dominio exclusivo, complementado con servidumbres prediales sobre espacios pertenecientes a una persona jurídica, generalmente una sociedad anónima. Así fueron organizados muchos conjuntos inmobiliarios en la Provincia de Buenos Aires (art. 1º, dec. 9404/86). Aquí también se han impuesto restricciones a la transmisión de acciones, como modo de encubrir el derecho de admisión, muchas veces ejercido de modo arbitrario.

Igual dificultad se presentará con aquellos integrados por parcelas de dominio privado y calles del dominio público. Aquí será menester

que la provincia de que se trate desafecte tales calles del dominio público, entre otros problemas a resolver.

Se considera inconstitucional la obligación de someter en forma compulsiva al régimen de propiedad horizontal a los emprendimientos ya constituidos bajo otra forma con anterioridad a la vigencia del Código.

c) *Normas administrativas*

Dispone el Código que "Todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción..." (art. 2075).

d) *Localización y límites perimetrales*

Siguiendo el criterio expuesto en el punto anterior, agrega el Código que "La localización de los conjuntos inmobiliarios depende de lo que dispongan las normas provinciales y municipales aplicables.

"Los límites perimetrales de los conjuntos inmobiliarios y el control de acceso pueden materializarse mediante cerramientos en la forma en que las reglamentaciones locales, provinciales o municipales establecen, en función de aspectos urbanísticos y de seguridad" (art. 2079).

En lo que hace a la ubicación, es claro que no es lo mismo autorizar en determinada zona residencial un club de campo que un parque industrial. El Estado local, por razones de higiene, urbanismo, estética, salud, protección del medio ambiente, seguridad, etcétera, se encuentra facultado para determinar en qué zonas pueden ser ubicados los distintos tipos de conjuntos inmobiliarios. Se trata de cuestiones atinentes al Derecho Público provincial y municipal.

Además, hay que tener en cuenta a la ley nacional 25.675, que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente.

En cuanto al *cerramiento*, ello también queda sujeto al control del poder administrador local, como sucede respecto de cualquier propiedad privada. Este tema se vincula, a su vez, como señala la norma, con el control de acceso.

e) *El uso de las calles públicas*

El artículo 3º, inciso g, del decreto 27/98 plantea como condicionante para la instalación de un barrio cerrado que debe garantizarse el uso de las calles públicas; de conformidad con lo previsto por los artículos 50 y 51 del decreto-ley 8912/77 —relativos a la subdivisión del suelo—, el artículo 1º del decreto-ley 9533/80 y el artículo 27 del decreto-ley 6769/58.

En lo que aquí interesa, el inciso g, del artículo 3º advierte que en todo supuesto, deberán respetarse y no podrán ocuparse por edificaciones, las proyecciones de avenidas y otras vías principales (y los retiros de líneas de edificación vigentes).

f) *Objeto del derecho real*

El objeto del derecho real no es el conjunto inmobiliario, sino sus sectores o partes de uso privativo (unidad funcional) y común que se transfieran en propiedad al adquirente. La relación entre partes privativas y comunes es indisoluble.

IV. Cosas y partes necesariamente comunes

Dice el Código que "Son necesariamente comunes o de uso común las partes y lugares del terreno destinadas a vías de circulación, acceso y comunicación, áreas específicas destinadas al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y sociales, instalaciones y servicios comunes, y todo otro bien afectado al uso comunitario, calificado como tal por el respectivo reglamento de propiedad horizontal que regula el emprendimiento.

"Las cosas y partes cuyo carácter de comunes o propias no esté determinado se consideran comunes" (art. 2076).

También son partes y cosas comunes las enumeradas en forma no taxativa por los artículos 2041 y 2042, en tanto sean compatibles (v. gr.: cañerías, locales destinados a sanitarios, piscina, etc.). El artículo 2076 destaca las más usuales en este tipo de conjuntos inmobiliarios, como las vías de circulación, áreas deportivas, entre otras. La enumeración tampoco es taxativa.

Las partes comunes, si lo prevé el reglamento, podrían estar afectadas al uso de algunas unidades, no de todas (art. 2040).

De acuerdo al texto del artículo 2076 el terreno o lote que constituye la unidad funcional, esto es, donde seguramente se construirá una casa u otro espacio, no es común sino propio. Aquí hay una excepción a lo previsto en el artículo 2041, inciso a, para la propiedad horizontal en general, ya que no todo el terreno de los conjuntos inmobiliarios reviste el carácter de común.

a) *Servidumbres y otros derechos reales*

Las partes comunes podrán en determinadas circunstancias ser gravadas con derechos reales, especialmente el de servidumbre. Dice el Código que "Con arreglo a lo que dispongan las normas administrativas aplicables, pueden establecerse servidumbres u otros derechos reales de los conjuntos inmobiliarios entre sí o con terceros conjuntos, a fin de permitir un mejor aprovechamiento de los espacios e instalaciones comunes. Estas decisiones conforman modificación del reglamento y deben decidirse con la mayoría propia de tal reforma, según la prevea el reglamento" (art. 2084).

Así, por ejemplo, podría constituirse una servidumbre de un conjunto inmobiliario en favor de otro vecino —terceros los llama el artículo—, como la de paso, desagüe, o la de sacar agua.

En cuanto a la mayoría necesaria, no se muestra muy feliz la redacción de la última parte del artículo 2084. Cabe inferir que debe ser la unanimidad, teniendo en cuenta que se trata de un acto de disposición de cosas o partes que pertenecen a todos. No es entonces la mayoría que prevea el reglamento, ya que no cabe otra que la mencionada, asamblea mediante, a menos que en el acto de adquisición los interesados hayan anticipado su conformidad.

Cuando el artículo 2084 dice que "pueden establecerse servidumbres u otros derechos reales de los conjuntos inmobiliarios entre sí", parece referirse a servidumbres entre unidades funcionales, de una a la otra. Esto no suscita ningún inconveniente ni es necesario que se modifique el reglamento, como prevé la norma, salvo que el reglamento lo prohíba. La modificación del reglamento tiene sentido cuando se trata de servidumbres entre conjuntos inmobiliarios autónomos, distintos.

b) *Uso y goce de las cosas y partes comunes*

MNR

En lo que respecta al uso y goce de las partes comunes, las reglas son similares a las señaladas respecto del derecho de propiedad horizontal. Es probable que tal uso se encuentre reglamentado. Así, por ejemplo, se suele prever que hay que anotarse para el uso de la parrilla, el quincho, la cancha de tenis, etcétera.

Algunos clubes de campo constituyen un régimen contributivo para el uso de las partes deportivas, donde el propietario y su familia se obligan a pagar una cuota para tal fin.

Tal uso y goce se extiende, en principio, al grupo familiar (art. 2083), especialmente si conviven con el titular. El reglamento puede limitar esta situación pero con mucho cuidado, ya que sería absurdo que, por ejemplo, pueda asistir a la piscina un cónyuge sin el otro, o con un hijo pero no con todos.

c) *Régimen de invitados*

Obviamente, no pueden estar en la misma situación los propietarios que quienes no lo sean, aun cuando sean invitados por los titulares. Si cada propietario invita sin limitación a varias personas, puede ocurrir que el uso de los sectores comunes colapse, y se terminaría desnaturalizando el sistema. Es común que los reglamentos limiten la cantidad de invitados, que ello varíe según se trate de un día de semana o de un feriado, que se cobre un canon por la admisión, etcétera.

Por tal motivo, el Código prevé lo siguiente: "El reglamento puede establecer la extensión del uso y goce de los espacios e instalaciones comunes a aquellas personas que integran el grupo familiar del propietario de la unidad funcional y prever un régimen de invitados y admisión de usuarios no propietarios de dichos bienes, con las características y bajo las condiciones que, a tal efecto, dicte el consorcio de propietarios.

"El uso de los bienes comunes del complejo por terceras personas puede ser pleno, parcial o limitado, temporario o permanente, es siempre personal y no susceptible de cesión ni transmisión total o parcial, permanente o transitoria, por actos entre vivos ni mortis causa. Los

no propietarios quedan obligados al pago de las contribuciones y aranceles que a tal efecto determine la normativa interna del conjunto inmobiliario" (art. 2083).

La norma agrupa dos casos diferentes: 1) la cesión del uso y goce por un tiempo (v. gr.: contrato de locación o de comodato); 2) los invitados, cuya situación es mucho más precaria, y naturalmente más restringida para evitar el colapso o la incomodidad de los restantes propietarios.

En ambos casos, el reglamento puede prever restricciones, así como el cobro de aranceles, en tanto sean razonables.

Dispone el artículo 2083 que dicho uso por terceros "es siempre personal y no susceptible de cesión ni transmisión total o parcial, permanente o transitoria, por actos entre vivos ni mortis causa". Por ende, ni aquellos que tengan un derecho personal al uso y goce de los bienes comunes, ni los familiares o invitados, pueden a la vez ceder tal posición a otros, ni por contrato ni mortis causa.

El propietario sigue siendo responsable ante el consorcio por los actos y/o hechos de sus usuarios, familiares o invitados.

V. Cosas y partes privativas

Tal como sucede en el régimen de propiedad horizontal, en los conjuntos inmobiliarios también el derecho recae principalmente sobre lo que es privativo. Dice el Código que "La unidad funcional que constituye parte privativa puede hallarse construida o en proceso de construcción, y debe reunir los requisitos de independencia funcional según su destino y salida a la vía pública por vía directa o indirecta" (art. 2077).

Lo destacable es que puede constituirse el sistema aun cuando la unidad funcional se encuentre "en proceso de construcción". Es común que los interesados adquieran lotes de terreno, para luego construir allí una casa, especialmente si se trata de un club de campo o barrio privado.

Aun cuando las unidades se hallen en proceso de construcción, para que se otorguen las autorizaciones necesarias para luego inscribir los actos registralmente, será menester que se encuentre concluida la red de circulación interna indispensable para la salida a la vía pública.

VI. Facultades y obligaciones del propietario

a) *Facultades*

El Código dispone que "Cada propietario debe ejercer su derecho dentro del marco establecido en la presente normativa, con los límites y restricciones que surgen del respectivo reglamento de propiedad horizontal del conjunto inmobiliario, y teniendo en miras el mantenimiento de una buena y normal convivencia y la protección de valores paisajísticos, arquitectónicos y ecológicos" (art. 2078).

La regla siempre es la misma, el propietario puede usar y gozar de las partes propias y de las comunes conforme a su destino, y respetando el derecho igual que tienen los demás titulares. El reglamento puede establecer diversas restricciones, algunas vinculadas al destino (v. gr.: vivienda), como edificaciones referentes a la altura máxima de los edificios, los materiales que se deben usar, la prohibición de construcciones prefabricadas, factor de ocupación del lote, retiros, velocidades máximas para los automotores, cuatriciclos o bicicletas, entre otras. También estos reglamentos pueden incluir normas de convivencia, sobre todo en los emprendimientos de gran tamaño por la gran cantidad de propietarios que en ellos conviven.

También estas reglamentaciones suelen prever obligaciones, como la ejecución de tareas de mantenimiento y conservación de esas edificaciones, el parqueizado y cuidado de jardines, no estacionar el automóvil en determinadas zonas, etcétera. Como dice la norma, también procurarán "la protección de valores paisajísticos, arquitectónicos y ecológicos".

Además, rigen las obligaciones y prohibiciones previstas en los artículos 2046 y 2047 para la propiedad horizontal.

a.1) *Transmisión del derecho*

El derecho que tiene cada propietario sobre su unidad funcional y, consecuentemente, su cuota sobre las partes comunes inseparables, es transmisible. Se trata de un derecho real sobre cosa propia que puede ser enajenado, gravado con derechos reales e, incluso, abandonado.

Además, por regla, los derechos reales son transmisibles (art. 1906) y el de propiedad horizontal no escapa a dicho carácter (art. 2045).

Dice el Código que "El reglamento de propiedad horizontal puede prever limitaciones pero no impedir la libre transmisión y consiguiente adquisición de unidades funcionales dentro del conjunto inmobiliario, pudiendo establecer un derecho de preferencia en la adquisición a favor del consorcio de propietarios o del resto de propietarios de las unidades privativas" (art. 2085).

Se prohíbe la cláusula de no enajenar en armonía con la regla general prevista en el artículo 1972, pero se permite establecer cierta limitación a la transmisibilidad del derecho de propiedad. En esta línea, es posible prohibir la transmisión a persona determinada (art. 1972, primer párrafo).

Además, el artículo 2085 permite ciertas restricciones en el reglamento, las que deben ser razonables. Tales limitaciones conciernen al derecho de preferencia que se puede establecer en favor del consorcio o del resto de los propietarios. Esta norma es muy importante ya que, aunque no fue su intención, deja en claro que el consorcio puede ser titular de unidades funcionales.

No es admisible que establezca en el reglamento un derecho de admisión que actúe de manera discriminatoria. En varias oportunidades la jurisprudencia ha intervenido ante situaciones arbitrarias, como la de no permitir el ingreso de una nueva cónyuge o situaciones semejantes.

Al adoptar el Código el régimen de propiedad horizontal, el derecho de admisión liso y llano resulta incompatible.

No obstante, el Código le ofrece al consorcio o a los restantes titulares contar con un derecho de preferencia en la adquisición.

El propietario deberá comunicar por medio fehaciente al consorcio y a los demás propietarios su decisión de disponer de su unidad, para que éstos hagan valer, o no, la preferencia prevista en el reglamento.

a.2) *Cesión del uso y goce de la unidad*

Como se dijo, el titular de la unidad funcional puede enajenarla, abandonarla, gravarla con derechos reales, esto es, realizar actos de

disposición. También, como es lógico, puede realizar actos de administración, otorgando si lo desea derechos personales en favor de terceros. Puede ceder el uso y goce ya sea a través de un derecho real (usufructo), o de uno personal (v. gr.: locación).

Esta facultad puede encontrar algunos límites en el reglamento. Dice el Código que "El reglamento del conjunto inmobiliario puede establecer condiciones y pautas para el ejercicio del derecho de uso y goce de los espacios e instalaciones comunes por parte de terceros en los casos en que los titulares del dominio de las unidades particulares ceden temporariamente, en forma total o parcial, por cualquier título o derecho, real o personal, el uso y goce de su unidad funcional" (art. 2082). Además, el artículo 2131 legitima para constituir usufructo al titular del derecho de propiedad horizontal.

La cesión temporaria de la unidad, a través de la locación, del comodato, o cualquier otra modalidad no puede, en principio, impedirse. Pero pueden establecerse condiciones para que en el caso de transmisión temporaria el tenedor o poseedor pueda usar de las cosas comunes, especialmente las recreativas.

a.3) *Otros derechos reales*

Los titulares de las unidades funcionales las pueden gravar con hipoteca (art. 2206). Aunque es raro, podría en algún caso admitirse la anticresis (art. 2213).

b) *Obligaciones*

En los conjuntos inmobiliarios existen las mismas obligaciones que en la propiedad horizontal. Así, por ejemplo, cumplir con el reglamento de propiedad horizontal y con los reglamentos internos, mantener en buen estado la unidad funcional, integrar el fondo de reserva, permitir el acceso si hay que realizar reparaciones en partes comunes, entre las más importantes (ver art. 2046).

También los titulares están sometidos a las prohibiciones previstas para la propiedad horizontal (v. gr.: respetar el destino, no perturbar la tranquilidad de los demás, etc. —ver art. 2047—).

Además de las obligaciones y prohibiciones mencionadas, la ley

(Código, leyes, ordenanzas, etc.) y el reglamento pueden prever otras, de acuerdo a la índole del conjunto inmobiliario en cuestión. El artículo 2075 alude a "las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción". Además, como surge del artículo 2078, deben respetarse los "valores paisajísticos, arquitectónicos y ecológicos".

b.1) *Expensas*

Una obligación esencial que existe en el régimen de propiedad horizontal, y que se traslada a los conjuntos inmobiliarios, es la de soportar los gastos de mantenimiento.

Agrega el Código que "Los propietarios están obligados a pagar las expensas, gastos y erogaciones comunes para el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto inmobiliario en la proporción que a tal efecto establece el reglamento de propiedad horizontal. Dicho reglamento puede determinar otras contribuciones distintas a las expensas legalmente previstas, en caso de utilización de ventajas, servicios e instalaciones comunes por familiares e invitados de los titulares" (art. 2081).

El Código no distingue según la unidad se halla construida o en construcción. Por ende, salvo que el reglamento prevea algo diferente, cabe inferir que los propietarios deben pagar las expensas en la proporción prevista en el reglamento aun cuando el lote esté vacío o la unidad en proceso de construcción. Donde la ley no distingue, no cabe distinguir. Además, si no fuera así, la situación podría ser inmanejable, ya que algunos titulares podrían demorar la construcción de la unidad para no pagar expensas.

Como surge de la última parte del artículo 2081, el reglamento puede incorporar en el concepto de expensas otras contribuciones, tales como —por ejemplo— el uso de la cancha de tenis, la piscina, el acceso de invitados, etcétera. Como se dijo anteriormente, todo esto debe ser razonable. También puede prever multas (art. 2086) por infracciones al reglamento, que deberán ser satisfechas mediante el pago de las expensas.

El certificado de deuda expedido por el administrador, y aprobado

en su caso por el consejo de propietarios si éste existe, es título ejecutivo para el cobro de estas contribuciones (art. 2048, último párrafo).

Los obligados al pago de las expensas son, además del propietario, los poseedores por cualquier título (art. 2050).

c) *Limitaciones y restricciones reglamentarias*

En los conjuntos inmobiliarios puede haber limitaciones y restricciones especiales en normas administrativas (leyes, decretos, ordenanzas municipales), que el reglamento de propiedad horizontal debe contemplar. Además, éste puede imponer o agregar otras. El reglamento integra el título de adquisición.

Dispone el Código que "De acuerdo a las normas administrativas aplicables, el reglamento de propiedad horizontal puede establecer limitaciones edilicias o de otra índole, crear servidumbres y restricciones a los dominios particulares, como así también fijar reglas de convivencia, todo ello en miras al beneficio de la comunidad urbanística. Toda limitación o restricción establecida por el reglamento debe ser transcrita en las escrituras traslativas del derecho real de propiedad horizontal especial. Dicho reglamento se considera parte integrante de los títulos de propiedad que se otorgan sobre las unidades funcionales que componen el conjunto inmobiliario, y se presume conocido por todo propietario sin admitir prueba en contrario" (art. 2080).

Las restricciones, según surge de la norma, deben apuntar al beneficio común. Generalmente son edilicias, aunque también pueden ser de otra índole. Asimismo deben apuntar a una mejor convivencia.

d) *Sanciones*

Es común en los conjuntos inmobiliarios, especialmente en aquellos que cuentan con muchas unidades, que el reglamento prevea sanciones para determinadas conductas. Generalmente se trata de apercibimientos, multas, aunque pueden preverse otras tales como la prohibición de uso de un espacio común por cierto tiempo (suspensión). La decisión suele estar a cargo de una comisión u órgano disciplinario, integrado por propietarios.

La facultad disciplinaria no es absoluta, pues no podría incluir

sanciones que impliquen la suspensión *definitiva* en el uso y goce de las áreas comunes (cuya titularidad poseen todos los propietarios) o la prohibición de acceso al conjunto inmobiliario.

Dispone el Código que "Ante conductas graves o reiteradas de los titulares de las unidades funcionales violatorias del reglamento de propiedad horizontal, el consorcio de propietarios puede aplicar las sanciones previstas en ese instrumento" (art. 2086). A su vez, aclara el artículo 2074 que una de las características de los conjuntos inmobiliarios es el "régimen disciplinario". Las infracciones que pueden ser materia de juzgamiento no son delitos, se trata del incumplimiento de obligaciones contractualmente asumidas.

Debe tratarse de conductas "graves o reiteradas". Así, por ejemplo, circular con un vehículo a excesiva velocidad por las vías internas, poniendo en riesgo la vida o la salud de los demás o realizar en público exhibiciones obscenas.

Un tema que ha generado controversias es la publicación de la lista de morosos respecto del pago de las expensas, especialmente cuando tal difusión no está autorizada por el reglamento ni por una decisión de la asamblea.

VII. Protección al consumidor

Respecto del tiempo compartido y los cementerios privados, el Código consagra expresamente, en sendos artículos, la aplicación de las normas tuitivas que regulan la relación de consumo "previstas en este Código y en las leyes especiales" (arts. 2100 y 2111). En cambio, no hay referencia alguna respecto de los conjuntos inmobiliarios, por lo que surge la duda acerca del espíritu del Código sobre el punto.

No obstante el silencio del Código, debe aplicarse también en este ámbito el régimen protector del consumidor ya que se mantiene el criterio de considerar consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

CAPÍTULO XIV

TIEMPO COMPARTIDO

MNR

SUMARIO: I. Situación anterior a la sanción de la ley 26.356. II. La sanción de la ley 26.356. III. El Código Civil y Comercial.

I. Situación anterior a la sanción de la ley 26.356

a) El régimen del Código Civil derogado

Han surgido nuevas figuras de naturaleza comunitaria que responden a necesidades sociales de diversa índole, que si bien pueden desarrollarse satisfactoriamente en el ámbito de los derechos personales al amparo del principio de la autonomía de la voluntad, encontraron variados escollos para adecuarse al esquema de los derechos reales por la clausura de su nómina y el orden público incluido en sus normas reguladoras. El tiempo compartido es uno de esos casos, que se difundió en nuestro país a partir de la segunda mitad de la década de 1980.

El tiempo compartido es un nuevo estado jurídico de la propiedad, producto de una modalidad contractual que consiste en otorgar un derecho que atribuye la facultad de usar y gozar con exclusividad de determinados bienes (generalmente inmuebles), sucesiva y alternadamente, por períodos previamente establecidos, de duración perpetua o temporal y transmisible por actos entre vivos o por causa de muerte.

En cuanto a otras posibilidades de aplicación, aún no muy difundidas en nuestro medio, se menciona la comercialización de yates, equipos, sistemas y programas de computación, diseños industriales,

marcas y patentes, infraestructuras industriales, civiles y navales, laboratorios, estudios jurídicos, notariales, contables y de auditoría y todas aquellas cosas y bienes cuyo uso y goce pueda ser objeto de partición convencional.

Las ventajas del sistema son varias, entre las que se visualiza que varios usuarios se aseguran el uso y goce de un bien por un período de tiempo, con una notable disminución en los gastos de adquisición y mantenimiento, ya que se dividen entre todos. También para el empresario, que seguramente obtiene más renta que si enajenara unidades en forma tradicional.

Lo cierto es que el Código Civil de Vélez no previó esta modalidad de uso de la propiedad. Tampoco era posible darle cabida dentro del marco de los derechos reales, pues para ello era necesario forzar demasiado la tipicidad de los derechos reales reconocidos.

b) *Denominación*

En la experiencia local, la denominación por la cual se conoce y difunde la figura es la de "tiempo compartido", pero también se ha utilizado la de "multipropiedad", que predomina en el Derecho Comparado. También se designa a la figura como "propiedad de espacios temporales"; "derecho de aprovechamiento por turnos"; "propiedad vacacional"; "condominio afectado a disfrute periódico con indivisión forzosa y perpetua"; "time sharing"; "right of use"; "derecho de habitación vitalicio", o "polidominio".

c) *La figura en el campo de los derechos personales*

En este ámbito puede concretarse sin dificultad, en tanto rige el principio de la autonomía de la voluntad, asegurado por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

En la "praxis" argentina, mayoritariamente, se lo ha caracterizado como un derecho personal emergente de una participación societaria que se vincula con la facultad de usar y gozar, sucesiva y alternadamente, un determinado turno, según las previsiones contenidas en la estructura obligacional de sus estatutos, limitado temporalmente a la duración de la persona jurídica que ostenta su titularidad.

d) *La figura en el campo de los derechos reales*

No obstante el satisfactorio funcionamiento del instituto en las figuras societarias referidas, es preferible brindar a los interesados en acceder a este complejo sistema, la posibilidad de adquirir algún derecho real, por las mayores ventajas que otorga y la seguridad que se deriva de su publicidad registral.

Al no admitirse la autonomía de la voluntad en materia de derechos reales y al estar éstos dominados sustancialmente por el número cerrado y el orden público, la cuestión resultaba de difícil solución.

Sobre esta cuestión, vigente el Código de Vélez, se han sostenido dos criterios distintos:

- 1) Hay quienes postularon que las diferencias que separaban al tiempo compartido, o multipropiedad, de las distintas figuras legisladas en el Libro III del Código Civil y en leyes especiales (p. ej., ley 13.512) eran insalvables y, por tanto, se tornaba necesario dotar al instituto de una regulación legal propia que capte su verdadera esencia.
- 2) Para otros, esta moderna modalidad contractual podía acomodarse a las normas que regulaban el condominio, subsunción que presentaba algunas dificultades, derivadas del orden público, y a la inestabilidad esencial de este derecho real, conformado según los moldes romanos.

En ese orden de ideas, al no estar prevista legalmente la indivisión forzosa, cualquiera de los condóminos está autorizado a pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común.

Suponiendo la hipótesis de un piso o departamento enajenado a un número máximo de cincuenta y dos personas (las semanas de un año), estará expuesto también a la división que puede ser reclamada por cualquiera de sus titulares, lo que tornaba incierta la duración del derecho real adquirido.

Este último criterio requería una reforma legislativa que dispusiera la indivisión forzosa para este supuesto en forma expresa, o bien admitiera la virtualidad de pactos de indivisión cuya duración estuviera relacionada con la de la supervivencia del sistema.

II. La sanción de la ley 26.356

El 28 de febrero de 2008 se sancionó la ley 26.356, complementaria del Código Civil, con arreglo a su artículo 41.

La ley de tiempo compartido o, como prefiere el legislador más ampliamente, del Sistema Turístico de Tiempo Compartido (STTC), viene conformada por cuarenta y cuatro artículos dispuestos en diez capítulos.

El primero está dedicado a las llamadas *Disposiciones generales* (arts. 1° a 3°), resultando los subsiguientes relativos a la *Autoridad de aplicación* (arts. 4° a 7°), a la *Constitución del STTC* (arts. 8° a 13), al *Contrato de tiempo compartido* (arts. 14 a 21), a la *Administración de los STTC* (arts. 22 a 25), a la *Comercialización y publicidad* (arts. 26 y 31), a la *Instancia arbitral* (arts. 32 y 33), a las *Sanciones* (arts. 34 a 38), a la *Extinción del STTC* (art. 39) y finalmente a las *Disposiciones complementarias* (arts. 40 a 44). La normativa en análisis está imbuida de normas protectoras del usuario de tiempo compartido, e introduce reformas al régimen del consumidor.

La ley desarrolla un sistema que comprende la totalidad de las relaciones que se establecen entre los distintos protagonistas que participan en este negocio inmobiliario (desarrollista y/o propietario, vendedor, revendedor, usuario, administrador, comercializador y prestador de servicios) abarcando, además, al intercambio vacacional y, para reiterarlo, con total abstracción de los derechos que se constituyan o transmitan y del régimen legal al que se encuentran sometidos los bienes que lo integran.

El sistema consiste básicamente en adquirir bajo alguna de las formas jurídicas previstas en nuestra legislación, un derecho a disfrutar de un período de tiempo de vacaciones en un departamento o habitación de hotel que formen parte de un complejo turístico vacacional equipado con servicios y actividades recreativas adecuadas y acordes a la finalidad del sistema.

En lo que aquí interesa, por el momento cabe advertir que comienza definiendo su ámbito de aplicación, y traza aquí una primera y distintiva línea conceptual: no importa qué derechos se constituyan o transmitan —si personales o reales, conforme la antigua discusión en la materia—

ni tampoco bajo qué régimen legal se ubican los bienes. Es que si se cumplen determinados recaudos (básicamente cumplir con la conceptualización del art. 2° y con requisitos registrales y de admisión administrativa) se está ante un STTC y serán entonces aplicables las reglas de la ley y las que de ella se desprendan.

Claro que esta libertad tiene su lado negativo, ya que la ley permite que se configure el instituto como derecho real, pero sin establecer de cuál se trata ni su régimen imperativo. Ocurre que el tiempo compartido navega más cómodo en el terreno de los derechos personales.

Uno de los pilares de la ley es la libertad de elección del emprendedor respecto del tipo de derecho transmitido o constituido a favor del usuario de STTC. La ley en su artículo 1° precisa que regula los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido (STTC), “con independencia de la naturaleza de los derechos que se constituyan o transmitan y del régimen legal al que se encuentren sometidos los bienes que los integran”; principio que se reitera en los artículos 10, inciso b; 1° y 5°; 13; 15, primer párrafo e inciso d; 26 y 28, inciso b.

En los Fundamentos del Proyecto del Poder Ejecutivo se expresa que se lo considera independientemente del tipo de derecho constituido, como un conjunto de prestaciones periódicas que se traducen en una serie de facultades y obligaciones, susceptibles de enmarcarse en la órbita contractual. La elección de la modalidad operativa y del tipo de derecho que ella genera es asignada al emprendedor, en razón de que es éste quien da forma al producto que ofrece, de acuerdo a su concepción de la actividad, a las circunstancias del mercado y esencialmente a la respuesta del consumidor”.

Lo cierto es que en esta ley no se ha creado un nuevo derecho real, ni sobre cosa propia ni sobre cosa ajena. En otras palabras, podrán seguir otorgándose en el marco de la ley y con las adecuaciones que imperativamente impone, cualquiera de los derechos que se han concebido originalmente para transmitir o constituir a favor del usuario, los cuales, a su vez, tienen su propia regulación. En el marco de los derechos reales sobre cosa propia sería el derecho real de condominio y en los de disfrute sobre cosa ajena se recurriría principalmente al uso, generándose una comunidad de tales derechos (co-uso).

La libertad de elección hace imprescindible que el usuario tenga la certeza del derecho que adquiere. Por ello, en la escritura de constitución del sistema deberá constar "la naturaleza o tipo de derecho a transmitirse o constituirse a favor de los futuros usuarios y, en caso que corresponda, plazo de duración" (art. 10, inc. b, 1); idéntica previsión deberá resultar del contrato de tiempo compartido (art. 15, inc. d); los operadores del sistema tienen el deber de informar el tipo y alcances de los derechos que se transmiten o constituyen (art. 26) y en el documento informativo se deberá precisar "la naturaleza real o personal de los derechos que se ofrecen y su duración" (art. 28, inc. b).

a) *El decreto 760/2014*

El decreto 760/2014 reglamenta la ley 26.356. Determina las obligaciones y los derechos de las partes, delimita cuáles son las facultades del prestador del servicio, fija las condiciones de esa prestación, establece sanciones para el caso de incumplimiento y crea los registros respectivos, necesarios para asegurar un adecuado ámbito de control.

Además de reglamentar la ley de STTC, el decreto también crea el Consejo Técnico Consultivo de los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido, cuya función será la de examinar y pronunciarse sobre cuestiones referentes a la organización, coordinación, promoción y regulación de los STTC y toda otra que proponga la autoridad de aplicación, sin efecto vinculante. Se señala expresamente en el artículo 3º, segundo párrafo, que "En la constitución y en la contratación de los STTC deberá especificarse la naturaleza real o personal del derecho que se transmitirá al usuario".

III. El Código Civil y Comercial

Si bien la ley 26.356 pretendió dotar al sistema de un régimen jurídico adecuado, lo cierto es que la intención del legislador quedó a mitad de camino ya que no resolvió la naturaleza jurídica de la figura, limitándose a regular la relación del usuario con el sistema en tanto sistema organizado para vacaciones.

El Código regula al derecho de tiempo compartido dentro del tí-

tulo VI del Libro Cuarto, en el Capítulo 2. Esto significa que el tiempo compartido, junto a los conjuntos inmobiliarios y al cementerio privado, forma parte de esa categoría. Criterio por cierto opinable, ya que hay diferencias importantes entre estas figuras. Además, como se verá, el objeto del sistema no se limita a los inmuebles, ni al uso residencial turístico, sino que puede aplicarse a cosas muebles cuyo alto costo aconseje un disfrute compartido, y hasta podría tratarse de bienes que no sean cosas. De ahí que sorprenda su categorización como "conjunto inmobiliario".

El artículo 2088 dice "Con independencia de la naturaleza de los derechos que se constituyen o transmiten..." El legislador omitió definir el tema, dejando librado a la voluntad de las partes involucradas caracterizarlo según las distintas modalidades, usos y costumbres de plaza, ya sea como derecho real o personal. No es obligatorio constituirlo como derecho real.

Cualquiera sea la índole del derecho concedido sobre esos bienes, lo que sí queda claro es que éste se sujeta al esquema jurídico previsto por este capítulo, al que habrá de sumarse la normativa propia de los contratos de consumo que contiene el mismo cuerpo legal, y las demás disposiciones vigentes en la materia.

El Código crea el derecho real de tiempo compartido como derecho autónomo, y le da suficiente tipicidad.

La ley 26.994, aprobatoria del nuevo Código Civil y Comercial, deroga los Capítulos III, IV, V y IX de la ley 26.356, de modo que a continuación se examinarán las normas del Código en combinación con aquellas de la ley 26.356 que se mantienen vigentes.

a) *Concepto*

Dice el artículo 2087 que "Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su destino".

En rigor, lo que menos se comparte es el tiempo. Lo que se comparte, como se verá, es el uso de un bien.

A diferencia de la ley referida, no se alude a sistema "turístico", con lo que la afectación puede tener otros destinos. Tampoco se alude a inmuebles sino a "bienes", lo que también da la idea de un marco más amplio. Así, por ejemplo, varios podrían adquirir y usar por turno un barco, un helicóptero, una máquina, etcétera. Normalmente se tratará de cosas, pero también pueden ser bienes o servicios (v. gr.: el uso de software, la locación de un estudio jurídico, servicios de auditoría contable, etc.).

El derecho de tiempo compartido implica que el titular, mediante el pago de un precio en dinero, puede usar y gozar, en forma periódica, exclusiva y alternada, durante un cierto período de tiempo, ubicado en el año calendario o a ubicar (flotante), de un ámbito espacial determinado o determinable (departamento, casa, cabaña) o de una cosa mueble u otro bien, sin alterar su sustancia (en el doble aspecto: material y destino) y al mismo tiempo aprovechar de los servicios e instalaciones que se ofrece como accesorios integrantes del sistema para su más placentero disfrute (restaurant, piscina, etc.); pudiendo existir para el titular la posibilidad de intercambiar el período que le corresponde respecto del bien afectado por otro similar respecto de otro bien afectado, ubicado en el país o en el extranjero (esto último es usual cuando se trata de destinos turísticos).

Entre los caracteres principales cabe mencionar:

- 1) Debe haber un uso periódico (v. gr.: una vez al año), esto es que se reitere y mantenga en el tiempo, luego de vencidos los turnos de los restantes usuarios. Este período puede ser fijo (siempre la misma semana de cada año), o flotante (se puede usar en diversos períodos del año). Puede haber variantes, como por ejemplo, dos semanas durante la época estival o bien, sin ninguna especificación.
- 2) Cada usuario puede usar de la cosa o bien por un período de tiempo determinado (v. gr.: una semana al año), llamado "turno".
- 3) El derecho puede ser perpetuo o temporario. En este último caso, se lo suele otorgar por un largo período.
- 4) El derecho del usuario suele ser transmisible.

- 5) Se prevé la protección especial del usuario consumidor, para evitar abusos, publicidades engañosas o informaciones insuficientes.

El alcance de estos caracteres dependerá del título constitutivo que contendrá los derechos y obligaciones de los intervinientes, y de las normas imperativas. Así, por ejemplo, el contrato puede permitir permutas, acumulaciones, intercambios, etcétera. Cuando se trata de inmuebles destinados a turismo, por ejemplo, el usuario tiene derecho a la prestación de determinados servicios.

b) *Bienes que lo integran*

Dice el artículo 2088: "Con independencia de la naturaleza de los derechos que se constituyen o transmiten, y del régimen legal al que los bienes se encuentren sometidos, el tiempo compartido se integra con inmuebles y muebles, en tanto la naturaleza de éstos sea compatible con los fines mencionados".

A diferencia de la ley 26.356, como se dijo anteriormente, el artículo 2088 se refiere a inmuebles y muebles, lo que puede dar cabida a otras posibilidades (v. gr.: barcos, máquinas). Incluso, el artículo anterior y éste dicen "bienes" en lugar de inmuebles.

Por último, debe recalcar que más allá de la naturaleza jurídica del contrato, el usuario, como "consumidor" de estos derechos y servicios, está protegido por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, aplicable en forma complementaria al caso, y por las normas del Código que se refieren a la relación de consumo.

c) *Afectación*

La afectación de la cosa o bien al sistema de tiempo compartido es uno de los puntos más importantes. Ocurre que si los adquirentes (usuarios) cuentan con un derecho personal, se corre el riesgo de que la cosa cuyo uso se comparte pueda ser embargada y ejecutada por otros acreedores, y que el sistema se derrumbe en perjuicio de los beneficiarios. Éste es uno de los riesgos más grandes del sistema, así como la posibilidad de que la cosa sea gravada con derechos reales de garantía que terminen imponiéndose a los derechos de los usuarios.

Por ende, tanto la ley 26.356 como ahora el Código instrumentan un sistema de afectación de la cosa o bien, para evitar que sea alterado su destino mientras la afectación se mantenga. Claro que esto es mucho más eficiente cuando se trata de cosas o bienes registrables, la seguridad es mayor.

La afectación resultará siempre necesaria, aun cuando el derecho de tiempo compartido no involucre inmuebles, y se organice como derecho real o como derecho personal.

Dice el artículo 2089 que "La constitución de un tiempo compartido requiere la afectación de uno o más objetos a la finalidad de aprovechamiento periódico y por turnos, la que, en caso de tratarse de inmuebles, debe formalizarse por escritura pública, que debe contener los requisitos establecidos en la normativa especial".

La afectación puede ser por un tiempo (ver art. 2099). Si se trata de un inmueble el Código requiere escritura pública. Si se trata de cosas muebles, la afectación puede hacerse por instrumento privado de fecha cierta.

Esta norma remite a la "normativa especial". Cabe entender que esta legislación especial es la ley 26.356, en aquello que el Código no deroga expresamente. Llama la atención que la ley aprobatoria derogue, entre otros, al Capítulo III, que es donde se regula el contenido de la escritura pública en cuestión.

Al respecto, dispone el artículo 10 de la ley 26.356, lo siguiente: "*Contenido de la escritura.* La escritura de constitución hará constar la expresión de voluntad del emprendedor y del propietario en su caso, de afectar determinados bienes a un STTC y expresamente deberá contener": la descripción del inmueble y de las unidades vacacionales, derechos y deberes de los usuarios, obligaciones del administrador, el reglamento de uso, etcétera.

Deberá figurar la existencia de gravámenes hipotecarios, por cuanto, a pesar de que el artículo 2091 establece que los bienes deberán estar libres de gravámenes, en el inciso 6° del apartado a, del artículo 10 de la ley 26.356 —al que el Código remite—, se advierte que en la escritura deberá constar la conformidad del acreedor hipotecario "...cuando el bien sobre el que se constituirá el STTC, estuviese gravado".

Esta alternativa no puede descartarse ya que, de lo contrario, tal como se ha afirmado: "¿Quién financiará la construcción en un inmueble para afectarlo a STTC con garantía hipotecaria, si luego no va a poder hacer efectiva su garantía?" (Adriana Abella).

Hubiera sido aconsejable que la escritura de afectación contenga una relación circunstanciada de las causas legales que provocaron el otorgamiento de la garantía hipotecaria preexistente cuando se trate de aquélla no prevista, a fin de que también forme parte del contenido el contrato constitutivo para conocimiento del usuario.

Tratando de armonizar las diversas normas, se puede entender que si la hipoteca preexiste, o bien el titular del dominio la cancela antes de la afectación, o bien se afecta con la conformidad del acreedor hipotecario, quien aceptará someterse a este sistema, lo que implica que en caso de ejecución deberá mantenerse el destino impuesto por la afectación.

Otra posibilidad es interpretar que el Código se apartó del sistema previsto en la ley 26.356 y no acepta que se pueda afectar un inmueble estando constituida una hipoteca, y que la única posibilidad es cancelarla previamente, máxime advirtiendo que el artículo 2093, inciso b, no reproduce exactamente al artículo 12, inciso b, de la ley 26.356, que menciona expresamente al acreedor hipotecario. Es factible esta tesis, aunque la poco prolija remisión a la ley especial genera alguna confusión.

El artículo 3° de la ley 26.356, en su última parte, permite que la afectación de una unidad o club vacacional sea total o parcial. Esta norma no ha sido derogada ni modificada.

d) *Legitimados para afectar*

Según el artículo 2090: "El instrumento de afectación de un tiempo compartido debe ser otorgado por el titular del dominio. En el supuesto en que dicho titular no coincida con la persona del emprendedor, éste debe comparecer a prestar su consentimiento a la afectación instrumentada".

Si bien la ley habla únicamente del titular de dominio, no existe óbice para que se trate también de un inmueble en condominio y en

tal caso requerirá el consentimiento unánime de todos los condóminos, o bien un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, y allí será necesario el consentimiento unánime de los consorcistas.

Puede agregarse también al superficiario respecto de la propiedad superficiaria. En este caso, el derecho de tiempo compartido no podría extenderse más allá del plazo previsto para el derecho de superficie.

e) *Los bienes*

"Los bienes deben estar libres de gravámenes y restricciones.

"El emprendedor, el propietario, el administrador y el comercializador no deben estar inhibidos para disponer de sus bienes.

"El propietario puede constituir hipoteca u otro gravamen con posterioridad a la inscripción de la escritura de afectación, con los efectos previstos en el artículo 2093" (art. 2091).

Si hay una hipoteca anterior debe estar cancelada para que se pueda afectar el inmueble. Lo mismo cabe decir de un embargo o de algún otro gravamen. En cuanto a los posteriores, cabe entender que si no se paga el crédito y se ejecuta el inmueble, hay que respetar la afectación. Prevalecen los derechos de los usuarios (art. 2093, inc. b).

Si se trata de cosas muebles no registrables, este sistema no podría ser invocado frente a terceros de buena fe y a título oneroso que hubiesen gravado la cosa.

Además de la exigencia de no estar afectados los bienes, requiere el Código que los sujetos involucrados no se encuentren inhibidos.

El propietario, y en su caso el emprendedor, no pueden darle —luego del sometimiento al sistema— a las cosas otro destino ni jurídica ni materialmente que no se compadezca con el sistema de la ley. La única morigeración se encuentra dada por la última parte del inciso a, del artículo 2093 cuando regla que "puede comercializar los períodos de disfrute no enajenados, con otras modalidades contractuales".

f) *Inscripción de la afectación y sus efectos*

El instrumento en el que conste la afectación debe ser publicitado

teniendo en cuenta que produce importantes efectos respecto de los usuarios y de terceros interesados.

Dice el artículo 2092: "El instrumento de afectación debe ser inscripto en el respectivo Registro de la Propiedad y en el Registro de Prestadores y Establecimientos afectados a Sistemas de Tiempo Compartido previsto en la ley especial, previo a todo anuncio, ofrecimiento o promoción comercial".

Agrega el artículo 2093: "La inscripción del instrumento de afectación en el respectivo Registro de la Propiedad determina:

- "a) la prohibición al propietario y al emprendedor de modificar el destino previsto en el instrumento; sin embargo, el emprendedor puede comercializar los períodos de disfrute no enajenados, con otras modalidades contractuales;
- "b) la oponibilidad de los derechos de los usuarios del tiempo compartido, que no pueden ser alterados o disminuidos por sucesores particulares o universales, ni por terceros acreedores del propietario o del emprendedor, ni siquiera en caso de concurso o quiebra".

f.1) *Inscripción*

Del instrumento debe hacerse una doble inscripción. Por un lado, en el "Registro de Prestadores y Establecimientos afectados a Sistemas de Tiempo Compartido previsto en la ley especial". Además, cuando se trate de cosas o bienes registrables, deberá ser inscripto en el Registro que corresponda (v. gr.: inmuebles, automotor, etc.). Cuando se trate de cosas que no sean registrables, habrá que consultar previamente en el Registro de Prestadores.

El artículo 6° de la ley 26.356 dice: "Créase el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación..."

Ahora, como ya se dijo, el Registro no se limitará a establecimientos vacacionales, ya que pueden darse otras finalidades.

La inscripción debe ser hecha antes de que se comercialice el sistema o se haga publicidad.

Sobre la referencia al Registro de Prestadores y Establecimientos afectados a Sistemas de Tiempo Compartido, para su creación y funcionamiento será necesaria una ley especial, y como esta inscripción se dispone que sea llevada a cabo previo a todo anuncio, ofrecimiento o promoción comercial, no resultará operativo el régimen hasta su creación.

La otra alternativa es interpretar que, hasta tanto se reglamente esta situación, habrá que inscribir en el Registro creado para turismo por la ley 26.356.

f.2) Efectos

El sistema, en lo que concierne a los bienes afectados, así como a los derechos de los usuarios, tiene fuerte oponibilidad. De modo que si las cosas son enajenadas, debe respetarse el destino.

La afectación importa la inhibición del propietario para apartarse de la destinación comprometida. El propietario está impedido de variar el destino comprometido, esto es, de ejercer un derecho que le asistiría de no mediar la afectación.

Los acreedores del propietario o del emprendedor podrán agredir los bienes afectados pero respetando siempre la afectación al sistema. Del mismo modo en el caso de quiebra del propietario o el desarrollador, los bienes afectados podrán ser desapoderados y luego liquidados, pero manteniéndose siempre la afectación al STC y todo lo que ello implica. La idea central es no perjudicar a los usuarios quienes tienen un derecho preferencial.

En todos los casos, tanto al acreedor hipotecario como a los adquirentes en subasta del inmueble, les serán oponibles –en la eventual ejecución– los derechos de los “usuarios” del sistema, que resultan intangibles frente a aquéllos; se trata de normas de orden público que los acuerdos privados no pueden alterar.

Salvedad de lo expuesto constituiría el caso del bien afectado y constituido a un STC pero que no registre transferencias o ventas de unidades o tiempos de uso o disfrute, o haya rescindido los contratos (ver art. 2099), ya que en ese caso, al no existir usuario alguno, el sistema protector no tiene razón de ser y debe ceder ante los derechos

de los acreedores, estimándose que es posible la cancelación de la afectación por orden judicial para la libre disponibilidad posterior de los bienes.

f.3) Períodos no enajenados

El artículo 2093, inciso a, consagra una excepción a lo expuesto al prever: “...sin embargo, el emprendedor puede comercializar los períodos de disfrute no enajenados, con otras modalidades contractuales”.

Otra modalidad contractual podría ser, por ejemplo, que si una habitación o unidad está vacía se la comercialice como hotel tradicional, o que se la alquile. Los períodos no asignados los mantiene el propietario en su poder, quien está autorizado a comercializarlos fuera del sistema, a diferencia de los usuarios.

f.4) Registro de titulares

Además de los registros mencionados, debe haber uno de titulares en el que figurarán los datos de los usuarios (art. 2094, inc. b).

f.5) Oponibilidad de los derechos de los usuarios del tiempo compartido

Establece el inciso b, del artículo 2093 que la inscripción también determina “la oponibilidad de los derechos de los usuarios del tiempo compartido...”

Una vez inscripto el acto de afectación, los derechos de los futuros usuarios estarán a resguardo de los problemas que puedan afectar al propietario. La afectación asegura que el tiempo compartido se mantendrá.

g) Sujetos

En este sistema habrá distintas relaciones contractuales entre los participantes: dueño del objeto, emprendedor, usuarios, etcétera.

El artículo 2091 menciona al emprendedor, al propietario, al administrador y al comercializador, quienes luego son mencionados en

otras normas del Código. A ellos se suman los usuarios, destinatarios principales de las normas que tienden a protegerlos.

A su vez, el artículo 3° de la ley 26.356 ofrece las siguientes definiciones:

“- *Usuario*. Es quien adquiere el derecho de uso periódico en un Sistema Turístico de Tiempo Compartido, por sí o por terceros.

“- *Propietario*. Es el titular dominial de un inmueble, quien lo afecta total o parcialmente, al Sistema Turístico de Tiempo Compartido.

“- *Emprendedor*. Es la persona física o jurídica propietaria o con justo título de disposición del inmueble, que constituye el STTC para comercializar períodos de disfrute y brindar a los usuarios las prestaciones que lo integran, por sí o por intermedio de terceros.

“- *Vendedor*. Es la persona física o jurídica que, en nombre y representación del emprendedor, promueve y ofrece en venta períodos de uso en un STTC.

“- *Revendedor*. Es la persona física o jurídica que, por sí o por cuenta y orden de un usuario intermedia en el mercado secundario para la comercialización de períodos de un STTC.

“- *Administrador*. Es la persona física o jurídica, que tiene a su cargo la gestión y coordinación del mantenimiento y uso de los bienes que integran un STTC.

“- *Red de Intercambio*. Es la persona física o jurídica que intermedia entre la oferta y la demanda de períodos de los STTC, prestando servicios adicionales a usuarios.

“- *Prestador*. Es la persona física o jurídica que comercializa STTC, y que de acuerdo al rol que ocupa en la comercialización del STTC responderá ante posibles conflictos que se susciten con los usuarios”.

El usuario además es llamado adquirente, beneficiario o adherente. El emprendedor también es conocido como desarrollista o inversor. El prestador, que la ley diferencia de los demás, suele confundirse con el vendedor y/o el revendedor.

Estos personajes están pensados para el sistema turístico, que ahora es uno más entre otras finalidades posibles.

En la contratación masiva, el adherente se encuentra en una situación de franca debilidad frente a la superioridad del estipulante, pese

a lo cual existe un acto jurídico, toda vez que han jugado válidamente los factores determinantes de la voluntad, aunque la libertad aparece seriamente menoscabada. Los usuarios están protegidos por las normas sobre consumo previstas en el Código y en las leyes especiales (ver art. 2100).

h) *Deberes del emprendedor*

Dice el artículo 2094: “Son deberes del emprendedor:

- “a) establecer el régimen de utilización y administración de las cosas y servicios que forman parte del tiempo compartido y controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del administrador;
- “b) habilitar un Registro de Titulares, que debe supervisar la autoridad de aplicación, en el que deben asentarse los datos personales de los usuarios y su domicilio, períodos de uso, el o los establecimientos a los que corresponden, tipo, extensión y categoría de las unidades, y los cambios de titularidad;
- “c) garantizar el ejercicio del derecho de los usuarios, en la oportunidad y condiciones comprometidas;
- “d) abonar las cuotas por gastos del sistema de las unidades no enajenadas”.

Tal como se adelantó, pueden coincidir, o no, la persona del propietario del inmueble y del emprendedor. El emprendedor es quien comercializa por el régimen de la ley y puede ser propietario o no. Si no lo fuere, deberá prestar su consentimiento para la afectación a cargo del dueño.

Se desprende del inciso a, que es el emprendedor quien fijará el régimen de administración. Luego, el administrador que se designe deberá ajustarse a ese régimen, y a las obligaciones que le impone el artículo 2097.

El artículo 2101 remite a las normas de derechos reales. Entonces, en el caso de inmuebles o cosas muebles registrables, además de estar inscripta la afectación, surge la duda de si los adquirentes deberían contar con un título que también se inscriba en el Registro de la Propiedad pertinente, sin perjuicio de este Registro interno.

Esto parece lo ideal, para dotar de oponibilidad plena al título del adquirente. Pero también hay que observar la dificultad que puede implicar la anotación de cientos de títulos.

i) *Deberes de los usuarios del tiempo compartido*

Dispone el artículo 2095 que "Son deberes de los usuarios del tiempo compartido:

- "a) ejercer su derecho conforme a su naturaleza y destino, sin alterarlos ni sustituirlos y sin impedir a otros usuarios disfrutar de los turnos que les corresponden;
- "b) responder por los daños a la unidad, al establecimiento, o a sus áreas comunes, ocasionados por ellos, sus acompañantes o las personas que ellos autorizan, si tales daños no son ocasionados por su uso normal y regular o por el mero transcurso del tiempo;
- "c) comunicar a la administración toda cesión temporal o definitiva de sus derechos, conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de uso;
- "d) abonar en tiempo y forma las cuotas por gastos del sistema y del fondo de reserva, así como todo gasto que pueda serle imputado particularmente".

Esta norma se ocupa de los deberes de los usuarios, sin mencionar sus derechos. Los derechos son varios y diversos, lo cual dependerá del tipo de cosa o servicio afectado, y de lo que convengan las partes. No obstante, como regla general puede decirse que las facultades principales son la de usar y gozar del objeto y de los servicios afectados durante el período establecido. Además, el usuario puede disponer jurídicamente de su derecho. En el plano personal, contractual, tiene principalmente derecho a recibir los servicios estipulados y, en caso de incumplimiento, el de demandar el cumplimiento y/o la indemnización del daño sufrido.

El artículo 2095 pone límites a las facultades mencionadas. El uso debe ceñirse al destino previsto, y al respeto al uso y goce de los demás.

La cesión temporal o definitiva debe ser comunicada a la administración. Esto es más propio de los derechos personales que de los

reales. Pareciera que no pueden, en cambio, gravar su derecho con usufructo, uso o habitación (arg. art. 2131). Sin embargo, también es factible interpretar que la enumeración del artículo 2131 no es taxativa (conf. XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Bahía Blanca, 2015).

Es importante, para la seguridad del adquirente, que conste en el reglamento de administración el sistema que se utilizará para el cobro de los gastos. Éste es un tema que ha sido conflictivo, ya que muchos vendedores, para captar adquirentes, al principio ofrecen gastos menores, o los eximen por uno o dos períodos, y luego aumentan para sorpresa del usuario.

Muchos emprendimientos cuentan con un fondo de reserva, para evitar sorpresas ante gastos imprevistos.

Por otra parte, suelen prever los reglamentos que el moroso en el pago de los gastos no tenga derecho al uso de su turno mientras no regularice la situación.

j) *El administrador*

j.1) *Designación*

Prevé el artículo 2096: "La administración puede ser ejercida por el propio emprendedor, o por un tercero designado por él. En tal caso, ambos tienen responsabilidad solidaria frente a los usuarios del tiempo compartido, por la debida gestión y coordinación en el mantenimiento y uso de los bienes".

Puede ser administrador el propio emprendedor, o bien un tercero que él designe. Es la persona física o jurídica que tiene a su cargo la gestión y coordinación del mantenimiento y uso de los bienes y servicios.

A diferencia de lo que sucede en el ámbito de la propiedad horizontal, aquí el administrador es elegido por el emprendedor. Tampoco se prevé la necesidad de que una asamblea ratifique al designado por primera vez en el Reglamento (ver art. 2065), ni que los usuarios puedan removerlo.

Este administrador tiene poderes más amplios que los previstos para la propiedad horizontal.

j.2) *Deberes del administrador*

Establece el artículo 2097: "El administrador tiene los siguientes deberes, sin perjuicio de los establecidos en los regímenes legales específicos:

- "a) conservar los establecimientos, sus unidades y los espacios y cosas de uso común, en condiciones adecuadas para facilitar a los usuarios el ejercicio de sus derechos;
- "b) preservar la igualdad de derechos de los usuarios y respetar las prioridades temporales de las reservaciones;
- "c) verificar las infracciones al reglamento de uso y aplicar las sanciones previstas;
- "d) interponer los recursos administrativos y acciones judiciales que corresponden;
- "e) llevar los libros de contabilidad conforme a derecho;
- "f) confeccionar y ejecutar el presupuesto de recursos y gastos;
- "g) cobrar a los usuarios las cuotas por gastos, fondos de reserva y todo otro cargo que corresponde;
- "h) rendir cuentas al emprendedor y a los usuarios, conforme a liquidaciones de ingresos y gastos certificadas por contador público, excepto en el caso que se optara por aplicar el sistema de ajuste alzado relativo;
- "i) entregar toda la documentación y los fondos existentes, al emprendedor o a quien éste indique, al cesar su función;
- "j) comportarse tal como lo haría un buen administrador de acuerdo con los usos y prácticas del sector".

Aclara esta norma que puede haber otras obligaciones impuestas por regímenes legales específicos. Incluso, de este capítulo se infieren otras, como la de expedir el certificado que será título ejecutivo si un usuario no abona los gastos a su cargo. Además, el contrato con el emprendedor también podría imponerle obligaciones adicionales.

Además de las mencionadas en la norma pueden señalarse otras obligaciones, tales como cumplir con determinadas obligaciones legales (v. gr.: aportes previsionales de empleados), contratar seguros, representar a los usuarios, pago de servicios, entregar y recibir las unidades,

DEL PO COM ARTES
MNR

tomar y despedir personal, convocar a reuniones ordinarias o extraordinarias según lo disponga el reglamento, entre las más notorias.

Esta norma también lo habilita para imponer sanciones. Al no intervenir un tercero, se puede sostener que el sancionado siempre contará con la posibilidad de impugnar judicialmente la sanción aplicada.

Como todo administrador, es responsable de su gestión, si no actúa con la diligencia debida. El artículo 2097, en el inciso j, establece un estándar de conducta, en tanto debe "comportarse tal como lo haría un buen administrador de acuerdo con los usos y prácticas del sector".

k) *Cobro ejecutivo*

Como es sabido, en el régimen de la propiedad horizontal, si uno de los consorcistas no paga las expensas el administrador cuenta con la vía ejecutiva para el cobro del crédito.

El Código dispone en el artículo 2098: "El certificado emanado del administrador en el que conste la deuda por gastos del sistema, los rubros que la componen y el plazo para abonarla, constituye título para accionar contra el usuario moroso por la vía ejecutiva, previa intimación fehaciente por el plazo que se estipula en el reglamento de administración".

El título ejecutivo lo constituye el certificado expedido por el administrador. Una solución similar se prevé en el artículo 2048 para la propiedad horizontal. Debe describir el monto de la deuda y los rubros que la componen. Goza de privilegio el crédito por expensas comunes (arts. 2582, inc. a; 2586, inc. c), pero nada dice sobre éste en particular. Hay dos posibilidades: 1) interpretar que, por analogía, este crédito también cuenta con privilegio, con apoyo asimismo en el artículo 2102 que dice que a este derecho real se le aplican las normas sobre derechos reales, y que el artículo 2582, inciso a, dice que tienen privilegio especial "los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa, sobre ésta", o 2) entender lo contrario, ya que los privilegios deben ser creados por ley y son de interpretación restrictiva.

Hubiera sido preferible que se definiera esta cuestión más claramente.

l) *Extinción*

Dice el artículo 2099: "La extinción del tiempo compartido se produce:

- "a) por vencimiento del plazo previsto en el instrumento de afectación;
- "b) en cualquier momento, cuando no se han producido enajenaciones, o se han rescindido la totalidad de los contratos, circunstancia de la que se debe dejar constancia registral;
- "c) por destrucción o vetustez".

La afectación puede estar sujeta a un plazo, a cuyo vencimiento se extingue este sistema. El objeto afectado recobra su condición jurídica original. El plazo tiene que estar previsto en el instrumento de afectación. Si bien la extinción es automática, el dueño del inmueble (o los condóminos) deberá presentarse en el Registro correspondiente y solicitar la desafectación.

En cualquier momento, si no hubo enajenaciones, o las que hubo fueron rescindidas. La circunstancia prevista en el inciso b, es lógica, pues la afectación tiene por objetivo asegurar a los adquirentes que sus derechos no serán afectados mientras esté vigente la afectación. Ahora, si no hubo enajenaciones, o las que hubo se dejaron sin efecto, quiere decir que no hay usuarios que proteger, y entonces el dueño puede dar por extinguido el sistema.

Por último, la destrucción o vetustez también son causas de extinción. En armonía con esta norma, prevé el artículo 1907 que "Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, éstos se extinguen, por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción..."

El Código prevé que el sistema se extingue. No obstante, no puede descartarse que si todos los involucrados (dueño, emprendedor, usuarios) se ponen de acuerdo y deciden la reconstrucción, puedan arribar a una solución diferente, ya que jugaría la autonomía de la voluntad. Si no hay ningún acuerdo, sólo queda la extinción.

m) *Relación de consumo*

Dice el artículo 2100: "La relación entre el propietario, emprendedor, comercializador y administrador del tiempo compartido con

quien adquiere o utiliza el derecho de uso periódico se rige por las normas que regulan la relación de consumo, previstas en este Código y en las leyes especiales".

Esto significa que en los conflictos debe interpretarse de la manera más favorable al usuario (ver arts. 7º, 1062, 1093/1094). A la vez, resultan aplicables las reglas sobre trato digno, publicidad, posibilidad de revocar la aceptación, etcétera, previstas en los artículos 1096 y siguientes del Código.

Además, el artículo 2654 del Código se refiere a la jurisdicción competente cuando se trata de contratos de consumo.

El adquirente en el sistema que se examina corre un serio riesgo ante ofertas que, por imprecisas desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico, no dejan de ser atractivas a los ojos de quienes contando con escaso capital ven la posibilidad de acceder a un sinnúmero de lugares placenteros dentro y fuera del país creyendo que lo adquiere en forma exclusiva, para toda la vida, y puede no ser así. Además, se utilizó un sistema de ventas muy agresivo con reuniones seductoras y supuestas ofertas "para ese día, que hacían dudar al adquirente".

n) *Derecho real del adquirente de tiempo compartido*

Dice el artículo 2101: "Al derecho del adquirente de tiempo compartido se le aplican las normas sobre derechos reales". Una norma similar existe para el nuevo derecho real de sepultura (art. 2112).

Esta norma, por un lado, es sobreabundante, y por otro, equívoca. El propietario y el emprendedor pueden optar por derechos personales o por derechos reales (art. 2088). Sólo en este último caso se aplican tales normas.

Ya se ha dicho que el Código crea un nuevo derecho real (art. 1887, inc. f), en este caso el tiempo compartido. Es un derecho real sobre cosa propia (art. 1888), principal (art. 1889), que puede ser perpetuo o temporario, se ejerce por la posesión (art. 1891), y atribuye a su titular las facultades de disponer jurídicamente, usar y gozar en forma periódica y por turnos, del objeto que puede consistir en una cosa u otro bien, registrable o no.

La calificación que hace el artículo 1888 como derecho real sobre cosa propia tiene sentido cuando se refiere al dueño del objeto que lo afecta al sistema, pero es equivocada respecto de los usuarios, salvo que también fueran condóminos, hipótesis poco probable. El derecho del usuario recae sobre una cosa ajena, que tiene uno o más dueños, quienes no dejan de serlo por la afectación.

Este derecho consiste en un pacto de usos y goces sucesivos y alternados entre varias personas en relación con un objeto común, creándose entre ellos una situación comunitaria que es preciso regular. Debe ser reputado inmediato ese uso y goce, derivado de la relación tan estrecha y directa que el titular de un derecho real tiene con su objeto.

El citado artículo 2101 remite a las normas sobre derechos reales, cuando hubiera sido preferible una mayor precisión. No obstante, pueden adelantarse pautas básicas:

- 1) El adquirente será tal cuando reúna el título y el modo suficientes. En el caso de los inmuebles, será menester la escritura pública. Cuando la inscripción registral sea constitutiva, será necesaria para la adquisición del derecho real (ver art. 1892).
- 2) Este derecho real es, por regla, transmisible (art. 1906), ya sea por actos entre vivos o *mortis causa*.
- 3) No puede ser constituido judicialmente (art. 1896).
- 4) Concede a su titular las facultades de poseer, usar y gozar de las cosas afectadas al sistema, de manera exclusiva, en los períodos de tiempo oportunamente adquiridos.
- 5) Surgen dudas acerca de si se puede adquirir por usucapión larga. Podría darse el supuesto, bastante extraño, de alguien que sin título gozara durante 20 años de un turno en forma periódica del objeto compartido con otros. Pero parece una hipótesis de laboratorio, ya que será difícil que pueda acceder al sistema quien no está incluido en el registro de adquirentes, o quien no es acompañante o autorizado.
- 6) Tiene más posibilidades la prescripción corta, cuando sea necesaria para sanear una situación irregular respecto de quien cuenta con justo título y buena fe.

- 7) El adquirente goza de la protección de las acciones posesorias y reales.
- 8) Su derecho real tiene las ventajas inherentes al *ius preferendi* y al *ius persequendi*.
- 9) Hay una suerte de comunidad en la que no se puede pedir la división, ya que es un derecho sobre cosa ajena y porque la duración del derecho depende del plazo previsto en la escritura de afectación.
- 10) Cuando se trate de cosas registrables, será necesaria la inscripción en el Registro correspondiente, ya sea para su publicidad o constitución. No es un tema tan sencillo, teniendo presente la gran cantidad de usuarios que puede registrar el sistema. Así, por ejemplo, en la hipótesis de un edificio con muchas unidades (v. gr., 50 o 100), es probable que cada una de ellas pueda tener a su vez hasta 52 adquirentes con derecho a usarla una semana al año. Así, entonces, el inmueble afectado podría tener miles de usuarios involucrados.

Si se aplican las normas de los derechos reales, la inscripción registral es un recaudo que debe satisfacerse cuando el objeto es registrable. Además, de este modo se protege a los adquirentes y a los terceros, al tener más seguridad el sistema.

ñ) Situación de los derechos constituidos antes de la sanción del Código

Corresponde interpretar que los tiempos compartidos constituidos antes de la sanción del Código, generalmente como derechos personales, no están obligados a adecuarse a todas las normas del Código.

Entre otras razones, lo cierto es que no hay una norma como el artículo 2075, que obliga a los conjuntos inmobiliarios, que se hubiesen establecido como derechos personales o que coexistan con derechos reales, a adecuarse a ese nuevo derecho real.

Además, el tiempo compartido puede adoptar la forma de derecho personal, de modo que ninguna norma de orden público impone el régimen exclusivo del derecho real.

o) *Normas de policía*

Dice el artículo 2102 que "El propietario, emprendedor, comercializador, administrador y usuario del tiempo compartido deben cumplir con las leyes, reglamentos y demás normativas de índole nacional, provincial y municipal relativas al funcionamiento del sistema". Una norma similar contiene el Código con relación al nuevo derecho real de sepultura (art. 2113).

Se trata de normas lógicas. Las normas que impone el Estado (nacional, provincial o municipal) en consideración al bien público, vinculadas a la higiene, sanidad, recaudos edilicios, seguridad, etcétera, deben ser respetadas.

CAPÍTULO XV
CEMENTERIOS PRIVADOS

MNR

SUMARIO: A) Cementerios públicos. I. Introducción. II. Prescripción. III. Los sepulcros son inembargables. IV. Acción de partición. V. No hay inscripción registral. B) Cementerios privados. I. Concepto. II. Naturaleza jurídica. III. Caracteres del derecho real de sepultura. IV. Afectación. V. Facultades del titular del derecho de sepultura. VI. Deberes del titular del derecho de sepultura. VII. Administración. VIII. Reglamento de administración y uso. IX. Registros de inhumaciones y sepulturas. X. Las parcelas son inembargables. XI. Relación de consumo. XII. Normas de policía mortuoria.

A) CEMENTERIOS PÚBLICOS

I. Introducción

Como es sabido, desde antiguo, por razones de higiene, salubridad, sentimentales, religiosas, culturales, entre otras, los cadáveres son retirados de la presencia humana y se les rinde homenaje.

Ha sido un tema profundamente discutido por la doctrina y la jurisprudencia nacional el de la naturaleza jurídica del derecho del particular concesionario sobre el sepulcro (*ius sepulchri*) en los cementerios municipales.

Cementerio es el lugar destinado al descanso de los restos mortales. La inhumación puede realizarse en sepulturas, osarios o fosas comunes, nichos, o en construcciones levantadas sobre la tierra que se conocen como sepulcros, y que comprenden los panteones, las bóvedas y los mausoleos.

Como la muerte es un fenómeno muy vinculado con la religión y las cuestiones sagradas, en su origen los cementerios se hallaron encargados a la administración de las autoridades eclesiásticas y aparecían anexados a iglesias y conventos.

Esto fue así hasta que en 1821 se produjo la secularización de los cementerios, circunstancia que los despojó de su carácter religioso, y fue el Estado quien por medio de leyes y ordenanzas municipales reguló la organización de estos lugares.

Habida cuenta de que en las ordenanzas municipales se utilizó la palabra "venta" a los efectos de transmitir derechos a los particulares, una corriente interpretativa sostuvo que éstos adquirían el derecho real de dominio regulado por el Código Civil entonces vigente. Dado que en dicho Código no existían normas destinadas a los cementerios y a los sepulcros, esta idea fue elaborada principalmente por la jurisprudencia. En esta línea, cabe hacer referencia al caso "Bourdieu" (*Fallos*: 145:307, 1925), en el cual la sentencia de primera instancia estableció que el terreno dedicado a los cementerios podía ser objeto de propiedad privada.

Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema, tribunal que entendió que el derecho del particular sobre una sepultura consiste en una concesión de uso sobre un bien del dominio público. Esta sentencia reviste singular importancia, pues la Corte dejó en claro que dicho derecho —si bien regido por el Derecho Administrativo— estaba amparado por la garantía constitucional de la propiedad.

Cabe entender que los cementerios públicos pertenecen al dominio público municipal (art. 235, inc. f, Cód. Civ. y Com.). Al ser así, los cementerios se hallan fuera del comercio de Derecho Privado, resultan inembargables, imprescriptibles e inenajenables (art. 237). Los derechos otorgados a los particulares sobre los sepulcros o sepulturas son concesiones de uso de Derecho Administrativo, según las leyes y ordenanzas que al efecto sean dictadas. La concesión implica otorgar al particular un poder jurídico especial sobre determinada dependencia pública.

Esta concesión de uso, que es bilateral, origina en favor del particular un derecho real administrativo. Su duración puede ser perpetua o temporaria —según lo que disponga la respectiva legislación—, y puede ser también gratuita u onerosa. En este último supuesto se paga un canon. La concesión de uso se diferencia del permiso de uso por ser este último precario.

En la Ciudad de Buenos Aires, el régimen jurídico aplicable emana

de la ley 4977, que establece que los particulares tienen sobre los sepulcros derechos que derivan del acto administrativo municipal que los otorgó.

II. Prescripción

En el importante plenario "Viana" la Cámara Civil estableció que los sepulcros pueden ser adquiridos por prescripción (L. L. 27-657).

En cuanto a los actos posesorios que deben ser ejecutados para adquirir sepulcros por usucapión, cabe señalar, siguiendo el estudio de Díaz de Guijarro, los siguientes: a) la inhumación de cadáveres; b) la disposición sobre el destino ulterior de los restos depositados en el sepulcro; c) la contratación de un cuidador para la limpieza y vigilancia de la sepultura, y d) la atención personal que se preste a la bóveda.

Esta enumeración de actos posesorios —por cierto, no taxativa— fue recogida por la jurisprudencia a partir del caso "Miranda Naón" (L. L. 110-688). En cambio, también se ha resuelto que "la concurrencia en alguna oportunidad a honrar la muerte de sus deudos y depositar flores en la tumba, son hechos que no tienen el carácter de actos posesorios". Ahora bien, si los sepulcros pertenecen al dominio público y, por consecuencia, son inembargables, inenajenables e imprescriptibles, cabe preguntarse cómo es posible que la jurisprudencia admita que puedan ser adquiridos por prescripción. Cabe entender que —aunque ésa no haya sido la intención de algunos jueces— lo que se adquiere por prescripción no es el derecho real de dominio regulado por el Código, sino el derecho real administrativo cuya causa-fuente es una concesión regida por el Derecho Público, y no por el Privado. Nada obsta a que un derecho real administrativo pueda ser adquirido por prescripción, en tanto una ley especial no disponga lo contrario.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ley vigente prohíbe la venta y el alquiler de los sepulcros o de alguna de sus partes.

III. Los sepulcros son inembargables

Los sepulcros o sepulturas no pueden ser embargados por las deudas

de su titular, pues así lo disponen la mayoría de los códigos procesales. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que nunca se trabará embargo sobre estos bienes, "salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales" (art. 219, inc. 2°).

IV. Acción de partición

Cuando son varias personas las titulares del derecho sobre una sepultura, ya sea por haber adquirido todas ellas en conjunto, o por haber heredado el derecho a la muerte de su titular, se presenta el problema de dilucidar si alguna de ellas puede solicitar la partición, como acontece en el condominio, al no estar prevista por la ley la indivisión forzosa.

La jurisprudencia ha marcado los principios aplicables, y puso en evidencia una tendencia adversa a admitir que uno de los cotitulares solicite la partición o división de la cosa común. Se estableció como criterio general que sólo prosperaría la acción divisoria si todos los titulares están de acuerdo. Otros fallos han agregado el requisito de que el sepulcro esté vacío para admitir el pedido de división.

V. No hay inscripción registral

Por tratarse de bienes del dominio público, los derechos concedidos a los particulares mediante actos administrativos no se inscriben en el Registro de la Propiedad Inmueble. El Gobierno de la Ciudad, o los respectivos municipios, llevan registros de concesionarios y de inhumaciones.

B) CEMENTERIOS PRIVADOS

I. Concepto

Se consideran cementerios privados aquellos que no pertenezcan al dominio del Estado (nacional, provincial o municipal). Dice el Código que "Se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos" (art. 2103). El

Código alude a la "propiedad privada", esto es, se trata de bienes de particulares (art. 236), pero no se puede descartar que un cementerio privado pertenezca al dominio privado del Estado (art. 236).

Cabe apartar del estudio de la problemática específica de los cementerios privados a los que algunas comunidades extranjeras se hallan autorizadas a mantener en virtud de tratados celebrados con los respectivos países de origen, cementerios que se han organizado como asociaciones de las comunidades correspondientes, ejerciendo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el municipio en que se encuentren, el poder de policía mortuoria.

En el ámbito legislativo, corresponde señalar que en la Provincia de Buenos Aires la ordenanza general 221 del año 1978 y la ley 9094 del mismo año autorizan el establecimiento de cementerios privados con fines especulativos o de lucro, sin connotaciones familiares o religiosas, reservándose el Estado el poder de policía mortuoria y el servicio público de inhumaciones, que es ejercido por las municipalidades.

A su vez, la citada ordenanza general 221/78, reglamentaria de la ley, regula las características físicas que debe reunir el inmueble, e impone la ausencia de restricciones religiosas, sociales, raciales o políticas. Además, las tarifas están sujetas a la previa aprobación del municipio.

Ahora bien, fuera de tales limitaciones, estos cementerios privados se rigen fundamentalmente por las normas del Derecho Privado, y pueden ser objeto de derechos en favor de otras personas distintas a las que pertenece el cementerio, de los que resulta la posibilidad de utilizar una parte del inmueble, que recibe comúnmente el nombre de sepulcro o sepultura. La denominación de "sepulcro" comprende a aquellas construcciones realizadas en forma de panteones, mausoleos o bóvedas, mientras que cabe llamar "sepultura" a los espacios más pequeños, cuya capacidad, a lo sumo, permite la inhumación de tres o cuatro féretros. Dado que la ordenanza general 221/78, sólo admite que los cementerios privados tengan el carácter de necrópolis parqueada o cementerio parque, en la Provincia de Buenos Aires no pueden tener cabida los sepulcros, sino tan sólo las llamadas sepulturas.

El Código se refiere en el artículo 2103 "a la inhumación de restos

humanos". No obstante, existen también cementerios privados para animales, especialmente las mascotas. Habrá que preguntarse si no se les aplican por analogía las normas de este Capítulo.

II. Naturaleza jurídica

Desde hace varios años se discute sobre la naturaleza jurídica del derecho del adquirente en un cementerio privado. La mayor parte de ellos han otorgado hasta el momento derechos personales (contrato innominado), y en algunos pocos casos derechos reales (v. gr.: uso o propiedad horizontal).

El Código ha optado por regularlo como derecho real. El artículo 1887, que enumera a los derechos reales permitidos, menciona en el inciso e, al "cementerio privado". Lo considera un derecho real sobre cosa propia (art. 1888), principal (art. 1889), registrable (art. 1890), y que se ejerce por la posesión (art. 1891). Sin embargo. Como se verá más adelante, se trata del "derecho real de sepultura" (arts. 2107, 2108, 2111, 2112); éste es el derecho real que adquieren los titulares de las parcelas exclusivas destinadas a sepultura. En rigor, el inciso e, del artículo 1887 debió referirse al derecho real de sepultura.

No impone el Código la conversión al nuevo régimen de los ya constituidos como derechos personales, como sí lo dispuso para los conjuntos inmobiliarios en el artículo 2075. Por ende, puede inferirse que los cementerios preexistentes podrán seguir funcionando bajo la forma elegida en su oportunidad.

III. Caracteres del derecho real de sepultura

En una norma ambigua y poco feliz, dispone el Código en el artículo 2112 que "Al derecho de sepultura sobre la parcela se le aplican las normas sobre derechos reales", sin decir cuáles.

a) ¿Derecho sobre cosa propia?

Según el artículo 1888 el "cementerio privado" es un derecho real sobre cosa propia. Es cierto que el cementerio recae sobre cosa propia ya que todo el inmueble pertenece a una o más personas en dominio

o condominio. El dueño o los condóminos decidirán si lo afectan a este régimen (ver art. 2104). Pero el derecho de los adquirentes de las parcelas que serán utilizadas para inhumar cadáveres, parece más bien un derecho sobre cosa ajena, ya que el dueño —o en su caso los condóminos— no deja/n de serlo por el hecho de la afectación.

No obstante, el Código parece considerarlo derecho sobre cosa propia. Podría interpretarse que se asemeja al derecho de superficie. Aquí una persona es dueña del terreno afectado a cementerio, y muchas otras tendrían un derecho real sobre cosa propia sobre el espacio destinado a sepultura (normalmente bajo el suelo), complementado con el derecho de uso de sectores de aprovechamiento común, que pertenecen al dueño del terreno.

b) Otros caracteres

El citado artículo 2112 remite a las normas sobre derechos reales; pueden adelantarse pautas básicas:

- 1) El adquirente será tal cuando reúna el título y el modo suficientes. Al tratarse de un inmueble, será menester la escritura pública (art. 1017).
También puede ser adquirido por sucesión, por prescripción, y por adquisición legal si el adquirente es un tercero de buena fe y a título oneroso.
- 2) Este derecho real es, por regla, transmisible (art. 1906), ya sea por actos entre vivos o *mortis causa*. El reglamento no podría prohibirlo (arg. art. 1972), pero podría aplicar un canon o derecho por la transferencia.
- 3) No puede ser constituido judicialmente (art. 1896).
- 4) Concede a su titular las facultades de poseer, usar y gozar de la parcela afectada al sistema, de manera exclusiva, conforme a su destino. A la vez, puede poseer, usar y gozar de las partes destinadas al uso común (v. gr.: caminos de acceso, capilla, etc.), respetando su destino y de acuerdo a lo previsto en la reglamentación de uso.

Se trata, principalmente, de las facultades de inhumar en la parcela los restos humanos de quienes disponga, hasta la di-

mención establecida en el reglamento, y efectuar las exhumaciones, reducciones y traslados, dando estricto cumplimiento a la normativa dictada al respecto (art. 2107, inc. a); construir sepulcros en sus respectivas parcelas, de conformidad a las normas de construcción dictadas al efecto (art. 2107, inc. b); acceder al cementerio y a su parcela en los horarios indicados (art. 2107, inc. c); utilizar los oratorios, servicios, parque e instalaciones y lugares comunes según las condiciones establecidas (art. 2107, inc. d).

- 5) Se puede adquirir por usucapión larga (arts. 1897 y 2565). Es difícil que este caso se verifique en la práctica en los cementerios privados, especialmente respecto de terceros totalmente ajenos al complejo, que practiquen inhumaciones en parcelas vacías a espaldas del propietario o administrador. En cambio, es probable la prescripción adquisitiva que uno de los cotitulares de este derecho real pueda practicar contra los restantes, impidiéndoles el ejercicio de sus facultades.
- 6) Es posible la prescripción corta, cuando sea necesaria para sanear una situación irregular respecto de quien cuente con justo título y buena fe.
- 7) El adquirente goza de la protección de las acciones posesorias y reales. Claro que cabe descartar la de confusión de límites.
- 8) Su derecho real tiene las ventajas inherentes al *ius preferendi* y al *ius perseguendi*.
- 9) Hay una suerte de comunidad en la que no se puede pedir la división.
- 10) Por tratarse de cosas registrables, será necesaria la inscripción en el Registro correspondiente para su publicidad.
- 11) Parece ser un derecho perpetuo, en tanto el artículo 2104 impide alterar el destino del cementerio afectado. No obstante, surgen dudas, ya que la limitación referida es para el cementerio, de modo que podrían otorgarse derechos por plazos que, obviamente, deberán ser extensos.
- 12) Por regla, es inembargable, aunque hay excepciones (art. 2110).

- 13) El titular de este derecho real goza de la protección que el Código y las leyes confieren a los consumidores.
- 14) Debe haber un administrador.
- 15) Se deben pagar expensas, además de los impuestos, tasas y contribuciones correspondientes.
- 16) Si hubiera cotitularidad sobre la parcela, este derecho real estaría sometido a una indivisión forzosa temporaria (arg. arts. 2001 y 2331). Esta indivisión también podría ser pactada (art. 2000), o impuesta en un testamento (art. 2330).

IV. Afectación

Establece el artículo 2104 que "El titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad de cementerio privado, que se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble juntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. A partir de su habilitación por parte de la municipalidad local el cementerio no puede alterar su destino ni ser gravado con derechos reales de garantía".

La afectación del inmueble como cementerio privado es uno de los puntos más importantes. Ocurre que se corre el riesgo de que el inmueble pueda ser desafectado, o ser embargado y ejecutado por otros acreedores, y que el sistema se derrumbe en perjuicio de los beneficiarios. Por ende, el Código instrumenta un sistema de afectación, para evitar que sea alterado el destino del inmueble, la seguridad es mayor. Además, impide que el inmueble sea gravado con derechos reales de garantía (hipoteca o anticresis).

Entiendo que el cementerio es inembargable ya que es un bien de los particulares afectado a un servicio público (art. 243).

Debe tratarse de un inmueble susceptible de dividirse en *parcelas*. Las parcelas, su número y características estarán aprobadas por el municipio respectivo y deberán ser anotadas en los registros habilitados por la comuna. Allí constará la titularidad de las mismas y sus transferencias, comunicadas por el propietario del cementerio.

El fin específico es la inhumación de restos humanos y su conser-

vacación por largo término. Todo esto se complementa con la prestación de determinados servicios.

a) *Legitimados*

Pueden afectar un inmueble a este sistema el dueño o los condóminos de un terreno apto para esta finalidad.

b) *Forma*

La afectación, que luego será inscripta en el Registro, debe ser formalizada en escritura pública.

c) *Oponibilidad de la afectación*

La inscripción del acto jurídico de afectación pondrá al inmueble al resguardo de los ataques de terceros (sucesores, acreedores, etc.), al hacerla oponible a terceros.

d) *Prohibición de cambiar el destino*

No se prevé la posibilidad de retractación o desafectación, como sí lo establece el Código en el artículo 2099 para el tiempo compartido y en el artículo 2044 para la propiedad horizontal, y por lo tanto para los conjuntos inmobiliarios.

V. Facultades del titular del derecho de sepultura

Dice el artículo 2107 que "El titular del derecho de sepultura puede:

- "a) inhumar en la parcela los restos humanos de quienes disponga, hasta la dimensión establecida en el reglamento, y efectuar las exhumaciones, reducciones y traslados...;
- "b) construir sepulcros en sus respectivas parcelas, de conformidad a las normas de construcción dictadas al efecto;
- "c) acceder al cementerio y a su parcela en los horarios indicados;
- "d) utilizar los oratorios, servicios, parque e instalaciones y lugares comunes según las condiciones establecidas".

a) *Facultades materiales*

Dentro de esta categoría se puede mencionar la de inhumar o exhumar restos humanos, disponer su traslado o reducción, etcétera. Luego se enumera la de construir sepulcros, lo que debe ajustarse al respectivo reglamento.

A diferencia del derecho real de propiedad horizontal, los titulares de este derecho real no pueden reunirse en asamblea y tomar decisiones que involucren cambios en los lugares comunes, en la administración, ni de otro tipo. Asimismo, están sujetos a horarios para ejercer su derecho, principalmente el de visita.

b) *Facultades jurídicas*

Nada dice el Código en el Capítulo 3 del Título VI, dedicado a los cementerios privados, sobre las facultades jurídicas del titular. No obstante, aplicando las reglas generales, puede inferirse que es posible enajenar su derecho, ya sea por actos entre vivos o de última voluntad, a título oneroso o gratuito, y que no sería válida una cláusula de no enajenar. Puede transmitir la parcela a terceros aun cuando se encuentre total o parcialmente ocupada, ya que su eventual desocupación dependerá de lo que pacte con el adquirente.

Si el titular muere, sus herederos serán los titulares de este derecho real. Esta deducción es indiscutible, si se advierte que muchas personas pueden adquirir este derecho pensando en su futura muerte y en dejar solucionado el tema para no complicar a sus familiares. El artículo 2106, inciso b, obliga a llevar un registro de titulares "en el que deben consignarse los cambios de titularidad producidos".

Teniendo en cuenta que este derecho, según el artículo 2110, es inembargable (salvo para determinados créditos), se puede llegar a la conclusión de que tampoco puede ser gravado con hipoteca. Además, el artículo 2206 no menciona al titular de este derecho entre los legitimados para constituir hipoteca. Lo mismo ocurre con el artículo 2213 y la legitimación para constituir anticresis, derecho que, por otra parte, no se muestra compatible con el de sepultura, ya que implica percibir frutos para imputarlos a una deuda (art. 2212).

El titular del derecho de sepultura se encuentra facultado para iniciar acciones posesorias o reales en defensa de su derecho.

Finalmente, el titular de este derecho real puede abandonarlo (arts. 1907 y 2105, inc. f). De esta última norma se puede inferir que la sepultura es readquirida por quien sea dueño del cementerio (persona humana o jurídica), y que podrá ser adjudicada nuevamente a otro titular.

VI. Deberes del titular del derecho de sepultura

Dispone el artículo 2108: "El titular del derecho de sepultura debe:

- "a) mantener el decoro, la sobriedad y el respeto que exigen el lugar y el derecho de otros;
- "b) contribuir periódicamente con la cuota de servicio para el mantenimiento y funcionamiento del cementerio;
- "c) abonar los impuestos, tasas y contribuciones que a tales efectos se fijen sobre su parcela;
- "d) respetar las disposiciones y reglamentos nacionales, provinciales y municipales de higiene, salud pública y policía mortuoria".

Entre los mencionados deberes, cabe destacar el de *contribuir con los gastos de mantenimiento y funcionamiento (expensas)*. Se trata de una situación similar a la existente en propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y tiempo compartido. Estos emprendimientos generan gastos de diversa índole, ya que el lugar debe ser mantenido en buen estado, se requiere la contratación de personal, hay que pagarle honorarios al administrador, etcétera.

La proporción en que cada uno de los titulares contribuirá deberá estar prevista en el reglamento de administración y uso, conforme se desprende del inciso c, del artículo 2105, en tanto debe fijar no sólo la proporción sino también la forma de pago del canon por administración y mantenimiento, que puede pactarse por períodos mensuales, anuales o mediante un único pago a perpetuidad.

No queda claro si el *crédito por expensas* puede ser reclamado por la vía ejecutiva, y si goza de privilegio. En cuanto a lo primero, para el derecho real de propiedad horizontal se previó expresamente que el certificado expedido por el administrador constituye título eje-

cutivo (art. 2048, último párrafo); igualmente se previó para el derecho de tiempo compartido (art. 2098). En lo que hace a los cementerios, el artículo 2112 dice que al derecho real de sepultura se le aplican las normas de los derechos reales, sin aclarar de cuáles se trata.

En cuanto al privilegio, el artículo 2582, inciso a, menciona expresamente al "crédito por expensas comunes en la propiedad horizontal". No menciona el caso de los cementerios. No obstante, dicho inciso se refiere en forma genérica a "los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa, sobre ésta". Aquí se abriría la puerta para reconocer el carácter privilegiado de estas deudas.

VII. Administración

Este derecho real requiere de un administrador, quien dirige y administra el cementerio. Puede ser una persona humana o jurídica; podría también ser un órgano colegiado. Dice el Código que "La dirección y administración del cementerio está a cargo del administrador, quien debe asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios comunes que permita el ejercicio de los derechos de sepultura, de acuerdo a las condiciones pactadas y reglamentadas" (art. 2109). La constitución y funcionamiento de la administración debe estar prevista en el reglamento de administración y uso (art. 2105, inc. h).

El administrador será designado por los dueños o condóminos del inmueble afectado, salvo que otra cosa se disponga en el reglamento de administración y uso. Podría incluso ser el propio dueño, ya que no hay norma que lo impida.

Tiene una función similar a la del administrador de propiedad horizontal, en lo que respecta al mantenimiento del lugar en buen estado, ocuparse de las reparaciones, del personal de servicio necesario, de recaudar y administrar los fondos, velar por el cumplimiento del reglamento, llevar el registro de inhumaciones y sepulturas, un registro de titulares, libro de contabilidad, conservar la documentación necesaria, entre las más importantes. Obviamente, debe rendir cuentas de su gestión.

Dispone el artículo 2106 que "El administrador de un cementerio privado está obligado a llevar: a) un registro de inhumaciones con los

datos identificatorios de la persona inhumada; b) un registro de titulares de los derechos de sepultura, en el que deben consignarse los cambios de titularidad producidos”.

VIII. Reglamento de administración y uso

Este reglamento es una pieza clave, ya que ordena las cuestiones principales del cementerio, y regula los derechos y deberes de los titulares del derecho real de sepultura. El cementerio no puede funcionar como tal sin dicho reglamento, pues el artículo 2104 exige que la escritura de afectación del inmueble se inscriba en el Registro de la Propiedad Inmueble, “juntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio”. También se desprende del artículo 2104 que, sin dichos pasos, no se obtendrá la necesaria habilitación municipal. El reglamento, entonces, pasa a ser un requisito sin el cual no puede configurarse este derecho real. Además, integra el título del adquirente del derecho real de sepultura.

En cuanto a su contenido, dispone el artículo 2105 que “El reglamento de administración y uso debe contener:

- “a) la descripción del inmueble sobre el cual se constituye el cementerio privado, sus partes, lugares, instalaciones y servicios comunes;
- “b) disposiciones de orden para facilitar a los titulares de los derechos de sepultura el ejercicio de sus facultades y que aseguren el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y de policía aplicables;
- “c) fijación y forma de pago del canon por administración y mantenimiento, que puede pactarse por períodos anuales o mediante un único pago a perpetuidad;
- “d) normativa sobre inhumaciones, exhumaciones, cremaciones y traslados;
- “e) pautas sobre la construcción de sepulcros;
- “f) disposiciones sobre el destino de los restos mortales en sepulturas abandonadas;
- “g) normas sobre acceso y circulación de titulares y visitantes;
- “h) constitución y funcionamiento de los órganos de administración”.

Tal como surge del inciso d, el reglamento preverá los pasos que deben satisfacerse para las inhumaciones, exhumaciones, cremaciones y traslados. Esto tiene que ver con horarios, documentación que se debe acompañar, constancias médicas, acreditar ciertos vínculos de parentesco, etcétera.

Para inhumar es necesario contar con una licencia de inhumación otorgada por la autoridad competente.

El inciso e, se refiere a las pautas de construcción. Seguramente el reglamento preverá límites o pautas para la construcción de sepulcros, con la finalidad de asegurar el aspecto arquitectónico y paisajístico del lugar, así como la debida protección del ambiente.

Si el titular del derecho real de sepultura no paga las expensas, la unidad puede ser ejecutada (art. 2110). Lo mismo sucede si no se paga el precio de compra, o los impuestos, tasas y contribuciones. Por tal motivo, el inciso f, del artículo 2105 impone reglamentar acerca de las “disposiciones sobre el destino de los restos mortales en sepulturas abandonadas”.

Se puede interpretar que una sepultura está abandonada, sin duda, si el titular del derecho real la abandona (art. 1907), esto es, abandona el derecho real, lo que en el caso requerirá de escritura pública (art. 1017, inc. a). Otra alternativa es que el titular no pague determinados créditos y que la sepultura sea embargada y ejecutada.

Tanto en uno como en otro caso, el cementario deberá disponer de los restos mortales allí inhumados, ya sea por falta de titular, o bien porque el nuevo adquirente debe recibirla desocupada, para hacer de ella el uso que estime conveniente.

IX. Registros de inhumaciones y sepulturas

Dispone el artículo 2106: “El administrador de un cementerio privado está obligado a llevar:

- “a) un registro de inhumaciones con los datos identificatorios de la persona inhumada;
- “b) un registro de titulares de los derechos de sepultura, en el que deben consignarse los cambios de titularidad producidos”.

Se trata de registros internos.

X. Las parcelas son inembargables

Por regla, dispone el artículo 2110 que "Las parcelas exclusivas destinadas a sepultura son inembargables, excepto por:

- "a) los créditos provenientes del saldo de precio de compra y de construcción de sepulcros;
- "b) las expensas, tasas, impuestos y contribuciones correspondientes a aquéllas".

También el artículo 744, en el inciso c, prevé que están fuera de la garantía común "los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación". Una disposición similar contiene el artículo 219, inciso 2°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicable en los cementerios del dominio público.

El respeto a los muertos conlleva la inembargabilidad de los sepulcros.

Esta regla general tiene excepciones, cuando se reclama el precio de venta o de construcción, o cuando se trata de créditos por expensas, impuestos, tasas o contribuciones.

En lo que hace al precio de venta o construcción, se trata de evitar el abuso, ya que alguien podría comprar la parcela, o bien ordenar una construcción en ella, y luego no pagarla escudándose en el carácter inembargable de su derecho.

En lo que respecta a las expensas, ocurre que si los titulares dejan de pagarlas el cementerio no puede subsistir, se iría deteriorando y no tendría una administración que ponga orden interno. En cuanto a los impuestos, se privilegia el interés público del Estado por encima de los intereses de los particulares.

Cabe preguntarse si, fuera de los créditos mencionados, las parcelas son inembargables cuando están vacías. En un caso, se solicitó en una quiebra la subasta de cinco parcelas ubicadas en un cementerio privado. El tribunal decidió que las parcelas de propiedad del quebrado que se encontraran sin haber sido ocupadas, son ejecutables.

XI. Relación de consumo

"La relación entre el propietario y el administrador del cementerio privado con los titulares de las parcelas se rige por las normas que regulan la relación de consumo previstas en este Código y en las leyes especiales" (art. 2111).

Aquí el Código, tal como lo hizo al regular el derecho de tiempo compartido, señala con acierto que se trata de una relación de consumo.

Esto implica que debe respetarse la dignidad del adquirente, que se condenan las cláusulas abusivas, el deber de informar adecuadamente, la interpretación más favorable al consumidor, etcétera.

XII. Normas de policía mortuoria

Culmina el capítulo dedicado a los cementerios privados con la siguiente norma: "El administrador, los titulares de sepulturas y los visitantes deben cumplir con las leyes, reglamentos y demás normativas de índole nacional, provincial y municipal relativas a la policía mortuoria" (art. 2113). Una norma semejante prevé el Código para el tiempo compartido (art. 2102; ver también el art. 2075 para los conjuntos inmobiliarios).

Las normas que impone el Estado (nacional, provincial o municipal) en consideración al bien público, vinculadas a la higiene, sanidad, recaudos edilicios, seguridad, etcétera, deben ser respetadas. La policía mortuoria pertenece siempre al Estado, y por tanto es propio del poder de policía local todo lo referido a inhumaciones, cremaciones, exhumaciones, etcétera, que comprenden aspectos de control sanitario, modos de efectuar las inhumaciones (en tierra, en nichos, en osarios comunes, reducciones, etc.), pago de tasas e impuestos, registraciones, etcétera. El servicio estará siempre bajo el control del Estado, ya sea que se preste en forma directa por organismos públicos o por particulares mediante concesión o autorización expresa del Estado. Estando de por medio el decoro, la salud, el culto y la seguridad de la comunidad, el control del Estado debe ser amplio.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ley 4977 se refiere al régimen jurídico y poder de policía en materia mortuoria en los cementerios.

CAPÍTULO XVI

EL DERECHO REAL DE SUPERFICIE

MNR

SUMARIO: I. Antecedentes. II. Objetivos de la ley 25.509. III. El Código Civil y Comercial de la Nación. IV. Modos de adquirir el derecho. Aspectos registrales. V. Facultades materiales del superficiario sobre el inmueble ajeno. Uso y goce. VI. Facultades jurídicas del superficiario. VII. Facultades del dueño del suelo. VIII. La hipoteca inscripta anterior al derecho de superficie. IX. Defensas. X. Obligaciones a cargo del superficiario. Pacto comisorio y cumplimiento de la condición resolutoria como causal de extinción. XI. Destrucción de la propiedad superficiaria. XII. Extinción del derecho real de superficie forestal. XIII. Efectos de la extinción. XIV. Normas aplicables al derecho de superficie y a la propiedad superficiaria.

I. Antecedentes

El derecho de superficie es, en términos simples, el derecho real de tener una cosa propia en terreno ajeno. La superficie, con más técnica, es el derecho real de construir, plantar o forestar sobre un inmueble ajeno y hacer propio lo incorporado, o de adquirir una construcción, plantación o forestación ya existente separada de la propiedad de su emplazamiento, por un plazo determinado.

Este derecho otorga a su titular la propiedad superficiaria, así como el derecho de plantar, cultivar, edificar, etcétera. Tiene antecedentes en el Derecho Romano, especialmente bajo Justiniano, que lo concibió como un *jus in re aliena*.

Más moderno resulta el concepto de superficie acuñado por el Código Italiano, que comprende el derecho a edificar y adquirir lo construido. Ya no es el concepto del Derecho Romano que sobre lo cons-

truido sólo atribuye un derecho de uso y goce, sino que va a existir una verdadera propiedad, la propiedad superficiaria.

En el Derecho italiano se afirma que se trata de un derecho de goce sobre cosa ajena.

En el derogado Código Civil argentino, el Codificador -Vélez Sársfield-, en la conocida nota al artículo 2503, en la que se manifiesta francamente contrario a la regulación del derecho de superficie -lo suprimió de modo expreso en el artículo 2614-.

A pesar de la prohibición expresa del Código Civil, parte de la doctrina insistió sobre la necesidad de que se regulara el derecho real de superficie para la instrumentación de negocios modernos, y para el mejor aprovechamiento de los bienes. Así, por ejemplo, es posible que una persona sea dueña de un terreno pero carezca de dinero para explotarlo, y que otro esté dispuesto a invertir en ese inmueble a largo plazo, pero que no encuentre seguridad en los derechos reales admitidos por el Código, en el que rige el *numerus clausus*, ni en las figuras contractuales conocidas.

El 14 de noviembre de 2001 se sancionó en la Argentina la ley 25.509, que creó y reguló en sus 15 artículos el derecho real de superficie forestal. Se incorporó así, en forma parcial, en una de sus variantes, el derecho real de superficie, únicamente para la forestación o silvicultura por parte de un tercero en terreno ajeno.

II. Objetivos de la ley 25.509

Un primer objetivo procura que la explotación forestal alcance un desarrollo más sostenido y extendido.

Así se facilita la inversión de los interesados ya que no tienen que adquirir la superficie a explotar.

Un segundo objetivo tiende a ampliar la franja de los potenciales interesados, convocando a quienes posean recursos limitados para invertir, a pequeños colonos o chacareros que no cuentan con capital suficiente para la explotación, y a industriales madereros que no disponen de materia prima, a sumarse a los planes de forestación, generando así grupos mucho más competitivos.

Un último objetivo apunta a la implementación de un mercado foresto-industrial organizado y plural.

Este nuevo derecho puede contribuir a la desconcentración del mercado y a la desarticulación de los monopolios multinacionales que lo dominan.

Claro que también la ley ha generado duras críticas, en tanto algunos entienden que permite la explotación por parte de los extranjeros de los bosques situados en la Argentina.

III. El Código Civil y Comercial de la Nación

a) Introducción

En primer lugar, cabe advertir que la ley 26.994, que aprueba el nuevo Código, deroga a la ley 25.509. Lo que regula ahora el Código será la normativa en materia de superficie, sin necesidad de complementarlo con otra ley especial.

En segundo lugar, ya no se limita a la superficie forestal, sino que en el Código el derecho de superficie es amplio, ya que puede asumir otras finalidades, como son las de plantar o construir.

Aclara en el artículo siguiente (1888) que la superficie es un derecho sobre cosa propia cuando ya hay propiedad superficiaria. Mientras no se construya, foreste o plante, el derecho recae sobre un inmueble ajeno.

b) Concepto. Naturaleza jurídica

Establece el Código que "...El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales. Todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a su dueño, excepto lo dispuesto respecto de los derechos de propiedad horizontal y superficie..." (art. 1945).

Al ser así, el dueño del suelo extiende su derecho al subsuelo y al espacio aéreo, todo lo que se plante o construya sobre dichos espacios le pertenece. Ésta es la regla, que reconoce excepciones. En lo que aquí interesa, el derecho real de superficie implica una de ellas.

Dice el artículo 2114: "El derecho de superficie es un derecho real temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este Título y las leyes especiales".

Este derecho real puede asumir dos formas: 1) como derecho sobre construcciones, forestaciones o plantaciones a realizarse en el futuro; 2) como derecho sobre construcciones, forestaciones o plantaciones ya realizadas. En la primera modalidad, o primera etapa, el derecho de superficie recae sobre un derecho, mientras que en la segunda tiene por objeto una cosa (construcción o plantación existente), que recibe el nombre de propiedad superficiaria.

No es un expediente tan simple decidir, comparando lo que establecen los artículos 1888 y 2114, qué tipo de derecho real se está legislando, si sobre cosa propia o ajena.

Cabe entender, ante lo categórico del artículo 1888, que recae sobre cosa propia, aunque el inmueble sea ajeno. Claro que es sobre cosa propia si ya hay plantaciones, forestaciones o construcciones; no mientras el espacio esté vacío.

En cuanto a la determinación del objeto, cuando el derecho se constituya con la finalidad de forestar, plantar o construir, no deben quedar dudas: lo será la cosa ajena, el inmueble sobre el que se llevará a cabo la actividad, afirmación que defienden Papaño, Kiper, Dillon y Causse para descartar la tesis de que en tal caso su objeto lo sea el espacio aéreo hasta que las plantaciones queden materializadas. Esta postura será admisible cuando legislativamente se establezca que ese espacio puede ser objeto de los derechos reales, mientras tanto solamente lo serán las cosas.

Ahora, cuando el negocio jurídico tenga por objeto una plantación o construcción existente, el derecho real que se constituye será siempre sobre una cosa propia.

El artículo 1888 es categórico: el derecho de superficie recae sobre cosa propia "si existe propiedad superficiaria".

c) Objeto

El objeto será un inmueble susceptible de forestación, plantación o construcción.

El derecho de forestar o de plantar se ejerce sobre un inmueble ajeno y que la propiedad superficiaria recae sobre las plantaciones, las que revisten la naturaleza de inmuebles por naturaleza.

El artículo 225 del Código Civil y Comercial dispone que "Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre".

Dice el artículo 2116: "*Emplazamiento*. El derecho de superficie puede constituirse sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada, con proyección en el espacio aéreo o en el subsuelo, o sobre construcciones ya existentes aun dentro del régimen de propiedad horizontal.

"La extensión del inmueble afectado puede ser mayor que la necesaria para la plantación, forestación o construcción, pero debe ser útil para su aprovechamiento".

Se ha previsto que el derecho se extienda más allá de la superficie indispensable para llevar a cabo la forestación, plantación o construcción, lo que podría ser pactado por las partes en el acto constitutivo, precisamente para ocuparla con los implementos necesarios para el desarrollo de la actividad.

Con el texto del artículo 2116 se amplía el campo de actuación del derecho de superficie, ya que no se limita a un inmueble rural destinado a la explotación agroforestal. Puede tratarse de un inmueble urbano, teniendo en cuenta que una posible finalidad es la construcción. Incluso, el artículo menciona a la propiedad horizontal.

El superficiario puede plantar, edificar o forestar sobre suelo ajeno. Pero también cabe la posibilidad de que lo haga sobre el subsuelo o vuelo ajeno. Así, por ejemplo, en este último caso, cuando el dueño de un inmueble ya construido, o los consorcistas de uno sometido al

régimen de propiedad horizontal, concedan a un tercero el poder de elevar una o más plantas. En esta hipótesis, sobre el vuelo, cabe descartar a las plantaciones y a la forestación; sólo puede interesar la construcción.

A la vez, como se verá más adelante, el derecho de plantar, forestar o construir, aún no ejercido, puede ser objeto de determinados actos jurídicos.

d) Caracteres

- 1) Es un derecho real autónomo y principal (art. 1889).
- 2) Sobre cosa propia o ajena según que la actividad haya comenzado o no (art. 1888).
- 3) Temporario (art. 2117). No vitalicio.
- 4) Su objeto es un inmueble, o bien un derecho a ejercer sobre el inmueble.
- 5) Transmisible.

e) Legitimados

En los términos del artículo 2118, este derecho real puede ser constituido a favor de terceros, por "los titulares de los derechos reales de dominio, condominio y propiedad horizontal".

Los titulares del dominio, condominio o propiedad horizontal y aquellos a cuyo favor se constituya este derecho podrán ser personas físicas o jurídicas.

Si el dominio del inmueble le pertenece a más de una persona, todos los condóminos deberán concurrir al acto constitutivo y prestar su consentimiento, lo que implica que no sea posible la constitución de este derecho por uno de los comuneros sobre su parte indivisa.

El artículo 1990 del Código requiere la conformidad de todos los condóminos para los actos de disposición sobre toda la cosa.

Quien adquiera el derecho de superficie debe ser una persona distinta del dueño del suelo, pues aquí también rige la máxima *nulli res sua servit*. No obstante, sí sería posible que el superficiario fuese condómino del terreno.

El superficiario no puede conceder a su vez derecho de superficie sobre lo construido o plantado. Lo que sí puede hacer es transmitir a un tercero su propio derecho (art. 2123).

f) Duración

El derecho de superficie es temporario.

Dice el artículo 2117: "El plazo convenido en el título de adquisición no puede exceder de setenta años cuando se trata de construcciones y de cincuenta años para las forestaciones y plantaciones, ambos contados desde la adquisición del derecho de superficie. El plazo convenido puede ser prorrogado siempre que no exceda de los plazos máximos".

Esta limitación temporal es aplicable a cualquiera de sus variantes: derecho real sobre cosa ajena o sobre cosa propia, máxime teniendo en cuenta que el plazo se cuenta desde la adquisición del derecho.

La norma se pronuncia sobre la fecha a partir de la cual comienza a correr este plazo. Dice que corre desde la "adquisición del derecho de superficie". Cabe interpretar que para fijar el inicio debe tenerse en cuenta el día en que se le traslada al adquirente la posesión del inmueble de que se trate (establecido como condición para adquirir el derecho), si ocurre después de firmado el instrumento de constitución del derecho. El derecho real se adquiere cuando concurren el título y el modo.

Cuando el plazo pactado sea superior al legal, se lo deberá considerar constituido por el máximo que admite la ley, pero no se anula todo el contrato (arg. arts. 1668 y conchs. del Código).

Aunque el Código no lo dice expresamente, podría pactarse la duración subordinada a una condición resolutoria, en lugar de un plazo, en tanto no se excedan los máximos legales.

g) Dominio imperfecto del constituyente

La calidad de temporario asignado a este derecho regula sobre la imperfección de los derechos resultantes. En efecto, tanto es imperfecto el derecho real sobre cosa propia que se le otorga a otro sobre una

masa arbórea ya implantada o cultivada, o una construcción, porque concluirá inexorablemente al vencimiento del plazo legal —o antes, de ocurrir alguno de los supuestos contemplados—, como lo será el dominio del propietario al sufrir su desmembramiento cuando constituya a favor de otro el derecho de forestar o hacer silvicultura, plantar o construir. Su plenitud la recuperará al vencimiento de la afectación.

También se torna imperfecto el dominio del propietario que constituyó el derecho para que otro adquiriera como propia una masa arbórea, plantación o construcción que ya existe.

Todo indica que la imperfección del dominio de este propietario es una consecuencia inevitable. En primer lugar, porque la constitución de este nuevo derecho, en cualquiera de sus variantes, produce una afectación que limita el contenido del derecho del que podrá disponer en adelante el propietario del inmueble. El sucesor del derecho del dueño (adquirente que adquiere por enajenación) debe respetar el de superficie forestal constituido, el que, por otra parte, no podrá desconocer por los efectos de la publicidad registral legalmente prevista. En segundo lugar, por una situación fáctica inevitable, dada porque en los hechos para que el titular de la masa arbórea pueda disponer de ella, necesariamente tendrá que desarrollar su actividad sobre la superficie del suelo, limitando sensiblemente el ejercicio de los actos posesorios de aquel sucesor.

IV. Modos de adquirir el derecho.

Aspectos registrales

El artículo 2119 del Código dice que "El derecho de superficie se constituye por contrato oneroso o gratuito y puede ser transmitido por actos entre vivos o por causa de muerte. No puede adquirirse por usucapión. La prescripción breve es admisible a los efectos del saneamiento del justo título". Aquí el Código se refiere al "derecho de superficie", esto es cuando aún no se construyó, plantó o forestó.

a) *Contrato*

Toda persona física o jurídica puede celebrar este contrato. La adquisición del derecho, en consecuencia, es derivada.

El contrato puede ser oneroso o gratuito. La contraprestación está librada a la autonomía de la voluntad, puede ser una suma de dinero, permitir el uso de un local, que el dueño haga suyo lo plantado sin pagar indemnización, etcétera. En el primer caso se aplicarán supletoriamente las reglas previstas para la compraventa (art. 1124, inc. a, del Código). En el segundo caso, las reglas previstas para la donación (art. 1543).

La instrumentación por escritura pública es una derivación necesaria de aplicar lo que establece el actual artículo 1017, inciso a, del Código, porque se trata de la constitución de un derecho real que recae sobre inmuebles.

En el caso de la superficie, para la publicidad del contrato se requiere la inscripción en el Registro.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Registro de la Propiedad Inmueble ha dictado la Disposición Técnico Registral 3/2015, del 29 de julio de 2015, que establece lo siguiente:

Art. 2°— Serán calificadas verificando que de ellas resulten, además de la determinación física y jurídica de los inmuebles y de la identificación de los otorgantes, en los términos de la ley 17.801 y del artículo 305 del Código Civil y Comercial, los siguientes datos:

- a) Extensión y modalidades del derecho superficiario;
- b) Plazo de duración, de conformidad con el artículo 2117 del Código Civil y Comercial;
- c) Si el derecho real de superficie abarcara sólo una parte determinada del inmueble, su extensión y medidas surgidas del plano de mensura confeccionado a ese efecto y registrado en el organismo catastral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; no siendo necesaria la presentación del plano si la superficie se constituye sobre la totalidad del inmueble.

Art. 3°— La inscripción del derecho real de superficie se practicará en la matrícula donde conste inscripto el dominio o el condominio, en el rubro referido a sus gravámenes y restricciones y haciendo constar la constitución del derecho real, el plazo convenido en su título o su condición resolutoria, los datos personales del superficiario, el número y fecha de la escritura, el nombre del escribano autorizante y su registro notarial, los certificados utilizados, si el

negocio ha sido gratuito u oneroso indicando, en su caso, el precio establecido, y la fecha y número de presentación del documento. Inscripto este último en forma definitiva, se abrirá una submatrícula, con el número de la de origen y la sigla ST, si la superficie se constituye sobre todo el inmueble, o SP, si la superficie se constituye sobre parte determinada de aquél; en este último supuesto, la sigla SP se completará con un número de orden que permita individualizar cada uno de los derechos de superficie constituidos en un inmueble determinado.

Art. 4° – En las submatrículas de superficie, que tendrán características similares a los folios reales, se hará constar:

- a) En el rubro descripción del inmueble, el objeto y la extensión del derecho de superficie y su determinación según el plano respectivo, si fuere parcial;
- b) En el rubro titularidad del superficiario, sus datos personales, la individualización de la escritura de constitución, el plazo convenido y demás condiciones relativas al negocio causal, replicando los contenidos del asiento de constitución.

Art. 5° – La extinción del derecho real de superficie deberá ser rogada expresamente y se inscribirá tanto en la matrícula de origen como en las correspondientes submatrículas.

b) Prescripción corta

Debido a la convencionalidad predisuelta por la norma, con acierto se descarta que se pueda adquirir por usucapión larga. La posibilidad de adquirir este derecho por usucapión breve, nada descartable, ha sido recogida por el Código.

No es descabellado imaginar la hipótesis de que un falso propietario transmitiese a un tercero el derecho de superficie. Si el adquirente es de buena fe y ejerce la posesión, si bien está expuesto a la acción reivindicatoria del verdadero dueño, podría consolidar su situación al cabo de diez años.

La prescripción larga para adquirir el “derecho de superficie” es inconcebible, ya que nada se construyó, ni plantó, de modo que no hay actos posesorios posibles.

Además, en cuanto a la “propiedad superficiaria”, será raro que se quiera adquirir por prescripción veinteañal un derecho de superficie si

MNR

con los mismos actos posesorios se puede adquirir el dominio que es perpetuo y más completo.

c) Actos de última voluntad

La superficie puede ser constituida por testamento, y si fue constituida por contrato y el superficiario muere, sus herederos ocuparán su lugar, al ser un derecho transmisible.

d) Otros modos

El derecho podría ser adquirido por partición judicial –en la medida que nazca del acuerdo de todos los herederos, mediando aprobación judicial del acto particionario–, como por subasta judicial –en cuyo caso se adquiere un derecho cuya extensión está legalmente tarifada–.

V. Facultades materiales del superficiario sobre el inmueble ajeno. Uso y goce

Por un lado, se encuentran las facultades materiales. Dice el artículo 2115 que “El superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre la rasante, vuelo y subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado o construido...”

En esto, pues, consiste el derecho de superficie: construir, plantar, forestar sobre el inmueble que pertenece a otro u otros. Tales actos pueden hacerse por encima o por debajo del suelo, y también sobre “la rasante”.

A la vez, si bien el inmueble es ajeno, el superficiario hace suyo lo plantado, edificado o forestado.

Agrega dicha norma que “También puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyendo al superficiario su propiedad...”

Tales plantaciones, construcciones o forestaciones pueden ser hechas por el dueño, y posteriormente el superficiario adquirir su propiedad, lo que produce el desdoblamiento característico, ya que el

dueño conservará su derecho sobre el suelo. Es también factible que a partir de allí el superficiario cuente también con la facultad de ejercer su actividad sobre lo hecho como, por ejemplo, ejerciendo el derecho de sobreelevar.

Mientras el derecho que adquiere el superficiario es temporario y destinado a extinguirse, el derecho del dueño del suelo es perpetuo y con proyección a expandirse y hacer suyo lo plantado, forestado o construido (ver art. 2125). Es la típica elasticidad del dominio.

Antes de realizar la construcción, plantación o forestación, el superficiario tiene facultades conexas, preparatorias. Así, por ejemplo, transportar y depositar materiales, hacer pasar obreros, trabajar el suelo para que sea apto, etcétera. Completada la actividad, el superficiario también puede usar la parte sin construir, plantar o forestar que sea funcional al uso y goce de lo realizado (por ej., destinándola a lugar de estacionamiento). De allí que el artículo 2116, segundo párrafo, disponga que "La extensión del inmueble afectado puede ser mayor que la necesaria para la plantación, forestación o construcción, pero debe ser útil para su aprovechamiento".

VI. Facultades jurídicas del superficiario

Los actos de disposición del superficiario se extinguen juntamente con su derecho, si éste acaba por vencimiento del plazo pactado, o del legal (art. 2125). En cambio, hay casos de subsistencia de los derechos y obligaciones del superficiario y del nudo propietario que el Código admite, que se examinarán más adelante.

Además, el superficiario puede renunciar, aunque ello no lo libera de las obligaciones asumidas (art. 2123).

Dice el artículo 2120: "El titular del derecho de superficie está facultado para constituir derechos reales de garantía sobre el derecho de construir, plantar o forestar o sobre la propiedad superficiaria, limitados, en ambos casos, al plazo de duración del derecho de superficie.

"El superficiario puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal, con separación del terreno perteneciente al pro-

pietario excepto pacto en contrario; puede transmitir y gravar como inmuebles independientes las viviendas, locales u otras unidades privativas, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad de consentimiento del propietario".

a) *Derechos de garantía*

El derecho de construir, plantar o forestar, o la propiedad superficiaria, pueden ser objeto de derechos reales de garantía. La utilización del plural hace suponer que puede gravarse, además de hipoteca, con anticresis (conf. art. 2213). El primer supuesto podría ser un caso de derecho real sobre derecho. Cuando ya la propiedad superficiaria existe, hay una suerte de subrogación legal.

En el caso de la anticresis, cuesta imaginar que ese derecho real recaiga sobre un derecho que aún no fue ejercido, teniendo en cuenta que el acreedor anticresista recibe la posesión, y percibe frutos que puede imputar al pago de la deuda. En cambio, se torna más viable sobre lo ya construido, plantado o forestado.

Estos derechos reales de garantía no podrían durar más de 50 o 70 años, plazos máximos previstos para el derecho de superficie. Si se pactase la prohibición de hipotecar, cabe entender que el pacto no sería eficaz (art. 1972 del Código).

De una primera lectura se podría inferir que lo que se puede gravar con derecho real de garantía es la propiedad de las plantaciones o construcciones existentes (más las que se vayan agregando en el futuro), lo que parece razonable porque en tal caso existiría la cosa sobre la que recaería el gravamen. Pero ésta sería una afirmación poco conducente, en orden a los objetivos de la ley, porque cuando el derecho del superficiario tiene por finalidad forestar o hacer silvicultura, o emprender una construcción importante, se le negaría la posibilidad de obtener los recursos necesarios para emprender la explotación. Y en esto no existe contradicción alguna con el régimen general de los derechos reales, en cuanto se trataría de la constitución de un gravamen sobre un derecho y no sobre una cosa, habida cuenta de que es la propia regulación legal la que lo admite.

Superado el escollo de que el gravamen tenga por objeto un derecho,

cuando la masa arbórea, la plantación o la construcción existan, éstas deberían ser su nuevo objeto, lo que no sería sino el resultado de una transformación automática del derecho de plantar o construir en derecho sobre lo plantado o edificado. Esta subrogación será operativa sin que, a tales efectos, se requiera el otorgamiento de ningún acto complementario al que deban comparecer el nudo propietario, el superficiario o el titular del gravamen.

No obstante, es aplicable lo dispuesto sobre subrogación real por el artículo 2194.

Otro tema interesante surge en caso de ejecución judicial de la hipoteca. La ejecución supone la extinción de la hipoteca, pero no de la superficie en sus dos planos. Cabe entender que el adjudicatario, como sucedería si el derecho se hubiera transmitido voluntariamente, deberá seguir pagando el canon y cumpliendo con otras obligaciones, y que tendrá derecho a plantar, forestar o cultivar como surja del título constitutivo.

b) *Derechos de disfrute*

En cuanto a si puede constituir derechos de disfrute, en tanto sean compatibles, la cuestión es poco clara. El artículo 2131 expresamente admite que el superficiario está legitimado para gravar el inmueble con usufructo, pero el artículo 2120 que aquí se comenta sólo menciona los derechos reales de garantía. Me inclino por aceptar la posibilidad, en tanto no impidan el ejercicio del derecho del superficiario (conf. XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil). Así, por ejemplo, si se trata de unidades sujetas a propiedad horizontal, el superficiario podría darlas en usufructo, o permitir el usufructo de determinadas plantaciones. A su vez, la servidumbre no parece ser un obstáculo al derecho del superficiario. Por último, el artículo 2125 se refiere a los derechos reales constituidos por el superficiario, sin distinción.

c) *Propiedad horizontal*

La superficie puede ser afectada a la propiedad horizontal, salvo

pacto en contrario. Cabe recordar que hay un plazo máximo de 70 años para las construcciones.

Dice la norma que el terreno sigue perteneciendo al dueño, lo que configura una excepción, ya que en el régimen de la propiedad horizontal el terreno es parte común, pertenece a los titulares de las unidades funcionales (art. 2039).

Pues bien, puede darse la situación de que el superficiario, sobre el terreno ajeno, edifique unidades que cumplan con los recaudos necesarios para poder someterse al régimen de propiedad horizontal (v. gr.: independencia, salida a la vía pública, reglamento, administración, etc.), y las utilice o explote mientras dure su derecho.

Al concluir el derecho de superficie, tales unidades corresponderán al dueño del suelo, y todo el inmueble estará afectado al sistema de propiedad horizontal, a menos que decida extinguirlo.

Esta facultad que tiene el superficiario de utilizar el régimen de propiedad horizontal existe, como dice la norma, mientras no se pacte lo contrario.

d) *Efectos de los actos de disposición*

El superficiario puede disponer de su derecho por actos entre vivos o por disposición de última voluntad (art. 2119). Como consecuencia de esta facultad que tiene el superficiario de transmitir su derecho, éste puede ser objeto de medidas cautelares y de ejecución y subasta por sus acreedores. Por cierto que el derecho que va a adquirir el postor triunfante en la puja estará limitado al que tenía el ejecutado.

Los actos de disposición del superficiario se extinguen juntamente con su derecho. No obstante, hay casos de subsistencia de los derechos y obligaciones del superficiario que la ley admite, si la superficie se extingue antes del vencimiento del plazo legal o convencional (v. gr.: consolidación; ver art. 2125).

En cuanto a la conformidad del dueño para el otorgamiento de ciertos actos, puede servirle al nudo propietario para sortear el problema de que las obligaciones que son accesorias de un derecho real sólo afectan al que las haya acordado y a sus herederos, partiendo del

principio de que no hay obligaciones que sigan a los derechos reales, de manera tal que, antes de otorgarla, exija la asunción de las referidas obligaciones por el adquirente. Porque al nudo propietario quizá no le resulte indiferente la persona del superficiario, al contrario, pudo haber tenido especialmente en cuenta las calidades de aquel con quien terminó contratando.

La última parte del artículo 2120, al referirse al supuesto de propiedad horizontal y a la posibilidad de que el superficiario enajene unidades, dice que ello es así "sin necesidad de consentimiento del propietario".

Agrega el artículo 2123 que "La transmisión del derecho comprende las obligaciones del superficiario.

"La renuncia del derecho por el superficiario, su desuso o abandono, no lo liberan de sus obligaciones legales o contractuales".

Si bien las obligaciones que son accesorias de un derecho real sólo afectan al que las haya acordado y a sus herederos, partiendo del principio de que no hay obligaciones que sigan a los derechos reales, esta norma dispone lo contrario y le impone al sucesor particular las obligaciones que el superficiario haya asumido en el contrato.

Por otro lado, en casos de renuncia, desuso o abandono, el superficiario no se libera de sus obligaciones.

Surge la duda acerca de si se libera o no, si transmite a título oneroso a un tercero. Dice el Código que no se libera en los casos de renuncia, desuso o abandono, de modo que puede interpretarse que sí lo hace en el caso de transmitir su derecho a título oneroso. En la propiedad horizontal no se libera el transmitente (ver art. 2049). Quizás una pauta importante sea lo que diga el contrato, y/o la aceptación del dueño de la transmisión al tercero. Pero si nos atenemos al texto legal, cabe entender que se libera de las obligaciones asumidas con el dueño, las que pasan al sucesor. Pero desde otra visión, puede alegarse que si su derecho se extingue antes del vencimiento del plazo legal o convencional, por la causa que sea, sigue obligado.

Como consecuencia de esta facultad que tiene el superficiario de

transmitir su derecho, éste puede ser objeto de medidas cautelares y de ejecución y subasta por sus acreedores. Por cierto que el derecho que va a adquirir el postor triunfante en la puja estará limitado al que tenía el ejecutado, por simple aplicación de los principios generales.

e) *Turbación por parte del propietario*

El Código le permite al superficiario exigir el cese de la turbación que estuviera ejerciendo el nudo propietario (art. 2121).

f) *Derechos personales*

También está facultado el superficiario para la constitución de derechos personales (v. gr.: locación).

VII. Facultades del dueño del suelo

Dice el artículo 2121: "El propietario conserva la disposición material y jurídica que corresponde a su derecho, siempre que las ejerza sin turbar el derecho del superficiario". Para realizar esta clase de actos no precisa el consentimiento del superficiario.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2121, el propietario del inmueble afectado a superficie conserva el derecho de enajenarlo, debiendo el adquirente respetar el derecho real de superficie constituido.

El límite que establece esta norma es que no podrá "turbar el derecho del superficiario".

Podrá afectar su derecho con usufructo, uso, habitación o servidumbres, pero siempre y cuando ello no interfiera con las facultades del superficiario, ya que, materialmente, pueden resultar inconvenientes para el ejercicio de la facultad que se le confiere al superficiario.

En cuanto a los derechos reales de garantía, durante la vigencia del contrato no se presenta en la norma comentada una limitación, de modo que el nudo propietario no ve restringidas sus posibilidades de obtener asistencia financiera, cuando el otorgamiento de tales "garan-

tas" nunca llegaría a representar una perturbación para el superficiario, salvo la anticresis.

La constitución de derechos personales no está prohibida.

VIII. La hipoteca inscrita anterior al derecho de superficie

Puede ocurrir que la superficie se convenga sobre una propiedad que ya se encuentra gravada con un derecho de disfrute o garantía. Para los derechos de disfrute distintos de los de servidumbre sucede, sin embargo, que el derecho de superficie podría constituirse, en tanto no se presente una incompatibilidad de su contenido con el de aquéllos.

Por lo que específicamente se refiere a la hipoteca, cabría considerar que, como se extiende por ley a las mejoras y construcciones que se produzcan sobre la finca, ningún inconveniente habría en que se constituyera después un derecho de superficie, pues en nada habría de perjudicarlo al acreedor. Además, la hipoteca estaría a salvo y se impondría sobre cualquier derecho posteriormente concluido.

La realización de la garantía se traducirá, para lo que aquí interesa, en el cese de la superficie convenida, junto con el de los derechos que, asimismo, la graven. Para impedir o, al menos, reducir la total pérdida de sus inversiones, el superficiario aún contaría con la costosa oportunidad de presentarse como postor y adquirir la finca en la subasta que se celebre.

Dispone el artículo 2195 que "El constituyente de la garantía conserva todas las facultades inherentes a su derecho, pero no puede realizar ningún acto que disminuya el valor de la garantía. Si esto ocurre, el acreedor puede requerir la privación del plazo de la obligación, o bien puede estimar el valor de la disminución y exigir su depósito o que se otorgue otra garantía suficiente".

IX. Defensas

Tanto el superficiario como el propietario cuentan a su favor con

las defensas judiciales de la posesión, no sólo contra terceros, sino también contra ellos mismos, dada su distinta calidad posesoria.

X. Obligaciones a cargo del superficiario. Pacto comisorio y cumplimiento de la condición resolutoria como causal de extinción

Si el contrato se celebra a título oneroso, el superficiario queda obligado a satisfacerle al nudo propietario la contraprestación pactada.

En caso de incumplimiento de obligaciones se permite el ejercicio del pacto comisorio tácito (ver arts. 1083 y 1084).

XI. Destrucción de la propiedad superficiaria

Dice el artículo 2122: "La propiedad superficiaria no se extingue, excepto pacto en contrario, por la destrucción de lo construido, plantado o forestado, si el superficiario construye, nuevamente dentro del plazo de seis años, que se reduce a tres años para plantar o forestar".

El artículo 1907 dice que los derechos reales se extinguen por la destrucción total de la cosa "si la ley no autoriza su reconstrucción". Aquí hay un supuesto de excepción. La propiedad superficiaria queda subsistente sobre el terreno correspondiente, como en una especie de letargo, en espera de la correspondiente reforestación, reconstrucción o nueva plantación.

Esto es así si no se pacta lo contrario. Es factible interpretar que se puede pactar en contrario: a) que la destrucción extinga inmediatamente el derecho del superficiario; b) que el plazo para reconstruir o plantar sea mayor al legal. Esta última posibilidad se considera descartable, pues permitiría mantener por mucho tiempo un fundo improductivo.

XII. Extinción del derecho real de superficie forestal

Prevé el artículo 2124: "El derecho de construir, plantar o forestar se extingue por renuncia expresa, vencimiento del plazo, cumplimiento de una condición resolutoria, por consolidación y por el no uso durante diez años, para el derecho a construir, y de cinco, para el derecho a plantar o forestar".

a) *Renuncia expresa*

En el Código se descarta la renuncia tácita. Además, los actos que tienen por finalidad extinguir un derecho real sobre un inmueble deben ser hechos en escritura pública.

La renuncia no libera al superficiario de sus obligaciones (art. 2123).

b) *Vencimiento del plazo contractual*

Este supuesto de extinción operará por el simple transcurso del plazo que se haya convenido o, a falta de convenio, por haberse llegado al término del tope legal de 50 o de 70 años que admite la ley (art. 2117).

c) *Cumplimiento de una condición resolutoria*

Si transcurridos 50 o 70 años, según el caso, la condición no se cumplió, de todos modos debe tenerse por extinguido al derecho por haberse alcanzado el plazo máximo de duración.

d) *Consolidación*

En esta causal quedan comprendidas todas las alternativas posibles: que la consolidación ocurra en cabeza del nudo propietario, del superficiario o de un tercero.

El artículo 1907 alude a la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena, y el derecho de superficie una vez realizada la edificación o plantación es un derecho sobre cosa propia. No obstante, no se advierte impedimento en la aplicación de la causal, pues en definitiva el terreno es ajeno y tiene un dueño, de manera que la confusión es perfectamente posible. Tampoco tiene sentido que un dueño sume otro derecho sobre lo que le pertenece.

e) *No uso*

Finalmente, se prevé el no uso: "diez años, para el derecho a construir, y de cinco, para el derecho a plantar o forestar".

Respecto de la facultad de forestar, construir o plantar y hacer propio lo plantado o construido, se produciría la extinción del derecho

MNR

del superficiario si éste, dentro del plazo indicado, no construye ni foresta o explota la plantación producida. Respecto de la segunda -derecho sobre una forestación o construcción que ya existe-, si no la explota en ese plazo.

En el artículo 2123 del Código se alude al "desuso" junto con otras causales de extinción, que no liberan al superficiario de sus obligaciones. Todo hace suponer que no se trata de otra causal autónoma de extinción, sino de la misma contemplada en el artículo 2124, a la que le son aplicables las consideraciones precedentes.

f) *Desuso y abandono: ¿son causales de extinción autónomas?*

Se genera el interrogante porque están mencionadas en un artículo distinto del anterior y por el empleo de una terminología que induce a equívocos. Dice el artículo 2123: "...La renuncia del derecho por el superficiario, su desuso o abandono, no lo liberan de sus obligaciones..."

Respecto del primero, ya se dijo que se trata del "no uso" que menciona el artículo siguiente, por lo que no se trataría de una causal autónoma de extinción. En cuanto al segundo, la doctrina se ha planteado si el legislador lo utiliza como sinónimo de "no uso", porque en tal caso "desuso" y "abandono" serían términos equivalentes y por lo tanto tampoco podría constituir una causal autónoma de extinción.

g) *Otras causas no mencionadas*

Existen causas de extinción que el Código no enumera: el acuerdo extintivo que es perfectamente posible, la cesación de la existencia legal de la persona jurídica a cuyo favor se hubiera constituido, y la expropiación del inmueble, que sí provocará la extinción del derecho, generándose una subrogación real por la que el derecho del nudo propietario y del superficiario serán sustituidos por la indemnización debida (art. 28, ley 21.499). Este derecho también se extingue por pérdida del objeto si el mismo suelo desaparece (ej., avulsión).

XIII. Efectos de la extinción

a) En general

El Código distingue si el derecho de superficie se extingue antes o después de vencido el plazo legal o convencional.

Dispone el artículo 2125 del Código: "Al momento de la extinción del derecho de superficie por el cumplimiento del plazo convencional o legal, el propietario del suelo hace suyo lo construido, plantado o forestado, libre de los derechos reales o personales impuestos por el superficiario.

"Si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo legal o convencional, los derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan gravando separadamente las dos parcelas, como si no hubiese habido extinción, hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie.

"Subsisten también los derechos personales durante el tiempo establecido".

La adquisición del titular del suelo es automática, y no hace falta tradición de la cosa, y el dueño entonces extiende su dominio a lo plantado o construido, según el caso. Es una consecuencia de haber recobrado toda su fuerza el principio *superficie solo cedit*. Esta consecuencia se suele denominar "derecho de reversión".

Cabe interpretar que si el superficiario continúa en el *corpus* del inmueble una vez extinguido el derecho, lo será en el carácter de tenedor.

Si la superficie se extingue antes del plazo, subsisten los derechos reales y personales impuestos por el superficiario.

b) Indemnización

Dice el artículo 2126: "Producida la extinción del derecho de superficie, el titular del derecho real sobre el suelo debe indemnizar al superficiario, excepto pacto en contrario. El monto de la indemnización es fijado por las partes en el acto constitutivo del derecho real de superficie, o en acuerdos posteriores.

"En subsidio, a los efectos de establecer el monto de la indemni-

zación, se toman en cuenta los valores subsistentes incorporados por el superficiario durante los dos últimos años, descontada la amortización".

En primer lugar, el derecho a la indemnización existe salvo pacto en contrario. Se trata de evitar un enriquecimiento sin causa.

Si las partes no acuerdan el *quantum* indemnizatorio, ya sea al constituirse el derecho o posteriormente, la fijación del valor deberá ser establecida judicialmente.

Aquí el Código acude a una fórmula bastante objetiva: "se toman en cuenta los valores subsistentes incorporados por el superficiario durante los dos últimos años, descontada la amortización". En alguna medida refleja el mayor valor aportado al inmueble.

c) Derechos reales y personales constituidos

Si el derecho de superficie se extingue al cumplirse el plazo pactado o el máximo legal, se extinguen los derechos reales y personales que hubiere constituido el superficiario.

Si la extinción se produce antes de los momentos señalados, por una causal distinta a la del vencimiento del plazo establecido (v. gr.: renuncia expresa), tales derechos se mantienen, ya que pueden presentarse casos en los que los terceros se vean defraudados en sus expectativas.

d) Obligaciones del superficiario

El artículo 2123 dice que la renuncia, el desuso o el abandono no liberan al superficiario de sus obligaciones, lo que abarca, además de los terceros, al dueño del suelo con quien el superficiario contrató.

e) Consolidación

La extinción por consolidación que se opera por voluntad del dueño y del superficiario no puede perjudicar los derechos de los terceros acreedores titulares de derechos reales. Si por ejemplo existiera una hipoteca sobre la propiedad superficiaria, no obstante que al extinguirse el derecho de superficie no cabe hablar de propiedad superficiaria, aun mientras dure la hipoteca va a subsistir al solo fin de ser objeto del derecho real que no se extingue a pesar de la consolidación.

XIV. Normas aplicables al derecho de superficie y a la propiedad superficiaria

En primer lugar, se aplican estas normas específicas. En segundo lugar, en aquello que esté permitido, prevalecerá lo pactado por las partes. Finalmente, en aquello no previsto el Código sienta pautas subsidiarias.

Respecto al derecho del superficiario dice el artículo 2127: "Son de aplicación supletoria las normas relativas a las limitaciones del uso y goce en el derecho de usufructo, sin perjuicio de lo que las partes hayan pactado al respecto en el acto constitutivo".

Con relación a obras ya existentes, establece el artículo 2128: "Si el derecho de superficie se ejerce sobre una construcción, plantación o forestación ya existente, se le aplican las reglas previstas para el caso de propiedad superficiaria, la que a su vez queda sujeta a las normas del dominio revocable sobre cosas inmuebles en tanto sean compatibles y no estén modificadas por las previstas en este Título".

CAPÍTULO XVII

USUFRUCTO. USO. HABITACIÓN

MNR

SUMARIO: A) Usufructo. I. Derechos de disfrute sobre cosa ajena. II. Concepto de usufructo. III. Objeto. IV. Legitimados para constituir usufructo. V. Usufructo a favor de varias personas. VI. Modos de constitución. VII. Presunción de onerosidad. VIII. Duración. IX. Modalidades. X. Derechos del usufructuario. XI. Obligaciones del usufructuario. XII. Derechos del nudo propietario. XIII. Deberes del nudo propietario. XIV. Extinción del usufructo. B) Uso. I. Concepto. II. Objeto. III. Régimen legal. Normas supletorias. IV. Facultades del usuario. V. Ejecución por acreedores. C) Habitación. I. Concepto. II. Caracteres. III. Régimen legal. IV. Objeto. V. Impuestos, contribuciones y reparaciones. VI. Derecho real de habitación del cónyuge o conviviente supérstite.

A) USUFRUCTO

I. Derechos de disfrute sobre cosa ajena

El usufructo, junto al uso, la habitación y la servidumbre son los clásicos derechos de disfrute sobre cosa ajena. También se los conoce como derechos "limitados", porque su contenido no abarca todo aquello para lo que puede ser utilizado el objeto, a la vez que limitan las facultades del dueño. El dominio se ve comprimido, y al desaparecer estos derechos se extiende nuevamente (elasticidad).

El Código, a los referidos derechos, los clasifica como derechos sobre cosa ajena, junto a los de garantía (art. 1888). Respecto del dueño de la cosa, constituyen cargas o gravámenes reales (art. 1888); para aquél se trata de un dominio imperfecto (art. 1946), por estar desmembrado (art. 1964). Además, son derechos principales (art.